

目 录

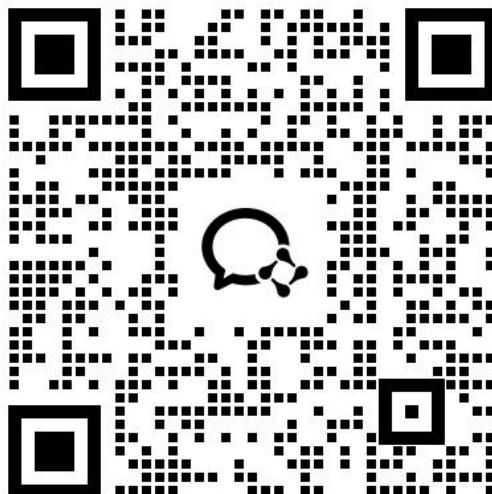
第一章 绪论	1
第一节 民法概述	1
第二节 民法的调整对象	4
第三节 民法的基本原则	5
第二章 民事法律关系	8
第一节 民事法律关系概述	8
第二节 民事法律关系的要素	10
第三节 民事权利、民事义务	11
第四节 民事责任	13
第五节 民事法律事实	15
第三章 自然人	16
第一节 自然人的民事权利能力	16
第二节 自然人的民事行为能力	17
第三节 监护	19
第四节 宣告失踪和宣告死亡	21
第五节 个体工商户、农村承包经营户	23
第四章 法人	24
第一节 法人概述	24
第二节 营利法人	25
第三节 非营利法人	25
第四节 特别法人	26
第五节 法人的设立、变更和终止	27
第五章 非法人组织	29
第一节 非法人组织概述	29
第二节 合伙企业	29
第六章 民事法律行为	30
第一节 民事法律行为概述	30
第二节 民事法律行为的分类	31
第三节 意思表示	32
第四节 民事法律行为的成立和有效	34
第五节 无效的民事法律行为	34
第六节 可撤销的民事法律行为	35
第七节 效力未定的民事法律行为	37
第八节 附条件和附期限的民事法律行为	37
第七章 代理	39

第一节 代理概述	39
第二节 代理的分类	40
第三节 代理权	41
第四节 无权代理	41
第五节 代理终止	43
第八章 诉讼时效与期间	44
第一节 诉讼时效	44
第二节 期间	46
第九章 物权通则	46
第一节 物权概述	46
第二节 物权法的基本原则	48
第三节 物权的变动	49
第四节 不动产登记	50
第五节 物权的保护	51
第十章 所有权	52
第一节 所有权概述	52
第二节 建筑物区分所有权	55
第三节 相邻关系	56
第四节 共有	57
第十一章 用益物权	59
第一节 用益物权概述	59
第二节 土地承包经营权	59
第三节 建设用地使用权	60
第四节 宅基地使用权	61
第五节 居住权	62
第六节 地役权	62
第十二章 担保物权	63
第一节 担保物权概述	63
第二节 抵押权	64
第三节 质权	67
第四节 留置权	68
第十三章 占有	70
第一节 占有概述	70
第二节 占有的效力和保护	70
第十四章 合同通则	71
第一节 债与合同概述	71

第二节 合同的订立	73
第三节 合同的效力	77
第四节 合同的履行	77
第五节 合同的保全	80
第六节 合同的变更和转让	81
第七节 合同的权利义务终止	84
第八节 违约责任	86
第十五章 典型合同	89
第一节 买卖合同	89
第二节 供用电、水、气、热力合同	92
第三节 赠与合同	92
第四节 借款合同	93
第五节 保证合同	94
第六节 租赁合同	96
第七节 融资租赁合同	97
第八节 保理合同	98
第九节 承揽合同	99
第十节 建设工程合同	99
第十一节 运输合同	100
第十二节 技术合同	102
第十三节 保管合同	104
第十四节 仓储合同	105
第十五节 委托合同	105
第十六节 物业服务合同	107
第十七节 行纪合同	108
第十八节 中介合同	108
第十九节 合伙合同	109
第十六章 准合同	110
第一节 无因管理	110
第二节 不当得利	110
第十七章 知识产权	111
第一节 知识产权概述	111
第二节 几种典型的知识产权	112
第十八章 人格权	118
第一节 人格权概述	118
第二节 具体人格权	119
第十九章 婚姻家庭	124

第一节 亲属	124
第二节 结婚	126
第三节 家庭关系	127
第四节 离婚	130
第五节 收养	134
第二十章 继承	136
第一节 继承概述	136
第二节 法定继承	138
第三节 遗嘱继承和遗赠	140
第四节 遗产的处理	143
第二十一章 侵权责任	145
第一节 侵权责任概述	145
第二节 一般侵权责任的构成要件	147
第三节 损害赔偿	148
第四节 数人侵权行为及其责任	149
第五节 侵权责任的抗辩事由	150
第六节 特殊责任主体的侵权责任	151
第七节 产品责任	154
第八节 机动车交通事故责任	155
第九节 医疗损害责任	156
第十节 环境污染和生态破坏责任	157
第十一节 高度危险责任	158
第十二节 饲养动物损害责任	159
第十三节 建筑物和物件损害责任	159

更多免费资料 咨询厚大法硕专业规划老师哦！



民法学

第一章 绪论

第一节 民法概述

一、民法的概念

【分析】民法是调整平等主体之间发生的人身关系和财产关系的法律规范的总和。我国《民法典》第2条明确规定，民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。《民法典》的规定揭示了我国民法调整的社会关系的范围及其特点，划分了民法与其他法律部门的界限。

民法的概念可以从以下三个方面来理解：

1. 民法调整的是平等主体之间的社会关系。民事法律关系主体之间法律地位的平等，是民法区别于调整具有隶属关系的主体之间的法律部门（如行政法等法律部门等）的重要标志。

2. 民法所调整的社会关系在内容上表现为人身关系和财产关系。

3. 民法是调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法律规范的总和。

纵观各国民事立法和民法理论，可将民法作以下划分：

第一，形式意义上的民法和实质意义上的民法。形式意义上的民法，指由立法机关系统编纂成《民法典》的民法规范体系。实质意义上的民法，指具备民法实质内容的民事法律规范体系，包括《民法典》和其他民事法律、法规。我国2020年编纂完成《民法典》，2021年1月1日起施行。

习近平总书记指出：民法典在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位，是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律，对推进全面依法治国、加快建设社会主义法治国家，对发展社会主义市场经济、巩固社会主义基本经济制度，对坚持以人民为中心的发展思想、依法维护人民权益、推动我国人权事业发展，对推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重大意义。民法典系统整合了新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范，汲取了中华民族5000多年优秀法律文化，借鉴了人类法治文明建设有益成果，是一部体现我国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典，是一部体现对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利平等保护的民法典，是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。

第二，广义的民法和狭义的民法。广义的民法，是指一切调整平等主体之间人身关系和财产关系的成文法和不成文法、民事基本法和民事特别法的总和，其外延包括民法典、其他民事法律法规以及传统商法等。狭义的民法，仅指编纂成民法典的民事法律规范系统。

二、民法的性质

【分析】民法的性质表现为以下五个方面：

1. 民法是私法。民法的调整对象决定了民法是私法，民法调整的社会关系主要涉及私人利益，民事主体之间是平等主体的关系，国家也是作为特殊的民事主体参与民事活动。将民法归入私法范畴，有助于提倡当事人意思自治，尽可能减少国家干预，并有助于培育和发展公民的权利意识和平等观念。

2. 民法是调整市场经济关系的基本法。这主要是从民法调整的财产关系的性质归纳得出的。从历史发展来看，民法始终与商品经济或市场经济的发展相联系；从内容来看，民法调整的财产关系主要是财产归属关系和财产流通关系。

3. 民法是调整市民社会关系的基本法。市民社会是与政治国家相对存在的，一般是指当代社会秩序中的各种非政治领域。民法调整市民社会关系，重在保护市民的私权，加大对个人自由权利的保障，以构建和谐的市民社会秩序。

4. 民法是权利法。民法最基本的职能在于对民事权利的确认和保护。从起源来看，民法就是为了排除公权力的不当干预、保障公民权利不受侵犯而产生的。民法体系的构建以权利为基本的逻辑起点，民法总则和民法分则都是围绕权利展开的。民法通过权利确认当事人的行为规则，通过救济确保权利得到实现。

5. 民法是实体法。民法规定民事主体相互间权利义务的实体内容。民法作为实体法，既是行为规则，又是裁判规则。民法作为行为规则具有确立交易规则和生活规则的功能，作为裁判规则是司法机关正确处理民事纠纷所要依循的准则。

三、民法和社会主义核心价值观

【分析】坚持用社会主义核心价值观塑造《民法典》是我国民法的显著特征。党的十八大提出，倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观。

在《民法典》编纂过程中，科学立法要求坚持正确的政治立场，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在立法目的和价值取向上旗帜鲜明地弘扬社会主义核心价值观。社会主义核心价值观融入《民法典》，其明显的表现为《民法典》第1条规定：“为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。”用社会主义核心价值观塑造《民法典》的精神灵魂，不仅要在立法技术上通盘考虑，还要在立法宗旨上宣示、在基本原则恪守、在一般规范上体现、在具体规范中融入，使社会主义核心价值观成为鲜明的精神轴线，贯穿《民法典》的始终，为民事主体参与民事活动提供基本规则和价值遵循。

《民法典》是对社会生活规则的总结，在社会主义市场经济运转过程之中，竞争压力不可避免地会带来人际关系的紧张，各种社会矛盾凸现，培育和践行社会主义友善价值观，无疑能为缓解社会矛盾、维护社会良好秩序、促进社会和谐提供坚实的价值基础。《民法典》的编纂是在整合既有的民事立法的基础上展开的，除了价值同源，很大程度上也在具体制度上表现出对社会主义核心价值观的表达。需要注意的是，在司法实践中，法律人不能简单地认为很多传统民法既有的具体规则已经表达出社会主义核心价值观的独特精神内涵，还需要结合社会主义的本质去解释和适用这些规则。

四、民法的渊源

【分析】民法的渊源是指民法的具体表现形式。

民法的渊源包括两种类型：一是制定法，二是非制定法。制定法是指经过具有立法权或准立法权的国家机关，以条款形式加以编纂，而制定成文件的法律或法规。作为民法渊源的制定法主要包括：

1. 宪法。《宪法》是我国的根本法，具有最高的法律效力。

2. 民事法律。法律是指由国家立法机关制定的具有普遍约束力的立法文件。包括：（1）作为民事基本法的《民法典》。（2）民事单行法，例如《商标法》《专利法》《著作权法》等，以及针对特定权利主体、客体或特殊问题而制定的既有民法规范又有行政法规范的法律，如《合伙企业法》《消费者权益保护法》等。

3. 行政法规。行政法规是国务院制定的规范性文件，其中有些规范属于民事规范，属于民法的渊源。

4. 地方性法规。地方性法规是由地方人大制定的规范性文件，其中的民法规范属于民法的渊源。

5. 规章。规章包括部门规章和地方政府规章，规章中的民事规范属于民法的渊源。

6. 司法解释。司法解释主要是指最高人民法院所做的司法解释等。

7. 国际条约。我国签订的国际条约对于我国国内的自然人、法人等民事主体也具有与国内法一样的约束力。

非制定法主要包括民事习惯。民事习惯，是指当事人所知悉或实践的生活和交易习惯。在一定地域、行业范围内，长期为一般人从事民事活动时普遍遵守的民间习俗、惯常做法等，可以认定为《民法典》第10条规定的“习惯”。在我国，习惯作为民法的渊源是受限制的，根据《民法典》第10条的规定，只有不违背社会主义核心价值观和公序良俗的习惯，才具有民法渊源的意义，而且只有在法律没有规定的情况下才能适用习惯。

五、民法的解释

【分析】民法的解释，是指当民法规范不明确时，特定的解释主体运用一定的方法和原则并遵循法定的权限和程序探求民事法律规范含义的活动。民法解释的必要性体现在：第一，法律必须通过解释才能适用。第二，通过梳理法条的内在结构和逻辑关系从而弥补法律漏洞的需要。第三，法律解释也是法官创造性地适用法律，充分实现司法公正的要求。

民法解释的方法主要有以下七种：

1. 文义解释。文义解释是指根据民事法律规范中所使用的文字的字面意义进行解释的方法，又称文理解释。法律解释必须以文义解释为出发点，所作的解释不能超过条文可能的文义的范围。

2. 体系解释。体系解释是指根据民事法律规范在法律体系中的位置，即与其他法律规范的关联，确定其含义和内容的解释方法。

3. 历史解释。历史解释又称立法解释，是通过探求立法者在制定民事法律规范时的立法意图进行民法解释的方法。历史解释的主要依据是立法过程中相关的立法资料，如法律草案、立法理由书等。

4. 目的解释。目的解释是指不拘泥于民事法律规范的字面含义以及立法者制定法律时的立法意图，从现实的社会关系发展的要求出发，依据合理的目的进行法律解释。

5. 扩张解释。扩张解释是指当民事法律规范的条文中所使用的文字、词语的文义过于狭窄，不足以涵盖立法者所欲调整的范围时，为符合立法本意，对文义进行扩张，将排除在适用范围之外的案件纳入调整范围的解释方法。

6. 限缩解释。限缩解释是指当民事法律规范的条文中所使用的文字、词语的文义过宽泛，包含了本应排除在调整范围之外的案件时，为符合立法本意，对文义进行限制，将不应适用该条文的案件排除在外的解释方法。

7. 当然解释。当然解释是指虽然法律没有明文规定，但是依据规范的目的进行衡量，某一事实比法律所规定的事实更有适用的理由时，直接将法律规定适用于该事实的法律解释方法。这种解释方法通常被称为“举重以明轻，举轻以明重”。

此外，还有合宪性解释、比较法解释、社会学解释等民法解释的方法。

六、民法的适用

【分析】民法的适用也称民法的效力，是指民事法律规范在何时、何地、对何人发生法律效力。民法的效力包括以下三个方面：

（一）民法在时间上的效力

民法在时间上的效力，主要指两个方面：

1. 民事法律规范发生法律效力的起止时间，即从什么时间开始生效，到什么时间效力终止。立法上对民事法律规范开始生效的时间规定，通常有两种：（1）在法律文件中明确规定该法从通过或公布之日起开始生效；

(2) 在法律文件中单列一条说明该法在公布后的某一具体时间开始生效。例如《民法典》于2020年5月28日通过,《民法典》第1260条第一句规定:“本法自2021年1月1日起施行。”这种规定是为了让人们在新法生效之前了解该法,并给有关司法机关以准备时间。民事法律的失效时间,法律本身一般都不作规定,而是通过下列方式确定:(1)自然失效。当某一民事法规规定的任务已经完成后,该法规的效力自然终止。(2)在公布新的法律时,明确宣布以前的同类法规与其相抵触的部分效力终止。(3)修改并重新公布实施新的法律的同时宣布原法律的效力终止。如《民法典》第1260条规定:“本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国收养法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国民法总则》同时废止。”

2. 民法溯及既往的效力,即民法对于其公布实施以前发生的民事法律关系有无溯及既往的效力。通常情况下,新的民事法律只适用于该法生效后所发生的民事法律关系,也就是说民法原则上没有溯及既往的效力。但在例外的情形下,民法也可以具有追溯力。

(二) 民法在空间上的效力

民法在空间上的效力是指民法在什么地域内适用。由于制定法律的机关不同,民法在空间上的适用范围也不同。一般分为两种情况:

1. 凡是由全国人民代表大会及其常委会、国务院及其各部委等中央机关制定并颁布的民事法规,适用于中华人民共和国的领土、领海、领空,以及根据国际法和国际惯例应当视为我国领域的一切领域。例如我国的驻外使馆、领馆,我国在境外的船舶、飞机等。

2. 凡是地方各级政权机关所颁布的法规,只在该地区内发生法律效力,在其他地区不发生效力。

从以上两种情况可以看出,我国民法的适用范围以属地法为原则,即凡是在中国领域内发生的民事活动,原则上都适用。

(三) 民法对人的效力

民法对人的效力即指民法对哪些人有法律效力。我国民法对人的效力主要有以下三种情况:

1. 对居住在我国境内的中国公民和设立在中国境内的中国法人及非法人组织,都具有法律效力。

2. 对于居留在我国境内的外国人、无国籍人和经我国政府准许设立在中国境内的外国法人,原则上具有法律效力,但依法享有外交豁免权的人除外。另外,我国民法中某些专门由中国公民、法人或非法人组织享有的权利,对外国人、无国籍人和外国法人不具有法律效力。

3. 居住在外国的我国公民,原则上适用居住国的民法,而不适用我国民法。但是,依照我国法律以及我国与其他国家缔结的双边协定或我国参加的国际条约、认可的国际惯例,应当适用我国民法的,仍然适用我国民法。

第二节 民法的调整对象

一、民法调整的人身关系

【分析】人身关系是指与民事主体的人身不可分离,以特定精神利益为内容的社会关系。民法调整的人身关系,是指平等主体之间基于人格或身份而发生的,与人身不可分离,不具有直接财产内容的权利义务关系。民法调整的人身关系包括人格关系和身份关系。人格关系是指民事主体为实现人格利益而发生的权利义务关系,

是因民事主体的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等的享有而产生的民事法律关系。身份关系是自然人基于身份利益发生的权利义务关系，在民法上表现为自然人因婚姻家庭关系等产生的身份关系。

民法调整的人身关系有以下特征：

1. **主体地位平等**。在民法所调整的人身关系中，主体之间虽然存在性别、年龄上的差别，在其他社会关系中还存在职业、职务的差别，但是在民事法律关系中法律地位是平等的，任何人都不得把自己的意志强加于他人。
2. **与人身不可分离**。人身关系与人身不可分离，离开了人身就不会发生人身关系。
3. **民法所调整的人身关系虽然不具有直接的财产内容，但是某些人身关系是财产关系产生的前提条件**，如亲属间的身份权是亲属间取得财产继承权的前提条件。同时，对民事主体的人身权进行侵害会导致民事主体的财产损失。因此，对于人身权进行法律保护的责任方式既有停止侵害、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉等非财产性的责任方式，也有赔偿损失这样的财产性的责任方式。

二、民法调整的财产关系

【分析】财产关系，是指人们在物质资料的生产、分配、交换、消费的过程中形成的具有经济内容的社会关系。民法调整的财产关系，是指平等主体之间以财产归属和财产流转为主要内容的权利义务关系。

民法调整的财产关系具有以下特征：

1. **主体地位平等**。民事主体具有独立的法律人格，其法律地位平等、互不隶属，不存在领导与被领导、管理与被管理的关系。
2. **主体意思表示自由**。民法所调整的财产关系的产生、变更、消灭都是在民事主体自愿的基础上进行的，一方不得将自己的意志强加于另一方。
3. **民法所调整的财产关系的基本内容是财产归属关系和财产流转关系**。财产归属关系是指民事主体因占有、使用、收益、处分财产而形成的权利义务关系。财产流转关系是指民事主体为获取利益而相互交换财产所形成的权利义务关系，如债权债务关系等。财产归属关系与财产流转关系之间有着密切的联系，财产归属关系是财产流转关系的前提，财产流转关系又常常是财产归属关系的发生根据。
4. **民法所调整的财产关系在利益实现方面大多具有有偿的特点**。在法律法规允许的范围内，民事主体可以合理谋求利益最大化，不需要遵循过高的道德标准。取得财产利益应当支付相应的对价，这一特点是市场经济条件下民事主体对于财产利益实现的基本要求。但在坚持民事主体平等、自愿的前提下，赠与、借用等民事法律关系中不适用有偿原则也是法律所允许的。

第三节 民法的基本原则

一、民法基本原则的概念和功能

【分析】民法基本原则，是指效力贯穿于民法始终的基本准则，是对民事立法、民事行为和民事司法具有普遍指导意义的基本准则。民法基本原则是民法调整的社会关系和民法观念的综合反映。

民法基本原则的功能主要表现为以下三个方面：

1. **指导功能**。民法基本原则的功能突出表现在它的指导性。民法基本原则对民事立法、民事行为和民事司法均有指导意义。
2. **约束功能**。民法基本原则对民事立法、民事行为和民事司法有约束力。
3. **补充功能**。民法基本原则在民事法律规范中处于指导和统帅的地位，但是通常在民事法律规范有具体规

定的情况下，必须适用具体规定，不能直接适用民法基本原则。

二、平等原则

【分析】《民法典》第4条规定，民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。平等原则是由民法调整的社会关系的性质决定的，没有平等就没有民法，市场经济最本质的特征就体现在主体之间的平等性上。

平等原则具体表现在以下四个方面：

1. 自然人的民事权利能力一律平等。任何自然人在法律上不分尊卑贵贱、财富多寡、种族差异、性别差异，其抽象人格都是平等的。

2. 不同民事主体参与民事法律关系适用同一法律，处于平等的地位。

3. 民事主体在民事法律关系中必须平等协商。任何一方当事人不得将自己的意志强加给另一方当事人。

4. 对权利予以平等的保护。在法律上，无论具体的人具有何种事实上的差异，当其权利受到侵害时，法律都给予平等保护。

三、自愿原则

【分析】《民法典》第5条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。自愿原则，是指民事主体在从事民事活动时，在法律允许的范围内自由表达自己的意愿，并按其意愿设立、变更、终止民事法律关系的原则。自愿原则在传统民法中表述为意思自治原则。自愿原则与民事法律关系主体法律地位平等具有密切的关系。法律地位平等是自愿原则的前提，自愿原则是法律地位平等的体现。民事主体的法律地位平等，每个人都具有独立的意志，任何一方当事人都不受他方当事人意志的支配。

自愿原则具体表现在以下三个方面：

1. 民事主体有权自主决定是否参加民事活动以及如何参加民事活动。也就是说，当事人可以对所参与的民事法律关系的相对人、内容、行为方式、形式等依据其意志自由选择。

2. 民事主体应当以平等协商的方式从事民事活动，就民事法律关系的设立、变更、终止达成合意。

3. 在法律允许的范围内，民事主体有权依其意愿自主作出决定，并对其自由表达的真实意愿负责，任何组织和个人不得非法干预。

四、公平原则

【分析】《民法典》第6条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。公平原则，是指民事主体应当本着公平的理念从事民事活动，司法机关应当根据公平的理念处理民事纠纷。公平原则是将市场经济活动中公平交易和公平竞争的道德准则上升为法律原则的结果。这一原则对于维护市场经济秩序、弥补法律漏洞有重要意义。

公平原则与自愿原则有着密切的关系。公平原则是自愿原则的必要补充，并为是否适用诚实信用原则和显失公平原则树立了判断标准。公平原则的适用需要以自愿原则的适用为前提和基础，即使当事人之间利益关系不符合等价有偿原则，只要是当事人自愿的结果，就不能认为违背了公平原则。

公平原则具体表现在以下两个方面：

1. 民事主体在从事民事法律活动时，应当本着公平的理念合理地确定权利义务关系，并且正当地行使权利、履行义务，兼顾他人利益和社会公共利益。

2. 司法机关在处理民事纠纷的过程中应当做到公平合理。在法律没有明文规定时，司法机关依据公平原则获得自由裁量权，本着公平、正义的理念进行裁判，解决民事纠纷。

五、诚实信用原则

【分析】《民法典》第7条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。诚实信用原则，是指民事主体从事民事活动时，应当诚实守信，正当地行使民事权利并履行民事义务，不实施欺诈和规避法律的行为，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。诚实信用原则是市场经济活动中的一项基本道德准则。民法将这一道德准则上升为法律原则，要求民事主体在民事活动的过程中维持民事主体之间的利益平衡以及当事人利益与社会利益之间的平衡。诚实信用原则在现代民法中具有重要的地位，被誉为现代民法的“帝王条款”。

诚实信用原则具体表现在以下三个方面：

1. 民事主体在从事民事活动时，必须将有关事项和真实情况如实告知对方，禁止隐瞒事实真相和欺骗对方当事人。
2. 民事主体之间一旦作出意思表示并且达成合意，就必须重合同、守信用，正当地行使权利和履行义务。法律禁止当事人背信弃义、擅自毁约的行为。
3. 民事活动过程中发生损害，民事主体双方均应及时采取合理的补救措施，避免和减少损失。

六、合法原则

【分析】《民法典》第8条规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。合法原则，是指民事主体从事民事活动，应当符合法律尤其是公法规范的要求。在我国的法律体系中，有以行政管理性的法律关系为主要规范对象的公法规范，民事活动必须在其秩序框架中进行，尤其是民事法律行为效力的判断中，违反法律的效力性强制性规定的，会导致民事法律行为无效。民事主体行使民事权利也不是绝对自由的，应当受到国家法律等的必要约束和限制，从而协调个人利益和社会利益的关系，维持社会的正常秩序。

七、公序良俗原则

【分析】《民法典》第8条规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。公序良俗即公共秩序和善良风俗。公序包括政治的公序和经济的公序。政治的公序主要是保护国家和家庭的公共秩序。经济的公序包括指导的公序和保护性的公序。在现代社会的条件下，指导的公序日渐式微，保护的公序逐渐占据重要地位。良俗即善良风俗，是指一国或地区在一定时期占主导地位的一般道德或基本伦理要求。公序良俗原则，是指民事主体从事民事活动的内容和目的不得违反公共秩序和善良风俗。

公序良俗原则是现代民法的一项重要法律原则，具有维护社会一般利益以及一般道德观念的重要功能。民法规范的禁止性规定不可能涵盖一切损害社会公共利益和道德秩序的行为，因而需要依据公序良俗原则授予法官自由裁量权以处理民事案件。

民法理论将违反公序良俗行为类型归纳为：危害国家公序的行为类型、危害家庭关系的行为类型、违反两性道德准则的行为类型、射幸行为类型、违反人权和人格尊严的行为类型、限制营业自由的行为类型、违反公共竞争的行为类型、违反消费者保护的行为类型、违反劳动者保护的行为类型、暴利的行为类型等。

八、绿色原则

【分析】《民法典》第9条规定，民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。绿色原则，是指民事主体的民事活动应当符合资源的有效利用和环境保护的要求。绿色原则是代际正义的要求，当代社会经济的发展不能牺牲未来的社会资源和环境。绿色原则也是社会可持续发展的要求，对于民事活动中民事责任承担的利益考量，应当符合绿色原则，例如在环境侵权等特殊侵权构成中基于绿色原则而确定其特殊的构成要件。

《民法典》第9条规定中的绿色原则也是倡导性的原则规定，倡导民事主体的民事活动应有利于节约资源、保护生态环境。民事主体应当选择低能耗、对环境友好的生产、生活方式，以实现节约资源、保护环境、绿色发展的理念。

九、禁止权利滥用原则

【分析】《民法典》第132条规定，民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。禁止权利滥用原则是民事主体行使民事权利的界限，权利都有一定的界限，没有不受任何限制的权利，行使权利超出了一定的界限而损害国家与他人合法权益或社会公共利益则构成权利滥用。权利滥用的构成有三个条件：一是当事人有权利存在；二是权利人有行使权利的行为；三是当事人的行为有滥用权利的违法性。

第二章 民事法律关系

第一节 民事法律关系概述

一、民事法律关系的概念和特征

【分析】民事法律关系是由民事法律规范所确立的以民事权利和民事义务为主要内容的法律关系。

在社会生活中，自然人、法人和非法人组织为了满足自身的各种需要，必须从事各种类型的社会活动，相互之间要发生各种社会关系。为了使社会关系的确立和发展符合国家的要求，国家运用各种法律来调整社会关系，从而使受到法律调整的社会关系获得了法律关系的性质。法律关系是法律规范在调整人们之间的社会关系过程中所形成的一种特殊的社会关系。由于调整各种社会关系的法律不同，所形成的法律关系也就不同。经由民法调整所形成的法律关系就是民事法律关系。

民事法律关系作为现代社会一种重要的社会关系，既具有一般法律关系的特征，也有不同于其他法律关系的特征：

1. 民事法律关系是民法在调整平等主体之间的人身关系和财产关系的过程中所形成的特殊社会关系，民事法律关系的发生，大多取决于民事主体的意思。民法调整一定的人身关系和财产关系，是赋予当事人以民事权利和民事义务，而不是在这些被调整的社会关系之外，形成另一种独立的社会关系。民事法律关系产生以后，民事法律规范便落实为约束当事人行为的具体的权利和义务。民事法律关系的参加者地位平等，相互独立，互不隶属。在权利和义务内容方面，当事人的权利义务对等，双方往往都享有权利，并且都负有义务。一方的权利往往是对方的义务，反之亦然。即使国家作为特殊的民事主体参与民事法律关系，其与其他主体的地位也是平等的，权利义务也是对等的。而且民事法律关系的产生、变更和消灭，特别是民事法律关系的内容，都要取决于当事人的意思。只有充分尊重和保护当事人的真实意思，才能切实保护当事人的合法权益。同时，当事人的意思自由也要受到一定的限制，如不得违反公序良俗等。

2. 民事法律关系的保障措施具有补偿性。民事法律关系是一种由国家强制力保证其实现的社会关系。民事

法律关系中确定的民事权利和民事义务受到法律的保护和约束。法律对于民事权利的保护，主要是赋予遭受损害的一方当事人以**请求权**。通过请求权的行使，弥补该方当事人所遭受的损失。民事法律关系的保障措施具有补偿性，以弥补损失为主要目的，惩罚性的赔偿责任不是主要的民事责任形式。

二、民事法律关系的分类

► 人身法律关系和财产法律关系

【分析】民法以人身关系和财产关系为其调整对象。根据调整对象的不同，民事法律关系也分为人身法律关系和财产法律关系或称人身权关系和财产权关系。这是民事法律关系最基本的分类。

人身法律关系是指与民事主体的人身不可分离，为满足民事主体的人身利益所形成的民事法律关系。如因民事主体的姓名、名称、名誉、荣誉而发生的关系，因发明以及因创作出科学、文学、艺术作品而发生的法律关系中的人身权利义务方面，都属于人身法律关系。人身法律关系不具有直接的物质利益内容，这是它与财产法律关系的基本区别。但这并不是说人身法律关系与人的物质利益不发生联系。比如名誉权，就可能给权利人带来一定的物质利益；反之，如果名誉权受到侵害，也可能给权利人造成财产损失。

财产法律关系是与财产有关的民事法律关系。具体而言，它是民事主体之间因财产的归属和流转而形成的，满足民事主体财产利益需要的民事法律关系。所有权关系、用益物权关系、担保物权关系、买卖合同关系、租赁合同关系、借款合同关系等都属于财产法律关系。由于民法主要调整财产关系，因此财产法律关系在民事法律关系中占有很大的比重。

人身法律关系和财产法律关系有以下区别：

1. 两类关系中的权利性质不同。在财产法律关系中，权利人所享有的权利是财产权利，通常是可以被权利人依其意志转让的。而在人身法律关系中，权利人所享有的权利是人格权或身份权，这些权利与权利主体的人身不可分离，权利人一般不能将其转让给他人。例如，姓名权的权利人是不能把姓名权转让给任何人的。当然也有例外，如营利法人的名称权就可以转让。

2. 对这两类关系的保护方法不同。在财产法律关系受到破坏时，对加害人主要适用财产性质的责任，以补偿受害人所受的财产损害，如要求加害人返还原物、赔偿损失、支付违约金等。而在人身法律关系受到破坏时，对加害人则主要适用非财产性质的责任，以恢复权利人被侵害的权利，如要求加害人赔礼道歉、消除影响等。当然，如果侵犯人身法律关系的行为给权利人造成了物质利益损害，也可对加害人适用财产性质的责任，但这种责任形式并不是保护人身法律关系的主要方法。

► 绝对法律关系和相对法律关系

【分析】根据民事法律关系的义务主体范围的不同，民事法律关系可以分为绝对法律关系和相对法律关系。

绝对法律关系，是指与权利人相对应的义务人是权利人以外一切不特定人的民事法律关系。在这种法律关系中，权利人无须通过义务人的协助，即可直接行使和实现其权利；义务人则是一切不特定的人，其义务一般表现为消极的不作为，即不得实施任何妨碍权利人行使和实现权利的行为。相对法律关系，是指与权利人相对应的义务人是特定人的民事法律关系。在这种法律关系中，权利人实现其权利必须有具体的义务人协助。义务人可以是特定的一人或数人，其所承担的义务一般是实施某种积极的行为，其他第三人对权利人则不负有积极义务。在绝对法律关系不能正常实现时，也会产生相对法律关系，例如所有权和人身权受到侵害时，就会在权利人和侵害人之间产生侵权损害赔偿关系。

区分绝对法律关系和相对法律关系，有利于确定民事法律关系的义务人及其义务，从而更好地适用民法规范。

► 物权关系和债权关系

【分析】根据权利人权利实现方式的不同，财产法律关系又可分为物权关系和债权关系，这也是绝对法律关系和相对法律关系在财产法律关系中的具体体现。

物权关系是指以物为客体所形成的法律关系。物权关系中的权利人可以直接支配物，而不需要义务人实施某种积极行为予以配合。在物权关系中，义务人为权利人之外的一切不特定人，其义务一般为不实施阻碍权利人行使其权利的行为，它是一种绝对法律关系。所有权关系就是一种物权关系。债权关系是指权利人必须由义务人的一定行为相配合，才能行使和实现其权利的民事法律关系。在债权关系中，义务人可以为一人也可为数人，但总是特定的，义务人的一定行为通常是积极的行为。债权关系属于相对法律关系。

区分物权关系与债权关系的意义在于明确物权和债权作为两类基本的财产权的不同特点。正是根据这种分类，民法中建立了物权法和债权法这两种主要的财产法律制度。

第二节 民事法律关系的要素

一、民事法律关系的主体

【分析】民事法律关系的主体，也称为民事主体，是指参加民事法律关系，享受民事权利并承担民事义务的人。民事法律关系的主体并不等同于民法中所谓的主体。民法中的主体，是得到法律的承认，能够以其自己的名义参与民事法律关系的客观存在。也就是说，作为民法中的主体有两个基本要件，即客观存在和为法律所承认。在一定的历史时期，哪些人可以作为民法中的主体，取决于法律规定，所以民法中的主体是一个历史范畴。而民事法律关系的主体是就具体的民事法律关系而言，即存在于某一民事法律关系中的具体的、特定的主体才是民事法律关系的主体。因此，民法中的主体只是有成为民事法律关系主体的可能性，只有当他参与到具体的民事法律关系中才能成为民事法律关系的主体。在我国，民事主体主要包括自然人、法人和非法人组织。国家作为整体，在一些场合也是民事法律关系的特殊主体。任何个人和组织要成为民事主体，必须由法律赋予其主体资格。

民事法律关系作为人与人之间的社会关系，总是要有多方主体参加。如果只有一方主体存在，就不可能发生社会关系，也不可能形成法律关系。因此，在民事法律关系中总是存在相对应的多个主体，其中享有权利的一方是权利主体，承担义务的一方是义务主体。在某些民事法律关系中（例如赠与等），一方只享有权利，另一方只承担义务。而在大多数民事法律关系中，双方当事人既享有权利，又承担义务。例如，在买卖合同关系中，买方既有请求卖方交付标的物并移转标的物所有权的权利，又有支付价款的义务；卖方既有交付标的物并移转标的物所有权的义务，又有收取价款的权利。因此，在这些民事法律关系中，每一方当事人既是权利主体，又是义务主体。当事人的这种双重主体身份，是由这些法律关系的**双务性**决定的。

民事法律关系的主体并非总是只有一人，也即民事法律关系的主体有**单一主体、多数主体**之分。民事法律关系的每一方主体可以是单一的，也可以是多数的。例如，在债权关系中，债权人和债务人双方既可以是一个人，也可以是几个人。如果债权人或债务人为多个人时，则他们同时作为债权人或债务人一方享有权利或承担义务。民事法律关系的主体有**特定主体和不特定主体**之分。在相对法律关系中，每一方主体都是特定的；在绝对法律关系中，承担义务的一方是不特定的。可见，**只有义务主体才存在特定和不特定之分，任何法律关系中的权利主体都是特定的。**

二、民事法律关系的内容

【分析】民事法律关系的内容是指民事主体所享有的民事权利和承担的民事义务。这种权利义务内容是民法调整的社会关系在法律上的直接表现。任何个人和组织作为民事主体参与民事法律关系，必然要享有民事权

利、承担民事义务。

民事法律关系中的权利和义务是相互对立、相互联系的。在任何一个民事法律关系中，权利和义务都是一致的，权利的内容要通过相应的义务表现，而义务的内容则由相应的权利限定。当事人一方享有权利，必然有另一方负有相应的义务，并且权利和义务往往是同时产生、变更和消灭的。因此，民事权利和民事义务是从不同的角度来表现民事法律关系的内容的。

三、民事法律关系的客体

【分析】民事法律关系的客体与主体相对应，是指民事权利和民事义务所指向的对象。

民事法律关系的客体主要有五类，即物、行为、智力成果、人身利益和权利。其中，物权法律关系的客体主要是物，例如所有权；用益物权法律关系的客体一般仅限于物；担保物权法律关系的客体一般也是物，但不限于物，还包括权利，如权利质押等；债权法律关系的客体是给付行为，行为所指向的对象包括物和行为；人身权法律关系的客体是人身利益，如健康、肖像、名誉、隐私等；知识产权法律关系的客体是智力成果。

物的分类主要有：（1）根据物是否具有可移动性，物可以分为动产与不动产。动产是指能够移动且不会因移动损害其价值的物，如生产设备、运输工具等；不动产是指不能移动或虽可移动但会因移动损害其价值的物，如土地、附着于土地的建筑物及其他定着物、建筑物的固定附属设备等。二者的物权变动公示方式不同，在二者之上存在的物权种类也不同。（2）根据两物之间的关系，物可以分为主物和从物。在为同一所有人所有，需共同使用才能更好地发挥作用的两物中，起主要作用的即为主物，辅助主物发挥效用的即为从物。主物转让的，从物随主物转让，但当事人另有约定的除外。（3）根据两物之间的派生关系，物可以分为原物与孳息。原物是指能够产生收益的物，孳息为原物产生的收益。孳息分天然孳息与法定孳息，前者为基于物的自然属性产生的孳息，如果实等；后者是依法律关系产生的孳息，如利息等。根据我国现行法之规定，天然孳息由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。（4）根据物是否具有独特的特征或是否被特定化，物可以分为特定物和种类物。特定物既包括独具特征、独一无二的物，也包括经交易当事人指定而被特定化的种类物；种类物是指具有共同的属性，可以通过品种、规格、型号等加以确定的物。在交易中，种类物的所有权只能在交付后转移，而特定物的所有权转移时间可由当事人约定。另外，如在交付前意外灭失，特定物因不可替代发生债的履行不能，债务人改负赔偿责任；标的物为种类物的，债务人不能免除继续履行的责任。

第三节 民事权利、民事义务

一、民事权利

►民事权利的概念和特征

【分析】民事权利是指民事主体为实现某种利益而依法为某种行为或不为某种行为的自由。民事权利是由民法所赋予的，并且是构成民法的基本内容。从性质上看，任何民事权利都体现着一定的利益，但它并不是生活中的一切利益，而是权利人的个体利益与整个社会利益的结合。对社会不利、不符合社会利益的个体利益，法律是不会保护的。权利所体现出的一定的利益，实际上是确定人们享有利益和实现某种利益行为的范围或限度，在这一限度内，权利主体可以依自己的意志享有某种利益，或者依自己的意志去实现某种利益，由此表现出权利的意志因素，反映出权利人发挥其积极性、主动性的行为自由。

民事权利的特征包括：

1. 权利人依法直接享有某种利益，或者实施一定行为的自由。

2. 权利人可以请求义务人为一定行为或不为一行为，以保证其享有实现某种利益的自由。

3. 这种自由是有保障的自由，它表现为在权利受到侵犯时，具有请求有权国家机关予以保护的可能性。

►民事权利的分类

【分析】民事权利按照不同的标准可以作如下分类：

1. 人身权和财产权。这是依据权利的客体的不同所作的分类。人身权是指以实现人身利益的自由为内容，与权利人的人身密不可分的民事权利，如生命权、健康权、肖像权、名誉权、隐私权、配偶权、亲属权等。《民法典》第五章第 109 条至第 112 条规定的是人身权。财产权是指以实现财产利益的自由为内容，直接体现某种物质利益的权利，如物权、债权等。《民法典》第五章第 113 条至第 122 条规定的是财产权。另外还有一些权利不能简单概括为人身权还是财产权，例如股权等。

2. 支配权、请求权、抗辩权、形成权。这是根据权利的作用的不同所作的分类。支配权是指可以对标的物直接支配并排除他人干涉的权利，例如所有权。请求权是指请求他人为一定行为或不为一行为的权利，例如债权。抗辩权是指对抗请求权或否认对方权利的权利，例如不安抗辩权。形成权是指当事人一方可以以自己的行为使法律关系发生变动的权利，例如对可撤销合同的撤销权、合同解除权、对效力未定合同的追认权、选择之债中的选择权等。

3. 绝对权和相对权。这是以权利人可以对抗的义务人的范围为标准所作的分类。绝对权，又称对世权，是指义务人不确定，权利人无须通过义务人实施一定的积极协助行为即可实现的权利，如所有权、人身权等。相对权，又称对人权，是指权利人和义务人均均为特定人，权利人必须通过义务人的积极实施或者不实施一定行为才能实现的权

4. 主权利和从权利。这是根据权利的相互关系所作的分类。主权利是指相互关联的两个民事权利中可以独立存在的权利。从权利则指以主权利的存在为其存在前提的权利。主权利移转或者消灭时，从权利也随之移转和消灭。典型的从权利是担保物权。

5. 既得权和期待权。这是根据民事权利的成立要件是否全部实现所作的分类。既得权是指成立要件已经全部具备并被主体实际享有的权利。期待权是指成立要件尚未全部具备，将来有可能实现的权利。在所有权保留的买卖合同中，买受人对其购买的物品在获得完全的所有权之前所享有的权利就是期待权。

►民事权利的行使

【分析】民事权利的行使也就是民事权利内容的实现。民事权利的行使是实现民事权利内容的过程，民事权利的实现是民事权利行使的结果。行使民事权利的方法多种多样，主要包括事实行为和民事法律行为两种方法。民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。

民事权利的行使应当遵循以下原则：

1. 民事权利的行使必须符合国家法律和社会公共利益的要求。

2. 不得滥用权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素认定是否构成权利滥用。

3. 民事权利的行使必须符合诚实信用原则。

►民事权利的保护

【分析】民事权利的保护措施根据性质的不同可以分为私力救济和公力救济两种。

1. 民事权利的私力救济，又称民事权利的自我保护，是指权利人自己采取各种合法手段来保护自己的权利不受侵犯。民事权利主体可以以法律许可的方式在法律允许的限度内保护自己的权利。例如，正当防卫、紧急

避险、自助行为等。

2. 民事权利的公力救济，又称民事权利的国家保护，是指民事权利受到侵害时，由国家机关给予保护。民事主体的民事权利受到侵犯时，可以诉请人民法院或仲裁机关予以裁判，也可以依法请求有关的国家机关给予保护。

二、民事义务

►民事义务的概念和特征

【分析】民事义务和民事权利相对应，是指义务人为满足权利人的利益而受到的为一定行为或不为一定行为的约束。民事义务和民事权利一样，也是由法律所确认的，同样也体现着个人利益和社会利益的统一。民事义务规定了义务主体的行为范围，即义务人必须这样做或那样做。如果没有义务人的这种必要行为，既不能满足权利人的利益需要，也不能维护国家所需要的社会秩序。可见，义务同样体现着个人利益和社会利益的统一，不同的是，民事义务体现了主体行为的必要性，而民事权利体现的是主体行为的可能性。

民事义务的特征包括：

1. 义务人必须依据法律的规定或合同的约定，为一定的行为或不为一定的行为，以便满足权利人的利益。
2. 义务人只承担法定的或约定的范围内的义务，而不承担超出这些范围以外的义务。
3. 义务人必须履行其义务。民事义务是一种受到国家强制力约束的法律义务，如果义务人不履行其义务，

将依法承担法律责任。

►民事义务的分类

【分析】民事义务与民事权利相对应，因此可以与民事权利的分类相对应。除此之外，民事义务还有独立的分类，按照不同的标准可作如下分类：

1. 法定义务与约定义务。这是以民事义务的发生根据为标准作的分类。法定义务是指民法规定的民事主体应负的义务。约定义务是由当事人协商约定的义务，约定的义务不得违反法律的强制性规定。

2. 作为义务和不作为义务。这是以民事义务主体行为的方式为标准作的分类。作为义务是指义务人应当做出一定积极行为的义务，又称为积极义务。例如，给付财产、完成工作等。不作为义务是指义务人应为消极行为或者容忍他人的行为，又称为消极义务。例如，不侵害他人物权的义务等。

第四节 民事责任

一、民事责任的概念和特征

【分析】民事责任，是指民事主体违反民事义务应当承担的民事法律后果。民事责任是法律责任的一种类型。法律责任是指实施违法行为或者违约行为而应承担的某种不利法律后果。

民事责任特征包括：

1. 民事责任是民事主体一方对他方承担的责任。

2. 民事责任主要是为了补偿权利人所受损失和恢复民事权利的圆满状态。民事责任侧重于补偿，一般不具有惩罚性。

3. 民事责任既有过错责任又有无过错责任。有些民事责任的构成以民事主体有过错为要件，有些民事责任的构成不以民事主体有过错为要件。

4. 民事责任的内容可以由民事主体在法律允许的范围内协商。

二、民事责任的分类

【分析】民事责任按照不同的标准可以作如下分类：

1. 财产责任和非财产责任。财产责任，是指以一定的财产为内容的责任，例如赔偿损失等。非财产责任，是指不具有财产内容的责任，如消除影响、恢复名誉等。

2. 违约责任、侵权责任和其他责任。违约责任，是指因违反合同义务而产生的责任。侵权责任，是指因侵害他人的财产权益或者人身权益而产生的责任。其他民事责任，是指违约责任与侵权责任之外的民事责任，主要包括基于不当得利和无因管理产生的责任等。这种分类的意义在于责任的构成要件和责任承担方式有所不同。

3. 无限责任和有限责任。无限责任，是指责任主体以自己的全部财产承担责任。例如，合伙企业的普通合伙人对合伙企业债务承担无限责任。有限责任，是指责任主体以其有限的财产承担责任。例如，有限责任公司股东以其出资为限对公司承担责任。

4. 单独责任和共同责任。单独责任，是指由一个民事主体独立承担的责任。共同责任，是指两个以上的民事主体共同承担的责任。

5. 按份责任、连带责任和补充责任。根据各责任主体的共同关系，还可将共同责任分为按份责任、连带责任和补充责任。二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。连带责任，由法律规定或者当事人约定。补充责任是指在责任人的财产不足以承担应负责任时，由有关的人对不足部分予以补充的责任。

《民法典》第185条还特别规定了对英雄烈士特别保护的民事责任，侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。

三、承担民事责任的方式

根据《民法典》第179条的规定，承担民事责任的方式主要有：

（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。

上述责任方式，可以单独适用，也可以合并适用。需要注意的是，有些责任方式只适用于违约责任，如继续履行、支付违约金等；有些责任方式只适用于侵权责任，如赔礼道歉；有些责任方式只适用于对人身权的侵害，如消除影响、恢复名誉，赔礼道歉等。此外，《民法典》或其他法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。

四、民事责任的免责事由

民事责任的免责事由又称抗辩事由，是指不承担责任或者减轻责任的事由。免责事由一般包括不可抗力、正当防卫、紧急避险、受害人过错、第三人原因、自甘风险、自助等。本部分主要介绍下列三种免责事由，其余免责事由参见第十四章中的“违约责任的免责事由”和第二十一章中的“侵权责任的抗辩事由”。

1. 不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

2. 正当防卫

正当防卫是指为了使公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他合法权益免受正在进行的不法侵害，

而对不法侵害人所采取的合理的防卫行为。

因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等因素判断正当防卫人的防卫行为是否超过必要的限度。

3. 紧急避险

紧急避险是指为了使公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他合法权益免受正在发生的危险，而不得已采取的损害另一较小合法权益从而保全更大利益的行为。

因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。应当综合危险的性质、急迫程度、避险行为所保护的权益以及造成的损害后果等因素判断紧急避险人的避险行为是否超过必要的限度。

第五节 民事法律事实

一、民事法律事实的概念

【分析】民事法律事实，是指依法能够引起民事法律关系产生、变更和消灭的客观现象。客观现象是否成为法律事实，取决于法律的规定。时间的经过，严重自然灾害的发生，战争和封锁禁运，人的出生、死亡、成年、失踪、精神失常等，都能引起民事法律关系的发生、变更和消灭，因而属于法律事实。民事法律规范本身并不能在当事人之间引起民事上的权利义务关系，而只是表明民事主体享有权利和承担义务的可能性。民事法律关系的产生、变更和消灭需要具备三个基本的条件：民事法律规范、民事主体和民事法律事实。民事法律规范和民事主体是民事法律关系产生的抽象条件，而民事法律事实则是民事法律关系产生的具体条件。只有在一定的民事法律事实发生后，民事法律关系才能产生，并因一定的民事法律事实的发生而变更或消灭。

民事法律事实出现时，产生如下法律后果：

1. 引起民事法律关系的产生，即民事法律事实的出现使当事人取得权利、承担义务。例如，签订买卖合同这一法律事实，使买方享有请求卖方交付标的物的权利和承担支付价款的义务，使卖方相应享有请求买方支付价款的权利和承担向买方交付标的物的义务。只有通过民事法律事实，才能使民事法律规定的权利义务，转化为当事人实际享有的权利和承担的义务。

2. 引起民事法律关系的变更，即民事法律事实的出现使已存在的民事法律关系的要素发生变化。例如，法人的合并和分立这一民事法律事实，导致债的关系中的主体发生变更。因民事法律事实的出现而导致民事法律关系的变更通常包括：主体变更（权利主体或义务主体发生变化），内容变更（主体享有的民事权利和承担的民事义务在范围和性质上发生变化），客体变更。

3. 引起民事法律关系的消灭，使主体之间的权利义务不再存在。民事法律关系的消灭有两种情形：一是一定民事法律事实的出现导致某一民事法律关系的消灭，并且在当事人之间不会因此而产生其他民事法律关系。例如，所有物被消费，所有权关系因此被消灭；债务被清偿，债的关系因而被消灭。二是一定民事法律事实的出现导致某一民事法律关系的消灭，同时在当事人之间产生其他民事法律关系。例如，所有物被他人毁灭，所有权关系消灭，同时原所有权人和侵害人之间产生债的关系。

民事法律关系的产生、变更和消灭，有时只需要以一个民事法律事实为根据，有时需要以两个或两个以上的民事法律事实的相互结合为根据。例如，遗嘱继承法律关系，就需要立遗嘱的行为和遗嘱人死亡这两个民事法律事实才能够发生。这种引起民事法律关系的产生、变更或消灭的两个以上的民事法律事实的总和，叫作民

事法律关系的事实构成。此时，只有在具备事实构成的情况下，才能引起民事法律关系的产生、变更或消灭。

二、民事法律事实的分类

► 行为

【分析】行为是指受主体意志支配，能够引起民事法律关系发生、变更和消灭的活动。行为又可以分为民事法律行为、准民事法律行为和事实行为。

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。准民事法律行为是指行为人以法律规定的条件业已满足为前提，将一定的内心意思表示于外，从而引起一定法律效果的行为。准民事法律行为包括：意思通知，如要约拒绝、履行催告、选择权行使催告等；观念通知，如承诺迟到通知、发生不可抗力通知、瑕疵通知、债权让与通知、债务的承认等；感情表达，如被继承人对继承人所作出的宽恕的表示等。事实行为是指行为人主观上不一定具有发生、变更或消灭民事法律关系的意思，但客观上能够引起这种后果的行为。如创作作品的行为，作为债权标的的给付行为如交货、付款也属于事实行为。

► 自然事实

【分析】自然事实，又称为非行为事实，是指与人的意志无关，能够引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观现象。自然事实又可分为事件和状态。

事件是指某种客观现象的发生。例如，人的出生、死亡，发生自然灾害等。状态是指某种客观现象持续，如人的下落不明、对物继续占有、权利继续不行使等。

第三章 自然人

第一节 自然人的民事权利能力

一、民事权利能力的概念和特征

【分析】民事权利能力是指民事法律赋予民事主体从事民事活动，从而享有民事权利和承担民事义务的资格。

自然人的民事权利能力是民事法律赋予自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。自然人民事权利能力的特征主要表现在以下四个方面：

1. 民事权利能力是一种资格，而不是实际的权利。民事权利能力是法律赋予民事主体享有民事权利和承担民事义务的一种可能性，还没有为民事主体带来实际的利益，但是它是民事主体获得民事权利的前提。

2. 民事权利能力的内容既包括民事主体取得民事权利的资格，也包括民事主体承担民事义务的资格。自然人享有民事权利和承担民事义务的前提都是自然人必须具有民事权利能力，所以它既可以称为民事权利能力，也可以称为民事义务能力。

3. 民事权利能力的内容和范围具有法定性。民事权利能力的内容和范围都是由法律加以规定的，与民事主体的个人意志无关。法律所赋予自然人的民事权利能力一律平等，不因民族、性别、年龄、职业、健康状况、教育程度、财产状况、宗教信仰等有任何差别，任何自然人不能以自己的意思改变民事权利能力的内容和范围。

4. 民事权利能力具有与民事主体人身的不可分离性。民事权利能力是一种资格，这种资格是由法律赋予的，不能转让或者放弃，除非法律有特别规定，任何民事主体的民事权利能力不受限制和剥夺。

民事权利能力和民事权利是两个不同的概念，民事权利是一种依法可以获得的实际权利，主体可以依法根据自己的意志确定权利的具体内容和实现方法，并且可以转让、放弃自己的民事权利。

二、自然人民事权利能力的开始

【分析】《民法典》第13条规定：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”据此规定，我国自然人的民事权利能力开始时间为出生之时，终止时间为死亡之时。

《民法典》第15条规定：“自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。”根据这一规定，尚未出生的胎儿不具有民事权利能力，不是合法的民事主体，不能享受民事权利、承担民事义务。但是胎儿毕竟未来会成为民事主体，所以，为了保护胎儿的利益，法律也做了特别规定。《民法典》第16条规定：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”父母在胎儿娩出前作为胎儿的法定代理人其主张相应权利。

三、自然人民事权利能力的终止

【分析】根据《民法典》的规定，自然人民事权利能力终止于自然人死亡之时。自然人死亡后，无法承担民事义务，其权利能力也随之消灭。

民法上的死亡，包括自然死亡和宣告死亡。这两种方式无论是哪一种，只要死亡的事实存在，都会导致民事权利能力的消灭。

关于自然死亡的时间确定，理论上也存在各种学说，如呼吸停止说、心脏停止说、脑死亡说等。在实践中，如果自然人在医院死亡的，应以死亡证明记载的时间为准；没有死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。如果相互有继承关系的几个人在同一事件中死亡而无法确定死亡先后时间的，根据《民法典》第1121条第2款规定，相互有继承关系的数人在同一事件中死亡，难以确定死亡时间的，推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人，辈份不同的，推定长辈先死亡；辈份相同的，推定同时死亡，相互不发生继承。

宣告死亡是一种法律拟制的死亡方式，如果被宣告人确实已经死亡，宣告死亡产生的法律效果与自然死亡完全相同。但是如果被宣告人尚未死亡，则其在被宣告死亡期间依然是合法的民事主体，其所从事的民事行为依然有效。当确知被宣告死亡人尚未死亡时，应当依被宣告人或其利害关系人的申请以新的判决撤销原先的宣告死亡判决。

第二节 自然人的民事行为能力

一、自然人民事行为能力的概念和特征

【分析】自然人的民事行为能力是指法律确认的自然人通过自己的行为从事民事活动，参加民事法律关系，取得民事权利和承担民事义务的能力。

自然人的民事权利能力只是一种资格，要想以自己的行为独立参加民事法律关系，还应当具有民事行为能力。自然人具有权利能力是具有行为能力的前提，具有行为能力则是独立实现权利能力内容的必要条件。

自然人民事行为能力的基础就是必须具有正确识别事物、判断事物的能力，即具有意思能力。具有意思能力必须满足两个方面的法律要求：一是要达到一定的年龄，有一定的社会活动经验；二是要有健康正常的精神状态，能够理智地从事民事活动。

自然人民事行为能力的特征主要体现在以下三个方面：

1. 民事行为能力法定性。自然人是否具有民事行为能力是由国家法律确认的，与自然人自己的意志无关。

国家法律规定了自然人具备民事行为能力应当满足的基本条件，这些条件不能通过私人的约定加以更改。

2. 民事行为能力与自然人的年龄和精神状况直接联系。年龄决定了自然人从事民事行为的一般社会认知程度，精神状况则决定了自然人是否能够正确理解和理智地实施民事行为。这两个方面的具体要求都由法律直接加以规定。

3. 民事行为能力非依法定条件和程序不受限制或被取消。除非法律有明确规定，任何组织或个人都不得非法限制或取消自然人的民事行为能力。

二、自然人民事行为能力的分类

【分析】《民法典》将民事行为能力划分为三类，即完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力。

► 完全民事行为能力

【分析】完全民事行为能力是指法律赋予达到一定年龄和精神状态正常的自然人通过自己的独立行为参加民事法律关系，取得民事权利和承担民事义务的能力。各国法律对成年年龄规定各不相同，《民法典》第17条规定：“十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。”《民法典》第18条规定：“成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”根据这一条规定，我国自然人具有完全民事行为能力应当同时满足下列两个条件：

1. 年满18周岁。18周岁是我国自然人成年的界限。对于年满16周岁而不满18周岁，但是以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，法律将其视为完全民事行为能力人。

2. 精神状况健康正常。自然人具有行为能力必须以能够正确理解法律规范和社会生活共同规则，理智地实施民事行为为前提条件。因患有精神病等原因而不能辨认自己行为的人，即使年满18周岁，也不属于完全民事行为能力人。

► 限制民事行为能力

【分析】限制民事行为能力，又称为不完全民事行为能力或部分民事行为能力，是指法律赋予那些达到一定年龄但尚未成年和虽已成年但精神不健全、不能完全辨认自己行为后果的自然人所享有的，可以从事与自己的年龄、智力和精神健康状况相适应的民事活动的能力。限制民事行为能力人实施的民事法律行为是否与其年龄、智力、精神健康状况相适应，人民法院可以从行为与本人生活相关联的程度，本人的智力、精神健康状况能否理解其行为并预见相应的后果，以及标的、数量、价款或者报酬等方面认定。

《民法典》第19条和第22条分别对限制民事行为能力人作出了规定。根据这两条规定，在我国，限制民事行为能力人有两大类：一是8周岁以上的未成年人，他们可以进行与其年龄、智力相适应的民事活动；其他民事活动由其法定代理人代理，或者征得其法定代理人的同意。二是不能完全辨认自己行为的成年人，他们可以进行与其精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由其法定代理人代理，或者征得其法定代理人的同意。

► 无民事行为能力

【分析】无民事行为能力人是指法律规定的完全不具有以自己的行为从事民事活动以取得民事权利和承担民事义务资格的行为人。根据《民法典》第20条和第21条的有关规定，在我国，无民事行为能力人主要有两类，一是不满8周岁的未成年人是无民事行为能力人，由其法定代理人代理民事活动。二是不能辨认自己行为的8周岁以上的自然人是无民事行为能力人，由其法定代理人代理民事活动。

三、自然人欠缺民事行为能力的认定

【分析】自然人的民事行为能力会受到年龄、精神健康状态等各种因素的影响而发生辨认行为能力变化，为此，法律设定了对自然人欠缺民事行为能力的认定制度。《民法典》第24条规定：“不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况，认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。本条规定的有关组织包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、民政部门等。”该条规定不仅规定了申请认定欠缺民事行为能力的制度，而且也规定了经申请恢复民事行为能力的制度，另外还解释了可以作为申请人的“有关组织”的范围。

第三节 监护

一、监护的概念和作用

【分析】民法上的监护是为了监督和保护无民事行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益而设置的一项民事法律制度。履行监督和保护职责的人就是监护人；被监护人监督、保护的人是被监护人。

二、监护的分类

【分析】根据我国《民法典》规定的需要监护的人的类型，监护主要包括未成年人监护和成年人监护两大类。

根据监护权的发生依据，可以将监护划分为法定监护、指定监护、遗嘱监护、协议监护与意定监护等不同的类型。

法定监护是指由法律直接规定的人担任监护人而形成的监护，包括对未成年人的监护与对不能辨认、不能完全辨认自己行为的成年人的监护。

指定监护是指具有监护资格的人之间对担任监护人有争议，或者都要求担任监护人，或者都不愿意担任监护人，由有关组织和人民法院依法指定监护人而形成的监护。

遗嘱监护是指被监护人的父母作为监护人通过遗嘱指定监护人的监护。

协议监护是指具有监护资格的人协议确定由其中一人或数人担任监护人而形成的监护。

根据《民法典》第33条的规定，**意定监护**是指具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。具有完全民事行为能力的成年人与他人订立书面协议事先确定自己的监护人后，协议的任何一方在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力前请求解除协议的，人民法院依法予以支持。该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力后，协议确定的监护人无正当理由请求解除协议的，人民法院不予支持。该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力后，协议确定的监护人有撤销监护人资格的法定事由的，有关个人、组织申请撤销其监护人资格的，人民法院依法予以支持。

三、监护人的设定

【分析】《民法典》第 27 条规定：“父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”根据该规定，未成年人的法定监护人主要为被监护人的关系亲密的近亲属，但并不限于亲属且有一定的监护顺序，顺序在前的监护人排斥顺序在后的监护人。未成年人的父母不能与其他依法具有监护资格的人订立协议约定免除具有监护能力的父母的监护职责。

《民法典》第 28 条规定：“无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）配偶；（二）父母、子女；（三）其他近亲属；（四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”根据该规定，成年人的法定监护人主要也是被监护人的关系亲密的近亲属，但并不限于亲属且也有一定的监护顺序。

《民法典》第 31 条规定：“对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。依据本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。监护人被指定后，不得擅自变更；擅自变更的，不免除被指定的监护人的责任。”指定监护人主要是在有监护争议的时候才会发生，有权指定监护人的机关包括：未成年人住所地的居民委员会、村民委员会、民政部门和人民法院。指定监护人需要考虑如下因素：与被监护人生活、情感联系的密切程度；依法具有监护资格的人的监护顺序；是否有不利于履行监护职责的违法犯罪等情形；依法具有监护资格的人的监护能力、意愿、品行等。意定监护协议确定的监护人无正当理由不能请求解除协议。

四、监护人的职责

【分析】根据《民法典》第 34 条的规定，监护人的职责主要有：

1. 代理被监护人实施民事法律行为。

2. 保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。

监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。

因发生突发事件等紧急情况，监护人暂时无法履行监护职责，被监护人的生活处于无人照料状态的，被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门应当为被监护人安排必要的临时生活照料措施。

根据《民法典》第 35 条的规定，监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。未成年人的监护人履行监护职责，在作出与被监护人利益有关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监护人的真实意愿。成年人的监护人履行监护职责，应当最大程度地尊重被监护人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。

五、监护关系的终止

【分析】监护关系的终止主要有以下五种原因：

1. 被监护人取得或者恢复完全民事行为能力。

2. 监护人丧失监护能力。

3. 被监护人或者监护人死亡。

4. 人民法院认定监护关系终止的其他情形。

5. 监护人被撤销监护人资格。监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：（1）实施严重损害被监护人身心健康的行为；（2）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；（3）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。

依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。被监护人的父母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。

第四节 宣告失踪和宣告死亡

一、宣告失踪

►宣告失踪的概念

【分析】宣告失踪是指经利害关系人申请，由法院依照法定条件和程序，宣告下落不明满法定期限的自然人为失踪人的民事法律制度。

►宣告失踪的条件和程序

【分析】《民法典》第40条规定：“自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。”第41条规定：“自然人下落不明的时间自其失去音讯之日起计算。战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。”根据这两条规定，宣告失踪的条件主要有：

1. 须有自然人离开其住所下落不明满2年的事实。自然人下落不明的时间从其失去音讯之日起计算。下落不明的期间必须持续满2年，有关利害关系人才能到法院申请宣告其失踪。

2. 须由利害关系人向法院提出申请。可以提出申请的利害关系人包括：被申请人的近亲属；代位继承人或者对公婆、对岳父岳母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿；债权人、债务人、合伙人等与被申请人有民事权利义务关系的民事主体，但是不申请宣告失踪不影响其权利行使、义务履行的除外。

3. 须由人民法院依照法定程序宣告。具体的程序为：先由利害关系人到法院提出申请，人民法院受理以后，应当发出寻找下落不明人的公告。公告期为3个月，期间届满后，人民法院根据失踪事实是否得到确认，作出宣告失踪或者驳回申请的判决，并在法定情形下指定失踪人的财产代管人。

►宣告失踪的后果

【分析】宣告失踪的法律后果就是为被宣告失踪人建立财产代管制度。《民法典》第42条规定：“失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。”失踪人所欠税款、债务和应付的其他费用，由财产代管人从失踪人的财产中支付。财产代管人因故意或者重大过失造成失踪人财产损失的，应当承担赔偿责任。失踪人的财产代管人向失踪人的债务人请求偿还债务的，人民法院应当将财产代管人列为原告。债权人提起诉讼，请求失踪人的财产代管人支付失踪人所欠的债务和其他费用的，人民法院应当将财产代管人列为被告。

经审理认为债权人的诉讼请求成立的，人民法院应当判决财产代管人从失踪人的财产中支付失踪人所欠的债务和其他费用。

►失踪宣告的撤销

【分析】如果被宣告失踪人又重新出现，则应当撤销原来的宣告失踪判决。《民法典》第 45 条规定：“失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。失踪人重新出现，有权要求财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。”

二、宣告死亡

►宣告死亡的概念

【分析】宣告死亡是指经利害关系人申请，由法院依照法律规定的条件和程序，判决宣告下落不明满法定期限的自然人死亡的民事法律制度。

►宣告死亡的条件和程序

【分析】《民法典》第 46 条规定：“自然人有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡：（一）下落不明满四年；（二）因意外事件，下落不明满二年。因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。”根据该条和《民法典》第 41 条的规定，宣告死亡的条件主要有：

1. 自然人下落不明达到法定的期间。一般情况下，自然人下落不明满 4 年，因意外事件下落不明满 2 年的，利害关系人就可申请宣告其死亡。因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间的限制。

2. 须有利害关系人的申请。

申请宣告死亡的利害关系人包括被申请人的配偶、父母、子女，以及对公婆、对岳父岳母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿。

符合下列情形之一的，被申请人的其他近亲属，以及代位继承人应当认定为利害关系人：

（1）被申请人的配偶、父母、子女均已死亡或者下落不明的；

（2）不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的。

被申请人的债权人、债务人、合伙人等民事主体不能认定为利害关系人，但是不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的除外。

3. 须由人民法院依照法定程序进行宣告。具体的程序为：首先由利害关系人向法院提出申请，法院受理以后，应当发出寻找失踪人的公告，公告期间为 1 年；因意外事件下落不明经有关机关证明该自然人不可能生存的，公告期间为 3 个月。期间届满下落不明的自然人仍无音讯的，法院应作出宣告该自然人死亡的判决。被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合《民法典》规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

►宣告死亡的后果

【分析】自然人被宣告死亡之后，产生与自然死亡大体相同的法律后果，如婚姻关系消除，个人财产作为遗产发生继承。自然人被宣告死亡但并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

►死亡宣告的撤销

【分析】《民法典》第 50 条规定：“被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。”《民法典》第 51 条至第 53 条规定，死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。被宣告死亡的人在死亡宣告期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养行为无效。在财产关系方面，被撤销死亡宣告的人有权请求依照《民法典》继承编取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡而取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

宣告失踪不是宣告死亡的必经程序，只要符合宣告死亡的条件，利害关系人就可以直接向人民法院申请宣告失踪人死亡。

第五节 个体工商户、农村承包经营户

一、个体工商户的概念和特征

【分析】个体工商户是指在法律允许的范围内，依法经过核准登记，从事工商业经营的自然人。《民法典》第 54 条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。”

个体工商户的特征主要有：

1. 个体工商户的经济性质是私人所有制。个体工商户以自然人个人财产或者家庭财产作为经营资本，其性质属于个体经济。
2. 个体工商户的经营范围必须符合法律规定。根据我国法律规定，个体工商户经营的范围仅限于工商业。
3. 个体工商户必须履行一定的核准登记手续方可成立。个体工商户应当在工商登记管理机关核准的范围内从事生产经营活动。
4. 个体工商户以户的名义独立进行民事活动。个体工商户可以依法起字号、刻图章、在银行开立账户，依法进行生产经营活动。
5. 个体工商户以其全部的个人财产对外承担无限清偿责任。个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

二、农村承包经营户的概念和特征

【分析】《民法典》第 55 条规定：“农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。”

农村承包经营户的特征体现在：

1. 农村承包经营户是我国农村劳动群众集体所有制经济的分散经营方式的法律形式。农村承包经营户是由农村集体经济组织的成员组成，不属于个体经济的范围。
2. 农村承包经营户从事的是农业生产经营活动。农村承包经营户进行生产的目的是进行商品交换，而不是为了满足家庭消费的需要。
3. 农村承包经营户存在的基础是享有土地承包经营权。农村承包经营户依据法律和承包合同享有土地承包经营权，从而经营集体所有的土地、森林、草原、荒地、滩涂、水面等生产资料，从事商品经营，不得违反法律和承包合同的规定。
4. 农村承包经营户以户的名义独立从事民事活动，对外承担无限责任。事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

第四章 法人

第一节 法人概述

一、法人的概念和特征

【分析】法人，是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

法人是相对于自然人的另一类民事主体，法人是一种组织体。虽然在理论上对法人的本质有不同的说法，但既然法律承认其为民事主体，就是要使其便于参加民事法律关系，进行民事活动；作为民事主体，法人不仅能参加民事法律关系，还应具备独立承担民事责任的能力。独立责任使得法人与其成员在人格上分离，也与其他非法人组织相区别；法人的成立还须依据法律的规定。

法人的特征包括：

1. 法人是社会组织。
2. 法人是具有民事权利能力和民事行为能力的组织体。
3. 法人是独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

二、法人的分类

【分析】根据不同的标准，法人分类如下：

1. 公法人和私法人。公法人与私法人的划分是学者将法律分为公法和私法的直接产物，划分标准多种多样，一般而言，“综合说”更为可取。根据该说，认定公法人和私法人应综合多种因素考虑，凡依国家意思设立，目的、事业由法律直接规定，在加入上有强制性规定，人事由国家任免，不得擅自设立和解散的法人是公法人；由私人设立，内部关系平等，经营私法事业，可以由成员大会决定解散的法人是私法人。

2. 社团法人和财团法人。这是根据成立的基础不同而将法人进行的划分。凡是以人的集合为成立基础的是社团法人，凡是以捐助的财产为基础而成立的是财团法人。这也是传统民法对法人进行的最重要的分类。需注意的是，在日本，组织体在经主管官厅许可取得法人资格后，称为社团法人或财团法人，在未取得法人资格前，称为“社团”或“财团”。社团法人与财团法人的区别有以下六个方面：（1）成立基础不同，如前所述。（2）设立人地位不同。社团法人的设立人，在法人成立时，可以成为法人的社员；财团法人的设立人，不能成为法人的成员。（3）设立行为不同。社团法人设立行为属于合同行为，而且为生前行为；财团法人的设立行为则为单方行为，并可以遗嘱方式实施。（4）有无意思机关不同。社团法人有自己的意思机关，而财团法人则没有该机关。（5）目的事业不同。社团法人的目的可以是公益的也可以是营利的；而财团法人的目的只能是为公益事业，不以营利为目的。（6）解散原因及后果不同。社团法人的解散原因是多种的，并可以因成员的协议而解散；而财团法人则只能因为期限届满或财产不足而解散。社团法人解散后，经清算仍有剩余的财产应分给其成员。

3. 营利法人、非营利法人和特别法人。《民法典》依据法人存在的目的，将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。营利法人是指以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，如有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。非营利法人是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。特别法人是指不能简单归入营利法人和非营利法人的法人，包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人等。

第二节 营利法人

一、营利法人的概念

【分析】营利法人是指以取得利润并分配给股东等出资人**为目的成立的法人**。营利法人的“营利”是指以取得利润并分配给股东等出资人**为目的的行为**。营利法人是市场经济活动的基本单位，也是社会生产经营活动的主体。营利法人的存在在于独立从事经营活动。

二、营利法人的机构

【分析】营利法人的机构包括**权力机构、执行机构和监督机构**：

1. 营利法人的权力机构行使修改法人章程，选举或者更换执行机构、监督机构成员，以及法人章程规定的**其他职权**。法人权力机构设置的目的在于确保出资人的利益，确保出资人得以实现其应得到的投资回报。

2. 营利法人的执行机构行使召集权力机构会议，决定法人的经营计划和投资方案，决定法人**内部管理机构**的设置，以及法人章程规定的**其他职权**。执行机构为董事会或者执行董事的，董事长、执行董事或者经理按照法人章程的规定担任法定代表人；未设董事会或者执行董事的，法人章程规定的主要负责人为其执行机构和法定代表人。执行机构是由权力机构选举或决定的。

3. 营利法人的监督机构依法行使检查法人财务，监督执行机构成员、高级管理人员执行法人职务的行为，以及法人章程规定的**其他职权**。由于营利法人的权力机构组成人员分散，可能不具备经营事务和财务方面的专业能力，为了防止执行机构的成员和高级管理人员等执行职务违反法律和章程，需要权力机构选出对法人经营业务的执行情况和法人财务进行专门监督的机构，可以是监事会或者监事等。

三、营利法人出资人的责任

【分析】营利法人的出资人不得滥用出资人权利损害法人或者其他出资人的利益；滥用出资人权利造成法人或者其他出资人损失的，应当依法承担民事责任。出资人滥用权利的行为，在某种意义上就是一般的侵权行为，往往也会侵害法人或者其他出资人的利益，应当承担一定的民事责任。但是出资人权利滥用的行为，应当是在其合法享有的权利基础上进行的行为，如果不是基于出资人的权利，也不构成出资人权利滥用的行为。出资人承担的民事责任属于一般的过错责任。

营利法人的出资人不得滥用法人独立地位和出资人有限责任损害法人债权人的利益。根据《民法典》第83条的规定，**滥用法人独立地位和出资人有限责任，逃避债务，严重损害法人债权人的利益的，应当对法人债务承担连带责任**。为了实现实质正义，依据法定的条件和范围，要求该出资人直接向营利法人的债权人履行民事义务和承担民事责任。这是营利法人的**人格否认制度**，以营利法人具有独立人格为前提，其设立目的是更好地保护债权人和营利法人的利益。

第三节 非营利法人

一、非营利法人的概念

【分析】非营利法人是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得**利润的法人**。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。这里的“非营利”是指目的上

的非营利，至于该类法人在日常运行中开展了某些营利性活动，甚至从中获取了营利收入，并不影响其作为非营利法人的性质。为公益目的成立的非营利法人终止时，不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的；无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的，由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人，并向社会公告。

二、非营利法人的类型

【分析】非营利法人主要包括以下类型：

1. 事业单位法人，是指具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。事业单位法人设理事会的，除法律另有规定外，理事会为其决策机构。事业单位法人的法定代表人依照法律、行政法规或者法人章程的规定产生。

2. 社会团体法人，是指具备法人条件，基于会员共同意愿，为公益目的或者会员共同利益等非营利目的设立的社会团体，经依法登记成立，取得社会团体法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有社会团体法人资格。设立社会团体法人应当依法制定法人章程。社会团体法人应当设会员大会或者会员代表大会等权力机构。社会团体法人应当设理事会等执行机构。理事长或者会长等负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。

3. 捐助法人，是指具备法人条件，为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会服务机构等，经依法登记成立，取得捐助法人资格。依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以申请法人登记，取得捐助法人资格。法律、行政法规对宗教活动场所规定的，依照其规定。设立捐助法人应当依法制定法人章程。捐助法人应当设理事会、民主管理组织等决策机构，并设执行机构。理事长等负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。捐助法人应当设监事会等监督机构。捐助人有权向捐助法人查询捐助财产的使用、管理情况，并提出意见和建议，捐助法人应当及时、如实答复。捐助法人的决策机构、执行机构或者法定代表人作出决定的程序违反法律、行政法规、法人章程，或者决定内容违反法人章程的，捐助人等利害关系人或者主管机关可以请求人民法院撤销该决定。但是，捐助法人依据该决定与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

第四节 特别法人

一、特别法人的概念

【分析】特别法人是除营利法人和非营利法人之外的，具有特殊性的法人组织。这里的“特殊性”主要是指此类法人具有行使公权力的职能。这些法人与营利法人和非营利法人在设立、终止等方面都有所不同，有利于其更好地参与民事活动以及更好地保护其成员和与其进行民事活动的相对人的合法权益。

二、特别法人的类型

【分析】特别法人主要包括：

1. 机关法人，是指有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，从成立之日起，可以从事为履行职能所需要的民事活动的法人。国家机关及承担法定行政职能的法定机构作为行政主体，依法行使行政职权和履行行政职能，在其进行活动、开展工作的过程中，不可避免地要参与商品交换等内容的民事活动。机关法人被撤销的，法人终止，其民事权利和义务由继任的机关法人享有和承担；没有继任的机关法人的，由作出撤销决定的

机关法人享有和承担。

2. 农村集体经济组织法人，是指在一定的村或乡镇的社区范围内的集体成员，利用土地等农民集体所有的资源要素，通过资金联合与劳动联合的方式合作实现共同发展的经济组织法人。

3. 城镇农村的合作经济组织法人，是指同类产品或产业的生产经营者或生产经营服务的提供者、利用者，在自愿联合的基础上，通过互助合作、民主管理共同实现成员利益的互助性经济组织法人。

4. 基层群众性自治组织法人，是指由我国城市居民和农村村民依照宪法、法律赋予的权利，通过民主选举的方式，实现“自我管理、自我教育、自我服务”的基层自治社会组织法人。基层群众性自治组织不属于国家其他机构的下属机构或派出机构，也不是国家的一级政权组织和行政组织，而只是群众自行发起的，为了更好地实现城市、农村的建设和发展而形成的一种群众性自治组织。

第五节 法人的设立、变更和终止

一、法人的设立

【分析】法人的设立是指依照法律规定的条件和程序使社会组织获得法律上的人格的全过程，即创设法人的一系列行为的总称。根据《民法典》第75条的规定，设立人为设立法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受；法人未成立的，其法律后果由设立人承受，设立人为二人以上的，享有连带债权，承担连带债务。设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。

依照《民法典》的规定，法人的成立必须具备以下条件：

1. 依法成立。依法成立就是依照法律规定而成立。法人是法律赋予其民事主体地位的团体，其成立必须符合法律的规定。所谓依法成立，一是指法人的目的、成立宗旨、组织机构、经营范围、经营方式等合法，不得违反宪法和其他法律的规定；二是指其成立的审核和登记程序要合法，需要有关部门批准的，必须依法取得批准后才能成立。

2. 有财产或经费。财产或经费是法人独立进行民事活动、承担民事义务的物质保障。“有财产或经费”是指法人应当有与其开展的各项业务相适应的一定数量的财产或经费。

3. 有自己的名称、组织机构和住所。法人的名称是一法人区别于另一法人的标志，在社会交往中，法人以自己的名称进行活动。法人对已经注册登记的名词享有专用权。企业法人的名称与其信誉紧密相连，具有良好信誉的企业的名词是其无形资产，所以，企业的名词权应当受到保护。《市场主体登记管理条例》第10条第1款规定：“市场主体只能登记一个名称，经登记的市场主体名称受法律保护。”法人的名称也是与其经营范围、业务性质相联系的。

法人的组织机构是对内管理法人事务、对外代表法人从事民事活动的机构。法人具有团体性，这就要求有一定的机构来承担管理和对外交往的职责。法人的组织机构包括权力机构（股东大会、社员大会）、执行机构（执行董事、董事会、理事会）、监督机构等，统称为法人的机关。法人的意志是通过其机关而形成、表示和实现的，因此，法人机关的行为就是法人的行为，法人对其机关的行为后果负责。监督机关是对法人的执行机关的行为进行监督的机关，不是一切法人都设置了监督机关，它是依据章程、命令或特别法的规定才设置的。在法人的机关中，最主要的是其法定代表人。法人的法定代表人是指依照法律或法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法人的法定代表人有权代表法人对外行使职权，也有义务正确地组织、领导法人的经营活动，遵守法律和政策，否则，就要承担法律责任。根据《民法典》第62条的规定，法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或

者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。

法人的住所具有唯一性。

二、法人的变更

【分析】法人的变更是指法人在其存续期间发生的组织机构或其他重大事项的变更。具体包括：

1. 法人的分立。法人的分立是一个法人分裂设立为两个以上法人的法律行为。分为创设式分立和存续式分立。前者是解散原法人，而分立为两个以上的新法人；后者是原法人继续存在，只是从中又独立出一个或多个新的法人。法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。

2. 法人的合并。法人的合并是指两个以上的法人，无须清算而归并为一个法人的法律行为。合并分为创设式和吸收式。创设式合并是两个以上的法人归并为一个新法人，原有的法人均告消灭的合并方式。吸收式合并是指一个法人或多个法人归并于其他法人，被归并的法人人格消灭，该其他法人仍然存续的合并方式。因法人合并而消灭的法人的权利和义务概括地由新设立或存续的法人承受。

3. 法人的组织性质变更。法人成立后，其组织形式、性质可能会因各种各样的情况而发生变化，如由有限公司变成股份公司等。这种变更，凡依法须经登记者，必须办理登记手续。

4. 其他事项的变更。如名称、注册资金、住所、活动宗旨、经营方式、经营范围等方面的重大变更等。

法人的分立与合并统称法人组织机构的变更。《民法典》第64条规定：“法人存续期间登记事项发生变化的，应当依法向登记机关申请变更登记。”第65条规定：“法人的实际情况与登记的事项不一致的，不得对抗善意相对人。”

三、法人的终止

【分析】法人的终止指法人法律上人格的丧失。

法人的终止，其意义如同自然人的死亡，法人终止后即不再具有民事主体资格。但作为组织体，法人的终止与自然人的死亡毕竟不同，法人的终止须经一定的法律程序才会发生。

1. 法人终止的原因。依据《民法典》第68、69条的规定，法人终止的原因主要包括以下三方面：（1）解散。法人解散的事由包括五个。其一是法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现；其二是法人的权力机构决议解散；其三是因法人合并或者分立需要解散；其四是法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销；最后是法律规定的其他情形。（2）依法被宣告破产。法人在其资产不足以清偿到期债务时，经法人或其债权人申请，依照有关法律规定，由人民法院依照法定程序宣告其破产，法人终止。（3）法律规定的其他原因。

2. 法人终止时的清算。清算是指对终止的法人的业务和财产进行清理，并依照法定程序对其债务进行清偿，使法人在法律上消灭的程序。法人终止前必须进行清算，根据《民法典》的有关规定，法人解散的，除合并或者分立的情形外，清算义务人应当及时组成清算组进行清算。法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。清算期间法人存续，但是不得从事与清算无关的活动。清算结束并完成法人注销登记时，法人终止；依法不需要办理法人登记的，清算结束时，法人终止。

第五章 非法人组织

第一节 非法人组织概述

一、非法人组织的概念和特征

【分析】非法人组织是指不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。现代各国民法中，在自然人和法人之外，大都承认这种非法人而具有某种主体性的组织体的存在。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

非法人组织主要具有如下特征：

1. 非法人组织是具有稳定性的人合组织。
2. 非法人组织具有相应的民事权利能力和民事行为能力。非法人组织不具有一般意义上的民事权利能力和民事行为能力。
3. 非法人组织不能完全独立承担民事责任。

二、非法人组织的类型

【分析】非法人组织的主要类型包括：

1. 个人独资企业，是指由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
2. 合伙企业。关于合伙企业的内容，详见本章第二节。
3. 不具有法人资格的专业服务机构，是指应用某方面的专业知识和专门知识，按照服务对象的需要和要求，在相应专业知识领域内提供服务的社会组织，并且该组织不能依据法人的设立条件登记为法人。

第二节 合伙企业

一、合伙企业的概念和类型

【分析】合伙企业，是指民事主体依法设立的，由各合伙人订立合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的营利性组织。合伙企业属于非法人组织的一种。根据《合伙企业法》的规定，合伙人可以是自然人，也可以是法人和其他组织。

在我国，合伙企业分为普通合伙企业和有限合伙企业。普通合伙企业又可以分为一般的普通合伙企业与特殊的普通合伙企业。

二、普通合伙企业

► 普通合伙企业的概念

【分析】普通合伙企业是指由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙企业。

► 普通合伙企业的设立条件

【分析】普通合伙企业的设立条件包括：（1）有两个以上合伙人。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力。（2）有书面合伙协议。（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资。合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。（4）有合伙企业的名称和生产经营场所。（5）

法律、行政法规规定的其他条件。普通合伙企业名称中应当标明“普通合伙”字样。

►普通合伙企业的责任承担

【分析】对于合伙债务，普通合伙人承担无限连带责任。所谓无限连带责任是指每个普通合伙人都负有用自己的全部财产清偿全部合伙债务的义务，而不受各合伙人对合伙财产的出资比例或合伙协议中约定的债务承担份额的限制。在内部关系上，偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。

►特殊的普通合伙企业

【分析】以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业。在特殊的普通合伙企业中，一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

三、有限合伙企业

►有限合伙企业的概念

【分析】有限合伙企业是指由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任的合伙企业。

►有限合伙企业的设立条件

【分析】有限合伙企业的设立条件除普通合伙企业的设立条件外，还包括：（1）除法律另有规定外，合伙人为2个以上50个以下，且至少应当有一个普通合伙人。（2）国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。（3）有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资，但不得以劳务出资。（4）有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

►有限合伙企业的责任承担

【分析】在有限合伙企业中，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

第六章 民事法律行为

第一节 民事法律行为概述

一、民事法律行为的概念

【分析】民事法律行为，是指民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。作为一个抽象概念，民事法律行为是从合同、婚姻、收养、遗嘱等具体行为中抽象而来的，以意思表示为构成要素，与事实行为截然不同。

二、民事法律行为的特征

【分析】民事法律行为有如下特征：

1. 民事法律行为以意思表示为基本要素。意思表示是指民事主体将设立、变更或消灭一定民事法律关系的内在意思以一定的方式表示于外部的行为。意思表示是民事法律行为的基本构成要素，没有意思表示就没有法律行为。虽然也有某些国家交替使用这两个概念，但我国大部分学者认为，意思表示并不等于法律行为。民事法律行为在多数情况下，需要双方当事人意思表示一致，才能成立；有的民事法律行为除了当事人意思表示一

致外，还必须要交付实物，才能成立。即使是只有当事人一方意思表示就能成立的民事法律行为，也应将意思表示理解为法律行为的构成要素，而不能将二者混淆。

2. 民事法律行为是以设立、变更、终止民事法律关系为目的的行为。任何有意识的活动，都是有一定目的的活动，都能引起一定的后果，但民事法律行为不是要达到一般的目的，而是要设立、变更、终止某种民事权利和民事义务关系，并能引起行为人预期的法律后果。现实生活中，如邀请朋友看电影、去饭馆吃饭等，并没有产生某种民事权利义务关系的目的，所以就不是民事法律行为；有的虽然产生了一定的权利义务关系，但并不是行为人所预期的或与预期正好相反，如侵权行为所引起的赔偿对方损失的结果等，这些都不是民事法律行为。

第二节 民事法律行为的分类

一、单方行为、双方行为和多方行为

【分析】这是根据民事法律行为的成立是取决于一方、双方还是多方的意思表示进行的划分。单方行为是指仅由一方当事人的意思表示就能成立的民事法律行为。例如，订立遗嘱、放弃债权、抛弃所有权、无权代理的追认等，这些行为不需要他人同意，就能发生行为人预期的法律后果。双方行为是指须双方当事人的意思表示相一致才能成立的民事法律行为，如合同等。多方行为是指由多个行为人的意思表示达成一致而成立的民事行为。此外，《民法典》还规定了决议行为。根据《民法典》第134条第2款的规定，法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立。

二、财产行为和身份行为

【分析】这是根据行为人实施民事法律行为所要发生的法律后果的性质进行的划分。财产行为是指当事人实施的民事法律行为所要发生的后果为财产关系变动的行为。例如，抛弃所有权的行为、免除债务的行为等都是财产行为。身份行为是指当事人实施的民事法律行为所要发生的后果为身份关系变动的行为。例如，结婚、离婚、收养等均属于身份行为。身份行为往往有特别的规定，不能简单适用《民法典》总则编中有关民事法律行为效力的一般规定。

三、要式行为和不要式行为

【分析】这是根据民事法律行为的成立是否必须依照某种特定的形式为标准进行的划分。要式行为，是指必须履行某种特定的形式才能成立的民事法律行为，如遗嘱须根据法律规定的方式订立方能成立。要式行为之所以强调其形式要件，目的是促使当事人谨慎行事，使法律关系明确具体，并在产生纠纷时有据可查。不要式行为，指不需要履行某种固定形式就能成立的民事法律行为，即行为人究竟采取何种形式，由其自由选定。

四、有偿行为和无偿行为

【分析】这是根据民事法律行为是否有对价进行的划分。有偿行为是指一方从对方获取利益，必须向对方支付相应的财产对价的民事法律行为。例如，买卖合同是典型的有偿行为。无偿行为是指一方取得某种财产利益，无需向对方支付财产对价的行为。例如，遗赠行为就是典型的无偿行为。

五、主行为和从行为

【分析】这是以民事法律行为之间的相互依从关系为标准进行的划分。区分的意义主要在于：除非法律另有规定或当事人另有约定，从行为随着主行为的成立而成立，也随着主行为的无效而无效。主行为是指不需要以其他法律行为存在为前提的法律行为，如在当事人为担保债权实现设定抵押权的情形下，借款合同是主行为，抵押合同是从行为。

六、负担行为和处分行为

【分析】这是以民事法律行为所产生的效果的不同为标准进行的划分。区分的意义主要在于：负担行为主要产生请求权，处分行为则是直接完成权利转移的行为。负担行为，是指以发生债权债务为内容的民事法律行为，也称为债权行为。处分行为，是指直接使某种权利发生、变更或消灭的民事法律行为。处分行为包括物权行为和准物权行为。

七、有因行为和无因行为

【分析】这是以民事法律行为与原因的关系为标准进行的划分。区分的意义主要在于：有因行为如原因不存在，则行为无效；无因行为若原因不存在或者有瑕疵不影响行为的效力。有因行为是指行为与原因不可分离的行为。所谓原因就是民事行为的目的。无因行为，是指行为与原因可以分离，不以原因为要素的行为。例如票据行为就是无因行为。无因行为非没有原因，而是指原因无效并不影响行为的效力。

八、诺成性行为和实践性行为

【分析】这是以民事法律行为是否需要交付标的物或者完成其他给付为标准进行的划分。区分的意义主要在于：二者成立的要件与当事人义务的确定不同。诺成性行为在当事人各方意思表示一致即成立；实践性行为又称为要物行为，是指除双方当事人的意思表示一致之外，尚需交付标的物或者完成其他给付才能成立的法律行为。

九、独立行为和辅助行为

【分析】这是以民事法律行为有无独立的实质性内容为标准进行的划分。区分的意义主要在于：辅助行为只是独立行为生效的条件，自身没有独立的实质内容，而受其辅助的独立行为在没有辅助行为之前不生效。独立行为是指行为凭借其意思表示即可成立的行为。辅助行为是指并不具有独立的内容，而仅仅是辅助其他行为生效的法律行为。

第三节 意思表示

一、意思表示的概念和特征

【分析】意思表示是民事法律行为的要素，指向外部表明意欲发生一定私法上效果的意思的行为。

意思表示具有如下特征：

1. 意思表示的表意人具有旨在使法律关系发生变动的意图，该意图不违反法律强制性规定和公序良俗，因而发生当事人所预期的效力。
2. 意思表示是一个意思由内到外的表示过程。单纯的停留在内心的主观意思是没有法律意义的，该意思必

须表示在外，能够为人所知晓。

3. 意思表示依据是否符合生效要件，法律赋予其不同的效力。

二、意思表示的形式

【分析】意思表示的形式是民事主体为意思表示时，表意人所采用的方式。依我国法律的规定有以下三种形式：

1. 口头形式。指用语言进行意思表示，包括面对面地交谈、电话交谈等。凡是法律不要求必须以书面形式进行的法律行为，都可以采取口头形式进行。口头形式的优点是简便易行、直接迅速，缺点是没有文字根据，一旦产生争议不易取得确实的证据。因此，口头形式一般只适用于数额不大或即时清结的法律行为。

2. 书面形式，即以文字进行意思表示的法律行为形式。包括一般书面形式和特殊书面形式（公证、鉴证、审核、登记等）。

3. 默示形式是指行为人并不直接表示其内在的意思，而是根据其某种法律事实，按逻辑推理的方法或按生活习惯，推断其内在意思表示的形式。默示的形式包括两种：作为的默示和不作为的默示。（1）作为的默示。行为人进行了某种积极行为，根据这种行为，可以推断出行为人的内在意思。如租赁合同期届满，承租人继续支付租金并租用房屋，而出租人继续收取租金，即可推定双方同意继续租赁关系。（2）不作为的默示。行为人没有任何积极行为，但从其沉默就可以推断其内在意思。例如，依《民法典》继承编的规定，继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以书面形式作出放弃继承的表示。没有表示的，视为接受继承。又如，在买卖合同中，买方收货后，在规定的时间内对产品的数量、质量没有提出异议，就可认定交付的货物符合合同规定等。

沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。

三、意思表示的生效和撤回

【分析】意思表示的生效根据有无相对人的不同而有区别。

1. 有相对人的意思表示。以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

2. 无相对人的意思表示。无相对人的意思表示，表示完成时生效。法律另有规定的，依照其规定。

3. 以公告方式作出的意思表示。以公告方式作出的意思表示，公告发布时生效。

行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

四、意思表示的解释

【分析】有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。无相对人的意思表示的解释，不能完全拘泥于所使用的词句，而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定行为人的真实意思。

第四节 民事法律行为的成立和有效

一、民事法律行为的成立

【分析】民事法律行为的成立，是指符合民事法律行为的构成要素的客观情况。民事法律行为的成立要件可分为一般成立要件和特别成立要件。

1. 一般成立要件。民事法律行为的一般成立要件，是指任何民事法律行为成立均须具备的共同要件。包括：

(1) 有行为人；(2) 行为人作出意思表示；(3) 有标的，标的指行为的内容，即行为人通过其行为所要达到的效果。

2. 特别成立要件。民事法律行为的特别成立要件，是指成立某一具体的民事法律行为除需要具备一般成立要件外，还须具备的其他特殊事实要素。例如，实践性行为以标的物交付为特别成立要件。

二、民事法律行为的有效

【分析】民事法律行为的有效，是指已经成立的民事法律行为因符合法定有效要件而取得认可的效力。民事法律行为的成立是民事法律行为有效的前提。民事法律行为的有效要件包括实质要件和形式要件。在绝大多数情况下，民事法律行为只要具备实质要件就发生法律效力，但在某些特殊的情况下，民事法律行为还必须具备形式要件才发生效力。对于要式的法律行为，如果没有采取相应的形式，该行为无效；对于不要式的法律行为，当事人应在法律允许的范围内选择适用口头形式或书面形式，也可以采取其他形式。

民事法律行为的实质有效要件包括：

1. 行为人合格。行为人合格是指行为人具有相应的民事行为能力。民事法律行为是设立、变更或消灭民事法律关系的行为，没有民事行为能力的主体，不能正确判断自己行为的性质和正确预见自己的行为后果，就不能独立实施民事法律行为，所以，当事人的民事行为能力是民事法律行为的首要条件。“相应的民事行为能力”指行为能力与其所进行的民事法律行为要相适应。如完全民事行为能力人可以独立进行法律允许的一切民事活动；8周岁以上的未成年人可以进行与其年龄、智力相适应的民事法律行为，法人在进行民事法律行为时，也须在法定活动范围内，或在核准登记的经营范围范围内实施。

2. 意思表示真实。所谓意思表示真实，是指行为人的外部表示与其内心的真实意思相一致。实际生活中，造成行为人意思表示不真实的主要有两种情况：一是由于相对人或者第三人的胁迫、欺诈，使行为人在违背真实意思的情况下而为民事行为；二是由于行为人自己对该行为的重大误解，使其行为与其内在意思不一致。对意思表示不真实的行为，根据不同的情况，应当认定为无效或可撤销。

3. 不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。不违反法律和公序良俗是民事法律行为有效的重要条件。不违法指行为内容和形式都不违法。如不得买卖禁止流通物，否则行为无效。又如中外合资经营企业合同必须经审批机构批准，否则合同不生效。公序良俗是社会公共秩序和善良风俗的合称，民事主体进行民事活动必须与公序良俗相符，违背公序良俗的行为是无效的。

第五节 无效的民事法律行为

一、无效的民事法律行为的概念和特征

【分析】无效的民事法律行为是指因欠缺民事法律行为的有效条件而不产生法律效力的民事法律行为。无效的民事法律行为在法律上当然无效，它不需要任何人主张。根据《民法典》第155条的规定，无效的民事法

律行为自始没有法律约束力。但无效的民事法律行为也是一种民事法律行为，不能说无效的民事法律行为没有任何法律效力，它也能产生一定的法律后果，只是无效的民事法律行为不能产生行为人进行民事行为时所预期的后果。例如，甲私自倒卖黄金给乙，甲是希望得到价金，乙是希望得到黄金，但由于黄金是限制流通物，甲和乙私下交易属于内容违法，标的物 and 价金被依法收缴。双方预期的结果都未达到，因为这是一种无效的民事法律行为。

无效的民事法律行为具有如下特征：

1. 无效的民事法律行为具备了民事法律行为的成立要件，但不具备有效要件，因此，不能发生当事人所预期的法律后果。
2. 无效的民事法律行为绝对、确定无效，没有任何事实可以使其有效，且包括当事人在内的任何人均有权主张该行为无效。
3. 无效的民事法律行为自始当然无效，无须任何人主张。

二、无效的民事法律行为的情形

【分析】根据《民法典》的规定，导致民事法律行为无效的情形包括：

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。例如，不满8周岁的未成年人和8周岁以上的不能辨认自己行为的无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。
2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。隐藏行为，是指表意为人虚假的意思表示，但其真意为发生另外法律效果的意思表示。隐藏行为中的虚假意思表示无效，真实意思表示有效。
3. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
4. 恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。恶意串通是指当事人以恶意实现了通谋的状态，包含主观上的恶意与客观上的通谋两个要件。

三、无效的民事法律行为的法律后果

【分析】依照《民法典》等法律规定，民事法律行为被确认无效、被撤销或者不发生效力以后会发生以下法律后果：

1. 返还财产。民事法律行为被确认无效，当事人因该行为取得的财产应当返还给对方。如果一方取得，取得方应返还给对方；如果双方取得，则双方返还。
2. 赔偿损失。民事法律行为被确认无效后，有过错的当事人应当赔偿对方的损失；双方有过错的，则应各自承担相应的责任。
3. 收归国家、集体所有或者返还第三人。双方恶意串通，实施民事法律行为损害国家、集体或者第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人。

第六节 可撤销的民事法律行为

一、可撤销的民事法律行为的概念和特征

【分析】可撤销的民事法律行为指由于欠缺有效条件，当事人有权依照法律规定请求人民法院或者仲裁机

关予以撤销的民事法律行为。此种民事法律行为不是当然无效，而是必须由当事人向法院或仲裁机关请求裁定。

可撤销的民事法律行为具有如下特征：

1. 可撤销的民事法律行为主要是因意思表示不真实而发生的民事法律行为。意思表示不真实往往只有当事人人才知晓，这就需要由当事人自己决定是否撤销不真实的意思表示。

2. 可撤销的民事法律行为须由撤销权人主动行使撤销权。撤销权在性质上属于形成权，撤销权人通过单方的意思表示行使撤销权，可导致可撤销民事法律行为的效力溯及既往的消灭。

3. 可撤销的民事法律行为在被撤销前仍然是有效的。

二、可撤销的民事法律行为的情形

【分析】根据《民法典》相关规定，导致民事法律行为可撤销的情形包括以下四种：

1. 重大误解的民事法律行为。重大误解的民事法律行为，指行为人对于民事行为产生错误的理解，并基于这种错误理解而为之的民事法律行为。所谓误解，又称错误。具体包括：（1）对行为性质的误解，如把买卖误解为赠与行为等；（2）对标的物的误解，如把复制品当作原件等；（3）对价金的误解，如将 1000 元误认为 100 元等；（4）对当事人的误解，如把某甲当作某乙等。

民法上的误解仅限于对行为内容的误解，不包括对行为动机的误解，而且这种误解是重大的，是由于行为人的过失造成的。另外，行为人的意思表示存在第三人转达错误可以适用重大误解的规则。

2. 因受欺诈实施的民事法律行为。具体分为两种情况：（1）一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。欺诈是指行为人故意实施的，以引起、强化或维持他人的错误认识并使其基于此错误认识而做出意思表示为目的的欺骗行为。（2）第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。第三人欺诈，是指民事法律行为当事人以外的第三人故意实施的，以引起、强化或维持他人的错误认识并使其基于此错误认识而做出意思表示为目的的欺骗行为。特别需要注意的是，民事法律行为的对方知道或应当知道第三人欺诈行为的，该民事法律行为才是可撤销的。

3. 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。胁迫是指一方当事人或第三人向对方或其亲属预告危害，使其发生恐惧心理，并基于这种恐惧心理而作出的违背其真实意思的行为。

4. 显失公平的民事法律行为。这是指在双方、有偿的民事法律行为中，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的民事法律行为。它具有以下特点：（1）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形；（2）行为结果对一方当事人有重大不利，而另一方则获得显然超过了正常情况下所能获得的利益（暴利）；（3）不利一方当事人所为民事法律行为并非其本意，而是由于处于危困状态、缺乏判断能力等原因；（4）这种不公平是法律所不允许的，或者是当时社会所公认的不公平。需要注意的是，显失公平仅指一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形所造成的不公平，而不包括因为受欺诈或受胁迫而造成不公平。

三、可撤销的民事法律行为与无效的民事法律行为的区别

【分析】可撤销的民事法律行为在被撤销后，与无效的民事法律行为一样也具有自始无效的后果，但二者毕竟不同，主要表现在：

1. 无效的民事法律行为是不附带任何条件的，不论当事人是否主张，也不论当事人之间是否有争议，该行为都是无效的，是绝对无效；可撤销的民事法律行为是相对无效，是有条件的无效。当事人提出申请并经法院或仲裁机关认可是该行为无效的前提条件。

2. 无效的民事法律行为从行为开始时起，就不发生法律效力，对当事人就没有约束力；可撤销的民事法律行为在被撤销之前，已经发生了法律效力，对当事人就有了约束力，只有在被撤销后，才丧失法律上的效力。

当然，撤销行为具有追溯力，追溯到行为开始。

3. 无效的民事法律行为，双方当事人或与该民事法律行为有利害关系的人都可以主张无效，人民法院或仲裁机关在受理的案件中发现属于无效范围的，也可以主动确认其无效；可撤销的民事法律行为，只有享有撤销权的当事人（通常是因该行为而蒙受不利的一方，如受欺诈方、受胁迫方）才可请求撤销，其他人不享有撤销权。

另外，在可撤销的民事法律行为中，如果属于部分无效的，没有被撤销的部分继续有效。

第七节 效力未定的民事法律行为

一、效力未定的民事法律行为的概念和特征

【分析】效力未定的民事法律行为，是指民事法律行为成立之后，是否能发生效力尚不能确定，有待享有形成权的第三人作出追认或拒绝的意思表示来使之有效或无效的民事法律行为。

效力未定的民事法律行为具有如下特征：

1. 效力未定的民事法律行为已经成立，但因缺乏处分权或行为能力而使效力不齐备。
2. 效力未定的民事法律行为的效力既非完全无效，也非完全有效，而是处于一种效力不确定的中间状态。
3. 效力未定的民事法律行为是否发生效力尚不能确定，有待于其他行为或事实使之确定。

二、效力未定的民事法律行为的情形

【分析】现行法认可的效力未定的民事法律行为的情形主要有：（1）限制民事行为能力人从事依法不能从事的法律行为，其行为效力有待其法定代理人确认。（2）无权代理行为，但表见代理除外。

三、效力未定的民事法律行为的法律后果

【分析】效力未定的民事法律行为的效力确定基于以下不同法律事实：（1）真正的权利人行使追认权，对效力未定的民事法律行为进行事后追认。追认是一种单方意思表示，无须相对人的同意即可发生法律效力。（2）善意相对人行使撤销权，从而使效力未定的民事法律行为归于无效。（3）效力未定的民事法律行为会因特定事实的出现而补正其效力。

第八节 附条件和附期限的民事法律行为

一、附条件的民事法律行为

【分析】附条件的民事法律行为是指双方当事人在民事法律行为中设立一定的事由作为条件，以条件的成就与否（是否发生）作为决定民事法律行为效力产生或解除根据的民事法律行为。

附条件的法律行为是为行为人的某种特殊需要而设立的法律行为。民事法律行为中所附的条件是一种特定的法律事实，它可以是某种自然现象，也可以是人的某种行为，还可以是某种特定的事件。但并非任何自然现象或任何行为，都可以作为条件，民事法律行为所附的条件必须有下列特点：

1. 条件应当是将来发生的事实，具有未来性。已经发生的事实不得作为民事法律行为所附的条件。

2. 条件应当是将来可能发生也可能不发生的事实，具有或然性。如果是肯定能发生或肯定不能发生的事实，就不能作为民事法律行为所附的条件。民事法律行为所附条件不可能发生，当事人约定为生效条件的，人民法院应当认定民事法律行为不发生效力；当事人约定为解除条件的，应当认定未附条件，民事法律行为是否失效，依照《民法典》和相关法律、行政法规的规定认定。

3. 条件应当是当事人选定（商定）的事实，具有非法定性。法律规定的或基于行为性质所决定的事实，不能作为民事法律行为所附的条件。如在保险合同中约定，“一旦发生保险事故”保险公司就支付保险金。这里的“发生保险事故”是由保险合同本身性质决定的，是必须规定的条件，所以在保险合同中这种事实就不能作为所附条件。

4. 条件应当是合法的事实。违法的事实，不能作为民事法律行为所附的条件。如果所附条件是违背法律规定的，应当认定该民事法律行为无效。

根据不同的标准，可以将条件划分为：

1. 根据条件对法律行为所起作用的不同，可将条件分为延缓条件和解除条件。

延缓条件是指民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务，要在所附条件成就时发生法律效力的条件。

如“周日天晴即租车春游”，这里的“周日天晴”即延缓条件。在条件成就前，法律行为虽然已经成立，但双方的权利义务处于停止状态，在条件成就时才能生效。所以，延缓条件又称停止条件。

解除条件又称消灭条件，是指民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务，在所附条件成就时失去法律效力的条件。附解除条件的民事法律行为是已经发生法律效力的行为，当事人已经开始享受权利、承担义务，当所附条件成就时，其权利义务即失去效力。例如，甲将自行车借与乙，双方约定，甲的儿子要用自行车时，乙即还车。这里的“甲的儿子要用自行车”即是解除条件。当条件成就时，甲和乙之间的借用合同即解除。

2. 根据条件内容的不同，可将条件分为积极条件与消极条件。

积极条件又称肯定条件，是指以某种事实的发生为其内容的条件。如甲与乙约定，如果甲的孩子去国外留学，则将房子租给乙。此约定中的“甲的孩子去国外留学”即为积极条件。

消极条件又称否定条件，是指以某种事实的不发生为其内容的条件。如甲与乙约定，如果甲的儿子不回国工作，则将房屋卖给乙。这里的“甲的儿子不回国工作”即是消极条件。

无论是积极条件还是消极条件，都既可以作为延缓条件，也可以作为解除条件。

附条件的民事法律行为一旦成立，对当事人双方都有约束力，任何一方不得为了自己的利益，恶意促成条件成就或恶意阻碍条件成就，而应听任事物的自然发展。否则，恶意促成条件成就的，视为条件不成就；恶意阻碍条件成就的，视为条件已经成就。

二、附期限的民事法律行为

【分析】附期限的民事法律行为，是指双方当事人在民事法律行为中约定一定的期限，以期限的到来决定其效力发生或者终止的民事法律行为。

期限和条件都是当事人约定的对民事法律行为效力的某种限制，但二者又有不同特点。条件的成就与否是当事人所不能预知的，它将来可能发生，也可能不发生；而期限则是当事人可以预知的，是必然要到来的。

期限分延缓期限和解除期限：

1. 延缓期限，是指在民事法律行为中规定的期限到来之前，该民事法律行为所确定的民事权利和民事义务不发生法律效力，待期限到来时，其民事权利和民事义务开始发生法律效力。发生法律效力是指权利人开始有权请求义务人履行义务。因此，延缓期限又称始期。如甲乙双方约定，租赁合同自6月1日开始生效，则6月1日即为始期。

2. 解除期限，是指在民事法律行为中规定的期限到来时，该民事法律行为所确定的民事权利和民事义务的法律效力即行消灭的期限，又叫终期。例如租赁合同中规定的“某年某月某日”到期，这里的“某年某月某日”就是终期。

第七章 代理

第一节 代理概述

一、代理的概念

【分析】代理是指代理人以被代理人或者自己的名义，在代理权限内与第三人（又称相对人）实施法律行为，其法律后果直接或者间接由被代理人承受的民事法律制度。代理是一种至少有三方（被代理人、代理人、第三人）参加的民事法律关系。例如，甲接受乙的委托，在乙授权的范围内，以乙的名义同丙订立合同。在这种代理关系中，甲是代理人，乙是被代理人也称本人，丙是第三人也称相对人。实质上甲签订的合同是乙和丙之间的合同。

二、代理的特征

【分析】代理的法律特征主要包括以下四方面

1. 代理人在代理权限范围内实施代理行为。这里包含三层意思：一是代理人须有代理权，代理权的产生或因委托，或因法定和指定，没有授权属于无权代理；二是法律规定或当事人约定只能由本人实施的行为，不得代理，如婚姻登记、遗嘱等；三是代理人在进行代理行为时，有独立的意思表示，可视具体情况而决定表示内容，这与中介人相区别。中介人是受委托人的委托，为其报告签订合同的机会或充当双方当事人的媒介，而由委托人给付报酬的人。中介人不得代委托人签订合同，此是与代理人不同之处。

2. 代理人以被代理人的名义或者代理人自己的名义进行代理行为。前者为直接代理，后者为间接代理。我国《民法典》规定的代理包括直接代理和间接代理。

3. 代理主要是实施法律行为。代理主要是为被代理人设立、变更、消灭一定民事法律关系，如代签合同、代为诉讼等。不具有法律意义的行为，如代人算账、代人抄写等只能是一种事实行为，它不与第三人产生权利义务关系，不是代理。

4. 代理行为的后果直接或者间接由被代理人承担。代理的目的是为被代理人进行民事活动，代理人的行为效力当然归属于被代理人，包括设定的权利归被代理人享有，义务归被代理人承担，代理人的行为给他人造成的损害由被代理人赔偿。

三、代理的适用范围

【分析】自然人、法人可以通过代理人进行民事法律行为。但是，依照法律规定或者双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得通过代理人进行。这些行为包括：（1）具有人身性质的行为，如立遗嘱、婚姻登记、收养子女等；（2）法律规定或当事人约定应当由特定的人亲自为之的行为，如演出、讲课等。

第二节 代理的分类

一、委托代理和法定代理

【分析】这是根据代理权的来源不同对代理进行的分类。

1. 委托代理。委托代理又称意定代理，是指基于被代理人的委托授权而发生的代理，是最常见、最广泛适用的一种代理形式。委托代理一般是在委托合同基础上，由被代理人直接授权给代理人。需要注意的是，委托合同与授权是两个概念。有时，尽管委托合同成立了，但是合同中没有明确的授权条款，代理权仍不发生。也就是说，委托代理关系是基于两类法律事实而产生的，一是委托合同关系，二是授权行为。仅有委托合同但不涉及第三人时，也无法形成代理关系。授权行为是单方法律行为，仅一方意思表示即可成立。授权行为通常以授权委托书形式表明，一般应采用书面形式。授权委托书中应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。

2. 法定代理。法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为无行为能力人、限制行为能力人设置的代理，一般基于一定的亲属关系或某种隶属关系而产生，其确定带有强制性。法定代理不需要被代理人的授权（而且一般被代理人也无授权能力），但是作为第三人仍然有权要求代理人证明其代理资格。依据我国法律规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人为其法定代理人。

二、本代理和复代理

【分析】这是根据代理人的选任和产生方式的不同，对代理进行的分类。

1. 本代理是指由本人选任代理人或直接依据法律规定产生代理人的代理。

2. 复代理是指代理人为了被代理人的利益需要，将其享有的代理权的全部或一部分转委托给他人行使而产生的代理。此种代理是基于转委托而形成的代理关系，所以，又称为再代理或转委托。

复代理在适用中应当符合一定的法律规则。在复代理中，代理人只有在特殊情况下，为了被代理人的利益才能转委托。根据我国有关法律的规定，转委托要求事先征得被代理人的同意或事后得到追认，否则，代理人对转委托的第三人的行为承担责任。因为代理是一种人身信任关系，代理人信任的人不一定也能够为被代理人所信任，何况代理的法律后果是由被代理人来承受的。所以，法律对转委托作了严格限制。但在紧急情况下，代理人为了维护被代理人的利益而转委托的，不论被代理人是否同意，均产生转委托的法律效力。所谓“紧急情况”是指代理人有急病、通信联络中断、疫情防控等特殊原因，使自己不能办理代理事项，与被代理人不能取得联系，如果不及时委托他人代理，就会给被代理人造成损失。

三、直接代理和间接代理

【分析】这是根据代理人在进行代理活动时，是否以被代理人的名义实施代理行为而对代理进行的分类。

直接代理，是指代理人以被代理人的名义从事代理活动，该代理活动的法律效果直接归属于被代理人的代理。

间接代理，是指代理人以自己的名义从事代理活动，该代理活动的法律效果间接归属于被代理人的代理。我国《民法典》总则编规定的代理限于直接代理，对间接代理的承认体现在《民法典》合同编对委托合同的规定之中。

第三节 代理权

一、代理权的概念

【分析】代理权就是代理人以被代理人的名义与第三人实施法律行为，为被代理人设定、变更或消灭民事法律关系的权利。代理权是一种民事权利，它是为被代理人设定、变更或消灭某种民事权利义务关系而存在的。代理权的享有人即代理人必须以被代理人的名义进行某种民事活动，所产生的民事法律后果由被代理人承担。代理权的范围由委托人确定或由法律加以规定或由人民法院、有关单位指定，但代理人可以在代理权限范围内独立为意思表示。

二、代理权的产生

【分析】在不同代理关系中，代理权的产生有所不同。在委托代理关系中，代理权是基于被代理人的委托授权而产生的。在法定代理关系中，代理权是根据法律的直接规定而产生的。

三、代理权的行使

【分析】代理权的行使是指代理人在代理权限范围内完成代理事项的各种活动。根据我国法律的规定，代理权的行使必须遵守以下原则：

1. 代理人应在代理权限范围内行使代理权。代理人只有在代理权限范围内进行代理行为，才能由被代理人承担法律后果，超越代理权限所为的行为，除被代理人追认的以外，对被代理人不发生法律效力，而由代理人承担责任。

2. 代理人应为维护被代理人的利益而行使代理权。代理人的职责就是为被代理人服务，所以代理人应从被代理人的利益出发，本着对被代理人最有利的原则行使代理权，也只有在为了被代理人的利益的情况下才能转委托。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。

3. 代理人不得滥用代理权。滥用代理权主要有三种情形：（1）自己代理。这是指代理人以被代理人的名义与自己进行民事活动的行为。该行为通常为无效行为，但是被代理人同意或者追认的除外。（2）双方代理。这是指代理人以被代理人的名义与自己代理的其他人进行民事活动的行为。该行为原则上无效，但是被代理的双方同意或者追认的除外。（3）代理人与相对人恶意串通。此种行为属于无效的民事行为，给被代理人造成损害的，由代理人和相对人负连带责任。

第四节 无权代理

一、无权代理的概念

【分析】无权代理指没有代理权而以他人名义进行代理活动的民事行为。

无权代理，其根本特征在于行为人以他人名义进行民事活动时没有代理权。无权代理包括三种情形：（1）行为人根本没有代理权却从事代理活动。（2）行为人享有代理权，但却超越代理权限从事了本不该由其进行的代理活动。（3）行为人原本享有代理权，但其代理权已经终止，行为人仍以代理人的身份进行代理活动。

数个委托代理人共同行使代理权，其中一人或者数人未与其他委托代理人协商，擅自行使代理权的，按照无权代理或者表见代理处理。

二、无权代理的效力

【分析】无权代理是效力未定的民事法律行为，被代理人对所谓的代理行为不承担责任。但如果被代理人对此行为予以追认，则会使无权代理成为有权代理，被代理人就应当对该代理行为承担相应的法律后果。

无权代理人所实施的行为，如果不能得到被代理人的追认，又不能证明自己有代理权，则应对自己的行为承担责任，对该行为所造成的相对人的损失负赔偿责任。被代理人对无权代理行为有拒绝承认的形成权，该拒绝的意思表示一经作出即产生无权代理对被代理人无效的法律后果。该无权代理人应对第三人承担相应的法律后果。如果因无权代理行为而造成被代理人损失的，无权代理人也应负赔偿责任。在无权代理中，相对人对代理行为享有催告权，善意的相对人还享有撤销权。

三、表见代理

►表见代理的概念

【分析】表见代理是指行为人虽没有代理权，但第三人在客观上有理由相信其有代理权而与其实施法律行为，该法律行为的后果由本人承担的代理。表见代理在代理制度中起协调本人利益和相对人利益的作用，通过对善意第三人利益的保护而达到维护交易秩序的目的。根据《民法典》的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。此种代理即为表见代理。

►表见代理的构成条件

【分析】构成表见代理须具备以下条件：

1. 代理人无代理权。代理人在实施代理行为时，并无本人的授权，或虽有授权，但并未授权其可实施超出特定授权范围的行为。如果代理人对所实施的行为有代理权，当然不发生表见代理。

2. 该无权代理人有被授予代理权的外观。如果无权代理人以被代理人名义实施法律行为，但又没有任何迹象表明其被授权，那么不存在表见代理问题，即表见代理的成立须有“外表授权”的存在。如合同的签订人持有被代理人的介绍信签订合同、使用被代理人的合同专用章或盖有印章的空白合同书签订合同等，即属于有被授予代理权的外观。

3. 相对人不知道行为人行为时无代理权，且无过失。这是与第二个条件相联系的一个要件，因为虽有外表授权的存在，但如果相对人不相信，那么仍然不构成表见代理，而是狭义的无权代理。相对人如果有过失而不知行为人没有代理权，则不构成表见代理。

4. 相对人基于信任而与该无权代理人成立法律行为。这是判定是否构成表见代理的最终标准，虽然有以上三个要件，但最终相对人若未与该无权代理人就所谓的代理内容成立法律行为，那么也不构成表见代理。

►常见的表见代理情形

【分析】常见的表见代理情形包括：

1. 因表见授权表示而产生的表见代理。被代理人以直接或间接的意思表示，表明授予他人代理权，但事实上并未授权。在此情况下，相对人有理由相信该无权代理人为有权代理人，而与之为民行为。

2. 因代理授权不明而产生的表见代理。被代理人在代理授权时，未明确代理权限，或未将指明的代理权限有效告知相对人，致使相对人善意、无过失地相信代理人的越权代理为有权代理，而与之为民行为。

3. 因代理关系终止后未采取必要的措施而产生的表见代理。被代理人在代理关系终止后，应将此事实以适当的方式，有效地通知相对人，如果因为被代理人的原因，使相对人不知代理关系终止，而与原代理人为民事行为，则构成表见代理。

►表见代理的法律后果

【分析】表见代理成立后，产生类似有权代理的法律后果。由被代理人承担代理行为所带来的法律后果，即享有其权利、承担其义务。当然，被代理人有权要求无权代理人赔偿因无权代理而造成的损失。

第五节 代理终止

代理终止是指代理人与被代理人之间的代理关系消灭。代理终止有共同的原因，也有各自不同的原因。

一、委托代理的终止

【分析】根据《民法典》第 173 条的规定，委托代理终止的原因主要有以下五方面的事实：

1. 代理期限届满或者代理事务完成。如果代理是有期限的，在期限到来之时，代理关系自然终止；如果委托代理的事务已经完成，代理也就没有继续存在的必要，代理关系自然终止。这是委托代理终止的最常见的原因。

2. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托。委托代理是建立在被代理人和代理人相互信任的基础上的，它可以因任何一方的意思表示而终止，如果被代理人撤回委托或代理人辞去委托都会引起委托代理的终止。

3. 代理人丧失民事行为能力。代理是由代理人以被代理人名义进行民事法律行为的行为，其最基本的要求是代理人必须是完全民事行为能力人，如果代理人丧失民事行为能力，其代理资格消灭，自然也就不能以被代理人名义代理被代理人进行民事活动。

4. 代理人或者被代理人死亡。代理行为由代理人实施，代理人死亡代理关系自然终止。代理是为被代理人利益而设立的，如果被代理人死亡，就会出现没有代理行为后果承受者的局面，所以代理关系会因被代理人死亡而消灭。但被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：（1）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；（2）被代理人的继承人予以承认；（3）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；（4）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。

5. 作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。法人终止与自然人死亡一样，都是导致法律人格丧失的事实，法人终止也使代理关系终止。

二、法定代理的终止

【分析】除代理终止的共同原因外，法定代理还可以因下列原因而终止：

1. 被代理人取得或恢复民事行为能力。设立法定代理和指定代理是为保护无民事行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益，一旦他们长大成人或恢复辨认自己行为的能力而成为完全民事行为能力人，也就没有必要再为其指定代理人或规定代理人。

2. 代理人丧失民事行为能力。

3. 代理人或者被代理人死亡。

4. 法律规定的其他情形，主要指其他原因引起的被代理人与代理人之间的监护关系消灭。例如，收养关系解除，监护人不履行监护义务而撤销其监护，夫妻离婚后彼此之间的代理关系终止等。

第八章 诉讼时效与期间

第一节 诉讼时效

一、诉讼时效的概念

【分析】诉讼时效是指权利主体在法定期间内不行使权利，义务人便享有抗辩权，从而导致权利人无法胜诉的法律制度。法律上关于诉讼时效的规定，不允许当事人通过约定排除适用。当事人不得违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间、预先放弃诉讼时效利益。

我国《民法典》对于诉讼时效的效力采取抗辩权发生主义。根据《民法典》第192条的规定，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。当事人未提出诉讼时效抗辩，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外。当事人未按照前款规定提出诉讼时效抗辩，以诉讼时效期间届满为由申请再审或者提出再审抗辩的，人民法院不予支持。由此可见，诉讼时效期间届满的法律后果是产生请求权已经超过诉讼时效的抗辩权。这种抗辩权是当事人一方享有的权利，是否行使完全取决于当事人的自主判断，法院不得依职权主动适用诉讼时效。当事人未提出诉讼时效抗辩的，属于自动放弃有关的权利。

二、诉讼时效的适用范围

【分析】诉讼时效的适用范围也就是诉讼时效的客体，即哪些权利适用诉讼时效。依据诉讼时效制度的立法目的，诉讼时效仅对请求权适用。请求权以外的权利，如所有权、人格权等支配权不受诉讼时效的限制。另外，并非所有的请求权都适用诉讼时效。根据《民法典》第196条的规定，下列请求权不适用诉讼时效的规定：

（1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（3）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；（4）依法不适用诉讼时效的其他请求权。

三、诉讼时效的类型

【分析】诉讼时效按照适用范围和时效期间长短的不同，可以分为以下三种类型：

1. 普通诉讼时效。普通诉讼时效也称一般诉讼时效，是指由《民法典》规定的统一时效期间的诉讼时效。根据《民法典》第188条的规定，我国的普通诉讼时效期间为3年。

2. 特殊诉讼时效。特殊诉讼时效指由民事基本法或特别法就特别民事法律关系规定的短于或长于普通诉讼时效期间的时效。在我国主要指长期诉讼时效。长期诉讼时效即诉讼时效期间长于普通诉讼时效的时效。如根据《民法典》第594条的规定，国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼的时效期间为4年。

3. 最长诉讼时效。根据《民法典》第188条第2款的规定，自权利受到损害之日起超过20年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。20年即是最长时效期间，它适用于一切民事法律关系，它与普通诉讼时效的不同在于起算时间不同，不适用中断、中止的规定。

四、诉讼时效期间的起算

【分析】根据《民法典》的规定，诉讼时效期间的起算规则是：

1. 普通的诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受到损害以及义务人之日起计算。

2. 最长的诉讼时效期间自权利受到损害之日起计算。

3. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的权利受到损害的，诉讼时效期间自其法定代理人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

4. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满 18 周岁之日起计算。

五、诉讼时效的中止、中断和延长

► 诉讼时效的中止

【分析】诉讼时效的中止，是指在诉讼时效进行中，由于出现了法定事由而暂时中止诉讼时效进行的法律制度。诉讼时效中止须满足两个条件。一是出现法定中止的事由。诉讼时效中止的事由包括：不可抗力；无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；权利人被义务人或者其他他人控制；其他导致权利人不能行使请求权的障碍。二是中止的事由存在于诉讼时效期间的最后 6 个月内，包括在 6 个月前发生的，但持续到 6 个月内的情况。诉讼时效中止的法律后果是自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。

► 诉讼时效的中断

【分析】诉讼时效的中断，是指在诉讼时效进行中，因一定事由的发生，阻碍时效进行，致使以前经过的时效期间统归无效，从中断、有关程序终结时起，其诉讼时效期间重新计算的制度。

根据《民法典》的规定，在下列情况下，诉讼时效中断：（1）权利人向义务人提出履行请求。（2）义务人同意履行义务。（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁。提起诉讼即权利人依诉讼程序请求人民法院强制义务人履行义务的行为。提起诉讼本身说明权利人不行使权利的事实状态被打破，从而使诉讼时效中断。申请仲裁与此相似。（4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

► 诉讼时效的延长

【分析】诉讼时效的延长是对已经完成的诉讼时效期间，如果有特殊情况，人民法院可以根据权利人的申请给予适当延长的法律制度。普通诉讼时效期间可以适用中止、中断的规定，不适用延长的规定；最长诉讼时效期间可以适用延长的规定，不适用中止、中断的规定。这是为了充分保护当事人的合法权益，对诉讼时效的中止、中断的补救。

六、诉讼时效和除斥期间

【分析】除斥期间是指法律规定或者当事人约定的权利（主要是形成权）预定存在的期间。权利人在此期间不行使权利，预定期间届满，即发生该权利消灭的法律后果。例如《民法典》第 1124 条第 2 款规定：“受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。”这里的“六十日”即是除斥期间，该期间届满，权利人不行使权利，其受遗赠权利即消灭。撤销权、解除权的存续期间也属于除斥期间，期间届满，撤销权、解除权消灭。

除斥期间和诉讼时效一样，也是一定的事实状态经过一定的期间而发生一定的法律后果，但这两种制度又存在很大的差别：

1. 法律后果不同。除斥期间届满的法律效力是实体权利（主要是形成权）消灭，而诉讼时效期间届满的法律后果是抗辩权发生，实体权利并不消灭。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。

2. 适用范围不同。除斥期间主要适用于形成权，诉讼时效适用于请求权。

3. 起算时间不同。除斥期间根据法律规定的**时间或者权利发生的时间**起算，诉讼时效的起算点如前所述。

4. 适用条件不同。除斥期间届满，法院可依职权主动适用有关规定而无须当事人提出主张。义务人自愿履行的，也可以请求人民法院追回。而对诉讼时效人民法院不得主动适用相关规定。

5. 期间可变性不同。除斥期间是一个**不变期间**，法律规定多长时间就固定为多长时间，不能变动；而诉讼时效则可因各种原因而中止、中断甚至延长。

第二节 期间

一、期间的概念

【分析】期间是指民事法律关系产生、变更和终止的时间。例如，从某日到某日其中经过的时间。时间是永续的，但人们的法律关系在时间上的存在是有限的，民法对民事法律关系在时间上的有限性的规定，就是民法上的期间。同时，民法规定的时间上的效力，并非因时间在一般情况下的自然流逝而发生，而是要与法定的一定事实状态相联系。

二、期间的类型

【分析】期间可分为两大类：一是法定期间与意定期间。法定期间是指法律规定的期间，意定期间是指由当事人协商确定的期间。二是一般期间与特殊期间。一般期间是指适用于各种民事法律关系的期间，特殊期间是指有关特定民事法律关系的期间。

三、期间的计算

【分析】期间的计算方法按以下标准进行：

1. 民法所称的期间按照公历年、月、日、小时计算。

2. 按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。按照小时计算期间的，自法律规定或者当事人约定的时间开始计算。

3. 按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

4. 期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。期间的最后一日的截止时间为二十四时；有业务时间的，停止业务活动的时间为截止时间。

另外，民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数，所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

第九章 物权通则

第一节 物权概述

一、物权的概念和特征

【分析】物权是权利主体依法直接支配特定的物并享受其利益的排他性权利，包括所有权、用益物权和担保物权。说明如下：

1. 物权是一种财产权，具有直接的财产内容。

2. 物权是直接支配物的权利。所谓“直接”，是指物权人对标的物的支配无须他人意思或行为的介入便可实现。所谓“支配”，是指依权利主体的意思，对物加以管领处理。

3. 物权是支配特定物的权利。该特定物可以是动产，也可以是不动产；可以是权利人所有的物，也可以是他人的物。作为物权客体的物，在内容、范围上均须确定，需要指出的是，某些类型的物权也可以以权利为客体，物权以物之外的权利为客体的，须有法律的明确规定。

4. 物权具有排除他人干涉的效力。物权人得就特定的物为独立支配从而享受其利益，而无须他人积极配合，也当然排除他人干涉。当物权人行使权利遇到不法妨碍时，可以凭借物权直接请求排除妨碍。

与债权比较，物权具有下列特征：

1. 在权利的性质上，物权是支配权，而债权则是一种请求权。物权以物为支配对象，包括对物的全面支配和限定支配。权利人无须借助他人的行为就能行使其权利，并通过对物的直接管领、支配来实现自己的利益。对物进行支配，不是物权人的目的而是物权人的手段，物权人的目的在于通过支配而取得物之利益。

2. 在权利效力范围上，物权是绝对权，债权是相对权。物权的义务主体是权利人以外的一切人，故又称为对世权。而债权人则只能向特定的义务主体（债务人）主张权利，故债权又称对人权。

3. 在权利的客体上，物权的客体原则上为有体物，债权的客体则为行为。

4. 在权利的效力上，物权具有优先效力、追及效力、排他效力，而债权则没有这些效力。物权的优先效力包括两个方面，一是物权对于债权的优先效力，二是物权相互之间的优先效力。物权对于债权的优先效力体现在当物权与债权可能发生权利冲突时，物权原则上具有优先于债权的效力。如同一物上既有物权，又有以其为给付标的物的债权时，物权优先于债权。物权优先于债权也有例外，个别情形下法律赋予某些债权以优先于物权的效力，如根据《民法典》第 725 条确立的“买卖不破租赁”规则，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。物权相互之间的优先效力要解决的是能够并存且可能发生权利冲突的若干个物权之间何者优先的问题。该问题的解决规则是原则上成立在先则效力优先，但法律另有规定的除外。物权的追及效力是指作为物权客体的物无论辗转流向何处，权利人均得追及于物的所在，行使其权利。物权的排他效力则意味着同一物上不能同时存在两个或两个以上内容互不相容的物权，如一物之上只能存在一个所有权。

5. 在权利的发生上，物权的设定采取法定主义，而债权（合同之债）的设定则采取任意主义。

6. 在权利的保护方法上，物权的保护以恢复权利人对物的支配为主要目的，偏重“物上请求权”的方法，赔偿损失仅为补充方法，而债权的保护则主要采取赔偿损失的方法。

二、物权的分类

► 完全物权和定限物权

【分析】根据对物的支配范围的不同，物权分为完全物权和定限物权。

完全物权是对物永久全面支配的物权。所有权是最完整、最充分的物权，也是唯一的完全物权。定限物权也称限制物权，是仅能在特定范围内支配物的物权。定限物权除特殊情况外，均设立于他人的所有物上，所以又称为他物权。定限物权分为用益物权和担保物权。

► 用益物权和担保物权

【分析】这是按照对物的支配内容上的差异，对定限物权所作的分类。

用益物权是以物的使用、收益为内容的定限物权，包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。担保物权是为确保债权的实现而设定的，以支配特定财产的交换价值为内容的定限物权。典型的担保物权包括抵押权、质权、留置权。

► 动产物权、不动产物权和以权利为客体的物权

【分析】根据物权客体种类的不同，物权分为动产物权、不动产物权和以权利为客体的物权。

存在于动产之上的物权为动产物权；存在于不动产之上的物权为不动产物权；存在于权利之上的物权即为以权利为客体的物权。

► 主物权和从物权

【分析】根据物权有无从属性，可以将物权划分为主物权与从物权。

主物权是不需要从属其他权利，能够独立存在的物权。从物权是指从属于其他权利而存在的物权，如担保物权、地役权。从物权的获得、丧失、变更，从属于所附的主权利。

► 意定物权和法定物权

【分析】根据物权产生原因的不同，可以将物权分为意定物权和法定物权。

意定物权是指基于当事人的意思和行为而产生的物权。法定物权是指基于法律的规定而直接产生的物权，如留置权等。

第二节 物权法的基本原则

一、平等保护原则

【分析】平等保护原则是民法中平等原则在物权领域的具体化。基本内容包括：（1）法律地位平等。所有民事主体在有关物权的法律规范中都具有平等地位。（2）适用规则平等。除法律有特别规定的外，各民事主体参与物权相关法律关系时平等适用《民法典》物权编所确立的规则。（3）保护的平等。所有民事主体受有关物权的法律规范的平等保护。《民法典》第 207 条对平等保护原则作了明确规定。

二、物权客体特定原则

【分析】物权客体特定原则又称一物一权原则，其内容包括：（1）物权的客体限于在经济上和功能上完整的、独立的一物，物的组成部分不能成为物权的客体。（2）一物之上只能成立一个所有权。该原则与以下情形并不矛盾：第一，多人对同一物共享一项物权。第二，内容互不冲突的物权并存于一物之上。

三、物权法定原则

【分析】物权法定原则是指物权的类型和内容以及物权的变动方式由法律规定，而不允许当事人自行创设的原则。其法律依据是《民法典》第 116 条的规定：“物权的种类和内容，由法律规定。”

物权法定原则的内容：（1）物权的种类不得创设，即当事人不得创设法律所不认可的新类型的物权。（2）物权的内容不得创设，即当事人不得创设与物权的法定内容相悖的物权内容。

违反物权法定原则的后果是：（1）法律没有规定的物权，当事人不得自由设立，即使当事人有约定也不发生物权设定的法律效果。（2）当事人的约定部分违反内容强制的规定，但不影响其他部分效力的，物权仍得以设立，仅违反规定的内容无效。（3）违反该原则的行为无效不影响当事人之间其他法律行为的效力。

四、公示、公信原则

【分析】所谓公示，是指以一定的方式使公众知悉物权变动的事实。物权存在的公示，为物权的静态公示。按各国物权法的规定，“占有”是动产物权存在的公示方式，国家不动产物权登记簿上所作的“登记”记载是

不动产物权存在的公示方式。物权变动的公示，为物权的动态公示。按各国物权相关法律的规定，“交付”是动产物权变动的公示方式，变更“登记”是不动产物权变动的公示方式。所谓**公信**，又叫**公信力**，是指物权变动符合法定公示方式的就具有可信赖性的法律效力。依公信原则，物权变动经公示的，即发生法律效力，即使公示所表现的物权状态与真实的物权状态不相符合，也不影响物权变动的效力。

第三节 物权的变动

一、物权变动的概念

【分析】物权的变动，是指物权的设立、变更、转让和消灭。就物权主体而言，是指其取得物权和丧失物权；就物权内容而言，是指物权的内容发生变化。其中，物权的设立即物权的取得，物权的取得分为**原始取得**与**继受取得**。原始取得是指非依他人既存的权利而取得物权。继受取得是指基于他人既存的权利而取得物权。继受取得又分为**移转的继受取得**和**创设的继受取得**，前者是指从他人处取得他人原有的物权，如基于买卖合同受让所有权，后者是指在他人的所有物上设立他物权，如在国家所有的土地上设立建设用地使用权。

物权变动分为基于法律行为的物权变动和非基于法律行为的物权变动。在基于法律行为的物权变动中，公示为物权变动的**生效要件或者对抗要件**；非基于法律行为的物权变动则**不需要公示**，就其中的不动产变动而言，**登记既非生效要件也不是对抗要件，而是处分要件**。如根据《民法典》第229条至第232条的规定，因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。依照以上规定享有不动产物权的，处分该物权时，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不生物权效力。

二、物权变动的模式

【分析】物权变动的模式仅针对法律行为引起的物权变动。从比较法上看，物权变动的立法模式主要有**意思主义**、**物权形式主义**和**债权形式主义**三种。

意思主义是指仅需当事人的意思表示而无须其他要件即足以产生物权变动的立法例。其特点是不区分债权发生的意思表示和物权变动的意思表示。**物权形式主义**是指发生物权变动时，除了以产生债权债务关系为目的的债权合同外，还必须有物权变动的意思表示并履行登记或者交付的法定形式方能产生物权变动效力的立法例。其特点是区分债权行为与物权行为，且认为物权行为具有**独立性与无因性**。**债权形式主义**的做法介于意思主义与物权形式主义之间，规定物权的变动除债权合意外，还需要登记或者交付。其特点是不承认物权行为，认为物权变动的原因是债权行为与登记或者交付的结合。

我国立法对不同的物权变动采用的物权变动模式并不相同，有些物权变动采用意思主义，有些则采用债权形式主义。

三、不动产物权的变动

【分析】基于法律行为的不动产物权变动，除法律另有规定外，一律以登记作为物权变动的生效要件。**物权变动的时间点是将物权变动记载于不动产登记簿之日。**

四、动产物权的变动

【分析】基于法律行为的动产物权变动，除法律另有规定外，以交付作为物权设立与转让的生效要件。交付方式包括：

1. 现实交付，即将出让物转移给受让人占有。

2. 简易交付。动产物权转让前，受让人已经占有该动产的，转让人与受让人达成的物权转让合同生效时即为交付。动产物权设立亦适用这一规则。

3. 指示交付。出让人的出让动产被第三人占有的，出让人将返还请求权让与受让人，并告知占有人向受让人交付该动产，是为指示交付，也称“**返还请求权让与**”。根据现行规定，以指示交付方式完成交付的，**自转让人与受让人有关转让返还原物请求权的协议生效时为动产交付之日**。

4. 占有改定。出让人在转让物权后，需要继续占有出让的动产的，**可以与受让人约定**，由出让人继续占有该动产，在约定期限届满时，出让人再按约定将该动产交还受让人占有，**此种交付方式即为占有改定。有关占有改定的约定生效时即为交付**。

第四节 不动产登记

一、不动产登记的概念

【分析】不动产登记是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。此处的不动产是指土地、海域，以及房屋、森林、林木等建筑物、构筑物 and 定着物。

我国对不动产实行统一的登记制度。不动产登记由不动产所在地的登记机构办理。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，**自记载于不动产登记簿时发生法律效力**。

不动产登记簿与权属证书不同。不动产登记簿是物权归属和内容的根据，由登记机构管理，具有**权利推定**的效力。不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；**记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准**。但当事人有证据证明不动产登记簿的记载与真实权利状态不符、其为该不动产物权之真实权利人的，应依法确认其享有的物权。

二、不动产登记的类型

【分析】不动产登记的类型有：

1. 变动登记。这是指不动产物权登记机关就不动产物权的产生、变更、转让和消灭等事实进行的登记。故不动产的变动登记包括**首次登记、变更登记、转移登记、注销登记**等。不动产首次登记，是指不动产权利第一次登记。未办理不动产首次登记的，不得办理不动产其他类型登记，但法律、行政法规另有规定的除外。变更登记是指在登记事项发生改变时进行的登记，如**权利人的名称发生变更、不动产权利期限发生变化的**，不动产权利人可以向不动产登记机构申请变更登记。而在**买卖、互换、赠与不动产时或者因继承、受遗赠导致不动产权利发生转移时**，当事人可以向不动产登记机构申请转移登记。在不动产权利因**不动产灭失、权利人放弃、不动产被依法征收**等原因消灭时，当事人可以申请办理注销登记。

2. 预告登记。这是指在当事人所期待的不动产物权变动所需要的条件缺乏或者尚未成就时，即权利取得人对未来取得物权享有请求权时，为保护这一债权请求权而进行的登记。

预告登记的效力是：**预告登记后，未经预告登记的权利人同意**，处分该不动产的，如转移不动产所有权或设定建设用地使用权、地役权、抵押权等其他物权的，**不发生物权效力**。预告登记后，**债权消灭或者自能够进**

行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。此处的债权消灭包括买卖不动产的协议被认定无效、被撤销、被解除，或者预告登记的权利人放弃债权等。

3. 更正登记。权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项有错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。

4. 异议登记。异议登记是指登记机构将利害关系人对不动产登记簿登记事项的异议记载于登记簿上的行为。其适用情形是利害关系人申请更正登记而不动产登记簿记载的权利人不同意更正。登记机构予以异议登记的，申请人在异议登记之日起十五日内不提起诉讼的，异议登记失效。异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿。

三、不动产登记的效力

【分析】不动产登记是基于法律行为发生的不动产物权变动的公示方式，对该公示的效力，《民法典》采取的是登记生效和登记对抗相结合的做法。登记为不动产物权变动生效要件的情形主要有：因买卖、赠与等行为发生不动产所有权变动，建设用地使用权的设立，居住权的设立，不动产抵押权的设立等。登记为对抗要件的情形主要有：土地承包经营权互换、转让，地役权的设立。

四、不动产登记错误的责任

【分析】不动产登记错误的原因既可能出自登记机构，也可能出自当事人。根据规定，当事人提供虚假材料申请登记，造成他人损害的，应当承担赔偿责任。因登记错误，造成他人损害的，登记机构应当承担赔偿责任。登记机构赔偿后，可以向造成登记错误的人追偿。

第五节 物权的保护

一、确认物权

【分析】当物权归属不明或对物权内容发生争议时，当事人可以向法院提起诉讼，请求确认物权。

请求确认物权，包括请求确认所有权和请求确认他物权。确认物权是保护物权的一种独立方法。在某些情况下，确认物权是给物权以其他法律保护的前提。

二、返还原物

【分析】物被他人无权占有时，权利人可以请求返还原物。

返还原物的请求，以原物存在为前提，而且受到善意取得等制度的限制。

三、排除妨害、消除危险

【分析】他人的行为妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。排除妨害、消除危险的请求，不仅可以由直接占有物的所有人提出，也可以由直接占有物的用益物权人提出。

四、修理、重作、更换或者恢复原状

【分析】当物权的标的物因他人的侵权行为而毁损时，如果能够修复，物权人可以请求侵权行为人加以修理。如果难以修复，权利人可以要求重作或者更换。一般认为，修理、重作、更换适用于动产。对于不动产，

可以用其他方式恢复原状，以恢复物的原有状态。如对被污染的土地在可能的情况下应当予以修复。

五、损害赔偿

【分析】当物权人因他人的侵害行为而遭受经济损失时，物权人可以依法请求损害赔偿，也可以依法请求承担其他民事责任。

上述保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。其中的返还原物、排除妨害、消除危险这三种请求权属于**物权请求权**。物权请求权依附于物权，与物权不可分离，其目的在于恢复对物的圆满支配状态。

第十章 所有权

第一节 所有权概述

一、所有权的概念和特征

【分析】所有权是权利人在法律限制的范围内，对物全面支配并排除他人干预的物权。所有权的内容包括人对物的权利和人对人的权利：

1. 人对物的权利。所有权是所有人对物全面支配的权利，包括占有、使用、收益、处分几项具体的权利。上述权利属于**原权**，是所有权的核心内容，属于所有权的**积极内容**。

2. 人对人的权利。在受到他人非法干预或侵害时，所有人有权行使包括**返还请求权**、**妨害排除请求权**、**妨害预防请求权**、**恢复原状请求权**等在内的请求权。上述请求权属于**救济权**，是所有人基于对特定范围内财产的权利而产生的对非所有人的权利，属于所有权的**消极内容**。

所有权具有以下特征：

1. 全面性。所有权是所有人法定限制范围内对所有物加以全面支配的权利，区别于仅在某些方面对物予以支配的**定限物权**。

2. 整体性。所有权并非占有、使用、收益、处分等各种权能的简单相加，而是一个整体的权利，所有人对物有**统一的支配力**。

3. 弹力性。所有权人在其所有的财产上为他人设定他物权后，虽然占有等权能与所有权人发生分离，但**所有权并不消灭**。当所有物上设定的其他权利消灭，所有权的负担除去以后，所有权恢复其圆满的状态。

4. 排他性。所有权是独占的支配权，**同一物上只能有一个所有权存在**。

5. 恒久性。所有权属于**无期限物权**，法律不预设其存续期间。除因**作为客体的物灭失**、**所有人抛弃**等事由而消灭外，所有权可以永久存续。

二、所有权的分类

► 不动产所有权与动产所有权

【分析】不动产所有权与动产所有权的主要区别在于：首先，基于法律行为的不动产所有权变动原则上以**登记**为生效要件，基于法律行为的动产所有权变动原则上以**交付**为生效要件。其次，**先占**、**拾得遗失物**等**原始取得**方式仅适用于动产所有权。最后，只有不动产所有权才涉及**相邻关系**以及**建筑物区分所有权**问题。

► 单一所有权与多数人所有权

【分析】单一所有权是指所有权人为**单独一人**的所有权。多数人所有权是指所有权人为**多数人**的所有权，

多数人所有即**共有**。

►国家所有权和集体所有权、私人所有权

【分析】这是根据**生产资料所有制**的不同形式对所有权进行的划分。在我国，有些特定财产专属于国家所有，任何组织或者个人不能取得所有权，如城市土地、矿藏、水流、海城、无居民海岛、无线电频谱资源、国防资产等。**集体所有权的客体包括：**（1）法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂；（2）集体所有的建筑物、生产设施、农田水利设施；（3）集体所有的教育、科学、文化、卫生、体育等设施；（4）集体所有的其他不动产和动产。农民集体所有的财产，属于本集体成员集体所有。除了专属于国家的财产和集体所有的财产外，所有财产均可以成为私人所有权的客体。

三、所有权的权能和限制

【分析】所有权的权能包括积极权能和消极权能。

所有权的积极权能包括占有、使用、收益和处分。占有权能是**对所有物加以实际管领或控制的权利**。使用权能是**在不损毁所有物或不改变其性质的前提下，依照物的性能和用途加以利用的权利**。使用权能也可以转移给非所有人行使，并且**使用权能仅适用于非消耗物**。收益权能是**收取所有物所生利益（孳息）的权利**。以上三项权能既可以由所有权人行使，也可以由他人行使。处分权能是**对所有物依法予以处置的权利**。处分包括**事实上的处分和法律上的处分**。处分权能是所有权内容的**核心**和拥有所有权的**根本标志**，通常只能由所有人自己行使。

所有权的消极权能即排除他人的不法干预，如请求排除妨害、消除危险、恢复原状、赔偿损失等。

所有权受到的限制主要表现为：（1）行使所有权不得违反法律规定。（2）行使所有权不得妨害他人的合法权益。（3）行使所有权时必须注意保护环境、自然资源和生态平衡。（4）根据公共利益的需要，国家可以依法进行征收和征用。根据《民法典》规定，**为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋以及其他不动产**。征收组织、个人的房屋以及其他不动产，应当依法给予征收**补偿**，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当**保障被征收人的居住条件**。**因抢险救灾等紧急需要，依照法律规定的权限和程序可以征用组织、个人的不动产或者动产**。被征用的不动产或者动产使用后，应当**返还**被征用人。组织、个人的不动产或者动产被征用或者征用后毁损、灭失的，应当给予**补偿**。

四、所有权的取得

【分析】所有权的取得以**权利取得是否须以前权利人的所有权为前提**作为标准，可以分为**原始取得与继受取得**。**原始取得是指非依他人既存的所有权而取得所有权；继受取得是指基于他人既存的所有权而取得所有权**，如买卖、赠与等，即属于继受取得方式。

►原始取得

【分析】所有权的原始取得的主要方式包括：

1. 生产。生产是通过人的劳动攫取自然物，创造社会财富的过程。通过生产而取得产品的所有权是一种原始取得。

2. 先占。先占是以所有的意思占有无主动产而取得其所有权的法律事实。先占应具备以下**构成要件：**（1）须为无主物；（2）须为动产；（3）须以所有的意思占有无主物。**遗失物并非无主物，故不得适用先占取得所有权**。我国《民法典》未对先占作出规定。

3. 添附。添附是指不同所有人的财产结合在一起形成一个新的财产，或者对他人财产进行加工从而产生一个新的财产的事实。添附包括附合、混合和加工。

根据《民法典》规定，因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。一般认为，动产附合于不动产，如建材附合于房屋的，由不动产所有人即房屋所有权人取得附合物的所有权，动产所有权因此而消灭。加工后其所有权的确定规则是：加工物的所有权原则上归原材料的所有人，如果加工后增加的价值明显超过了原材料的价值，则归加工人，但加工人具有恶意的除外。

因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。

4. 拾得遗失物。在我国，拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当及时通知其领取；不知道的，应当及时发布招领公告。拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。

遗失物自发布招领公告之日起一年内无人认领的，归国家所有。

5. 拾得漂流物、发现埋藏物或者隐藏物。我国《民法典》规定，拾得漂流物、发现埋藏物或者隐藏物的，参照适用拾得遗失物的有关规定。法律另有规定的，依照其规定。

6. 善意取得。善意取得，又称即时取得，是指无处分权人将他人动产或者不动产让与第三人或者为第三人设定他物权时，如果第三人在取得该动产或者不动产的物权时系出于善意且符合其他条件，即取得该动产或者不动产的所有权或者他物权的制度。善意取得具有强化占有公信力、保护交易安全的功能。

动产所有权的善意取得条件是：（1）该项动产须为占有委托物且为非禁止流通物。（2）让与人系无处分权人。（3）受让人取得动产时出于善意。受让人受让动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意。受让人受让动产时，交易的对象、场所或者时机等不符合交易习惯的，应当认定受让人具有重大过失。（4）受让人以合理的价格受让。（5）已经完成交付。此处的交付不包括占有改定。

不动产所有权的善意取得条件为：（1）让与人系无处分权人但具有权利外观。（2）受让人受让该不动产是善意的。受让人受让不动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意。（3）受让人以合理的价格受让。（4）已经办理了登记。

善意取得的法律后果是：其一，受让人取得所有权，原所有权人丧失所有权。其二，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。其三，善意受让人取得动产后，该动产上的原有权利消灭。但是，善意受让人在受让时知道或者应当知道该权利的除外。

遗失物原则上不适用善意取得制度。根据《民法典》第312条规定，所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。该规则对漂流物、埋藏物或隐藏物也适用。

► 继受取得

【分析】所有权的继受取得是指通过某种法律行为或基于法律行为以外的事实从原所有权人处取得所有权。这种取得方式意味着原所有权人的所有权基于一定的法律事实转归于新的所有权人，亦即所有权的转移。所有权的转移对原所有权人来说也就是所有权的消灭。在理论上，所有权的消灭分为绝对消灭和相对消灭。所有权的绝对消灭是指因一定法律事实的发生使所有权的客体不复存在。所有权的相对消灭是指因一定法律事实的发生导致原所有权人丧失所有权，但原物依然存在，只是更换了所有权人。引起所有权相对消灭的原因主要是：

（1）转让所有权；（2）抛弃所有权；（3）国家机关依法采取强制措施；（4）所有权主体消灭。

所有权继受取得的原因包括法律行为和法律行为以外的事实两大类。所有权继受取得的主要方式包括买卖、互易、赠与、继承、受遗赠等。

第二节 建筑物区分所有权

一、建筑物区分所有权的概念和特征

【分析】建筑物区分所有权，是指根据使用功能，将一栋建筑物在结构上区分为各个所有权人独自使用的部分和由多个所有权人共同使用的共同部分时，每一个所有权人享有的对其专有部分的专有权、对共有部分的共有权以及各个所有权人之间基于建筑物的管理等共同事务而产生的管理权的结合。

建筑物区分所有权的主要特点有：

1. 复合性。建筑物区分所有权由**专有部分所有权、共有权及管理权**三要素构成，且建筑物区分所有权人的身份也具有多重性，既是专有权人，又是共有所有人，还是管理建筑物的管理权人，此有别于单一的不动产所有权。

2. 整体性。这是指建筑物区分所有权人的专有权、共有权及管理权，三者共为一体不可分离。在转让、继承、抵押时应将三者一起转让、继承、抵押。

3. 专有权的主导性。在构成建筑物区分所有权的三要素中，专有权具有主导性。业主转让房屋所有权的，其对共有部分享有的权利依法一并转让。

4. 客体的多元性。建筑物区分所有权的客体包括**专有部分与共有部分**，而不是仅局限于其中一部分。

二、建筑物区分所有权的内容

【分析】建筑物区分所有权的内容包括专有权、共有权与管理权。

专有权即专有部分所有权，系空间所有权，是建筑物区分所有权人对专有部分可自由占有、使用、收益及处分的权利。专有部分指在构造上能明确区分，具有排他性且可独立使用的建筑物部分。构成专有部分须具备三个条件：一是构造上的独立性，即“物理上的独立性”，从而能够明确区分；二是利用上的独立性，即“功能上的独立性”，可以排他使用；三是能够登记成为特定业主所有权的客体。业主在行使专有权时，不得违反法律、法规以及管理规约。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。

共有权即共有部分共有权，是建筑物区分所有权人依照法律或管理规约的规定，对区分所有建筑物之共有部分所享有的占有、使用及收益的权利。共有部分包括建筑物专有部分之外的其他部分，如楼梯、电梯、屋顶、地下室等，还包括**建筑物的附属建筑物和附属设施**，如物业服务用房、配电室、排水设备、消防设备、燃气管线、电缆、光缆等。

建筑物区分所有权人的管理权，指建筑物区分所有权人（业主）基于一栋建筑物的构造、权利归属及使用上的密切关系而形成的、作为建筑物管理团体之成员所享有的共同管理的权利。

根据《民法典》第 278 条规定，下列事项由业主共同决定：（1）制定和修改业主大会议事规则；（2）制定和修改管理规约；（3）选举业主委员会或者更换业主委员会成员；（4）选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人；（5）使用建筑物及其附属设施的维修资金；（6）筹集建筑物及其附属设施的维修资金；（7）改建、重建建筑物及其附属设施；（8）改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动；（9）有关共有和共同管理权利的其他重大事项。

业主共同决定事项，应当由**专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表**

决。决定前述第六项至第八项规定的事项，应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。决定前述其他事项，应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。

业主可以设立业主大会，由业主大会选举产生事务执行机构——业主委员会。管理权通过业主大会行使，业主大会或者业主委员会的决定对业主具有法律约束力。业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的，受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。

第三节 相邻关系

一、相邻关系的概念和特征

【分析】相邻关系，是指相互毗邻的不动产的所有人或使用人因对不动产行使所有权或使用权而发生的权利义务关系。相邻关系实质上是对财产所有人或占有人、使用人行使所有权或占有、使用权的合理延伸和必要的限制。例如，某农户承包的土地处于其他农户承包的土地范围之中，某农户在耕种土地时，必须通过其他农户的土地，其他农户都应当允许其通行。这对某农户来说，是使用权的延伸，而对其他农户则是使用权的限制。这种延伸和限制是法律允许的，是双方的权利或义务。

相邻关系的特征包括：

1. 相邻关系发生在两个以上权利主体之间。权利主体既可以是不动产所有人，也可以是不动产的使用人，如承包人、建设用地使用权人、承租人等。
2. 相邻关系的内容是相邻人间的权利、义务。相邻一方的权利受到法律的保护，但其不得滥用权利。
3. 相邻关系是在不动产毗邻或相近的特定条件下因对财产的使用而发生。

二、相邻关系的处理原则和依据

【分析】相邻关系的处理原则是有利生产、方便生活、团结互助、公平合理。

相邻关系的处理依据是：法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。

三、几种主要的相邻关系

【分析】我国有关物权的法律规范规定的相邻关系主要包括：相邻用水、排水关系；相邻不动产通行或利用关系；相邻通风、采光关系；相邻不可量物侵害防免关系；相邻损害防免关系。

► 相邻用水、排水关系

【分析】相邻用水、排水关系可以分为：

1. 相邻用水关系。在我国，水资源属于国家所有，相邻各方均有使用的权利。因此，相邻人应当保持水的自然流向，在需要改变流向并影响相邻他方用水时，应征得他方同意，并对由此造成的损失给予适当的赔偿。
2. 相邻排水关系。高地所有人或使用人有向低地排水的权利。但低地所有人或使用人对高地的排水所承担的义务，则因排放的水是自然流水或人工流水的不同而有所不同。对自然流水，低处的土地所有人或使用人有承水的义务，对自然流水给低地所有人或使用人造成的损害，若高处土地的所有人或使用人无过错，则不承担任何民事责任。而对于人工流水，低地所有人或使用人没有承水义务，只有过水义务，即允许流水通过的义务。高处土地所有人或使用人必须采取适当措施，将其人工流水安全通过低地，直达江河或公共排水系统。排放人

工流水给他人造成损害或危险的，受害方有权请求停止侵害、消除危险及赔偿损失。

还需注意的是，修建房屋时不得将屋檐滴水向邻人屋面排流，以防对邻人房屋的侵害。因屋檐滴水造成邻人损害的，受害人有权请求排除妨害、赔偿损失。

▶ 相邻不动产通行或利用关系

【分析】不动产权利人原则上有权禁止他人进入其不动产，但他人因通行等必须利用或进入其不动产的，不动产权利人应当提供必要的便利。对邻地享有通行权的人，应当依法赔偿邻人遭受的相应损失。对于历史上形成的通道，土地所有人或者使用人无权任意堵塞或改道，以免妨碍邻人通行，如果确实需要改道，应取得邻人的同意。

相邻不动产权利人难免需要临时或长期利用相邻土地或者建筑物。对此，《民法典》规定，不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利。因铺设管线利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害；造成损害的，应当给予赔偿。

▶ 相邻通风、采光和日照关系

【分析】《民法典》第293条规定，建造建筑物，不得违反国家有关工程建设标准，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。

▶ 相邻不可量物侵害防免关系

【分析】《民法典》第294条规定，不动产权利人不得违反国家规定弃置固体废物，排放大气污染物、水污染物、土壤污染物、噪声、光辐射、电磁辐射等有害物质。此规定列举的侵害即不可量物侵害。相邻各方可能产生有害气体的设施，应与邻人的生产、生活建筑物保持安全距离，并应采取预防和应急措施。相邻各方不得以持续的噪声、废气、辐射等侵害邻人。

▶ 相邻损害防免关系

【分析】《民法典》第295条规定，不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设备等，不得危及相邻不动产的安全。此规定即为相邻损害防免关系。不动产权利人挖掘土地等行为危及相邻不动产安全的，相邻不动产的权利人可以依法请求停止侵害、消除危险。

第四节 共有

一、共有的概念和特征

【分析】共有是指两个以上的权利主体对同一项财产都享有所有权。

共有的特征包括

1. 共有关系的主体为两个以上。

2. 共有关系的客体为同一项财产。只有在两个以上权利主体对同一项财产都享有所有权的条件下，才产生共有关系。

3. 共有关系的内容包括双重权利、义务关系。在共有关系内部，各个共有人作为相对独立的权利主体，都是共有财产的所有人。共有人或是对共有财产共同享有权利、承担义务，或是按照各自的份额，对共有财产分享权利、分担义务。在共有关系外部，共有人可以作为单一的权利主体，同共有人以外的民事主体发生财产所有关系和财产流转关系。

4. 共有关系的形成往往基于民事主体共同的生产经营目的或者生活需要，共有既可以是同一种类型所有权的联合，如两个自然人的共有；也可以是不同类型所有权的联合，如个人与集体组织的共有。

共有仅指共同享有所有权，共同享有益物权、担保物权的，参照适用关于共有的有关规定。

二、按份共有

【分析】按份共有，是指两个以上的共有人，对同一项财产按照确定的各自份额，对共有财产分享权利、分担义务的一种共有关系。其发生的根据是法律规定或者当事人的协议。

按份共有的基本特征是：共有人在共有关系中应当享有的权利和承担的义务，是以其在共有财产中一定份额为依据的。份额的确定规则是：有约定依约定，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；不能确定出资额的，视为等额享有。

按份共有人在享受权利的同时，也承担一定的义务。

按份共有人的权利包括：（1）依份额享有共有权。按份共有人行使权利、享受利益的大小与其预先确定的份额成正比。每个共有人享有的占有、使用和收益权，要受到其他共有人享有权利的影响与制约。因此，对共有财产的使用和收益方法，应从维护全体共有人的利益出发，由全体共有人事先协商决定。（2）分割请求权和转让权。根据《民法典》规定，共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割；没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割。因分割造成其他共有人损害的，应当给予赔偿。按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。（3）优先购买权。根据《民法典》规定，按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动产份额时，其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。按份共有人转让其共有的不动产或者动产份额的，应当将转让条件及时通知其他共有人。其他共有人应当在合理期限内行使优先购买权。两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。（4）在共有份额上设定担保物权。（5）物上请求权。共有物受到侵害时，共有人可单独或者共同请求停止侵害、排除妨害、消除危险，以维护共有权益。（6）共有物处分权。根据《民法典》规定，处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额三分之二的按份共有人同意，但是共有人之间另有约定的除外。

按份共有人在分享权利的同时，须分担共有财产的管理费用以及其他负担，同时对外承担因共有财产所生的债务。共有人的义务及于整个共有财产，各共有人享有债权、承担债务的规则是：因共有的不动产或者动产产生的债权债务，在对外关系上，共有人享有连带债权、承担连带债务，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外；在共有人内部关系上，除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿。

按份共有关系可依各种不同的根据产生，主要是法律规定和共有人之间的约定。实际生活中较常见的是依约定而产生的按份共有。如果共有人之间没有约定或者约定不明确，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有。按份共有关系可因共有人之间的协议、共有财产归一人所有、共有财产灭失或者被转让、共有财产的分割等原因而终止。

三、共同共有

【分析】共同共有是指两个以上的所有人根据共同关系对共有财产不分份额地共同享有权利并承担义务的共有关系。通说认为，共同共有主要包括夫妻财产共有、家庭财产共有和遗产分割前的共有三种类型。

共同共有的基本特征是：（1）各个共有人对共有财产共同地、平等地享有所有权，没有份额的区分。各自的份额只有在分割时才能确定。（2）各个共有人对共有财产享有平等的权利，承担平等的义务，没有权利大小或者义务多少的区分。（3）财产共同共有关系随着共有人的共同关系的存在而产生，并随着共同关系的解除而

消灭。

共同共有人的权利和义务由法律规定或者依共有人之间的约定。共同共有人因共同共有法律制度的限制，在共有关系存续期间不享有转让权和优先购买权，但共有人可以依《民法典》第303条的规定主张特定情形下的分割请求权。根据该条规定，共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割；没有约定或者约定不明确的，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割。因分割造成其他共有人损害的，应当给予赔偿。同时，共有人有权按照约定管理共有财产，没有约定或者约定不明确的，各共有人都有管理的权利和义务。此外，处分共有财产或者对共有财产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经全体共同共有人同意，除非共有人之间另有约定。最后，当共有财产被他人非法侵害时，任何一个共有人均有权行使物上请求权，使共有财产所有权恢复至圆满状态。

共有人对共有物的管理费用以及其他负担，有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，共同共有人共同负担。因共有的不动产或者动产产生的债权债务，在对外关系上，共同共有人享有连带债权、承担连带债务；在共有人内部关系上，除共有人另有约定外，共同共有人共同享有债权、承担债务。

无论是按份共有还是共同共有，共有人均可以协商确定分割方式。达不成协议，共有财产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍卖、变卖取得的价款予以分割。共有人分割所得的财产有瑕疵的，其他共有人应当分担损失。

第十一章 用益物权

第一节 用益物权概述

一、用益物权的概念和特征

【分析】用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产依法享有的占有、使用和收益的权利。

用益物权的特征是：（1）用益物权属于他物权、限制物权；（2）用益物权以占有为前提，以使用、收益为内容；（3）用益物权的客体包括动产和不动产，主要是不动产。

二、用益物权的种类

【分析】我国《民法典》对土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权五种用益物权作了较为具体的规定，对海域使用权、探矿权、采矿权、取水权、养殖权、捕捞权等特别法上的物权仅作了宣示性规定。有学者将这些物权称为准物权、特许物权。

第二节 土地承包经营权

一、土地承包经营权的概念和特征

【分析】土地承包经营权是指自然人或社会组织依据承包合同对于农民集体所有或者国家所有由农民集体使用的土地享有的占有、使用和收益的权利。

土地承包经营权具有如下特征：（1）土地承包经营权属于用益物权。（2）土地承包经营权的主体是承包人，包括自然人和社会组织。（3）土地承包经营权的客体是农民集体所有和国家所有由农民集体使用的耕地、林地、草地以及其他用于农业的土地。权利人必须将以上土地用于从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。（4）

土地承包经营权是由发包人与承包人通过**签订承包合同**的方式设定的。(5) 土地承包经营权是一种**有期限**的物权，承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。

二、土地承包经营权的设立

【分析】土地承包经营权的取得方式有两种：一是**原始取得**，二是**继受取得**。前者是指**承包人通过与发包人签订承包合同**的方式取得土地承包经营权，后者是指**新承包人通过与原承包人签订转让、互换合同**等方式取得土地承包经营权。

根据《民法典》规定，**土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立**。登记机构应当向土地承包经营权人发放**土地承包经营权证、林权证**等证书，并**登记造册**，确认土地承包经营权。

三、土地承包经营权的内容

【分析】土地承包经营权人享有的权利主要有：**(1) 对承包地进行占有、使用并获取相应的收益，自主组织生产经营和处置产品。****(2) 通过家庭承包取得的土地承包经营权，土地承包经营权人有权将土地承包经营权互换、转让。土地承包经营权互换、转让的，当事人可以向登记机构申请登记；未经登记，不得对抗善意第三人。****(3) 向他人流转土地经营权。**通过家庭承包取得的土地承包经营权，土地承包经营权人有权依法采取**出租、入股或者其他方式**向他人流转土地经营权。**流转期限为五年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。**当事人可以向登记机构申请土地经营权登记；**未经登记，不得对抗善意第三人。**通过**招标、拍卖、公开协商**等方式承包农村土地，经**依法登记取得权属证书**的，可以依法采取**出租、入股、抵押或者其他方式**流转土地经营权。**(4) 承包地被依法征收、征用、占用的，土地承包经营权人有权依法获得相应的补偿。**

第三节 建设用地使用权

一、建设用地使用权的概念和特征

【分析】建设用地使用权是指自然人、社会组织对国家或者集体所有的土地依法享有的利用该土地建造及保有建筑物、构筑物及其附属设施的权利。

建设用地使用权具有以下特征：**(1) 建设用地使用权属于用益物权。****(2) 建设用地使用权的主体为符合法定条件的自然人和社会组织。****(3) 建设用地使用权的内容为在土地上建造和保有建筑物、构筑物及其附属设施，以及对建设用地使用权的处分，如出资、转让、抵押等，但不包括对土地本身的处分。****(4) 建设用地使用权的客体包括国有土地和集体所有的土地，其范围包括土地表面及其上下的一定空间。****(5) 建设用地使用权具有排他性，在同一块土地上不允许有两个以上内容相同的建设用地使用权存在。**

二、建设用地使用权的设立

【分析】建设用地使用权的客体包括**国有土地和集体所有的土地**，在不同客体之上设立的建设用地使用权的条件和程序是不同的。以**集体土地**为客体的建设用地使用权限于**兴办乡镇企业、乡（镇）村公共设施和公益事业**，其使用权的取得必须报请有关政府部门**批准**，且**不得转让、出租或者抵押**。以**国有土地**为客体的建设用地使用权的取得方式有两种：一是通过**土地使用权的出让、转让**等方式取得。其中，出让是指**从国家取得土地使用权**，其方式包括**招标、拍卖、协议**等；转让是指**从土地使用权人处取得土地使用权**。二是通过**划拨**的方式取得。通过出让或者转让方式取得的土地使用权属于民法上可交易的财产范畴，除法律另有规定外，可以转让、

互换、出资、赠与或者抵押；而通过划拨方式取得的土地使用权只能由权利人自己使用，而不能作如上处分。划拨仅限于法律有明文规定的情形，如国家机关用地和军事用地，城市基础设施用地和公益事业用地，国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地以及法律、行政法规规定的其他用地等。设立建设用地使用权的，应向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自登记时设立。

三、建设用地使用权的内容

【分析】建设用地使用权人依法享有以下权利：（1）占有权。权利人对依法取得使用权的土地享有直接支配和控制的权力。（2）使用权。权利人可以对土地加以开发、经营和利用。（3）收益权。权利人可以直接利用土地以获得收益。如果是国有土地，权利人还可以将建设用地使用权合法转让、出租或者抵押以获得收益。除有相反证据证明的以外，建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物及其附属设施的所有权属于建设用地使用权人。（4）处分权。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，法律另有规定的除外。建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。

建设用地使用权期限届满的，如果是住宅建设用地使用权，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。如果是非住宅建设用地使用权，其续期依照法律规定办理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理。

第四节 宅基地使用权

一、宅基地使用权的概念和特征

【分析】宅基地使用权是指农村集体经济组织成员因建造自有房屋而依法对集体所有的土地享有的占有、使用的权利，是我国特有的一种用益物权。

宅基地使用权的特征在于：（1）宅基地使用权的主体限于农村集体经济组织成员。（2）宅基地使用权的内容限于建造、保有住宅及其附属设施。（3）宅基地使用权的客体限于集体所有的土地，换言之，宅基地的所有权归集体。（4）宅基地使用权的取得是无偿的且没有期限限制，故该权利具有福利性。

二、宅基地使用权的设立

【分析】宅基地使用权的设立即宅基地使用权的取得。该使用权的取得方式有原始取得与继受取得。原始取得的方式主要包括根据法律的直接规定或者权利人的依法申请和集体经济组织的审核同意而取得。继受取得是指通过依法继承，互换宅基地上的住宅而取得宅基地使用权。

三、宅基地使用权的内容

【分析】宅基地使用权的内容包括：（1）占有宅基地。（2）使用宅基地建造房屋和附属设施并因此取得房屋及其附属设施的所有权。（3）取得因行使宅基地使用权而获得的收益。

根据现行法规定，宅基地使用权不得抵押，不得单独转让，必须与合法建造的住房一并转让。但权利人出卖住房后，再申请宅基地的，不予批准。

第五节 居住权

一、居住权的概念和特征

【分析】居住权是指自然人为了满足生活居住的需要，按照合同约定，对他人的住宅享有的占有、使用的用益物权。

居住权的特征包括：（1）居住权的主体限于自然人；（2）居住权的内容是占有、使用他人的住宅；（3）居住权的客体是他人的住宅；（4）居住权的设立目的是满足权利人生活居住的需要；（5）居住权原则上是无偿的，当事人另有约定的除外；（6）居住权具有专属性，依附于特定人的身份而存在，故不得转让、继承，并因居住权人死亡而消灭；（7）居住权是有期限的物权。

二、居住权的设立

【分析】设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

居住权合同一般包括下列条款：（1）当事人的姓名或者名称和住所；（2）住宅的位置；（3）居住的条件和要求；（4）居住权期限；（5）解决争议的方法。

我国对居住权采取登记设立主义。《民法典》第368条规定，设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

三、居住权的内容

【分析】居住权人享有的权利包括：（1）按照合同的约定占有、使用他人的住宅。使用的目的应当限于自己生活居住的需要，故不得出租设立居住权的住宅，但是当事人另有约定的除外。（2）在权利受到侵害时主张物权保护或者请求侵权人承担侵权责任，如请求排除妨害或者消除危险、赔偿损失等。

居住权人承担的义务包括：（1）行使居住权时应当妥善使用他人住宅，避免对住宅造成损害。（2）在双方约定有偿设立居住权的情形下，向对方支付使用费用。

四、居住权的消灭

【分析】居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。居住权消灭的，应当及时办理注销登记。

以遗嘱方式设立居住权的，参照适用以合同方式设立居住权的有关规定。

第六节 地役权

一、地役权的概念和特征

【分析】地役权是指不动产的权利人，如所有权人或使用权人，为自己使用不动产的便利或提高自己不动产的效益而利用他人不动产的权利，如通行权、取水权、采光权、眺望权等。此处的他人不动产为供役地，自己的不动产为需役地。

在学理上，根据地役权内容的不同，可以将其分为积极地役权和消极地役权。前者以地役权人在供役地上为一定行为为内容，如通行、取水、排水。后者以供役地权利人不得在供役地上为一定行为为内容，如不得建筑超过一定高度的建筑物以保障地役权人的眺望权。

地役权的特征包括：（1）地役权的主体包括不动产的所有权人和使用权人。（2）地役权的内容是利用他

人不动产，并对他人的权利加以限制。（3）地役权的客体是他人不动产。（4）地役权的设立目的是为供自己使用不动产之便利或效益之提高。（5）地役权是否有偿及存续期限依当事人约定。（6）地役权具有从属性。

地役权的从属性意味着地役权不得脱离需役地而存在，不得单独转让、抵押。

二、地役权的设立

【分析】根据《民法典》相关规定，地役权合同应当采取书面形式，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。

需要强调的是，土地上已经设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等用益物权的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。土地所有权人享有地役权或者负担地役权的，设立土地承包经营权、宅基地使用权等用益物权时，该用益物权人继续享有或者负担已经设立的地役权。土地承包经营权、建设用地使用权等转让的，除合同另有约定外，地役权一并转让。土地经营权、建设用地使用权等抵押的，在实现抵押权时，地役权一并转让。

三、地役权的内容

【分析】地役权人享有的权利包括：（1）应当按照合同约定的利用目的和方法利用供役地，尽量减少对供役地权利人物权的限制。（2）在供役地内为必要的附属行为，如取水地役权可以在供役地通行。（3）在权利受到侵害时主张物权保护或者请求侵权人承担侵权责任，如排除妨害或者消除危险、赔偿损失等。

地役权人承担的义务包括：（1）行使地役权时应尽量减少对供役地权利人物权的限制。（2）维护为行使地役权而在供役地修建的设施，并在不妨碍地役权行使的限度内允许供役地权利人使用这些设施。

四、地役权的消灭

【分析】地役权人有下列情形之一的，供役地权利人有权解除地役权合同，地役权消灭：（1）违反法律规定或者合同约定，滥用地役权。（2）有偿利用供役地，约定的付款期限届满后在合理期限内经两次催告未支付费用。

第十二章 担保物权

第一节 担保物权概述

一、担保物权的概念和特征

【分析】担保物权是指以担保债务清偿为目的，而在债务人或者第三人的特定物或者权利上设立的定限物权。

担保物权的特征包括：（1）优先受偿性。担保物权人可以就担保财产的价值优先于债务人的普通债权人受偿。（2）从属性。担保物权是为担保债权受偿而设定的，从属于所担保的债权，以债权存在为前提，且不得与所担保的债权分离而单独存在。被担保的债权消灭，担保物权亦消灭。（3）不可分性。这是指债权人在全部债权受清偿前，可就担保财产的全部行使其权利。主要体现在两方面：一是债权人在全部债权受清偿之前，得对于担保财产整体主张权利；二是担保财产的部分变化或债权的部分变化均不影响担保物权的整体性，即使担保财产被分割或转让，或者被担保的债权得到部分清偿或被转让，担保物权人仍可以对担保财产的全部行使权利以担保全部债权的受偿。（4）物上代位性。担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可

以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。

二、担保物权的分类

【分析】根据《民法典》规定，担保物权包括抵押权、质权与留置权。在学理上，可以对担保物权作以下分类：根据产生依据的不同，担保物权可以分为意定担保物权与法定担保物权；根据担保财产种类的不同，担保物权可以分为动产担保物权、不动产担保物权和以权利为客体的担保物权。此外，所有权保留中出卖人的所有权、融资租赁中出租人的所有权事实上也具有担保功能，故被称为非典型担保，与动产抵押适用相同的登记对抗规则。同时，有关司法解释还承认让与担保的效力。债务人或者第三人与债权人约定将财产形式上转移至债权人名下，债务人不履行到期债务，债权人有权对财产折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款偿还债务的，该约定有效。当事人已经完成财产权利变动的公示，债务人不履行到期债务，债权人可以请求参照民法典关于担保物权的有关规定就该财产优先受偿。

担保物权可以与人的担保并存，从而形成混合共同担保。根据《民法典》规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。

三、担保物权的消灭

【分析】根据《民法典》第 393 条规定，有下列情形之一的，担保物权消灭：（1）主债权消灭；（2）担保物权实现；（3）债权人放弃担保物权；（4）法律规定担保物权消灭的其他情形。

第二节 抵押权

一、抵押权的概念和特征

【分析】抵押权是指债权人对于债务人或第三人提供的不转移占有而作为债务履行担保的财产，在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，得就该财产的价值优先受偿的权利。

抵押权的特征表现在：首先，抵押权是一种约定担保物权。其次，抵押权的客体是债务人或第三人提供的特定财产，该财产可以是动产、不动产，也可以是某种财产权利。再次，抵押权是不转移占有的担保物权，在抵押期间，抵押财产仍由抵押人占有。最后，抵押权除具有担保物权的优先受偿性、从属性、不可分性、物上代位性等特征之外，还具有追及性。根据我国现行法律规定，抵押期间，抵押财产转让的，抵押权不受影响，抵押人可以继续行使抵押权。但是，以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。

二、抵押权的设立

【分析】抵押权原则上属于约定担保物权，需要当事人通过签订抵押合同设定。抵押合同应当采取书面形式。抵押合同的有效，除了要求当事人具有相应的民事行为能力、意思表示真实、内容合法及具备法定形式之外，还要求抵押财产为法律、行政法规未禁止抵押的财产。根据《民法典》第 395 条规定，可以抵押的财产须为债务人或者第三人有权处分的财产，具体包括：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）

海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前述所列财产一并抵押。

根据《民法典》第399条规定，不得抵押的财产包括：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

我国实行“房地一体”原则，故以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依据该规定一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押。乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押。

我国现行法律主要根据抵押财产的不同，对抵押权分别实行登记设立主义和登记对抗主义。以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、海域使用权、正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。对第三人的范围，相关司法解释有明确规定。

抵押权人在债务履行期限届满前，与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，只能依法就抵押财产优先受偿。

三、抵押权的效力

【分析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人另有约定的，从其约定。

抵押权的效力不仅及于原抵押财产，而且及于抵押财产的从物、从权利、添附物、孳息和代位物。孳息的处理规则是债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，致使抵押财产被人民法院依法扣押的，自扣押之日起，抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息，但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。前述孳息应当先充抵收取孳息的费用。

当事人的权利和义务主要是：

1. 抵押人的权利和义务。抵押权设定后，抵押人仍保有抵押财产的所有权，有权占有、使用、收益抵押财产，同时还可以在上一抵押财产上设定多个抵押权，以及为他人设定用益物权。抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押人的义务包括：保持抵押财产的价值，不得实施降低抵押财产价值的行为；转让抵押财产时及时通知抵押权人。

2. 抵押权人的权利和义务。抵押权人的权利包括：（1）抵押权保全权，包括防止抵押财产价值减少的请求权，恢复抵押财产价值的请求权或者增加担保请求权。（2）抵押权处分权，如将抵押权转让或者用作债权的担保，放弃抵押权或者抵押权的顺位等。抵押权人可以与抵押人协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵押权、抵押权顺位或者变更抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。（3）优先受偿权。抵押权人于抵押权实现时，有权以抵押财产的价值优先受偿。（4）抵押财产转让时的权利。抵押人转让抵押财产时，抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押权人的义务主要是不得妨碍抵押人正常行使抵押财产的所有权。

四、抵押权的顺位

【分析】一物之上存在两个以上抵押权的，在实现抵押权时，须确定抵押权的顺位。根据《民法典》规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；（2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照适用前述规定。

抵押权人既可以放弃抵押权的顺位，也可以与抵押人协议变更抵押权顺位。但该变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。

五、抵押权的实现

【分析】抵押权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，得处分抵押财产，并就其价值优先受偿。

抵押权实现应具备以下条件：其一，须抵押权有效存在。其二，须发生可以实现抵押权的法定或约定情形。抵押权的实现方法主要有两种：一是与抵押人协议以抵押物折价，取得抵押物的所有权，但此协议不得损害其他债权人的利益。否则，其他债权人可以请求人民法院撤销。二是抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。抵押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

需要注意的是，《民法典》第417、418条规定，建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。但是，新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。以集体所有土地的使用权依法抵押的，实现抵押权后，未经法定程序，不得改变土地所有权的性质和土地用途。此外，《民法典》第416条规定了价款债权抵押权的超级优先效力。根据该条规定，动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后十日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

抵押权与质权并存的处理规则是：同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。

抵押权与租赁权并存的处理规则是：抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的，适用登记对抗规则。

抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。

六、动产浮动抵押

【分析】动产浮动抵押是指以法律规定的动产作为一财产整体设立的动产抵押。在动产浮动抵押中，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿。

动产浮动抵押的特征是：（1）抵押人限于企业、个体工商户、农业生产经营者，故主体具有特定性；（2）抵押财产限于抵押人的动产且具有集合性和变动性，包括现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品。

动产浮动抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

动产浮动抵押中的特有问题是抵押财产的确定。根据《民法典》第411条规定，抵押财产自下列情形之一发生时确定：（1）债务履行期限届满，债权未实现；（2）抵押人被宣告破产或者解散；（3）当事人约定的实现抵押权的情形；（4）严重影响债权实现的其他情形。

七、最高额抵押

【分析】最高额抵押是指在预定的最高债权额限度内，为担保一定期间内将要连续发生的债权的清偿而设立的抵押。最高额抵押权所担保的原则上是未来的债权，但设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。

最高额抵押的特征是：（1）所担保债权的不确定性。（2）适用范围的限定性。（3）非从属性。最高额抵押不以某一特定债权的存在为条件。最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，除当事人另有约定外，最高额抵押权不得转让。抵押期间某一具体债权消灭，最高额抵押权并不因此消灭。

根据规定，有下列情形之一的，抵押权人的债权确定：（1）约定的债权确定期间届满；（2）没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满二年后请求确定债权；（3）新的债权不可能发生；（4）抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押；（5）债务人、抵押人被宣告破产或者解散；（6）法律规定债权确定的其他情形。

第三节 质权

一、质权的概念和特征

【分析】质权是指债务人或者第三人将其动产或者财产权利交给债权人占有或者控制，以此作为履行债务的担保，在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形时，债权人得以该动产或者财产权利的价值优先受偿的权利。

质权的特征表现在：首先，质权是一种约定的担保物权。其次，质权的客体是债务人或者第三人提供的动产或者权利。最后，质权是转移占有的担保物权，质押期间，质押财产转由质权人占有。此外，质权具有担保物权的优先受偿性、从属性、不可分性、物上代位性。

二、动产质权

【分析】动产质权是指以动产为质押财产的质权，质权属于约定担保物权，当事人应当采用书面形式订立质押合同。质押合同应当符合合同的成立要件和生效要件，法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，只能依法就质押财产优先受偿。

质押合同为诺成性合同，出质人未按合同约定移交质押财产的，应当承担违约责任。但合同生效不等于质权设立，质权自出质人交付质押财产时设立。此处的交付不包括占有改定。

质权的效力包括以下内容：

1. 质权的担保范围。质权的担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质押财产保管费用和实现质权的费用。当事人另有约定的，按照约定。

2. 质权效力及于标的物的范围。质权效力及于质押财产、质押财产的从物、孳息和代位物，但从物未随同质押财产移交质权人占有的，质权的效力不及于从物。对于孳息是否作为出质财产，当事人可另作约定。

3. 当事人的权利和义务。（1）质权人的权利包括：第一，占有质押财产。第二，收取质押财产的孳息，质押合同另有约定的除外。收取并非取得，质权人收取的孳息应当先充抵收取孳息的费用。第三，保全质权。因不可归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的，质权人有权请求

出质人提供相应的担保；出质人不提供的，质权人可以拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或者提存。第四，**优先受偿权**。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以就质押财产折价，也可以就拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿。质权人可以放弃质权。**债务人以自己的财产出质，质权人放弃该质权的，其他担保人在质权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。**质权人的义务包括：**妥善保管质押财产**，因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担**赔偿责任**；未经出质人同意，**不得擅自使用、出租、处分质押财产，也不得将质押财产转质**，否则应当赔偿因此给出质人造成的损害；债务人履行债务或者出质人提前清偿所担保的债权的，质权人应当**返还**质押财产；应出质人的请求在债务履行期限届满后**及时行使质权**，**因怠于行使权利造成出质人损害的，应当承担赔偿责任**。（2）出质人的权利包括：第一，保留质押财产的所有权。第二，在质权人的行为可能使质押财产毁损、灭失时，可以请求质权人将质押财产**提存**，或者请求**提前清偿债务并返还**质押财产。第三，在债务人履行债务或者出质人提前清偿所担保的债权后，有权请求质权人**返还**质押财产。第四，有权请求质权人在债务履行期限届满后**及时行使质权**；质权人不行使的，出质人可以请求人民法院**拍卖、变卖**质押财产。出质人如果是债务人以外的第三人，还享有对债务人的**追偿权**。出质人的义务包括：**按照约定交付质押财产**；**不得妨碍**质权人行使质权；保证质押财产**无瑕疵**，否则因此造成质权人其他财产损害的，应当承担**赔偿责任**。

三、权利质权

【分析】权利质权是指以债权或者其他可让与的财产权利（如股权）为质押财产的质权。根据《民法典》规定，**债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：**（1）**汇票、本票、支票**；（2）**债券、存款单**；（3）**仓单、提单**；（4）**可以转让的基金份额、股权**；（5）**可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权**；（6）**现有的以及将有的应收账款**；（7）**法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利**。

权利质权的**设立条件**因出质权利的不同而不同：以**汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单**出质的，质权**自权利凭证交付质权人时设立**；没有权利凭证的，质权**自办理出质登记时设立**。以**基金份额、股权、注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权、应收账款**出质的，质权**自办理出质登记时设立**。

基金份额、股权、应收账款出质后，**不得转让**，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权、应收账款所得的价款，应当向质权人**提前清偿债务或者提存**。**知识产权中的财产权**出质后，出质人**不得转让或者许可他人使用**，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用**知识产权中的财产权**所得的价款，应当向质权人**提前清偿债务或者提存**。

权利质权的实现方式除折价、拍卖、变卖出质权利外，还有其**特殊的实现方式**。如根据《民法典》第442条规定，**汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单**的**兑现日期或者提货日期先于主债权到期的**，质权人可以**兑现或者提货**，并与出质人协议将**兑现的价款或者提取的货物提前清偿债务或者提存**。

第四节 留置权

一、留置权的概念和特征

【分析】留置权是指合法占有债务人动产的债权人，于债务人不履行到期债务时，得留置该动产并以其价值优先受偿的权利。其特征是：**（1）留置权属于法定担保物权；（2）留置权的客体限于动产；（3）留置权以合法占有留置财产为要件。**

二、留置权的成立

【分析】留置权的成立要件包括：

1. 债权人已经合法占有属于债务人所有的动产。
2. 债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系，但是企业之间留置的除外。
3. 债务已届清偿期而债务人未履行债务。
4. 符合法律规定和当事人的约定并且不违背公序良俗，同时与留置人承担的义务不相抵触。法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。

三、留置权的效力

【分析】留置权人的权利包括：（1）留置标的物，即在债权受清偿前，有权继续占有留置物；（2）收取留置物所生孳息并用以抵偿债权；（3）必要时适当使用留置物；（4）请求债务人偿还因保管留置物所支付的必要费用；（5）就留置物的价值优先受偿。债务人于宽限期届满后仍未履行债务且未另行提供担保的，留置权人可以行使留置权。留置权人与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。留置担保的范围包括主债权和利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

留置权人的义务包括：（1）妥善保管留置财产。债权人因保管不善造成留置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。（2）不得擅自使用、出租或处分留置财产。（3）经债务人的请求行使留置权。债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权。留置权人不行使的，债务人可以请求法院拍卖、变卖留置财产。（4）留置权消灭时，返还留置财产给债务人。

四、留置权的实现

【分析】留置权的实现与留置权的成立不同。符合留置权的成立条件的，债权人可以留置动产，但只有在宽限期届满后债务人仍未履行债务的，留置权人才可以行使优先受偿权。该宽限期可以由留置权人与债务人事先约定；没有约定或者约定不明确的，除鲜活易腐等不易保管的动产外，留置权人应当给债务人六十日以上履行债务的期限，债务人逾期未履行的，留置权人才可以行使留置权。

留置权的实现方式包括折价、拍卖与变卖。留置财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿。

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

五、留置权的消灭

【分析】留置权的消灭事由包括一般事由与特殊事由。一般事由包括主债权消灭、担保物权实现或者放弃、担保财产毁损、灭失且无代位物等。特殊事由包括留置权人丧失对留置财产的占有，或者接受债务人另行提供的担保。

第十三章 占有

第一节 占有概述

一、占有的概念

【分析】占有是指对于物具有事实上的管领力的一种状态。通说认为，占有是一种事实而不是权利。占有的特征在于：（1）占有的客体限于有体物，包括不动产和动产。但占有的客体不限于独立的物，对物的组成部分也可以成立占有。（2）占有必须是对物产生了事实上的支配与控制。

二、占有的分类

根据不同标准，占有可作不同分类。

► 有权占有和无权占有

【分析】以占有人的占有是否具有本权为标准，占有可以分为有权占有和无权占有。有权占有是指基于本权的占有，此处的本权包括所有权、他物权、租赁权等权利。无权占有是指欠缺本权的占有，如小偷对赃物的占有等。区分有权占有与无权占有的主要意义在于：第一，有权占有人可以拒绝他人的返还原物请求权；第二，无权占有中的占有人不享有留置权。

► 善意占有和恶意占有

【分析】根据占有人的主观心理状态，无权占有可以分为善意占有与恶意占有。善意占有是指占有人不知道且不应当知道自己的占有没有合法根据而占有；恶意占有是指占有人知道或者应当知道自己没有合法根据而占有。区分二者的主要意义在于：第一，只有善意占有人方可受到善意取得制度的保护；第二，占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任；第三，善意占有人对于因维护占有的不动产或者动产支出的必要费用，可以要求权利人返还，而恶意占有人无此项请求权；第四，无权占有的不动产或者动产毁损、灭失的，占有人无论是否为善意均应返还保险金、赔偿金或者补偿金给权利人。权利人的损害未得到足够弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。

► 直接占有和间接占有

【分析】依占有人是否直接占有物，可以将占有分为直接占有与间接占有。直接占有即直接对物加以管领之占有；间接占有指虽不直接占有物，但基于一定法律关系对物加以间接支配的占有。如在租赁合同中，承租人为直接占有人，出租人为间接占有人。

► 自主占有和他主占有

【分析】依占有人是否具有所有的意思，可以将占有分为自主占有与他主占有。自主占有是指占有人以自己所有的意思而占有，否则即为他主占有。

第二节 占有的效力和保护

一、占有的效力

【分析】占有的法律效力主要有：（1）权利推定效力。如果占有人在占有物上行使权利，则推定其享有此项权利。这就是占有的权利推定效力。根据占有的权利推定效力，在没有相反证据的情况下即推定占有人享有相应的物权或者债权。（2）权利取得效力。占有人在符合法定要件的情况下可以取得本权，此即占有的权利取得效力。具体包括两种情形，一是善意取得所有权或者他物权，二是因占有时效的完成而取得所有权或者

他物权。我国法律至今尚无关于占有时效的一般规定。(3) 保护效力。占有人的占有无论是否为有权占有，均可以对抗他人的侵犯。

二、占有的保护

【分析】根据有关规定，占有人享有以下请求权：(1) 占有物返还请求权。占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物。占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起1年内未行使的，该请求权消灭。(2) 妨害排除和消除危险请求权。在妨害已经发生或者有妨害之虞时，占有人有权请求排除妨害或者消除危险。(3) 损害赔偿请求权。因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。

第十四章 合同通则

第一节 债与合同概述

一、债的概述

► 债的概念

【分析】民法上的债，是指特定当事人之间可以请求为特定行为的民事法律关系。债的特征是：(1) 债是存在于特定当事人之间的民事法律关系；(2) 债是特定当事人之间请求为特定行为的民事法律关系；(3) 债是特定当事人实现自身特定利益的财产性民事法律关系；(4) 债是依照法律规定或者法律行为而产生的民事法律关系。债的存在表明债权人的利益尚未得到满足，在债权人的利益得到满足时，债的关系消灭。

债作为一种民事法律关系，包括主体、内容和客体三个要素。债的主体，即债的当事人，包括债权人和债务人。债权人和债务人均须为特定的主体。按照合同或者法律规定，债权人与债务人之间发生特别结合关系。债原则上仅在特定当事人之间产生效力，但基于法律的规定，债也可以发生对第三人的效力。债的内容，是指债权与债务。债权和债务具有特定性和对应性，债权是请求为特定行为的权利，债务是为该特定行为的义务。债的客体，亦称债的标的，是债权、债务共同指向的对象。债的客体是债务人的特定行为，亦称给付。给付包括积极给付与消极给付。积极给付是以作为为内容的给付，消极给付是以不作为为内容的给付。给付可以在债的关系成立时确定，也可以在债务履行时确定。

► 债的内容

【分析】债的内容即债权人与债务人之间的债权债务。

1. 债权。债权是指债权人享有的以请求债务人为一定给付为内容的权利。债权具有如下特征：(1) 为请求权。在债务人给付前，债权人不能直接支配债务人应给付的标的物，也不能以支配债务人的人身来强制债务人作出给付，只能请求债务人履行债务来实现利益。(2) 为相对权。债权人只能请求债务人履行债务，除法律另有规定外，即使因第三人的原因致使债权不能实现，债权人也只能以债之关系为基础向债务人主张权利。(3) 具有任意性。在不违反强行法规定的情况下，当事人可以任意设定债的关系；即使是法定之债，当事人也可以通过协商确定债的内容。(4) 具有非排他性。以同一给付为标的而成立的数个内容相同的债权相互之间不发生权利上的冲突。(5) 具有平等性。对于同一债务人先后成立的数个债权，效力一律平等。在该债务人陷入破产时，数个债权人根据债权数额的比例接受清偿。

一般认为，债权具有如下权能：(1) 请求权能。作为一种请求权，债权人可以直接请求债务人履行债务，也可以通过诉讼方式以国家强制力来实现其请求。(2) 保持受领权能。债务人履行债务或受强制执行提出给付时，债权人有权接受给付并保持因此获得的利益。(3) 保全权能。当债务人的某些行为对债权人造成损害时，

债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，或请求人民法院撤销债务人的行为。(4)处分权能。债权人可以通过抵销、免除、让与债权和设定债权质权等方式对享有的债权予以处分。上述权能齐备的债权为完全债权，否则为不完全债权，但欠缺保持受领权能的债权不再是债权。

2. 债务。债务是指债务人依照约定或法律规定向债权人作出给付的义务。债务的主要特征为：(1) 具有特定性。在债之关系中，债务人和债务内容均是特定的。依法成立的债务非依法律规定或经当事人协商不得变更。(2) 具有期限性。任何债务都有确定或可确定的期限。(3) 履行具有强制性。当债务人不履行债务时，债权人有权追究债务人的民事责任以满足其利益。责任是债务人履行债务的一种担保，无责任的债务无法律约束力。

债务有给付义务与附随义务之分，其中给付义务又分为主给付义务与从给付义务。主给付义务，是指债之关系中固有的、必备的可以决定债的类型的基本义务。在双务合同中，主给付义务构成对待给付义务。从给付义务是指辅助主给付义务的功能实现的义务。从给付义务不决定债的类型，但能够确保债权人的利益获得最大的满足。从给付义务可以基于法律规定或当事人的约定而发生，也可以基于诚实信用原则而发生。附随义务是指给付义务之外的，以诚实信用原则为依据而产生的协助、保护、照顾、保密等义务。此外，在债之关系中还有所谓的“不真正义务”。不真正义务没有一个与之相对应的权利，故该义务不可能被请求履行。当事人不履行不真正义务将承担法律上的不利后果。《民法典》第 591 条规定的防止损失扩大的义务即为不真正义务。

► 债的发生原因

【分析】债的发生原因，是指能够在特定当事人之间引起债之关系产生的法律事实。该法律事实可以是行为，也可以是事件，其中行为包括表示行为和事实行为。

1. 合同。合同依法成立后，当事人之间即产生债权债务关系。

2. 侵权行为。侵权行为发生后，侵权人与受害人之间则产生债权债务关系。

3. 无因管理。无因管理能够依法在管理人与受益人之间引起债的关系。

4. 不当得利。不当得利能够在得利人与受损失的人之间引起债的关系。

5. 其他事实。除上述引起债发生的原因外，单方允诺、缔约过失、遗赠等也可以成为债的发生原因。

二、合同概述

► 合同的概念和特征

【分析】合同是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同有广义和狭义之分。广义的合同包括有关财产关系的协议，也包括有关身份关系的协议。《民法典》合同编规定的合同是指狭义上的合同，即有关财产关系的协议。有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定，没有规定的，可以根据其性质参照适用《民法典》合同编的规定。

合同具有以下特征：(1) 是一种民事法律行为。(2) 合同是两方以上当事人意思表示一致的民事法律行为。(3) 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。

► 合同的分类

【分析】根据不同的标准，合同通常可以分为：

1. 有名合同和无名合同。这是以法律上是否设有规范并赋予名称为标准作出的划分。有名合同又称典型合同，是指法律上已经规定了合同名称及规则；无名合同是指法律上尚未规定合同名称及具体规则。二者的区别在于：有名合同适用法律已对其设定的规范；无名合同适用《民法典》合同编“通则”的规定，并可以参照《民法典》合同编“典型合同”或者其他法律中最相类似合同的规定。

2. 要式合同和不要式合同。这是以是否须具备一定形式为标准作出的划分。要式合同是指法律规定或当事人约定须具备特定形式的合同；不要式合同是无须具备特定形式的合同。二者的区别在于：要式合同在具备特

定形式时成立或生效；不要式合同在当事人意思表示一致时成立或生效。

3. 单务合同和双务合同。这是以双方当事人是否互负给付义务为标准作出的划分。单务合同是指仅有一方负担给付义务的合同；双务合同是指双方互负对待给付义务的合同。该分类的意义在于，在双务合同中，当事人享有同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权；单务合同则无此效力。另外，在双务合同中存在风险负担问题；而单务合同不发生风险负担问题。

4. 为自己利益订立的合同和为第三人利益订立的合同。这是以合同目的是否为自己利益订立为标准作出的划分。为自己利益订立的合同是指订约当事人自己享有权利并直接取得利益的合同；为第三人利益订立的合同是指订约当事人为第三人设定权利并使其取得利益的合同。后者的特征是：第三人不是当事人；第三人只享受权利，不承担义务；第三人对是否接受权利有选择权。如果第三人接受权利，则债务人应当向其履行，但债务人违约时，应当向债权人承担违约责任；如果第三人拒绝接受，则合同权利由为第三人利益订立合同的当事人自己享有。

5. 主合同和从合同。这是以合同相互间的主从关系为标准作出的划分。不以其他合同存在为前提即可独立存在的合同，为主合同；必须以其他合同存在为前提才能成立的合同，为从合同。主合同是否成立与生效直接影响着从合同的成立及效力，但从合同不成立或无效，通常不会影响主合同的成立与效力。

► 合同的解释

【分析】合同解释有广义和狭义之分。广义的合同解释包括确定合同成立与否、确认合同之性质、发掘合同默示条款或暗含条款以及明确合同条款含义，狭义的合同解释只是确定合同条款的含义。根据《民法典》合同编的规定，合同的解释对象主要是合同条款。

当事人对合同条款的理解有争议的，有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定争议条款的含义。合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。据此，我国确立了文义解释、整体解释、目的解释、习惯解释、诚信解释等合同解释方法。

三、债与合同的关系

【分析】债是债权和债务的统一体。合同之债是债的一种具体类型。

非因合同产生的债权债务关系，适用有关该债权债务关系的法律规定；没有规定的，适用《民法典》合同编“通则”的有关规定，但是根据其性质不能适用的除外。

第二节 合同的订立

一、合同的成立要件

【分析】合同的成立要件分为一般成立要件和特别成立要件。一般成立要件是所有合同成立均须具备的条件，包括有双方或多方当事人、当事人就合同必要条款达成合意、合同内容明确。除法律另有规定或者当事人另有约定外，能够确定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同成立。特别成立要件是指某些合同成立必须具备的要件，如某些合同需要具备特定的形式或须交付标的物才能成立。

二、合同订立的程序

【分析】当事人订立合同可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

► 要约

【分析】要约是当事人一方向对方发出的希望与对方订立合同的意思表示。其条件包括：（1）必须是特定人向相对人发出的意思表示。要约人必须是在客观上可以确定的人；要约的相对人可以是特定的，也可以是不特定的社会公众。（2）必须以缔结合同为目的。（3）内容应具体确定。要约至少应包括拟订立合同的必备条款，以供相对人考虑是否承诺。（4）必须表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

要约生效后，要约人应受要约的约束，在要约有效期内不得随意撤销或变更要约；受要约人则取得了承诺的权利，受要约人有权在要约的有效期限内作出接受要约的答复，但其不负必须承诺的义务。受要约人不承诺，没有通知要约人的义务。

要约的生效时间因要约形式的不同而有所不同。一般来说，以对话方式作出的要约自受要约人知道要约内容时生效，以非对话方式作出的要约自要约到达受要约人时生效；以非对话方式作出的采用数据电文形式的要约，受要约人指定特定系统接收数据电文的，要约自该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，要约自受要约人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效；要约人与受要约人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。在要约生效前，要约人可以撤回要约；要约生效后，在符合法定条件时，要约人可以撤销要约。

要约与要约邀请不同。要约邀请，是希望他人向自己发出要约的表示。要约与要约邀请的区别是：（1）目的不同。要约的目的在于获得对方的承诺以成立合同；要约邀请的目的在于引出对方的要约。（2）条件不同。要约的条件如前所述；要约邀请无须具备前述条件，只要邀请人足以确定即可。（3）效力不同。要约人须受要约约束；要约邀请没有法律效力，故邀请人不受要约邀请的约束。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等均为要约邀请，但商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。

► 承诺

【分析】承诺是受要约人向要约人作出的同意要约的意思表示。其条件包括：（1）必须是由受要约人本人或其代理人向要约人作出。（2）必须在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，若要约是以对话方式作出的，除当事人另有约定外，受要约人应当即时作出承诺；若要约是以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。（3）内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。（4）原则上应以通知方式作出，特殊情况下依交易习惯或者要约的规定也可以以行为方式作出。除法律有特别规定或当事人事先有明确约定外，沉默不能视为承诺的形式。

承诺的效力在于，承诺生效则合同成立，双方当事人由此承担合同产生的权利与义务。

对于承诺生效的时间，我国法律规定，以对话方式作出的，承诺在要约人知道其内容时生效；以非对话方式作出的，承诺在承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺也有效。

承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达要约人。

以拍卖方式订立合同的，拍卖公告属于要约邀请，竞买人的应价（或称报价）行为构成要约，拍卖人的买

定表示构成承诺。在竞买人的最高应价经拍卖师落槌或者以其他公开表示买定的方式确认后，合同成立。其后，买受人和拍卖人应当签署成交确认书。

以招标投标方式订立合同的，**招标为要约邀请，投标为要约，定标为承诺**。定标后，招标人应当向中标人发出**中标通知书**，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，双方应当自**中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同**。当事人拒绝签订书面合同的，应当依据**招标文件、投标文件和中标通知书**等确定合同内容。

►强制缔约

【分析】**强制缔约**，是指依照法律、行政法规的规定一方当事人负有应对方的请求而与之订立合同的义务。**在强制缔约情形，负有发出要约义务的当事人，应当及时发出合理的要约；负有作出承诺义务的当事人，不得拒绝对方合理的订立合同要求。**

►预约合同

【分析】**预约合同**，是指要约人与受要约人约定将来订立一定合同的合同。

当事人约定在将来一定期限内订立合同的**认购书、订购书、预订书**等，构成预约合同。预约合同与**本约合同**相对，**本约合同就是履行预约合同而订立的合同**。在订立预约合同后，**订立本约合同是当事人应当履行的义务，只要本约合同未订立，则预约合同就没有履行**。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的**违约责任**。

►悬赏广告

【分析】**悬赏广告**，是指当事人以发布广告的形式，对完成广告中所要求的特定行为的人，给付广告中所**声明的报酬的意思表示**。

在我国法律上，悬赏广告属于**要约**，悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，**完成该行为的人可以请求其支付**。

三、合同的内容和形式

►合同的内容

【分析】合同的内容即合同当事人对权利义务达成的合意，其表现为**合同条款**。合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：**当事人的姓名或者名称和住所，标的，数量，质量，价款或者报酬，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法**。

►合同的形式

【分析】合同形式，是指合同当事人设立、变更、终止民事权利义务关系的一致协议的表现形式。通常使用的合同形式有口头形式、书面形式和行为默示形式三种。

口头形式，是指合同当事人以口头交谈方式相互作出意思表示订立合同。**口头形式除了有约定的答复期限外，对方应立即作出接受的答复。否则，合同不成立**。口头合同形式的优点在于简便、易行、迅速、即时清结。但在口头合同中，若当事人之间发生纠纷则难以取得证据。

书面形式，是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。**以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式**。标的数额比较大、内容较复杂、不能立即履行的合同多采用书面形式。凡需要**公证、鉴证、登记或审批**的合同形式均为**特殊书面形式**。

行为默示形式又称**推定形式**，是指合同当事人以某种表明法律意图的行为间接地表示合同内容的形式。**认定行为默示形式系以合同的开始履行推定合同已经订立**。

四、格式条款

【分析】格式条款，是指当事人为了重复使用而预先拟订，并在订立合同时未与对方协商的条款。

我国法律对格式条款的特殊要求体现在：（1）提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻提供格式条款一方责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。（2）提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。（3）存在下列情形的，格式条款无效：一是具有民事法律行为的无效事由；二是格式条款中的造成对方人身损害的、因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款；三是提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；四是提供格式条款一方排除对方主要权利。（4）对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

五、合同成立的时间和地点

【分析】合同成立的时间原则上为承诺生效时。一般来说，当事人就合同条款协商一致，合同即成立。其中，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式，但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立。除当事人另有约定外，当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立。

合同成立的地点通常为承诺生效的地点。其中，除当事人另有约定外，采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。采用合同书形式订立合同的，最后签名、盖章或者按指印的地点为合同成立的地点，当事人另有约定的除外。

六、缔约过失责任

► 缔约过失责任的概念

【分析】缔约过失责任，是指在订立合同过程中，当事人一方因违反其依据诚实信用原则产生的先合同义务，致另一方信赖利益损失时所应承担的赔偿责任。其法理基础是诚实信用原则。法学通说认为，缔约过失责任是一种独立的民事责任。缔约过失责任主要适用于以下情形：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的对方商业秘密或者其他应当保密的信息；其他违背诚实信用原则的行为等。

► 缔约过失责任的构成要件

【分析】缔约过失责任的构成条件包括：（1）一方违背依诚实信用原则应负的先合同义务。（2）他方受有信赖利益的损失。（3）一方违反先合同义务与他方所受损失之间有因果关系。（4）违反先合同义务的一方具有过失。

缔约过失责任的赔偿范围是信赖利益的损失。一般包括：缔约费用，准备履行合同所支出的费用，丧失与第三人另订合同的机会所造成的损失。

第三节 合同的效力

一、合同的有效要件

【分析】合同的效力又称合同的法律效力，是指已成立的合同将对合同当事人乃至第三人产生的法律后果。已成立的合同满足相应的有效要件，则产生当事人预期的后果。

合同的一般有效要件是：（1）当事人缔约时有相应的缔约能力。（2）当事人的意思表示真实。（3）不违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗。有些合同除需要具备一般有效要件外，还需要具备特别生效要件，主要有：（1）法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续才能生效的合同，在办理相关手续后生效。（2）附生效条件的合同自条件成就时生效。（3）附生效期限的合同自期限届至时生效。合同欠缺一般有效要件的法律后果有三种情形：合同无效，合同可撤销，合同效力待定。

二、合同效力的特别规则

【分析】合同是民事法律行为的一种类型，《民法典》总则编中有关民事法律行为效力的规范适用于对合同效力的认定。同时，《民法典》合同编对合同效力作出了一些特殊规定。

依法成立的合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自成立时生效。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照《民法典》总则编有关民事法律行为效力和《民法典》合同编有关合同效力的规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。

合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。

第四节 合同的履行

一、合同履行的一般规则

【分析】合同的履行，是指债务人按照合同的约定履行其义务。合同履行的一般规则，是指当事人在履行合同过程中应当遵循的基本准则，包括全面履行规则、遵循诚实信用规则和保护生态环境规则。

全面履行规则，又称正确履行规则或适当履行规则，该规则要求当事人按照合同约定的标的、数量、质量、履行期限、履行地点、履行方式，全面完成合同义务。遵循诚实信用规则要求当事人应本着诚实、守信、善意的态度履行合同义务，不得滥用权利或故意规避义务。保护生态环境规则，是指在履行合同过程中，当事人应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

当事人按照合同的约定履行义务，如果当事人就某些条款约定不明，应当遵循以下规则：就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。如果还不能确定，则适用下列规定：（1）质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国

家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（2）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。（3）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。（5）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（6）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。

此外，通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。电子合同的标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间；前述凭证没有载明时间或者载明时间与实际提供服务时间不一致的，以实际提供服务的时间为准。电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间为交付时间。但是，电子合同当事人对交付商品或者提供服务的方式、时间另有约定的，按照其约定。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。以支付金钱为内容的债，除法律另有规定或者当事人另有约定外，债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行。而且，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

二、合同履行的特别规则

【分析】基于债权债务关系的不同类型，当事人在履行合同过程中应当遵循以下特别准则：

1. 选择之债的履行。选择之债，是指债的履行标的有数种，当事人可以选择其中之一予以履行的债。在履行债务之前，选择之债的给付标的必须特定，即通过在数种给付标中选定一种而将选择之债转变为简单之债。选择之债由选择权人行使选择权而将履行标的特定化，选择权人的确定顺序为：（1）根据法律规定、当事人的约定或者交易习惯确定；（2）标的有多项而债务人只需履行其中一项的，债务人享有选择权；（3）享有选择权的当事人在约定期限内或者履行期限届满未做选择，经催告后在合理期限内仍未选择的，选择权转移至对方。当事人享有的使选择之债的给付标的特定的选择权在性质上为形成权，选择权行使后效力溯及债之发生时。当事人行使选择权应当及时通知对方，通知到达对方时，标的确定。标的确定后不得变更，但是经对方同意的除外。可选择的标的发生不能履行情形的，享有选择权的当事人不得选择不能履行的标的，但是该不能履行的情形是由对方造成的除外。

2. 按份之债的履行。按份之债，是指债的多数主体各自按照确定的份额分享债权或者分担债务的债。其中，债权人按照确定的份额分享债权的，为按份债权；债务人按照确定的份额分担债务的，为按份债务。在按份之债中，各债权人的债权或各债务人的债务均是独立的，按份债权人在自己享有的债权份额得到清偿或按份债务人履行了自己承担的债务份额后，即退出债之关系。二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。

3. 连带之债的履行。连带之债，是指债的多数主体中任何一人都有权请求对方履行全部债务，或任何一人都有义务向对方履行全部债务的债。连带之债由法律规定或者当事人约定，其中多数人一方相互间有连带关系。多数人享有同一债权且每个债权人均可请求债务人履行全部债务的为连带债权；多数人负有同一债务且每个债务人均有义务对债权人履行全部债务的为连带债务。在连带之债中，在连带债权人中一人受领全部给付或连带债务人中的一人履行了全部债务后，连带之债归于消灭，但此时连带之债在连带债权人或连带债务人之间转化为按份之债。连带债权人或者连带债务人之间的份额难以确定的，视为份额相同。实际承担债务超过自己份额

的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿，并相应地享有债权人的权利，但是不得损害债权人的利益。其他连带债务人对债权人的抗辩，可以向该债务人主张。被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的，其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。部分连带债务人履行、抵销债务或者提存标的物的，其他债务人对债权人的债务在相应范围内消灭；该债务人可以依法向其他债务人追偿。部分连带债务人的债务被债权人免除的，在该连带债务人应当承担的份额范围内，其他债务人对债权人的债务消灭。部分连带债务人的债务与债权人的债权同归于一人的，在扣除该债务人应当承担的份额后，债权人对其他债务人的债权继续存在。债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，对其他连带债务人发生效力。实际受领债权的连带债权人，应当按比例向其他连带债权人返还。

4. 涉他合同的履行。涉他合同，是指当事人在合同中为第三人设定了权利或者义务的合同，包括为第三人利益的合同与由第三人履行的合同。当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债务人和第三人另有约定的则依照约定处理。

5. 提前履行。债务人一般应于履行期届至时履行义务。债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但是提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。

6. 部分履行。债务人应当按照法律的规定或者合同的约定全面履行自己的义务。债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但是部分履行不损害债权人利益的除外。债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。

7. 情事变更规则。情事变更，是指合同依法成立以后，非归因于当事人双方的原因，作为合同赖以成立的基础或环境的客观事实发生变更，使得继续维持合同的效力显失公平或者不能实现合同目的，遭受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构予以变更或解除的规则。根据《民法典》第 533 条规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同；人民法院或者仲裁机构应当结合案件的具体情况，根据公平原则变更或者解除合同。

三、双务合同履行中的抗辩权

【分析】双务合同履行中的抗辩权，是指在符合法定条件时，当事人一方对抗对方当事人的履行请求权。该权利属于暂时拒绝履行合同债务的权利，存在的基础是双务合同的牵连性。《民法典》合同编规定了以下三种抗辩权。

►同时履行抗辩权

【分析】同时履行抗辩权，是指双务合同的当事人在没有约定履行顺序或约定应同时履行的情况下，一方当事人在对方未为对待给付之前，得拒绝履行自己债务的权利。

同时履行抗辩权的构成要件包括：（1）须当事人就同一双务合同互负债务；（2）须双方互负的债务均届清偿期；（3）须对方未履行债务或履行债务不符合约定；（4）须对方的对待给付是可能履行的。

当事人因合同不成立、无效、被撤销或解除而互付义务，若具有对价关系，也可主张同时履行抗辩权。同时履行抗辩权属于延期抗辩权、一时抗辩权。如果对方已经履行了债务，该权利即消灭。

►先履行抗辩权

【分析】先履行抗辩权，是指在当事人互负债务且有先后履行顺序时，负有先履行债务的一方未履行债务或履行债务不符合约定时，后履行一方拒绝其履行请求的权利。

先履行抗辩权的成立要件包括：（1）当事人基于同一双务合同互负债务；（2）双方债务均已届清偿期；

（3）一方当事人应当先履行债务；（4）应当先履行的一方未履行债务或者履行债务不符合约定。

先履行抗辩权属于一时抗辩权，其成立及行使，使得后履行一方可中止履行自己的债务，以保护自己的期限利益、顺序利益；在先履行一方采取了补救措施、变违约为适当履行的情况下，先履行抗辩权消灭，后履行一方须履行债务。

►不安抗辩权

【分析】不安抗辩权，是指先履行一方在有确切证据证明后履行一方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况下，可暂时中止履行的权利。

不安抗辩权的成立要件包括：（1）当事人基于同一双务合同互负债务；（2）主张不安抗辩权的一方应当先履行债务且其债务已届清偿期；（3）先履行一方有确切证据证明对方履行能力明显降低，有不能为对待给付的现实危险。

不安抗辩权的效力在于：在具备上述条件时，先履行一方有权中止履行，但应当及时通知对方；对方提供适当担保的，应当恢复履行；中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

第五节 合同的保全

一、合同的保全的概念和类型

【分析】合同的保全，属于广义的合同担保，其理论及立法根据是任何一个债务人原则上均对外承担无限责任，故其一般财产是担保债权实现的总担保，该项财产亦称“责任财产”。法律规定的保障该项财产完整性的措施即为合同的保全，包括债权人的代位权和债权人的撤销权两种类型。

二、债权人的代位权

【分析】债权人的代位权，是指当债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利而影响债权人的到期债权实现时，债权人享有的以自己名义代位行使债务人对相对人的权利之权利。

债权人的代位权的成立条件包括：（1）债权人对债务人的债权合法。（2）债务人对第三人（相对人）享有债权。（3）债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利影响债权人的到期债权的实现。这是指债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼方式或者仲裁方式向相对人主张其享有的债权或者与该债权有关的从权利，以致影响债权人的到期债权的实现。（4）债务人对第三人的债权为非专属性权利和可以强制执行的权利。通常而言，抚养费、赡养费或者抚养费请求权，人身损害赔偿请求权，劳动报酬请求权和请求支付基本养老金、失业保险金、最低生活保障金的权利等为专属于债务人自身的债权。

债权人的代位权必须通过诉讼方式行使，代位权的行使范围以债权人的到期债权为限，行使代位权的必要费用，由债务人负担。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。人民法院认定代位权成立的，由债务人的相对人向债权人履行义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。

债务人对相对人的债权或者与该债权有关的从权利被采取保全、执行措施，或者债务人破产的，依照相关法律的规定处理。债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。

三、债权人的撤销权

【分析】债权人的撤销权，是指在债务人实施的处分行为影响债权人的债权实现时，债权人享有的依诉讼程序请求法院撤销债务人实施的行为的权利。

债权人撤销权的成立要件因债务人所为的行为系无偿或有偿而有所区别。若为无偿行为，则只需具备客观要件。若为有偿行为，则需同时具备客观要件与主观要件。其中，客观要件包括：（1）债务人实施了一定的处分财产的行为，具体包括以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，以及以明显不合理的价格实施互易财产、以物抵债、出租或者承租财产、知识产权许可使用等行为。（2）债务人的处分行为已发生法律效力。（3）债务人的行为影响债权人的债权实现。主观要件要求在债务人实施影响债权人的债权实现的行为时，债务人的相对人知道或者应当知道该情形。

债权人的撤销权由债权人以自己的名义在诉讼中行使，其行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法律约束力。

第六节 合同的变更和转让

一、合同的变更

【分析】合同的变更有广义与狭义之分。广义的合同变更包括合同的内容变更与合同的主体变更，狭义的合同变更仅指合同的内容变更。本节中合同的变更为狭义的合同变更。

合同的内容变更，是指不改变合同主体而对合同的内容予以改变。其特征在于：变更以原合同有效为前提；变更的是合同的内容而非合同的主体；变更之后，合同仍然有效。当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为合同未变更。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。合同变更后，当事人应当按照变更后的合同履行，但合同变更对已按原合同所作的履行没有追溯力；同时，合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

二、合同的转让

【分析】合同的转让即合同主体的变更，是指在不改变合同内容的情况下合同主体发生改变，包括债权让与、债务承担和债权债务的概括移转。在合同的主体变更时，合同的内容仍保持其同一性，即合同的效力不发生改变。合同可以因多种原因而转让，如基于法律直接规定而发生、基于法院裁决而发生、基于民事法律行为而发生等。由于依据法律规定而发生的合同转让在条件及效力方面均具有强制性，故此处不予赘述。

1. 债权让与。债权让与，是指在不改变债的内容的前提下，债权人入与第三人订立合同将其债权移转给第三人享有。其中债权人称为让与人，第三人称为受让人。债权让与可分为全部让与和部分让与。前者是指债权人

将其债权全部转让给第三人享有，并在转让协议生效后退出该债之关系，使受让人成为债权人；后者是指债权人将其债权部分转让给第三人享有，其在转让协议生效后与受让人共同成为债权人。在债权的部分让与中，转让协议对转让的债权份额有约定的，在让与人与受让人之间成立按份债权；双方对转让的债权份额没有约定的，则在让与人与受让人之间成立连带债权。

通过合同方式让与债权的条件包括：（1）存在有效的债权。诉讼时效已经完成的债权、可撤销但尚未撤销的债权、附条件或附期限的债权等均属于有效的债权。（2）让与人即原债权人与第三人达成合意且不违反法律规定。（3）债权具有可让与性。作为财产权的债权有自由流通的要求。设立债权让与的目的在于尊重债权人对于其债权的自由处分权，并增强债权的利用价值。在我国，下列债权不得转让：（1）根据性质不得转让的债权。此类债权主要包括：①基于当事人之间的特定身份关系发生的债权，如抚养费、赡养费之请求权等；②基于当事人之间的信赖关系而发生的债权，如定作人对于承揽人之债权。（2）按照当事人约定不得转让的债权。一些债权根据其性质具有可让与性，如果债权人与债务人特别约定该债权不得转让，则债权人不得将该债权让与他人。不过，当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人；当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。（3）依照法律规定不得转让的债权。

在让与人和受让人达成债权让与协议后，债权即移转于受让人，但此时债务人无从知晓债权已经发生变动，故债务人仍可能向让与人履行债务。若债权让与于转让协议成立时即对债务人具有约束力，则意味着在债务人不知债权已移转的事实时，其向让与人履行债务的行为无效，这对债务人而言极不公平。因此，我国法律规定，债权人转让债权未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。在债权让与通知到达债务人后，债务人应向受让人履行债务，此时撤销债权让与的通知将严重影响受让人的利益，故除经受让人同意外，债权转让的通知不得撤销。此外，法律、行政法规规定债权让与应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

债权让与的效力包括对内效力和对外效力。债权让与的对内效力即债权让与发生于让与人及受让人之间的效力，其内容主要包括：（1）转让协议一经生效，受让人取得让与人转让的债权。（2）受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外；受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。（3）转让协议生效后，让与人应将所有证明债权的文件交给受让人，并将有关行使债权的必要情况告知受让人，以便其能够完全行使债权。（4）让与人对让与的债权负权利瑕疵担保责任。债权让与的对外效力即债权转让协议对于债务人的效力。在让与通知到达债务人后，债权让与对债务人的效力主要有：（1）债务人应向受让人履行债务，债务人向让与人履行债务的，则该履行无效，且不能对抗受让人。（2）债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。（3）债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期，或者债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生的，债务人可以向受让人主张抵销。（4）因债权转让增加的履行费用，由让与人负担。

让与人将同一债权转让给两个以上受让人，债务人已经向最先通知的受让人履行的，其可不再履行债务。债务人明知接受履行的受让人不是最先通知的受让人，最先通知的受让人有权请求债务人继续履行债务或者依据债权转让协议请求让与人承担违约责任；除接受履行的受让人明知债权在其受让前已经转让给其他受让人外，最先通知的受让人无权请求接受履行的受让人返还其接受的财产。

2. 债务承担。债务承担又称债务移转，是指不改变债的内容而将债务人的全部或部分债务转移给第三人承受。债务承担可以依据法律规定而发生，也可以依据当事人之间的民事法律行为而发生，较为常见的方式是通过当事人之间的债务转移协议而发生。债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。债务转移以转移后原债务人是否免责为

标准，可以分为免责的债务承担和并存的债务承担。在债务承担中，接受转移债务的第三人为新债务人，又称承担人。

免责的债务承担，是指原债务人将全部或部分债务转移给第三人承担而脱离相应的债的关系。免责的债务承担的要件包括：（1）须存在有效的债务。（2）须有以债务转移为内容的协议。该协议可以是第三人与债权人签订的；也可以是第三人与债务人签订的，还可以是债务人、债权人与第三人三方共同签订的。（3）须债务具有可转移性。凡性质上不可转移的债务以及当事人约定不得转移的债务，均不具有可转移性。（4）须经债权人同意。当债务转移协议是第三人与债务人签订时，债务转移须经债权人同意。此外，法律、行政法规规定债务转移应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。**免责的债务承担的效力**表现为：（1）债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩；原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人主张抵销。（2）债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但是该从债务专属于原债务人自身的除外。从债务包括利息债务、违约金债务和损害赔偿债务等。（3）新债务人不得以对抗原债务人的事由对抗债权人。（4）由第三人为债权设定的担保，除担保人继续同意担保外，因债务承担而消灭。

并存的债务承担，是指原债务人将债务转移给第三人承担，原债务人与第三人共同负担同一内容的债务。在并存的债务承担中，第三人加入原债务人一方成为新债务人，使原来的单一之债转变为债务人为多数的多数人之债，故债权人与债务人之间的关系，以及各债务人之间的关系，应适用多数人之债的一般规则处理，即在第三人加入债的关系后，第三人作为新债务人在其同意承担债务的范围内与原债务人承担连带责任。

第三人加入债务并与债务人约定了追偿权，其履行债务后有权向债务人追偿；没有约定追偿权，第三人有权依照《民法典》关于不当得利等的规定，在其已经向债权人履行债务的范围内请求债务人向其履行，但是第三人知道或者应当知道加入债务会损害债务人利益的除外。债务人就其对债权人享有的抗辩，有权向加入债务的第三人主张。

3. 债权债务的概括移转。债权债务的概括移转，是指债的一方主体将其债权债务一并转移给第三人，使该第三人代替出让人的地位，成为债的新的当事人。债权债务的概括移转的发生原因包括合同承受和法定承受。

合同承受，是指合同的一方当事人经对方当事人同意，与第三人订立合同将其在合同中的债权债务全部或者部分转移给第三人。合同承受应具备的条件有：（1）须经合同一方当事人与第三人达成转移协议，并取得合同的对方当事人同意。（2）被转移的合同须为双务合同。（3）法律、行政法规规定必须采取特定形式的，应遵循法律、行政法规的规定。合同承受实为债权让与和债务承担同时发生，故其法律效力适用有关债权让与和债务承担效力的规定。在合同承受中，第三人完全取代了合同的一方当事人而成为新的合同当事人，原合同当事人一方完全退出合同关系。

法定承受，是指基于法律的直接规定而产生的债权债务的概括移转，包括法人合并和财产继承等。根据我国法律规定，法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担；法人分立的，除债权人和债务人另有约定外，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务。债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。上述规定同样适用当事人订立合同后合并与分立时的债权债务承担。该规定同样适用当事人订立合同后合并与分立时的债权债务承担。

合同承受与法定承受的主要区别有：（1）合同承受中的承受人可为任意第三人；法定承受中的承受人只能是法定第三人。（2）合同承受须债的当事人一方与承受人订立转让协议，并取得另一方当事人的同意；法定承受无须取得承受人同意，且对另一方当事人为通知或公告即发生效力。

第七节 合同的权利义务终止

一、合同的权利义务终止的概念和原因

►合同的权利义务终止的概念

【分析】合同的权利义务终止，即合同之债的消灭，是指因一定的法律事实致使合同之债的关系在客观上不复存在。在合同关系中，债权人是为了取得一定的利益才设立债之关系，只有债消灭了，债权人才能实现其目的；债的消灭不仅使主债终止，亦使从债一并终止，但**债的消灭不影响合同中结算和清理条款的效力**。合同之债消灭后，当事人之间的权利义务关系终止，债权的担保及从属的权利随之消灭，债权人应将**负债字据**返还给债务人。同时，**当事人应当遵循诚实信用等原则，根据交易习惯，履行通知、协助、保密、旧物回收等义务**，此种义务在学理上称为**后合同义务**。违反此义务致对方损害的，应当承担损害**赔偿责任**。

►合同的权利义务终止的原因

【分析】合同的权利义务终止的原因主要有：清偿、解除、抵销、提存、免除和混同。对于法律规定或者当事人约定终止的其他情形，依照法律规定或者当事人约定处理。

二、清偿

【分析】**清偿**，是指**债务人依法律规定或合同约定完成义务的行为**。清偿与履行同义。清偿是从债的消灭的角度而言；履行是从债的效力出发强调债权的实现过程。清偿是合同的权利义务终止的常见原因。在清偿中应注意**代物清偿**与**清偿抵充**两种特殊情形。

代物清偿，是指在履行债务过程中，债权人受领他种给付以代替原定给付而使债的关系消灭。**代物清偿须具备以下要件：**（1）有原债务存在；（2）经双方当事人约定，以他种给付代替原定给付；（3）有双方当事人关于代物清偿的合意；（4）债权人或其他有履行受领权的人现实地受领给付。

清偿抵充，是指在债务人对于同一债权人负担数项同种类的债务而债务人提供的给付不足以清偿全部债务时，决定以该给付抵充何项债务的规则。债权人与债务人对清偿的债务或清偿抵充**顺序有约定的，依约定进行抵充**。若债权人和债务人**没有约定的**，债务人的给付不足以清偿其对同一债权人所负的数项相同种类的全部债务，**由债务人在清偿时指定其履行的债务；债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；**数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；**负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行。**债务人在履行主债务外还应当**支付利息和实现债权的有关费用**，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，**应当按照下列顺序履行：**（1）**实现债权的有关费用；**（2）**利息；**（3）**主债务。**

三、解除

►合同解除的概述

【分析】合同解除，是指在合同有效成立之后尚未开始履行或者尚未全部履行之前，因当事人一方或双方的意思表示，提前终止合同效力的行为。其特征是：（1）发生在合同有效成立至履行完毕之前。（2）必须具备一定条件。这一条件可以是当事人约定的，也可以是法律直接规定的。（3）必须通过解除行为而实现。解除行为可以是单方法律行为，也可以是双方法律行为。（4）解除后果是使基于合同发生的债权债务关系消灭。

►合同解除的条件

【分析】合同解除的方式包括单方解除和协议解除。**单方解除**，是指在解除事由出现时，由**享有解除权的**

一方当事人以单方行为解除合同的方式。解除事由由当事人在合同中约定为**约定解除**，由法律直接规定为**法定解除**。同时，《民法典》还对行使**不安抗辩权**和基于**情事变更规则**解除合同作出了规定。

法定解除不必经对方当事人同意。当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，**任何一方当事人**均可以请求**人民法院**或者**仲裁机构**确认解除行为的效力。**当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。**

约定解除，是指**当事人以合同形式约定一方当事人享有解除权**，该当事人行使约定的解除权而导致合同的解除。只要不违反法律强制性规范和公序良俗，当事人可以约定一方当事人解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。**解除权条款既可以在当事人订立合同时约定，也可以在合同订立后另行约定。**

协议解除，是指**当事人通过协商一致解除合同的行为。**

当事人应当在法律规定或者当事人约定的期限内行使解除权，**期限届满当事人不行使的，该权利消灭。**法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起**一年内**不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。

►合同解除的效力

【分析】有效合同被解除后，合同权利义务关系终止。具体表现为：**合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失；合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外；主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。**

四、抵销

【分析】抵销，是指互负债务的双方当事人将两项债务相互充抵，以使双方债务在对等数额内消灭的行为。抵销依其产生根据的不同，可分为**法定抵销与合意抵销**。

法定抵销，是指依法律规定以当事人一方的意思表示所作的抵销。用作抵销的债权称为**主动债权**或**自动债权**，被抵销的债权称为**被动债权**。**法定抵销的构成要件包括：**（1）须双方当事人互负债务、互享债权；（2）须主动债权已届清偿期；（3）须双方债务的标的物种类、品质相同；（4）须不存在根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的情形。抵销权属于**形成权**，享有抵销权的当事人通知对方即可发生抵销后果，**无须对方同意**。当事人主张抵销的，应当通知对方，通知自到达对方时生效；但**抵销不得附条件或者期限**。抵销使当事人双方的债权在**对等数额**内消灭，对于未抵销的债务部分，债务人仍然负有清偿义务。抵销具有**溯力**，溯及抵销权成立之时。

合意抵销，是指**当事人协商一致时，双方的债权债务按对等数额消灭的抵销方式**。合意抵销是当事人意思自治的具体体现。合意抵销的发生条件、法律后果均须遵从当事人的约定，双方的抵销协议只需满足合同的成立及生效要件，不受法定抵销的限制。除当事人有特别约定外，**抵销合同没有溯及既往的效力**。

因侵害自然人人身权益，或者故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务，侵权人无权主张抵销。因侵害自然人人身权益，或者故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务侵权人无权主张抵销。当事人互负债务，一方以其诉讼时效期间已经届满的债权通知对方主张抵销，对方提出诉讼时效抗辩的，不得抵销；一方的债权诉讼时效期间已经届满，对方主张抵销的，可以抵销。

五、提存

【分析】**提存**，是指由于债权人的原因而无法向其交付履行标的物时，债务人将该标的物交付给提存机关以消灭债务的行为。**提存需具备的条件有：**（1）须有因债权人方面的原因使债务人难以履行债务的客观情况发生。根据我国法律规定，这种**客观情况包括：**债权人无正当理由拒绝受领；债权人下落不明；债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人；法律规定的其他情形。（2）须提存的标的物适宜提存。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。债务人将标的物或者将标的物依法拍卖、变卖所得价款交付提存部门时，提存成立。提存成立的，视为债务人在其提存范围内已经交付标的物。（3）须经法定程序进行。

提存的效力在于：提存之日起，债务人与债权人之间的权利义务终止。标的物提存后，**债务人应当及时通知债权人或者债权人的继承人、遗产管理人、监护人、财产代管人**，标的物毁损、灭失的风险由**债权人**承担。提存期间，标的物的**孳息归债权人所有**。提存费用由**债权人**负担。债权人可以**随时**领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人**未履行债务或者提供担保**之前，提存部门根据债务人的要求应当**拒绝其领取提存物**。债权人领取提存物的权利，**自提存之日起五年内不行使而消灭**，**提存物扣除提存费用后归国家所有**。但是，**债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃领取提存物权利的，债务人负担提存费用后有权取回提存物**。

六、免除

【分析】**免除**，是指**债权人以消灭债为目的而向债务人作出的抛弃债权的行为**。免除的对象可以是**部分债务**，也可以是**全部债务**。债权人免除债务人的债务时，须经**债务人同意**，**债务人在合理期限内未拒绝的，即为同意**。可见，免除为**双方、无偿、非要式**民事法律行为。

免除的效力在于，债务全部免除时，主债务与从债务全部消灭；部分免除时，主债务与从债务部分消灭。**债权人仅免除从债务时，主债务不消灭。**

七、混同

【分析】**混同**，是指**债权人和债务人为同一人的事实**。混同**无须以任何人的意思表示为成立要件**，属于法律事实中的**事件**。

混同的成立原因主要有：（1）**概括承受**。概括承受是发生混同的主要原因，如相互有债权债务关系的法人合并为一个法人；如**债权人继承债务人的遗产或者债务人继承债权人的遗产**。（2）**特定承受**。这是指**债务人受让债权人的债权、债权人承受债务人的债务**。

混同的效力在于**绝对地消灭合同关系及因合同所生的从债权和从债务**。但债权和债务同归于一人而债权债务终止**损害第三人利益的，则不发生混同的效力**。

除上述六种原因外，法律规定或者当事人约定的其他情形，如**当事人死亡、解除条件成就、终期届至等**，也可导致合同终止。

第八节 违约责任

一、违约责任的概念和特征

【分析】**违约责任**，是指**当事人不履行或不适当履行合同义务而应承担的民事责任**。

违约责任具有以下特征：（1）属于民事责任。（2）具有相对性。违约责任的相对性是由合同的相对性决定的。一方面，违约责任是**违反合同的一方当事人**承担的责任；另一方面，**合同当事人对于自己一方因第三人的原因造成的违约应承担责任**，其和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。（3）是**当事人不履行**合同债务而产生的责任。（4）是一种财产性的民事责任。（5）具有一定的任意性。根据合同自由原则，违约责任可由当事人在法定范围内约定。

二、违约责任的归责原则

【分析】归责原则是确定行为人承担民事责任的根据和准则，其贯穿于整个民事责任制度并对责任规范起着统率作用。

我国民法中违约责任的归责原则为严格责任原则。根据《民法典》合同编规定，只要当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，就应承担违约责任。当然，《民法典》合同编“典型合同”对有名合同违约的归责原则有特别规定的，应当优先适用该规定。

三、违约责任的构成要件及免责事由

【分析】**违约责任的构成要件**主要包括：（1）当事人之间存在有效合同。（2）客观上有违约行为。违约行为的主要表现有二。其一是不履行，包括**实际不履行**和**预期违约行为**。前者是指在合同履行期**届满之时仍然没有履行**，后者是指在合同履行期**届满之前明确表示或者以行为表明将不履行合同**。其二是**不当履行**，即当事人虽有履行合同义务的行为，但**履行不符合合同的要求**。（3）不存在免责事由。

免责事由又称**免责条件**，是指当事人即使违约也不承担责任的情况。根据我国法律规定，违约责任的免责事由有两大类：（1）法定的免责事由，即由法律直接规定的、无须当事人约定即可援用的免责事由。法定的免责事由可分为两种：①**一般的法定免责事由**。这是指适用于所有合同的违约责任的法定免责事由，通常指**不可抗力**。②**特殊的法定免责事由**。这是指由法律特别规定的只适用于个别合同的违约责任免责事由。如依《民法典》第823条的规定，在客运合同中，**承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担赔偿责任；但是，伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外**。此处的旅客自身健康原因、旅客故意或重大过失就属于特殊的法定免责事由。（2）**约定的免责事由**，即当事人在合同中约定的违约方免于承担违约责任的条件。当事人关于免责事由的约定**不得违反法律、国家政策和公共利益，不得违背公序良俗**。

由于承担违约责任的方式不同，在适用某些责任方式时，除以上三要件之外，还应具备其他一些法定或约定条件。

四、违约责任的承担方式

【分析】违约责任的承担方式主要包括：

1. 继续履行。继续履行，是指**在合同债务人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件时，债权人要求违约方继续按照合同的约定履行义务**。作为违约责任形式，继续履行是实际履行的延伸和补充，其内容是强制违约方按照合同约定交付标的。**我国采用继续履行为主、赔偿为辅的救济原则。**

由于债务性质不同，继续履行在适用时亦有所不同，具体而言：（1）违反金钱债务的，**应继续履行**。金钱债务不存在履行不能的问题。（2）违反非金钱债务的，除特殊情况外，原则上应继续履行。但有下列情形之一的除外：①**法律上或者事实上不能履行**；②**债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高**；③**债权人在合理期限内未请求履行**。由于上述不能继续履行非金钱债务的情形致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构

可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。

此外，当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。

2. 采取补救措施。补救措施是指继续履行、赔偿损失、支付违约金等之外的补救方法。如恢复原状、修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬。采取补救措施后对方还有其他损失的，违约方还应对损失予以赔偿。

3. 支付违约金。违约金是指依据法律规定或者当事人的约定，一方不履行或不适当履行合同时应当根据违约情况向对方支付的一定数额的金钱。根据我国法律规定，违约金只在当事人有约定时才适用。违约金与损失赔偿之间的关系是：约定的违约金低于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为过分高于造成的损失。恶意违约的当事人一方请求减少违约金的，人民法院一般不予支持。违约金与继续履行的关系是：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

4. 适用定金罚则。定金是指为担保合同的履行，由当事人一方在合同订立时或者订立后至履行前给付给对方的一定数额的金钱或替代物。

定金的特征在于：定金属于约定担保方式，当事人可以约定定金数额，但不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额；定金属于金钱担保，具有多重效力；定金合同是实践性合同，自实际交付定金之日起成立；定金具有从属性，主合同不成立或者无效，定金随之不成立或者无效。

定金的效力有四：（1）担保债务履行。定金是通过违约方适用定金罚则而起到合同担保作用的。定金罚则的基本规则是：给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。当事人一方不完全履行合同的，应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例，适用定金罚则。（2）证明合同成立。定金的交付本身可以视为合同成立的证据。（3）解除合同的条件。当事人约定定金性质为解约定金，交付定金的一方有权主张以丧失定金为代价解除合同，收受定金的一方也有权主张以双倍返还定金为代价解除合同。（4）预先给付。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。

定金不同于预付款，定金是一种担保方式，预付款是一种支付手段，二者的效力不同；同时，定金有制裁功能，预付款无此功能。

违约金与定金的关系是：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款；定金不足以弥补一方违约造成的损失，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

5. 赔偿损失。赔偿损失是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约方的违约行为而遭受损失的责任形式。承担赔偿责任的责任除应具备违约责任的必要条件外，还必须要有违约行为造成对方财产损失的事实。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿；当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任；当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。债务人按照约定履行债务，债权人无正当理由拒绝受领的，债务人可以请求债权人赔偿增加的费用；在债权人受领迟延期间，债务人无须支付利息。

五、违约责任与侵权责任的竞合

【分析】违约责任与侵权责任的竞合，是指行为人实施的某一违法行为，同时违反了合同规范和侵权规范，并符合违约责任和侵权责任的构成要件，导致违约责任与侵权责任同时产生，又互相排斥、彼此不能包容的法律现象。

违约责任与侵权责任竞合的原因主要有：（1）当事人实施了侵权性的违约行为，即侵权行为直接构成违约的原因。如保管合同中的保管人非法使用保管物而致保管物毁损灭失。（2）当事人实施了违约性的侵权行为，即违约行为造成了侵权的后果。如卖方交付的货物有瑕疵并因此导致买方财产或人身受损。

根据《民法典》第186条的规定，因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。由于违约责任与侵权责任存在着诸多不同，故受害人选择不同的责任，对其权益的保护有着重大的影响。

第十五章 典型合同

第一节 买卖合同

一、买卖合同的概念和特征

【分析】买卖合同，是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。转移标的物的所有权的一方为出卖人，支付价款的一方为买受人，由出卖人出卖而买受人受领的对象是买卖的标的物。买卖合同的主要特征是：双务合同、有偿合同、不要式合同、诺成合同，其核心在于转移标的物的所有权。

二、买卖合同的效力

【分析】买卖合同的效力，是指生效的买卖合同对双方当事人产生的法律后果，表现为出卖人和买受人享有的权利和承担的义务。此处仅从买卖合同当事人各自所负的义务角度阐述其效力内容。

出卖人的义务主要有：（1）交付标的物。出卖人应当依照合同的约定或法律规定的交付方式、时间、地点、数量、标的物的状况、包装方式等交付标的物。除当事人另有约定外，标的物的从物应随同交付。（2）转移标的物的所有权。关于标的物所有权的转移，根据《民法典》物权编的规定处理。因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任；法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。（3）担保标的物无瑕疵。瑕疵包括质量瑕疵和权利瑕疵。质量瑕疵是指标的物欠缺约定或法定品质。出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依法请求出卖人承担违约责任；当事人约定减轻或者免除出卖人对标的物瑕疵承担的责任，因出卖人故意或者重大过失不告知买受人标的物瑕疵的，出卖人无权主张减轻或者免除责任。权利瑕疵是指第三人对标的物享有权利。除法律另有规定外，出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务；买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担权利瑕疵担保义务。

买受人的义务主要有：（1）支付价款。这是买受人的首要义务，其应当按照双方约定或者法律规定履行该义务。（2）受领标的物。如果出卖人不按合同约定或法律规定交付标的物，买受人有权拒绝受领；出卖人交付的标的物符合约定或法定的条件而买受人拒绝受领的，构成受领迟延。（3）及时检验标的物。若买受人发现标的物不符合约定，可以行使拒收权，但同时应负通知义务、保管义务与紧急情况下的处置义务。买受人违反及时检验标的物的义务的，应承担由此产生的不利后果。出卖人依照买受人的指示向第三人交付标的物，出卖人和买受人约定的检验标准与买受人和第三人约定的检验标准不一致的，以出卖人和买受人约定的检验标准为准。

准。

三、买卖合同中标的物的风险负担和利益承受

【分析】买卖合同中标的物的风险，是指买卖合同的标的物因不可归责于双方当事人的事由毁损、灭失所致的损失。根据《民法典》合同编的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担；当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据相关规定标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人按照约定或者依据相关规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行义务不符合约定，买受人请求其承担违约责任的权利。

买卖合同中的利益承受，是指买卖合同的标的物在合同订立后所产生的孳息的归属。除当事人另有约定外，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。

四、买卖合同的解除

【分析】买卖合同可以基于合同解除的一般规则而解除，但也具有以下特殊性：（1）因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物；因标的物的从物不符合约定解除合同的，解除的效力不及于主物。（2）标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除合同；但是，该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，买受人可以就数物解除合同。（3）出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除合同；出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除合同；买受人如果就其中一批标的物解除合同，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除合同。

五、特殊买卖合同

【分析】除一般买卖合同外，《民法典》合同编还规定了分期付款买卖合同、凭样品买卖合同、试用买卖合同、互易合同等特殊买卖合同。

1. 分期付款买卖合同。分期付款买卖合同，是指双方当事人约定买受人于一定期限内分批支付价款的买卖合同。在分期付款买卖合同中，买受人将应付的总价款在一定期限内至少分三次向出卖人支付。如果买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的1/5，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费。此外，分期付款买卖合同约定出卖人在解除合同时可以扣留已受领价金，出卖人扣留的金额超过标的物使用费以及标的物受损赔偿额，买受人有权请求返还超过部分；当事人对标的物的使用费没有约定的，可以参照当地同类标的物的租

金标准确定。

在分期付款买卖合同中，出卖人须先交付标的物，买受人于受领标的物后分若干次付款，因此，为避免出卖人无法收回价款的风险，当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于出卖人。出卖人对标的物保留的所有权，未经登记，不得对抗善意第三人。当事人约定出卖人保留合同标的物的所有权，在标的物的所有权转移前，买受人有下列情形之一，造成出卖人损害的，除当事人另有约定外，出卖人有权取回标的物：（1）未按照约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付；（2）未按照约定完成特定条件；（3）将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分。出卖人可以与买受人协商取回标的物；协商不成的，可以参照适用担保物权的实现程序。买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人不得主张取回标的物；第三人依法已经善意取得标的物所有权或者其他物权的，出卖人也不得主张取回标的物。在所有权保留情形下，出卖人依照相关规定取回标的物后，买受人在双方约定或者出卖人指定的合理回赎期限内，消除出卖人取回标的物的事由的，可以请求回赎标的物；买受人在回赎期限内没有回赎标的物，出卖人可以以合理价格将标的物出卖给第三人，出卖所得价款扣除买受人未支付的价款以及必要费用后仍有剩余的，应当返还买受人；不足部分由买受人清偿。

2. 凭样品买卖合同。凭样品买卖合同，是指当事人双方约定一定的样品，出卖人交付的货物必须与样品具有相同品质的买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明，出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。合同约定的样品质量与文字说明不一致且发生纠纷时当事人不能达成合意，样品封存后外观和内在品质没有发生变化的，应当以样品为准；外观和内在品质发生变化，或者当事人对是否发生变化有争议而又无法查明的，应当以文字说明为准。此外，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合该种物的通常标准。

3. 试用买卖合同。试用买卖合同，是指根据合同双方当事人的约定，出卖人在合同成立时将标的物交付给买受人试验或检验，并以买受人认可该标的物为生效要件的买卖合同。试用买卖合同的当事人可以约定标的物的试用期限；对试用期限没有约定或者约定不明确，依据法律规定仍不能确定的，由出卖人确定。买受人在试用期内享有选择权。试用买卖合同的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买；试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。试用买卖合同的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的，视为同意购买。存在下列约定内容的，不属于试用买卖合同：（1）约定标的物经过试用或者检验符合一定要求时，买受人应当购买标的物；（2）约定第三人经试验对标的物认可时，买受人应当购买标的物；（3）约定买受人在一定期限内可以调换标的物；（4）约定买受人在一定期限内可以退还标的物。试用买卖合同的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确的，出卖人无权请求买受人支付。标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担。

4. 互易合同。互易合同，是指双方当事人约定相互转移金钱以外的标的物的所有权的合同。互易合同的双方当事人均称为互易人。互易合同中当事人的义务主要有：（1）交付标的物并转移标的物的所有权；（2）对交付的标的物互负瑕疵担保义务；（3）合同中有补足金条款时，负有补足金义务的当事人一方应按照约定支付补足金。

此外，《民法典》合同编还规定了招标投标买卖合同、拍卖合同。但这两种合同主要适用《招标投标法》和《拍卖法》。

第二节 供用电、水、气、热力合同

一、供用电、水、气、热力合同的概念和特征

【分析】供用电、水、气、热力合同，是指一方当事人向对方当事人提供电、水、气热力，对方当事人使用这些能源并支付报酬的合同。

供用电、水、气、热力合同的特征是：（1）合同主体具有特定性。该类合同的标的通常是由供应人专营，而电、水、气、热力的使用人往往是社会公众。（2）合同标的具有垄断经营性。电、水、气、热力一般由国家垄断经营，国家对其价格实行严格控制。（3）债务履行具有持续性。供应人供应电、水、气、热力和使用人支付价款都处于持续状态。（4）合同目的具有公益性。该类合同的主要目的是满足社会公众的生活需要，而不是盈利，故供应人有强制缔约义务，其不能拒绝使用人通常、合理的订立合同要求。

二、供用电合同

【分析】供用电合同，是指供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。供用电合同的履行地点，按照当事人约定；当事人没有约定或者约定不明确的，供电设施的产权分界处为履行地点。

在供用电合同中，供电人的主要义务有：按照国家规定的供电质量标准和约定安全供电的义务；中断供电时按照国家有关规定事先通知的义务；因自然灾害等原因断电时按照国家有关规定及时抢修的义务。用电人的主要义务有：按照国家有关规定和当事人的约定及时支付电费的义务；保持安全、节约和计划用电的义务；供电人有正当理由停电、限电时的配合和协助义务。

供用水、供用气、供用热力合同，参照适用供用电合同的有关规定。

第三节 赠与合同

一、赠与合同的概念和特征

【分析】赠与合同，是指赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。在赠与合同中，转让财产的一方当事人为赠与人，接收财产的一方当事人为受赠人。赠与的财产可以是物，也可以是财产权利。

赠与合同具有以下特征：（1）单务合同。赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务，但该义务不是赠与的对待给付义务。（2）无偿合同。在附负担的赠与中，受赠人的给付与赠与人的给付无对价关系。（3）诺成合同。赠与财产的交付不是合同的成立要件。（4）不要式合同。赠与的财产依法需要办理登记或者其他手续的，应当办理有关手续。

二、赠与合同的效力

【分析】在赠与合同中，赠与人的义务包括：（1）交付赠与财产并转移其权利。赠与人应当依照约定的期限、地点、方式等将赠与物转移给受赠人并转移其权利。经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人可以请求交付；上述应当交付的赠与财产因赠与人故意或者重大过失致使毁损、灭失的，赠与人应当承担赔偿责任。（2）瑕疵担保义务。赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任，但在附义务的赠与中，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限制内承担与出卖人相同的责任。此外，赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担

赔偿责任。

三、赠与合同的特殊终止事由

【分析】赠与合同终止后，赠与合同关系归于消灭，赠与人不再履行赠与义务。赠与合同除可以适用消偿、混同等合同终止的一般事由外，还存在以下特殊终止事由：

1. 赠与人的任意撤销权。赠与人的任意撤销权，是指在赠与合同成立后，赠与人可基于自己的意思任意撤销赠与的权利。根据我国法律规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与，但经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不得任意撤销。

2. 赠与人的法定撤销权。赠与人的法定撤销权，是指在具备法律所规定的撤销原因时，赠与人依法撤销赠与的权利。根据我国法律规定，在下列情形下，赠与人可以自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内撤销赠与：（1）受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；（2）受赠人对赠与人有扶养义务而不履行；（3）受赠人不履行赠与合同约定的义务。同时，因受赠人的违法行为致使赠与人死亡或者丧失民事行为能力的，赠与人的继承人或者法定代理人可以自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内撤销赠与。撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产。

3. 赠与人的穷困抗辩权。赠与人的穷困抗辩权，是指赠与人在经济状况显著恶化时享有的拒绝履行的抗辩权。赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。

第四节 借款合同

一、借款合同的概念和特征

【分析】借款合同，是指借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。在借款合同中，交付借款方为贷款人，接受借款方为借款人。

借款合同的主要特征有：（1）标的物是货币。（2）是转移货币所有权的合同。（3）除自然人之间借款合同外，当事人另有约定或法律另有规定外，一般为要式合同、有偿合同、诺成合同。

二、借款合同的效力

【分析】在借款合同中，贷款人的主要义务是：（1）按期、足额提供贷款的义务。贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。（2）保密义务。贷款人对于其在合同订立和履行阶段所了解的借款人的业务活动和财务状况负有保密义务，不得泄密或进行不正当使用。

借款人的主要义务是：（1）提供真实情况的义务。订立借款合同，借款人应当按照贷款人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情况。（2）按照约定的日期和数额收取借款的义务。贷款人提供借款是为了通过收取利息来实现其盈利目的，故为了避免损害贷款人的合法利益，即便借款人未按照约定的日期、数额收取借款，也应当按照约定的日期、数额支付利息。（3）按照约定用途使用借款的义务。借款人擅自改变借款用途，将增加贷款人的经营风险，故借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。（4）按期支付利息的义务。借款合同一般为有偿合同，借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依据法律规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还

借款时一并支付。我国禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息。（5）按期返还借款的义务。借款入未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前偿还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期；贷款人同意的，可以展期。（6）容忍检查、监督的义务。在当事人双方有约定时，贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表或者其他资料。

三、自然人之间的借款合同

【分析】自然人之间的借款合同属于民间借贷合同，其特征是：（1）双方当事人均为自然人。（2）是否有偿取决于双方的约定。没有约定或约定不明的，视为无偿；如果约定为有偿，则不得违反国家有关规定。（3）是实践性合同。该合同自贷款人提供借款时成立。贷款人提供贷款的情形包括：①以现金支付的，自借款人收到借款时；②以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时；③以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时；④出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时；⑤出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。（4）是不要式合同。

第五节 保证合同

一、保证合同的概念和特征

【分析】保证合同，是指为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。

保证合同的特征包括：（1）从属性。保证合同是主债权债务合同的从合同，以主债权债务合同的成立为前提，因主债权债务合同的消灭而消灭。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。（2）单务性和无偿性。在保证合同中，保证人单方面承担财产性义务或者责任，其不因此从对方获得财产利益，对方也不承担对待给付义务，至于债务人与保证人之间的关系是有偿还是无偿则没有强制性要求。（3）相对独立性。这种独立性体现在保证合同的成立要件和生效要件、保证变更和消灭原因、保证的效力、保证合同的内容等方面。保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。

二、保证合同的效力

【分析】保证合同效力的产生以保证合同成立并且生效为前提。保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务合同中的保证条款。第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。在我国，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

保证合同的效力体现在：（1）在保证人与债权人之间。当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求保证人承担保证责任。除当事人另有约定外，保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的，保证人仍有

权向债权人主张抗辩。债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。同时，一般保证的保证人还享有先诉抗辩权。此外，一般保证的保证人在主债务履行期限届满后，向债权人提供债务人可供执行财产的真实情况，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行的，保证人在其提供可供执行财产的价值范围内不再承担保证责任。（2）在保证人与债务人之间。保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益。

保证合同为担保主债权债务合同而订立，主债权债务合同发生变更对保证合同产生相应影响。具体规则是：第一，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。第二，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。保证人与债权人约定禁止债权转让，债权人未经保证人书面同意转让债权的，保证人对受让人不再承担保证责任。最后，债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，除债权人和保证人另有约定外，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任。第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

三、保证的方式

【分析】保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）人民法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃此项权利。

当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履行债务，也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。

当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。

四、保证期间

【分析】保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，保证期间不是诉讼时效期间，不发生中止、中断和延长。

债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，视为对保证期间约定不明。约债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

在一般保证中，债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日起，开始计算保证债务的诉讼时效。

在连带责任保证中，债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的，从债权人请求保证人承担保证责任之日起，开始计算保证债务

的诉讼时效。

第六节 租赁合同

一、租赁合同的概念和特征

【分析】租赁合同，是指出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。在租赁合同中，将自己的财产提供给对方使用、收益的一方为出租人，使用他人财产并支付租金的一方为承租人。出租人提供给承租人使用的财产为租赁物。租赁物可以是不动产，也可以是动产。租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。

租赁合同的特征表现为：（1）是有期限地转移标的物使用权的合同。租赁合同以承租人取得租赁物的使用、收益为目的，出租人无需向承租人转移标的物的所有权。在我国，租赁期限不得超过二十年，超过二十年的，超过部分无效。（2）是双务合同、有偿合同和诺成合同。（3）合同的标的物为非消耗物。租赁合同终止时，承租人须返还原物，故租赁物应当是特定物、非消耗物。此外，租赁期限六个月以上的应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。

二、租赁合同的效力

【分析】在租赁合同中，出租人的义务包括：（1）按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。（2）保证租赁物上不存在权利瑕疵与质量瑕疵。（3）除当事人另有约定外，负有维修租赁物的义务。承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担法律规定的维修义务。出租人的权利包括：保留租赁物的所有权，收取租金的权利。

承租人的义务包括：（1）按照约定的方法正确使用并妥善保管租赁物。承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损耗的，不承担赔偿责任。（2）未经出租人同意，不得擅自转租租赁物。（3）承租人不得擅自对租赁物进行改善或增设其他设施。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。（4）支付租金。（5）在合同终止时返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。承租人的权利包括：请求出租人交付租赁物，对租赁物进行使用和收益。

三、租赁权物权化

【分析】租赁权物权化，是指为了强化承租人的地位，保护承租人的利益，法律赋予租赁权在一定情形下具有对抗第三人的效力。租赁权物权化是对传统合同之债的相对性原理的突破，“买卖不破租赁”规则是其具体表现。根据我国法律规定，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力；抵押权设立前抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。

四、房屋租赁的特殊规定

►一房多租

【分析】一房多租。出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合

同的，按照下列顺序确定履行合同的承租人：（1）已经合法占有租赁房屋的；（2）已经办理登记备案手续的；（3）合同成立在先的。不能取得租赁房屋的承租人有权依据法律请求解除合同、赔偿损失。

► 转租

【分析】转租。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人，转租期限超过承租人剩余租赁期限的，除出租人与承租人另有约定外，超过部分的约定对出租人不具有法律约束力。出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在六个月内未提出异议的，视为出租人同意转租。

► 优先购买权

【分析】优先购买权。出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人履行通知义务后，承租人在15日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的，应当在拍卖5日前通知承租人。承租人未参加拍卖的，视为放弃优先购买权。出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。但是，出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。

► 优先承租权

【分析】优先承租权。在当事人之间的租赁合同期限届满而租赁关系终止时，出租人再次出租房屋的，原承租人享有在同等条件下优先于其他人承租房屋的权利。

第七节 融资租赁合同

一、融资租赁合同的概念和特征

【分析】融资租赁合同，是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。融资租赁合同集信贷与租赁为一体，涉及三方当事人，即出租人、承租人和出卖人。

融资租赁合同的主要特征是：（1）对合同的当事人有资格限制。出租人为经过有关机关批准有权经营融资租赁业务的法人。（2）承租人向出租人支付的租金并非单纯使用租赁物的代价，而是“融资”的代价。（3）合同的标的物是应承租人的要求购买的，通常是价值较高的固定资产。（4）是双务、有偿、诺成性的要式合同，应当采用书面形式。

二、融资租赁合同的效力

【分析】出租人的权利包括：享有租赁物的所有权；一定条件下的瑕疵担保免责权；风险负担免责权；租赁物造成第三人损害的免责权。出租人的义务包括：购买租赁物并不得擅自变更合同中与承租人有关的内容的义务；交付租赁物的义务；保证承租人占有和使用租赁物的义务；向出卖人付款的义务；协助承租人向出卖人索赔的义务。承租人对出卖人行使索赔权利，不影响其履行支付租金的义务。但是，承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的，承租人可以请求减免相应租金且出租人应对租赁物的瑕疵承担担保责任。

承租人的权利主要有：受领租赁物的权利；对出卖人的直接索赔权；出租人解除合同收回租赁物时的价值返还请求权。承租人的义务主要有：支付租金的义务；妥善保管、使用、维修租赁物的义务；合同终止时返还租赁物的义务。

出卖人的权利主要是向出租人收取货款。出卖人的义务主要有：交付租赁物的义务；瑕疵担保责任。

三、租赁期限届满租赁物的归属

【分析】出租人和承租人可以约定租赁期限届满时租赁物的归属；对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，依据相关规定仍不能确定的，**租赁物的所有权归出租人**。当事人约定租赁期限届满租赁物归承租人所有，承租人已经支付大部分租金，但是无力支付剩余租金，出租人因此解除合同收回租赁物，收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的，承租人可以请求相应返还。当事人约定租赁期限届满租赁物归出租人所有，因租赁物毁损、灭失或者附合、混合于他物致使承租人不能返还的，出租人有权请求承租人给予合理补偿。当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性价款的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人。

融资租赁合同无效，当事人就该情形下租赁物的归属有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还出租人。但是，因承租人原因致使合同无效，出租人不请求返还或者返还后会显著降低租赁物效用的，租赁物的所有权归承租人，由承租人给予出租人合理补偿。

第八节 保理合同

一、保理合同的概念和特征

【分析】保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同。

保理合同的主要特征是：（1）保理人须取得保理业务的资质。（2）是要式合同，应当采用书面形式。（3）是有偿合同、双务合同、诺成合同。

保理合同的内容一般包括业务类型、服务范围、服务期限、基础交易合同情况、应收账款信息、保理融资款或者服务报酬及其支付方式等条款。

二、保理合同的效力

【分析】在保理合同中，保理人的权利与义务有：保理人向应收账款债务人发出应收账款转让通知的，应当表明保理人身份并附有必要凭证。当事人约定有追索权保理的，保理人可以向应收账款债权人主张返还保理融资款本息或者回购应收账款债权，也可以向应收账款债务人主张应收账款债权。保理人向应收账款债务人主张应收账款债权，在扣除保理融资款本息和相关费用后有剩余的，剩余部分应当返还给应收账款债权人。当事人约定无追索权保理的，保理人应当向应收账款债务人主张应收账款债权，保理人取得超过保理融资款本息和相关费用的部分，无需向应收账款债权人返还。

应收账款债权人的义务主要有：应收账款债权人与债务人虚构应收账款作为转让标的，与保理人订立保理合同的，除保理人明知虚构外，应收账款债务人不得以应收账款不存在为由对抗保理人。应收账款债务人接到应收账款转让通知后，应收账款债权人与债务人无正当理由协商变更或者终止基础交易合同，对保理人产生不利影响的，对保理人不发生效力。

三、保理人债权实现的顺序

【分析】应收账款债权人就同一应收账款订立多个保理合同，致使多个保理人主张权利的，已经登记的先于未登记的取得应收账款；均已经登记的，按照登记时间的先后顺序取得应收账款；均未登记的，由最先到达

应收账款债务人的转让通知中载明的保理人取得应收账款；既未登记也未通知的，按照保理融资款或者服务报酬的比例取得应收账款。

第九节 承揽合同

一、承揽合同的概念和特征

【分析】**承揽合同**，是指**承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同**。完成工作交付成果的一方为**承揽人**，接受工作成果并给付报酬的一方为**定作人**。承揽包括**加工、定作、修理、复制、测试、检验**等工作。

承揽合同的主要特征是：（1）以完成一定工作为目的。（2）标的物为承揽人应向定作人交付的工作成果。承揽人必须根据定作人的要求完成工作成果，故该工作成果具有了**特定性**。（3）**承揽人的义务具有不可让与性**。承揽人应当以自己的设备、技术等独立完成工作成果，一般情况下不能将承揽的工作交由第三人完成，故承揽人一般不得将自己的义务移转给他人承担。（4）**承揽合同是双务、有偿、诺成的不要式合同**。

二、承揽合同的效力

【分析】在承揽合同中，**承揽人的义务主要包括：**（1）以自己的设备、技术和劳力完成主要工作并按期交付工作成果。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果**向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同**。（2）对完成的工作成果负瑕疵担保义务和保管义务。（3）按约定提供材料或者妥善处理定作人提供的材料。（4）接受定作人必要的监督、检查。（5）按定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。**承揽人的主要权利是报酬请求权及符合法定条件时的留置权**。

定作人的义务主要有：（1）依约定提供材料。（2）承揽工作需要定作人协助的，应当对承揽人进行协助。（3）按时接收、验收承揽人交付的工作成果。（4）按约定的期限和方式向承揽人支付报酬。**定作人的主要权利是监督承揽人工作，请求承揽人交付工作成果**。

此外，除当事人另有约定外，共同承揽人应当对定作人承担**连带责任**。**定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失**。

三、承揽人的留置权

【分析】在承揽合同中，除当事人另有约定外，定作人未向承揽人**支付报酬或者材料费等价款的**，承揽人对完成的工作成果**享有留置权或者有权拒绝交付**。留置权是**法定担保物权**，无须双方当事人在承揽合同中作出特别约定，**但双方当事人可以约定排除承揽人的留置权**。

第十节 建设工程合同

一、建设工程合同的概念和特征

【分析】**建设工程合同**，是指**建设工程的发包方为完成工程建设任务，与承包人签订的约定由承包人按照发包方的要求完成工作并交付建设工程，由发包人支付价款的合同**，包括工程勘察、设计和施工合同。在建设工程合同中，勘察、设计、施工单位一方为**承包方**，建设单位一方为**发包方**。

建设工程合同的主要特征是：（1）主体具有限定性。承包人必须是经过批准的具有相应资质的单位。（2）标的具有特殊性，为基本建设工程。（3）合同管理具有严格性。建设工程合同的订立与履行受到国家的严格管理和监督。（4）形式具有要式性。建设工程合同必须采用书面形式。（5）是双务合同、有偿合同和诺成合同。

二、建设工程合同的订立

【分析】建设工程合同的订立必须遵守国家规定的程序，原则上应采取招标投标的方式。建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。在建设工程合同中，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；禁止分包单位将其承包的工程再分包；建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。

三、建设工程合同的效力

【分析】在勘察、设计合同中，发包人的主要义务是：（1）按照约定，全面、准确、及时地提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件。（2）按照约定向勘察、设计人支付勘察、设计费。（3）维护勘察、设计成果。承包人的主要义务是：（1）按照约定按期完成勘察、设计工作，向发包人提交勘察、设计成果，并对勘察、设计成果负瑕疵担保责任。（2）按照约定完成协作事项。

在施工合同中，发包人的主要义务是：（1）做好施工前的准备工作，按照约定提供材料、设备、施工场地、建设资金、技术资料等。（2）为承包人提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。（3）组织工程验收。

（4）接收建设工程并依约定支付工程价款。承包人的主要义务是：（1）按时开工和按要求施工。（2）接受发包人的必要监督。（3）按期按质完工并交付建设工程。（4）对建设工程合理使用期限内的质量安全负担保证责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

四、建设工程合同无效与验收不合格的处理

【分析】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

五、建设工程承包人的优先受偿权

【分析】在建设工程合同中，如果发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

第十一节 运输合同

一、运输合同的概念和特征

【分析】运输合同又称运送合同，是指承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。运输合同分为客运合同、货运合同和多式联运合同。在运输合同中，

承担运送旅客及其行李或货物的当事人一方为**承运人或运送人**，与承运人订立运输合同的当事人一方为**旅客或托运人**，承运人所运输的货物为**运送物**。

运输合同的特征是：（1）标的是承运人的运输行为。承运人的工作是运送旅客或货物至目的地。（2）是**双务合同和有偿合同**。运输合同的双方当事人承担的义务互为条件。同时，承运人从事运输业务的目的是获得收益，旅客或托运人、收货人应向承运人支付对价。（3）一般为诺成合同。（4）通常是格式合同。由于承运人要与不特定的人随时订立运输合同，为了快捷方便，事先拟定格式条款成为通例，合同形式多采用票证式和表格式。（5）**承运人一般负有强制缔约义务。从事公共运输的承运人不得拒绝旅客、托运人通常、合理的运输要求。**

二、客运合同

【分析】客运合同是**旅客运输合同**的简称，是指**承运人将旅客及其行李运送至约定地点，旅客依照约定支付票款的合同**。除当事人另有约定或者另有交易习惯外，**客运合同自承运人向旅客出具客票时成立**。

在客运合同中，**承运人的义务包括：**（1）严格履行安全运输义务，及时告知旅客安全运输应当注意的事项。（2）按照有效客票记载的时间、班次和座位号运输旅客。（3）尽力救助患有急病、分娩、遇险的旅客。（4）**保证旅客人身安全**。在运输过程中旅客伤亡的，无论是持正常客票的旅客，还是按规定免票、持优待票或经承运人许可搭乘的无票旅客，**除伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的以外，承运人均应承担赔偿责任**。（5）**保证旅客行李安全**。在运输过程中旅客**随身携带物品**毁损、灭失，承运人**有过错的**，应当承担**赔偿责任**。如毁损、灭失的是旅客托运的**行李**，承运人应当**按照货物运输的有关规定承担责任**。

旅客的主要义务是：（1）支付票款。（2）持有效客票，按客票记载的时间、班次和座位号乘坐。**实名制**客运合同的旅客丢失客票的，可以请求承运人**挂失补办**，承运人**不得再次收取票款和其他不合理费用**。（3）**遵守安全事项，按限量和品类携带行李，不得携带危险或违禁物品**。（4）**协助义务**。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应当积极协助和配合。

三、货运合同

【分析】货运合同即货物运输合同，是指承运人将托运人交付运送的货物运送到约定地点，托运人或收货人依照约定支付运费的合同。

在货运合同中，**托运人的主要义务包括：**（1）如实申报托运的货物。（2）按照约定交付托运的货物，并在货物运输需要办理审批、检验等手续时将办理完有关手续的文件提交承运人。（3）按照规定支付包括运费在内的相关费用。（4）按照约定的方式**包装**货物。

承运人的主要义务包括：（1）按照合同的约定接受托运人托运的货物并交付运输单证。（2）遵从托运人中止运输、返还货物、变更到达地点或者将货物交给其他收货人的有关要求。（3）通知收货人或托运人并交付货物。（4）安全运送货物。若货物在运输途中毁损、灭失，承运人应承担赔偿责任，**除非承运人能够证明货物的毁损、灭失是由不可抗力、货物本身的自然性质或合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的**。

除法律另有规定外，**货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还**。托运人或者收货人不支付**运费、保管费或者其他费用**的，除当事人另有约定外，承运人对相应的运输货物享有**留置权**。**收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运人依法可以提存货物**。

四、多式联运合同

【分析】多式联运合同，是指两个或两个以上的承运人以不同的运输方式将旅客及其行李或货物运送至约定地点的运输合同。

多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。多式联运经营人可以参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任；但是，该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联运单据；按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担赔偿责任。货物的毁损、灭失发生于多式联运的某一运输区段的，多式联运经营人的赔偿责任和责任限额，适用调整该区段运输方式的有关法律规定；货物毁损、灭失发生的运输区段不能确定的，依照《民法典》关于运输合同的规定承担赔偿责任。

第十二节 技术合同

一、技术合同的概念和类型

【分析】技术合同，是指当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同包括技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同和技术服务合同。

二、技术开发合同

► 技术开发合同的概念

【分析】技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。该合同的客体是尚不存在的、有待开发的技术成果。

技术开发合同应当采用书面形式。

► 技术开发合同的类型

【分析】技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。

► 技术开发合同的效力

【分析】在委托开发合同中，委托人的主要义务是按照约定支付研究开发经费和报酬，提供技术资料，提出研究开发要求，完成协作事项，接受研究开发成果。研究开发人的主要义务是按照约定制定和实施研究开发计划，合理使用研究开发经费，按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果。委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

在合作开发合同中，当事人应当按照约定进行投资，包括以技术进行投资，分工参与研究开发工作，协作配合研究开发工作。除当事人另有约定外，合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，

另一方或者其他各方不得申请专利。

委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及收益的分配办法，由当事人约定；没有约定或者约定不明确，依据法律规定仍不能确定的，在没有相同技术方案被授予专利权前，当事人均有使用和转让的权利。但是，委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。

三、技术转让合同和技术许可合同

►技术转让合同的概念、类型和效力

【分析】技术转让合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同。技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。技术转让合同中关于提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定，属于合同的组成部分。

技术转让合同应当采用书面形式。

在专利权转让合同中，让与人的主要义务是依合同的约定将专利权以及与该专利权有关的技术资料移交给受让方并向受让方提供必要的技术指导；受让人的主要义务是依合同约定支付价款。

在专利申请权转让合同中，让与人的主要义务是依约定将申请专利的权利移交给受让方，同时提供申请专利和实施发明创造所需要的技术情报和资料；受让人的基本义务是依合同约定支付价款。

在技术秘密转让合同中，让与人的主要义务是按照约定提供技术资料，进行技术指导保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。受让人的主要义务是按照约定使用技术，支付转让费，承担保密义务。

►技术许可合同的概念、类型和效力

【分析】技术许可合同是合法拥有技术的权利人，将现有特定的专利、技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同。技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。技术许可合同中关于提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定，属于合同的组成部分。

技术许可合同应当采用书面形式。

在专利实施许可合同中，许可人的主要义务是按照约定许可被许可人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。被许可人的主要义务是按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利，并按照约定支付使用费。

在技术秘密使用许可合同中，许可人的主要义务是按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。被许可人的主要义务是按照约定使用技术，支付使用费，承担保密义务。

技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标。

四、技术咨询合同和技术服务合同

►技术咨询合同的概念和效力

【分析】技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。

在技术咨询合同中，委托人应当按照约定阐明咨询的问题，提供技术背景材料及有关技术资料，接受受托人的工作成果，支付报酬。受托人应当按照约定的期限完成咨询报告或者解答问题，提出的咨询报告应当达到约定的要求。

对于技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，除当事人

另有约定外，由委托人承担。

► 技术服务合同的概念和效力

【分析】技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同，不包括承揽合同和建设工程合同。

在技术服务合同中，委托人应当按照约定提供工作条件，完成配合事项，接受工作成果并支付报酬。受托人应当按照约定完成服务项目，解决技术问题，保证工作质量，并传授解决技术问题的知识。

技术咨询合同和技术服务合同对受托人正常开展工作所需费用的负担没有约定或者约定不明确的，由受托人负担。

技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。如果当事人对此另有约定的，则按照约定处理。

第十三节 保管合同

一、保管合同的概念和特征

【分析】保管合同，是指保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。保管合同中将物品交付他人保管的当事人为寄存人；保管寄存人交付的物品的当事人为保管人；保管人保管的物品为保管物。寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动，将物品存放在指定场所的，视为保管，但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。

保管合同的主要特征是：（1）原则上是实践性合同。除当事人另有约定外，保管合同自保管物交付时成立。（2）是否有偿由当事人约定，没有约定或者约定不明确，依照交易习惯也无法确定时，视为无偿保管。（3）以保管行为为标的。保管合同属于劳务合同的一种，保管合同的劳务为保管寄存物。（4）是不要式合同。

二、保管合同的效力

【分析】在保管合同中，保管人的义务主要有：（1）给付保管凭证。寄存人向保管人交付保管物的，除另有交易习惯外，保管人应当出具保管凭证。（2）妥善保管保管物。当事人可以约定保管场所或者方法；除紧急情况或者为维护寄存人利益外，不得擅自改变保管场所或者方法。保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任；但是，无偿保管人证明自己没有故意或者重大过失的，不承担赔偿责任。（3）亲自履行保管义务。除当事人另有约定外，保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，也不得将保管物转交第三人保管。保管人将保管物转交第三人保管，对保管物造成损失的，应当承担赔偿责任。（4）在第三人主张权利时有通知义务。第三人对保管物主张权利的，除依法对保管物采取保全或者执行措施外，保管人应当履行向寄存人返还保管物的义务。第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的，保管人应当及时通知寄存人。（5）返还保管物，包括原物和孳息。保管期限届满或者寄存人提前领取保管物的，保管人应当将保管物归还寄存人。保管货币的，可以返还相同种类、数量的货币；保管其他可替代物的，可以按照约定返还相同种类、品质、数量的物品。

寄存人的主要义务有：（1）负担必要费用和支付保管费。若双方当事人未另行约定，寄存人应偿付保管人为保管寄存物支出的必要费用，该必要费用以能维持寄存物原状为准。在有偿的保管合同中，寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。除当事人另有约定外，寄存人未按照约定支付保管费或者其他费用的，保管人对保管物享有留置权。（2）告知义务。寄存人交付的保管物有瑕疵或者根据保管物的性质需要采取特殊保管措施的，

寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知，致使保管物受损失的，保管人不承担赔偿责任；保管人因此受损失的，除保管人知道或者应当知道且未采取补救措施外，寄存人应当承担赔偿责任。（3）声明义务。寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的，应当向保管人声明，由保管人验收或者封存；寄存人未声明的，该物品毁损、灭失后，保管人可以按照一般物品予以赔偿。

第十四节 仓储合同

一、仓储合同的概念和特征

【分析】仓储合同又称仓储保管合同，是指双方当事人约定由保管人为存货人储存保管货物，存货人为此支付仓储费的合同。仓储合同中将货物交付他方储存并支付仓储费的当事人为存货人；为他人堆藏、保管货物的当事人为保管人、仓管人；用以堆藏和保管物品的工作物称为仓库；仓管人堆藏和保管的货物称为仓储物。仓储合同源于保管合同，在法律对仓储合同未设特别规定时，适用保管合同的有关规定。

仓储合同的主要特征是：（1）保管人须为专门从事仓储保管业务的人。（2）标的是保管行为。（3）是双务、有偿、诺成的不要式合同。

二、仓储合同的效力

【分析】在仓储合同中，保管人的主要义务有：（1）按合同的约定接收存货人交付的货物。（2）出具仓单、入库单。（3）妥善保管仓储物。储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。因仓储物本身的自然性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担赔偿责任。（4）接受检查。保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，应当同意其检查仓储物或者提取样品。（5）危险通知。保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏的，应当及时通知存货人或者仓单持有人。（6）返还仓储物。

存货人的主要义务有：（1）交付仓储物。储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或者易变质物品的，存货人应当说明该物品的性质，提供有关资料，否则，保管人可以拒收仓储物，也可以采取相应措施以避免损失的发生，因此产生的费用由存货人负担。（2）支付仓储费和必要费用。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。（3）提取仓储物。当事人对储存期限没有约定或者约定不明确的，存货人或者仓单持有人可以随时提取仓储物，保管人也可以随时请求存货人或者仓单持有人提取仓储物，但是应当给予必要的准备时间。储存期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取；逾期不提取的，保管人可以提存仓储物。

第十五节 委托合同

一、委托合同的概念和特征

【分析】委托合同又称委任合同，是指委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。

委托合同的主要特征是：（1）受托人可以以委托人的名义，也可以以自己的名义对外进行活动。（2）合同的订立在委托人和受托人彼此信任的基础之上，双方当事人均享有单方解除合同的权利。（3）标的为受托人提供的劳务。（4）是双务、诺成、不要式合同。（5）可以有偿合同，也可以是无偿合同。

二、委托合同的效力

【分析】在委托合同中，委托人的义务是：（1）偿付费用及支付报酬。（2）清偿受托人因处理委托事务产生的债务。（3）赔偿损失。受托人在处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人应当向受托人赔偿损失。

受托人的义务是：（1）亲自处理委托事务。（2）报告义务。（3）按照委托人的指示处理委托事务。（4）交付财产、转移权利给委托人。

委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，除当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的外，委托合同终止。因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。因受托人死亡、丧失民事行为能力或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止的，受托人的继承人、遗产管理人、法定代理人或者清算人应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人作出善后处理之前，受托人的继承人、遗产管理人、法定代理人或者清算人应当采取必要措施。

三、间接代理制度

【分析】间接代理，是指代理人以自己的名义从事代理活动，该代理活动的法律效果间接归属于本人的代理制度。

►委托人的自动介入

【分析】受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，即此时委托人自动介入受托人与第三人订立的合同关系中，取代受托人的合同当事人地位。当然，在有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人时，不发生委托人自动介入受托人和第三人之间的合同关系的后果。

►委托人的介入权

【分析】委托人的介入权，是指当受托人因第三人的原因对委托人不履行义务时，受托人应当向委托人披露第三人，以便委托人介入受托人与第三人之间的合同关系而直接向第三人主张权利。确认委托人的介入权制度是为了提高权利救济效率，维护委托人的利益。委托人的介入权的行使需要具备以下条件：（1）受托人以自己的名义与第三人订立合同；（2）第三人在订立合同时，不知道受托人和委托人之间存在代理关系；（3）受托人因第三人的原因对委托人不履行义务；（4）受托人在因第三人的原因对委托人不履行义务时，向委托人披露了第三人；（5）不存在“第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同”的情形。在委托人行使介入权时，第三人可以向委托人主张其对受托人的抗辩。

►第三人的选择权

【分析】第三人的选择权，是指当受托人因委托人的原因对第三人不履行义务时，受托人向第三人披露委托人，第三人因此可以选择委托人或者受托人作为相对人主张权利。第三人的选择权的行使需要具备以下条件：（1）受托人以自己的名义与第三人订立合同；（2）第三人在订立合同时，不知道受托人和委托人之间存在代理关系；（3）受托人因委托人的原因对第三人不履行义务；（4）受托人向第三人披露了委托人。第三人可以在受托人和委托人中选择一方作为相对人主张权利，但不能同时选择受托人和委托人为共同相对人。第三人在选择后不得变更选定的相对人。第三人选定委托人作为其相对人的，委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。

第十六节 物业服务合同

一、物业服务合同的概念和特征

【分析】物业服务合同，是指物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。

物业服务合同的主要特征是：（1）主体地位平等，相互之间没有隶属关系。（2）作为合同一方当事人的物业服务人包括物业服务企业和其他管理人。（3）是以劳务为标的的合同。（4）是双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同。

二、物业服务合同的效力

【分析】在物业服务合同中，物业服务人的主要义务是：（1）亲自提供物业服务。物业服务人将物业服务区域内的部分专项服务事项委托给专业性服务组织或者其他第三人的，应当就该部分专项服务事项向业主负责。物业服务人不得将其应当提供的全部物业服务转委托给第三人，或者将全部物业服务支解后分别转委托给第三人。（2）妥善提供物业服务。物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。（3）对物业服务区域内的违法行为采取合理措施。对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。（4）报告义务。物业服务人应当定期将服务的事项、负责人员、质量要求、收费项目、收费标准、履行情况，以及维修资金使用情况、业主共有部分的经营与收益情况等以合理方式向业主公开并向业主大会、业主委员会报告。（5）后合同义务。物业服务合同终止的，原物业服务人应当在约定期限或者合理期限内退出物业服务区域，将物业服务用房、相关设施、物业服务所必需的相关资料等交还给业主委员会、决定自行管理的业主或者其指定的人，配合新物业服务人做好交接工作，并如实告知物业的使用和管理状况。原物业服务人违反此项义务的，不得请求业主支付物业服务合同终止后的物业费；造成业主损失的，应当赔偿损失。物业服务合同终止后，在业主或者业主大会选聘的新物业服务人或者决定自行管理的业主接管前，原物业服务人应当继续处理物业服务事项，并可以请求业主支付该期间的物业费。

业主的主要义务是：（1）支付物业费。业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。（2）告知义务。业主装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务人，遵守物业服务人提示的合理注意事项，并配合其进行必要的现场检查。业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的，应当及时将相关情况告知物业服务人。业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。决定解聘的，应当提前六十日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。依据前述规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。

物业服务期限届满前，业主依法共同决定续聘的，应当与原物业服务人在合同期限届满前续订物业服务合同；物业服务人不同意续聘的，应当在合同期限届满前九十日书面通知业主或者业主委员会，但是合同对通知期限另有约定的除外。物业服务期限届满后，业主没有依法作出续聘或者另聘物业服务人的决定，物业服务人继续提供物业服务的，原物业服务合同继续有效，但是服务期限为不定期。对不定期物业服务合同当事人可以随时解除，但是应当提前六十日书面通知对方。

第十七节 行纪合同

一、行纪合同的概念和特征

【分析】行纪合同，是指行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。行纪合同是一种特殊的委托合同，在法律对行纪合同未设特别规定时，参照适用委托合同的有关规定。

行纪合同的主要特征是：（1）行纪人是以自己的名义办理行纪事务的，并且行纪人仅限于经过审查、登记可从事贸易活动的主体。（2）行纪人为委托人办理的事务仅限于商品的寄售、购销等贸易活动。（3）是双务、有偿、诺成的不要式合同。

二、行纪合同的效力

【分析】在行纪合同中，行纪人的义务包括：（1）依委托人的指示从事贸易活动。（2）负担交易费用。（3）直接履行与第三人签订的合同。（4）保管并合理处分委托物。（5）报告和移交交易所得。行纪人的权利包括：请求支付报酬，特定情况下享有介入权、提存权、处分权及留置权。

第十八节 中介合同

一、中介合同的概念和特征

【分析】中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

中介合同的主要特征是：（1）内容是为委托人报告订约机会或者提供订约媒介服务。（2）委托人的给付义务具有不确定性。委托人虽负有给付报酬义务，但只有中介人促成合同成立的，才可要求委托人支付报酬。（3）是诺成合同、不要式合同。

二、中介合同的效力

【分析】在中介合同中，委托人的主要义务就是支付报酬。中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人平均负担中介人的报酬。委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。

中介人的主要义务和权利有：（1）如实报告义务。中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。（2）负担中介活动的费用。中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担。（3）请求委托人支付中介活动费用的权利。中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬；但是，可以按照约定请求委托人支付从事中介活动支出的必要费用。

第十九节 合伙合同

一、合伙合同的特征

【分析】合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。

合伙合同的主要特征是：（1）合伙人数至少为两人。（2）合伙人必须共同出资。（3）合伙人必须有共同的事业目的。（4）合伙人之间负连带责任。

二、合伙合同的效力

【分析】在合伙合同中，合伙人的义务有：（1）履行出资义务。合伙人应当按照约定的出资方式、数额和缴付期限，履行出资义务。（2）不得请求分割合伙财产。合伙人的出资、因合伙事务依法取得的收益和其他财产，属于合伙财产。合伙合同终止前，合伙人不得请求分割合伙财产。（3）不得请求支付报酬。除合伙合同另有约定外，合伙人不得因执行合伙事务而请求支付报酬。

合伙人的权利有：（1）追偿权。合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。（2）转让财产份额权。除合伙合同另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其全部或者部分财产份额的，须经其他合伙人一致同意。（3）对合伙事务作出决定权。合伙人就合伙事务作出决定的，除合伙合同另有约定外，应当经全体合伙人一致同意。（4）对合伙事务的执行权或监督执行权。合伙事务由全体合伙人共同执行。按照合伙合同的约定或者全体合伙人的决定，可以委托一个或者数个合伙人执行合伙事务；其他合伙人不再执行合伙事务，但是有权监督执行情况。合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议；提出异议后，其他合伙人应当暂停该项事务的执行。（5）利益分配、亏损分担请求权。合伙的利润分配和亏损分担，按照合伙合同的约定办理；合伙合同没有约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。

三、合伙期限

【分析】合伙人对合伙期限没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的，视为不定期合伙。

合伙期限届满，合伙人继续执行合伙事务，其他合伙人没有提出异议的，原合伙合同继续有效，但是合伙期限为不定期。

四、合伙合同的终止

【分析】合伙合同终止的情形有：（1）合伙人可以随时解除不定期合伙合同，但是应当在合理期限之前通知其他合伙人。（2）合伙人死亡、丧失民事行为能力或者终止的，合伙合同终止；但是，合伙合同另有约定或者根据合伙事务的性质不宜终止的除外。

第十六章 准合同

第一节 无因管理

一、无因管理的概念

【分析】无因管理，是指没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或者服务的行为。法学通说认为，无因管理为事实行为。

二、无因管理之债的构成要件

【分析】无因管理的构成要件包括：

1. 管理他人事务。他人事务是指有关人们生活利益的一切事项，可以是有关财产的也可以是非财产性的，但不包括公益事业。管理是指处理事务的行为，包括事实行为和民事法律行为。但并非对所有事务的管理均会构成无因管理。管理下列事务的，一般不发生无因管理：违法或者违背社会公德的行为；纯粹道义上、宗教上或一般生活事务；依法须由本人亲自实施或须经本人授权才能实施的行为。

2. 有为他人谋利益的意思。这是无因管理成立的主观要件，也是无因管理阻却违法性的根本原因。该意思无须表示，只要管理行为在客观上避免了他人利益受损且管理人不纯粹是出于为自己谋利的目的，就构成无因管理行为，即使管理人主观上有为自己的动机且在客观上使自己同时受益，仍不影响无因管理的成立。

3. 没有法定的和约定的义务。在无因管理中，管理人管理他人事务时没有法定义务和约定义务。有无法定义务和约定义务应当以管理人开始管理时的客观事实而定。

三、无因管理之债的效力

【分析】无因管理一经成立，当事人之间即形成债的关系，管理人可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。管理事务不符合受益人真实意思的，管理人不享有上述权利；但是，受益人的真实意思违反法律或者违背公序良俗的除外。管理人管理事务不属于为避免他人利益受损失而管理他人事务的情形，但是受益人享有管理利益的，受益人应当在其获得的利益范围内向管理人承担义务。

管理人管理他人事务，应当采取有利于受益人的方法；中断管理对受益人不利的，无正当理由不得中断。管理人管理他人事务，能够通知受益人的，应当及时通知受益人；管理的事务不需要紧急处理的，应当等待受益人的指示。

管理结束后，管理人应当向受益人报告管理事务的情况。管理人管理事务取得的财产，应当及时转交给受益人。管理人管理事务经受益人事后追认的，从管理事务开始时起，适用委托合同的有关规定，但是管理人另有意思表示的除外。

第二节 不当得利

一、不当得利的概念

【分析】不当得利，是指一方没有法律根据取得不当利益而使另一方财产受损的事实。通说认为，不当得利属于事件。

二、不当得利之债的构成要件和类型

【分析】不当得利之债的构成要件包括：

1. 一方获得利益。即一方的财产增加。财产的增加包括积极增加与消极增加。前者是指财产或权利范围的增加或扩大；后者是指财产本应减少却因一定事实而未减少，如没有支出本应由自己支出的费用。

2. 另一方受有损失。可以表现为现有财产利益的减少，也可以表现为财产本应增加而未增加，即应得利益的损失。此处的应得利益是指在正常情形下可以得到的利益，而不是指必然得到的利益。

3. 一方获益和另一方受损之间有因果关系。此处的因果关系表现为另一方的损失是因一方受益造成的，即一方受益是另一方受损的原因。

4. 获益没有法律根据。即一方获益既无法律上的根据，亦无合同上的根据。没有法律根据包括取得利益时无法律根据和取得利益时有法律根据但嗣后丧失法律根据两种情形。

不当得利从利益获得的角度看，可以分为以下两类：（1）因给付而发生的不当得利。给付本为债务人以消灭债为目的的履行债务行为，但在该目的或者原因欠缺时，另一方因该给付所取得的利益就是没有法律依据的。在下列情形下，当事人一方在没有给付义务时而为给付不构成不当得利：一是为履行道德义务而进行的给付；二是债务到期之前的清偿；三是明知无给付义务而进行的债务清偿。（2）基于给付以外的事实而发生的不当得利。主要包括：①基于受益人的行为而发生的不当得利。此种情形下受益人的行为也可能构成侵权行为。②基于受损人的行为而发生的不当得利。③基于第三人的行为而发生的不当得利。④基于自然事件而发生的不当得利。⑤基于法律规定而发生的不当得利。

三、不当得利之债的效力

【分析】不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系，受损失的一方享有请求返还其利益的权利，获得利益的一方负有返还利益的义务。应予返还的利益，包括原物、原物所生的孳息以及利用原物所取得的其他利益。返还利益的具体范围依获益方的主观心态而定：得利人为善意时，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务；得利人为恶意时，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。一般认为，受益方为善意时，若损失大于利益，只返还现存利益；若损失小于利益，返还利益的范围以损失为准。受益方为恶意时，应返还其取得的全部利益，若利益少于损失，还须就损失与利益之间的差额进行赔偿。受益方取得利益时为善意，而后变为恶意的，返还的范围以恶意开始时剩余的利益为限。此外，得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。

第十七章 知识产权

第一节 知识产权概述

一、知识产权的概念和特征

【分析】知识产权是指民事主体对创造性智力成果依法享有的权利的总称。知识产权有广义和狭义之分。广义的知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（1）作品；（2）发明、实用新型、外观设计；（3）商标；（4）地理标志；（5）商业秘密；（6）集成电路布图设计；（7）植物新品种；（8）法律规定的其他客体。狭义的知识产权包括著作权、专利权、商标权，其中专利权与商标权合称工业产权。

知识产权具有如下特征：

1. 专有性。知识产权的专有性表现在：一方面，同一智力成果之上不能有两项以上完全相同的知识产权并存；另一方面，权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，没有法律规定或未经权利人许可，任何人不得擅自使用权利人的智力成果。同时，知识产权属于绝对权、对世权和支配权。

2. 地域性。知识产权的地域性是指一项知识产权只在其产生的特定国家或地区的领域内有效，不具有域外效力，其他国家没有必须给予保护的义务。权利人要想使自己的知识产权得到他国的法律保护，必须依有关国际条约、双边协议或按互惠原则，按照该国知识产权法的规定在该国获得知识产权。

3. 时间性。知识产权通常只在法律规定的期限内有效，超出法定保护期后，该知识产权消灭，有关智力成果进入公有领域，人们可以自由使用。须强调的是，不同知识产权的时间性呈现的是不同的特色，如商标权的期限届满后可通过续展依法延长保护期；少数知识产权没有时间限制，只要符合有关条件，法律可长期予以保护，如商业秘密权、地理标志权等。

4. 客体的无形性。知识产权的客体是智力成果，而智力成果不具有物质形态，与有体物不同。

二、知识产权的范围

【分析】如前所述，知识产权有广义与狭义之分，商业秘密即属于广义的知识产权范畴。商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。商业秘密具有以下构成要件：（1）非公知性，即不为公众所知悉。有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得，应当认定为“不为公众所知悉”。（2）具有商业价值。作为商业秘密的有关信息应当具有现实的或者潜在的商业价值，能为权利人带来竞争优势。（3）保密性。这要求权利人为防止信息泄露应当采取与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施。

我国保护商业秘密的立法主要为《反不正当竞争法》。《反不正当竞争法》第9条规定：“经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。”“第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。”

知识产权与反不正当竞争法之间有着密切的关系，在推动技术创新和经济发展方面，两者是统一的。在我国，与知识产权相关的不正当竞争行为主要是指经营者实施的引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为，如擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，擅自使用他人有一定影响的企业名称、社会组织名称、姓名，擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等。但是，知识产权权利人在市场竞争中也有可能滥用其独占权，在这个层面上，又需要反不正当竞争法保证知识产权人正当行使权利，防止滥用知识产权。

第二节 几种典型的知识产权

一、著作权

► 著作权的概念和特征

【分析】著作权，亦称版权，是指著作权人对文学、艺术和科学领域内的作品依法享有的各项专有权利。

著作权除具有知识产权的共同特征外，还具有**权利内容的双重性和权利自动产生**的特点。权利内容的双重性是指著作权包括**人身权与财产权**的双重内容，不过**两者的保护期限不同**。权利的自动产生是指**著作权基于作品的创作完成这一事实而自动产生**，既不需要发表，也无须任何部门审批。

►著作权的主体

【分析】著作权的主体即**著作权人**，是指依法对作品享有著作权的人。

著作权主体根据著作权取得方式的不同，可以分为**原始主体**和**继受主体**。原始主体是指在作品创作完成后，直接根据法律规定或合同约定，在不存在基础性权利的前提下对作品享有著作权的人，如**作者**。继受主体是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式对作品享有著作权的人。**通过受让、受赠、继承或者受遗赠的方式取得著作权的，著作权中的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权不发生转移。**

根据《著作权法》，著作权原则上属于作者。作者分为两种：一种是**创作作品的自然人**，另一种是**法人或者非法人组织**。**由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。**所谓创作，是指**直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动**。**为他人创作进行组织工作，提供咨询意见、物质条件，或者进行其他辅助工作，均不视为创作。**确认作者的**依据是署名**，在作品上署名的自然人、法人或者非法人组织为作者，且该作品上存在相应权利，**但有相反证明的除外。**

根据《著作权法》规定，**自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品**。主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图计算机软件等职务作品，报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品，**法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法人组织享有的职务作品**，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有。其他情形的职务作品，著作权由作者享有，但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。

►著作权的客体

【分析】著作权的客体即作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。具体包括：**（1）文字作品。（2）口述作品，如演讲、报告、授课、法庭辩论等。（3）音乐作品、戏剧作品、曲艺作品、舞蹈作品、杂技艺术作品。（4）美术作品、建筑作品。（5）摄影作品。（6）视听作品。（7）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品。（8）计算机软件。（9）符合作品特征的其他智力成果。**

不受著作权保护的对象包括：法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件及其官方正式译文；单纯事实消息；历法、通用数表、通用表格和公式

►著作权的内容

【分析】根据《著作权法》，著作权包括下列人身权和财产权：

1. **发表权**，即决定作品是否公之于众的权利；
2. **署名权**，**即表明作者身份，在作品上署名的权利；**
3. **修改权**，即修改或者**授权他人修改作品**的权利；
4. **保护作品完整权**，即保护作品不受歪曲、篡改的权利；
5. **复制权**，即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利；
6. **发行权**，即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利；

7. 出租权，即有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或者复制件的权利，计算机软件不是出租的主要标的的除外；

8. 展览权，即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利；

9. 表演权，即公开表演作品，以及用各种手段公开播送作品的表演的权利；

10. 放映权，即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利；

11. 广播权，即以有线或者无线方式公开传播或者转播作品，以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利，但不包括信息网络传播权；

12. 信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利；

13. 摄制权，即以摄制视听作品的方法将作品固定在载体上的权利；

14. 改编权，即改变作品，创作出具有独创性的新作品的权利；

15. 翻译权，即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利；

16. 汇编权，即将作品或者作品的片段通过选择或者编排，汇集成新作品的权利；

17. 应当由著作权人享有的其他权利。

以上权利中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。其他权利的保护期，著作权人为自然人的，为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日。

以上权利中，除前四项权利外，著作权人既可以全部或者部分转让，也可以许可他人行使上述权利并依照约定或者法律规定获得报酬。著作权的转让，专指著作财产权的转让，通过著作权转让，受让人成为该作品部分或者全部著作财产权的新的权利人。

► 著作权的保护

根据《著作权法》规定，有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任：（1）未经著作权人许可，发表其作品；（2）未经合作作者许可，与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表；（3）没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名；（4）歪曲、篡改他人作品的；（5）剽窃他人作品；（6）未经著作权人许可，以展览、摄制视听作品的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的，著作权法另有规定的除外；（7）使用他人作品，应当支付报酬而未支付的；（8）未经视听作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人、表演者或者录音录像制作者许可，出租其作品或者录音录像制品的原件或者复制件的，著作权法另有规定的除外；（9）未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的；（10）未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的；（11）其他侵犯著作权以及与著作权有关的权利的行为。

著作权的行使受到合理使用、法定许可等制度的限制。对此，《著作权法》第24条、第25条有具体规定。

二、专利权

► 专利权的概念和特征

【分析】专利权，是指发明创造的发明人、设计人或者其他申请人以及上述主体的合法继受人依法享有的对某项发明创造的独占使用权。

专利权除具有知识产权的共同特征外，还具有公开性和行政授予性特征。公开性是指只有将专利技术予以公开才能被授予专利权。行政授予性是指专利权并非自动产生的权利，必须经专利申请人申请和专利行政部门授予才能取得。

►专利权的主体

【分析】专利权的主体是**专利权人**，即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依照法定程序申请专利，成为专利权的主体。**外国人、外国企业或者外国其他组织**也可以成为我国的专利权人。

专利权人取得专利权的方式可以分为**原始取得与继受取得**。

在原始取得中，专利权的归属因发明创造是否为职务发明创造而有所不同。**职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造**。此处的本单位**包括临时工作单位**。执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：**（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（3）退休、调离原单位后或劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造**。**本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等**。**职务发明创造申请专利的权利属于发明人或者设计人的单位**。申请被批准后，**该单位为专利权人**。但利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，**从其约定**。**非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人**。**发明人或者设计人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人**。在完成发明创造过程中，**只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人**。此外，根据《专利法》规定，**两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除非另有协议，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人，申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人**。**两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人**。

继受取得是指通过合同或者继承取得专利权。在继受取得中，受让人或者继承人虽然是专利权人，但**不享有专属于发明人或者设计人的人身权利**。

►专利权的客体

【分析】专利权的客体，是指符合专利条件的发明创造，具体包括**发明、实用新型和外观设计**。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，又称“小发明”或“小专利”，是指**对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案**。它和发明比，**范围不如发明大，不包括物品的制造方法；创造性不如发明强；审批手续比发明简单，无须进行实质审查；保护期限亦不同**。

外观设计是工业品外观设计的简称，是指**对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计**。

根据《专利法》第5条，**以下两类发明创造不授予专利权**：一是**违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造**。二是**违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造**。此外，《专利法》第25条规定，**对下列各项，不授予专利权**：**（1）科学发现。（2）智力活动的规则和方法。（3）疾病的诊断和治疗方法。（4）动物和植物品种，但其产品的生产方法可以依法授予专利权。（5）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质。（6）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计**。

专利权具有时间性，根据专利法规定，**发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算**。

►专利权的内容

【分析】专利权的内容即专利权人享有的权利，具体包括：**（1）自己实施专利的权利。（2）许可他人实**

施专利的权利。(3) 转让权。专利权人有权转让专利权和专利申请权, 专利转让与许可他人实施专利不同。根据《专利法》, 转让专利申请权或者专利权的, 当事人应当订立书面合同, 并向国务院专利行政部门登记, 由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。(4) 报酬权或受奖权。职务发明创造的发明人或设计人有权得到报酬或奖励。(5) 署名权和标记权。发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人, 专利权人有权在其专利产品或包装上标明专利标识。

►专利权的保护

发明和实用新型专利权被授予后, 除专利权法另有规定的以外, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品, 或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

有下列情形之一的, 不视为侵犯专利权: (1) 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品, 由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后, 使用、许诺销售、销售、进口该产品的; (2) 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备, 并且仅在原有范围内继续制造、使用的; (3) 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具, 依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约, 或者依照互惠原则, 为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的; (4) 专为科学研究和实验而使用有关专利的; (5) 为提供行政审批所需要的信息, 制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的, 以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品, 能证明该产品合法来源的, 不承担赔偿责任。

三、商标权

►商标权的概念和特征

【分析】商标权, 是指商标注册人或者其合法继受人对注册商标享有的专有使用权。

商标权除具有知识产权的共同特征外, 还具有以下特征: (1) 权利内容的单一性。商标权只具有财产内容, 不具有人身内容。(2) 行政授予性。商标权并非自动产生的权利, 必须经商标注册申请人申请和行政部门授予才能取得。此外, 商标权虽然也具有时间性, 但其时间性具有相对性的特征, 只要商标权人愿意继续使用, 就可以通过不断续展, 使商标权长期甚至永久有效。

►商标权的主体

【分析】商标权的主体包括商标权的原始主体和继受主体。商标权的原始主体是指商标注册人, 继受主体是指依法通过注册商标的转让或者移转取得商标权的自然人、法人或者其他组织。根据《商标法》规定, 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中, 对其商品或者服务需要取得商标专用权的, 应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请, 应当予以驳回。

►商标权的客体

【分析】商标权的客体是注册商标, 即经商标局核准注册的商标。在我国, 未经注册的商标虽然可以在不侵害他人注册商标的前提下使用, 但原则上不受法律保护, 也不能取得商标专用权。注册商标包括商品商标、服务商标、集体商标、证明商标。商品商标即用于申请人生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上的商标。服务商标是指用于申请人提供的服务项目上的商标。集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册, 供该组织成员在商事活动中使用, 以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标, 是指由对某种商品或者

服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

根据《商标法》规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。根据《商标法》规定，下列标志不得作为商标注册：仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；其他缺乏显著特征的。前述所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

无论是注册商标还是非注册商标，均须符合合法性的要求。为保证商标的合法性，根据《商标法》规定，下列标志不得作为商标使用：（1）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（2）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（3）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（4）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（5）同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（6）带有民族歧视性的；（7）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（8）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

► 商标权的内容

【分析】商标权的内容，即商标权的主要权利，具体包括：

1. 独占使用权。商标一经注册，商标权人即对注册商标在法定范围内享有专有使用的权利，他人未经许可不得使用。

2. 转让权。商标权人有权依照法律规定，将商标权转让给他人。商标转让后，原商标权人的权利丧失，受让人取得商标权。转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

3. 使用许可权。商标权人有权许可他人使用自己的注册商标。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告，未经备案不得对抗善意第三人。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

► 商标权的保护

注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。注册商标的有效期为十年，自核准之日起计算。注册商标有效期满可以续展注册。

下列行为构成对商标权的侵犯：（1）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（2）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（3）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（4）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（5）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（6）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（7）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任，但应当停止销售。将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《反不正当竞争法》处理。

第十八章 人格权

第一节 人格权概述

一、人格权的概念和特征

【分析】人格权是指民事主体依法享有的为维护其独立法律人格所必备的基本民事权利。人格权是民事主体固有的权利，只要自然人出生、法人或非法人组织成立，无须任何意思表示或实施任何行为，就当然取得并受到法律保护。人格权兼具自然权利和法定权利的双重属性。

人格权具有如下特征：

1. 人格权是作为民事主体所应当具备的。
2. 民事主体享有人格权是经法律认可的。民事主体的人格权的种类和内容是经法律认可的，所谓悼念权、亲吻权等未经法律认可的“权利”不属于人格权的范畴。
3. 民事主体享有的人格权完全平等。人格权是民事主体资格本身所要求的基本权利。
4. 人格权以人格利益为客体。所谓人格利益是民事主体自然生存和社会生存所必需的利益。
5. 人格权不得放弃、转让或者继承。比较特殊的是，民事主体可以将自己的姓名、名称、肖像等人格标识许可他人使用，但是依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外。

人格权包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。

民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。人格权受到侵害的，受害人有权依照《民法典》和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。行为人因侵害人格权承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任的，应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。行为人拒不承担前述民事责任的，人民法院可以采取在报刊、网络等媒体上发布公告或者公布生效裁判文书等方式执行，产生的费用由行为人负担。需要说明的是，受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。在合同领域，因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方请求精神损害赔偿。

民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害的，有权依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。

死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

二、人格权和人身自由、人格尊严

【分析】除了《民法典》具体列举的人格权受法律保护，基于人身自由、人格尊严而产生的其他人格利益同样受法律保护。这又被概括为一般人格权。一般人格权，是指自然人基于人身自由以及人格尊严等根本人格

利益而享有的人格权。

一般人格权具有以下特征：

1. 主体限定于自然人。自然人平等地享有一般人格权。

2. 权利客体的高度概括性。一般人格权的客体是高度概括的民事主体一般人格利益，是具体人格权之外的、尚未或无法具体化的人格利益，它涵盖了具体人格利益之外民事主体应当享有的所有其他人格利益。

3. 所保护利益的根本性。人格平等、独立、自由和尊严都是民事主体之所以成为民事主体最根本的条件。

4. 权利内容的不确定性。一般人格权的内容无法事先确定，也不应当事先确定。

一般人格权具有三项功能：（1）产生具体人格权；（2）解释具体人格权；（3）补充具体人格权。

一般人格权的内容通常概括为**人身自由**及**人格尊严**两个方面。

第二节 具体人格权

一、生命权、身体权和健康权

►生命权

【分析】生命权是指自然人享有的生命安全不受非法侵害的权利。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的生命权。生命权是自然人作为权利主体的前提条件，也是其行使其他民事权利的基础，故为自然人最基本的人格权；生命权始于出生、终于死亡，不依赖其他权利而存在，故为独立的人格权。生命权以自然人的生命安全为客体，以维护人的生命活动的正常延续为基本内容，以人的生命活动能力为保护对象，其实质是禁止他人非法剥夺生命而使人的生命按自然界的客观规律延续。

生命权的基本内容包括两个方面：（1）**生命安全维护权**，即维护生命的延续、保护生命不受外来非法侵害；（2）**生命利益支配权**，即处分自己的生命。尽管传统理论对生命权是否包括生命利益支配权持否定态度，但献出自己的生命以挽救他人生命或健康的行为以及参加危险竞技项目的行为均被视为对生命利益的合法放弃。同时，在有些国家和地区，立法已经明确承认“安乐死”的合法性。

►身体权

【分析】身体权是指自然人享有的对其肢体、器官和其他人体组织进行支配并维护其安全与完整，从而享受一定利益的权利。自然人的身体完整和行动自由受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的身体权。完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。完全民事行为能力人依据前述规定同意捐献的，应当采用书面形式，也可以订立遗嘱。自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。法律禁止以任何形式买卖人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。以非法拘禁等方式剥夺、限制他人的行动自由，或者非法搜查他人身体的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

身体权具有以下特征：（1）身体权的主体限于自然人。（2）身体权的客体是权利人自身的物质性人格要素。（3）身体权的内容是自然人对其身体完整的维护及对肢体、器官和人体组织的支配，故身体权属于支配权。（4）身体权是不可转让的基本人格权。

身体权的基本内容是：（1）保护自然人的身体完整性和完全性。（2）支配自己的肢体、器官和其他人体组织等身体组成部分。

►健康权

【分析】健康权是指自然人依法享有的维护其健康，保持与利用其劳动能力并排除他人非法侵害的权利。自然人的身心健康受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。为研制新药、医疗器械或者发展新

的预防和治疗方法，需要进行临床试验的，应当依法经相关主管部门批准并经伦理委员会审查同意，向受试者或者受试者的监护人告知试验目的、用途和可能产生的风险等详细情况，并经其书面同意。进行临床试验的，不得向受试者收取试验费用。从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动，应当遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得危害人体健康，不得违背伦理道德，不得损害公共利益。违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。

健康权具有以下特征：（1）健康权以维护自然人的身体生理功能的正常发挥为根本利益。健康有两个要素：一是生理机能的正常运作，二是生理功能的完善发挥。通过这两个要素协调一致地发挥作用，人体正常的生命活动得以维持。（2）健康权是专属于自然人的人格权，始于出生，终于死亡，在自然人的有生之年具有不可转让性。（3）健康权是绝对权、对世权。

健康权与生命权、身体权不同。侵害生命权意味着生命不可逆转的丧失，侵害健康权的结果是健康受损，健康受损后经过医治可以康复或好转。生命权的根本利益在于维护生命安全与生命价值，健康权以维持人体的正常生命活动为根本利益。某一侵权行为侵犯的究竟是生命权还是健康权，以侵害的实际后果而不是侵权人的侵害目标为判断标准。侵害健康权并不当然侵犯身体权，如污染环境致人患病；侵害身体权也不当然侵害健康权，如非法剪人头发。

健康权包括三项基本内容：（1）健康维护权。权利人有权保持自己的健康状况，在健康水平下降时，有权请求并接受医疗以使健康状况达到完好的状态或者恢复到原有状态。上述权利的行使，不受任何人的干涉或强制。（2）劳动能力维护权。保有劳动能力，利用劳动能力以满足自己及社会的需要，并发展劳动能力。（3）健康利益支配权。自然人有权支配其健康利益，如冒健康受损的危险进行人体试验，从事危险性极大的体育竞技活动，舍己救人、见义勇为等。

二、姓名权和名称权

► 姓名权

【分析】姓名权是自然人依法享有的决定、使用、变更或者许可他人使用自己姓名，并排除他人非法侵害（如干涉、盗用、假冒等）的权利。自然人依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名不得违背公序良俗。

姓名权具有以下特征：（1）姓名权是以自然人的姓名为客体的人格权。姓名表明的是人格而不是身份，所以姓名权是人格权。（2）姓名权是专属于自然人的人格权，与自然人的人身不可分离，既不得转让也不得抛弃。（3）自然人决定、变更姓名应当依法向有关机关办理登记手续，但是法律另有规定的除外。

姓名权主要包括三方面内容：（1）姓名决定权，即决定自己姓名并排除他人非法干涉的权利。自然人成年以后有权自行决定姓名。在姓氏的选择上，自然人有权决定随父姓、母姓或采用其他姓；在名字的选择上，自然人不仅有权决定自己在户籍簿上登记的正式名字，而且可以决定自己的别名、笔名、艺名、字或号等其他名字。根据《民法典》第1015条，自然人应当随父姓或者母姓，但是有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：选取其他直系长辈血亲的姓氏；因法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏；有不违背公序良俗的其他正当理由。少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。（2）姓名使用权和许可他人使用权，即依法使用自己姓名排除他人非法干涉，并要求他人正确使用自己姓名，以及许可他人使用自己姓名的权利。法律对使用正式姓名有特殊要求的，应遵守法律的规定。对姓名等的许可使用，参照适用肖像许可使用的有关规定。（3）姓名变更权，即依照法律规定改变自己的正式姓名而不受他人非法干涉的权利。姓名变更权是姓名决定权的延伸。自然人在行使姓名变更权时，应当遵守法律的相关规定，如未满18周岁的自然人要

由本人的父母、收养人，18周岁以上的自然人要由本人，向户口登记机关申请变更登记。民事主体变更姓名、名称的，变更前实施的民事法律行为对其具有法律约束力。

►名称权

【分析】名称权是法人、非法人组织依法享有的决定、使用、变更、转让或者许可他人使用其名称并排除他人非法干涉的权利。

名称权具有以下特征：（1）名称权的主体是自然人以外的其他民事主体，包括法人、非法人组织。（2）名称权往往具有直接财产利益，商业名称权可以转让。（3）法人、非法人组织决定、变更、转让名称的，应当依法向有关机关办理登记手续，但是法律另有规定的除外。

名称权主要包括四个方面的内容：（1）名称决定权。法人、非法人组织名称的确定应当依照法律的规定，不得随意侵犯、盗用、仿冒其他组织的受法律保护的名称，并且应当依法办理有关登记手续。他人不得随意干涉法人和其他组织确定自己名称的权利。（2）名称使用权。法人、非法人组织对其名称享有独占的使用权，任何人不得干涉和非法使用。在登记的地区内，他人不得再登记该名称经营同一性质的业务；未经登记而使用者，同样构成对名称权的侵害。同时，法律对法人、非法人组织行使其名称权有一定的限制性规定，权利人应遵守这些规定。（3）名称变更权。变更名称应当遵循法律规定进行，必须办理变更登记。民事主体变更姓名、名称的，变更前实施的民事法律行为对其具有法律约束力。（4）名称转让权和许可他人使用权。在我国，法人、非法人组织有权依法转让自己的名称。除转让外，名称权人还有权许可他人使用自己的名称。此外，可转让的商业名称权还可以继承。

三、肖像权

【分析】肖像，是指通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。肖像不同于肖像的物质载体。肖像权是指自然人依法制作、使用、公开或者许可他人使用自己的肖像，借此享受一定利益并排除他人非法侵害的权利。对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。

肖像权具有以下特征：（1）肖像权是专属于自然人的人格权，其主体限于自然人。（2）肖像权的客体是肖像人的肖像，而不是肖像的载体。肖像的载体属于物的范畴，是财产权的客体。肖像载体的所有人与肖像权人可以分离。（3）肖像权是专有权。肖像直接关系到自然人的人格尊严与社会评价，与自然人的人格不可分离，故肖像权属于专有性的权利。肖像权的专有性首先体现在形象再现的专有权上，即只有肖像权人有权决定是否允许他人再现自己形象。此外，还体现在肖像使用的处分权上，肖像的使用权属于肖像权人，只有肖像人才有权利转让。

肖像权属于支配权，其内容是肖像权人对自已肖像的支配，具体包括：（1）肖像制作权。制作肖像即以物质材料反映肖像人的形象。自然人有权决定是否制作肖像，有权决定肖像的制作形式、肖像载体所用的材料；有权决定是由自己抑或由他人制作自己的肖像，也有权禁止他人非法制作自己的肖像。（2）肖像使用权和许可使用权。肖像权人对自已的肖像有权以任何合法的方式自己使用或者许可他人使用并获得一定的收益。当事人对肖像许可使用合同中关于肖像使用条款的理解有争议的，应当作出有利于肖像权人的解释。当事人对肖像许可使用期限没有约定或者约定不明确的，任何一方当事人可以随时解除肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前通知对方。当事人对肖像许可使用期限有明确约定，肖像权人有正当理由的，可以解除肖像许可使用合同，但是应当在合理期限之前通知对方。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于肖像权人的事由外，应当赔偿损失。自然人有权决定是否允许他人使用自己的肖像；未经肖像权人同意，任何人原则上不得使用其肖像。在涉及肖像作品时，未经肖像权人同意，肖像作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。（3）肖像利益维护权。肖像权人有权维护自己的肖像利益，对于恶意损毁、丑化、玷

污、利用信息技术手段伪造其肖像或以营利为目的非法使用其肖像的行为，均有权请求其停止侵害并可要求侵害人赔偿损失。但是，他人合法的使用行为应当受到法律的保护，根据《民法典》第1020条的规定，合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意：为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；为展示特定公共环境，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；为维护公共利益或者肖像权人合法权益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的其他行为。

四、名誉权和荣誉权

►名誉权

【分析】名誉权中的名誉是指对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。名誉权是指民事主体依法享有的维护其名誉，享受名誉给自己带来的利益并排除他人非法侵害的权利。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

名誉权具有以下特征：（1）名誉权的主体包括所有的民事主体。（2）名誉权的客体为名誉。名誉权的本质在于权利人有权要求他人对其进行客观公正的评价，有权排除他人对其名誉权的侵害。（3）名誉权不具有直接的财产内容，但与一定的财产利益相联系，尤其是对从事经营活动的民事主体而言，名誉权与其财产利益的联系更为密切，如企业法人名誉受损后，有可能导致其信誉降低、效益滑坡的不利后果。从这一意义上说，良好的名誉本身就是一种财富。

名誉权的基本内容包括：（1）名誉保有权。即保持自己的名誉，使社会评价不降低、不丧失以及通过自己的行为改善和提高自己的社会评价的权利。（2）名誉维护权。名誉权属于绝对权、对世权，权利人对于其他任何人都享有不得侵害自己权利的不作为请求权，任何人均负有不得侵害其名誉权的法定义务。对于恶意贬损或损害自己名誉等非法侵害自己名誉的行为，权利人有权要求其停止侵害，并可寻求司法保护，要求对自己遭受的损害进行救济。（3）名誉利益支配权。名誉权人可以利用自己良好的名誉，从事合法的经济、政治、文化活动并可享受因此获得的合法利益。

行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影响他人名誉的，不承担民事责任，但是有下列情形之一的除外：捏造、歪曲事实；对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务；使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。认定行为人是否尽到合理核实义务，应当考虑的因素包括：内容来源的可信度；对明显可能引发争议的内容是否进行了必要的调查；内容的时限性；内容与公序良俗的关联性；受害人名誉受贬损的可能性；核实能力和核实成本。

民事主体有证据证明报刊、网络等媒体报道的内容失实，侵害其名誉权的，有权请求该媒体及时采取更正或者删除等必要措施。民事主体可以依法查询自己的信用评价；发现信用评价不当的，有权提出异议并请求采取更正、删除等必要措施。信用评价人应当及时核查，经核查属实的，应当及时采取必要措施。

►荣誉权

【分析】荣誉是特定人从特定组织获得的一种专门化和确定化的积极评价。荣誉权是指主体对荣誉享有的获得、保持、利用并享受所生利益的权利。任何组织或者个人不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、贬损他人的荣誉。获得的荣誉称号应当记载而没有记载的，民事主体可以请求记载；获得的荣誉称号记载错误的，民事主体可以请求更正。

荣誉与名誉的区别在于：（1）来源不同。荣誉是由特定组织授予的，来源具有特定性；名誉是民事主体获得的生活评价，其来源是不特定的社会公众。（2）内容不同。荣誉是对民事主体的正面的、积极的、赞扬性的评价；名誉是对民事主体的客观评价，该评价可能是正面的、积极的，也可能是负面的、消极的，故名誉

有好坏之分，而荣誉则无此区分。同时，荣誉是由一定组织依一定条件和程序给予的，是一种正式评价，表现为一定的形式，如荣誉称号；名誉则是一种带有随意性的评价，没有固定的形式。（3）涉及的范围不同。荣誉仅仅是对民事主体的某个特定方面的评价，名誉则是对某一主体的综合性评价，涉及主体的各个方面。（4）荣誉可以依照一定的程序剥夺或者撤销，而名誉只可能发生改变，不可能被剥夺或者撤销。

荣誉权具有以下特征：（1）权利主体包括所有的民事主体。（2）客体是民事主体获得的荣誉。

荣誉权的基本内容包括：（1）荣誉获得权，即民事主体有权获得因其行为而授予的荣誉称号，任何人不得加以妨碍、阻挠和干涉。（2）荣誉维护权，即民事主体对于已经授予的荣誉有权保持归自己所有，排除他人非法侵害。荣誉一经获得即为民事主体终身享有，未经法定程序不得撤销或非法剥夺，也不得转让或继承。获得的荣誉称号应当记载而没有记载的，民事主体可以请求记载；获得的荣誉称号记载错误的，民事主体可以请求更正。（3）荣誉利用权，即民事主体可以利用荣誉，并享有和自主支配因一定的荣誉而获得的物质利益。如企业可以在商业广告中载明自己获得的荣誉以取信于社会。权利人利用荣誉必须遵守法律，不得损害社会公益。

五、隐私权和个人信息保护

►隐私权

【分析】隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。隐私权是指自然人享有的对自己的个人隐私进行支配并排除他人非法干涉的人格权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

隐私权具有以下特征：（1）隐私权的主体限于自然人，是专属于自然人的人格权利。法律创设隐私权的目的是保护个人私生活的自由与安宁。需要说明的是，自然人的隐私范围并不完全相同，如普通公民和国家公务人员的隐私范围就不相同。（2）隐私权的客体是隐私，因隐私与他人及社会公共利益无关，故法律禁止他人以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害权利人的隐私权。（3）隐私权是支配权，权利人既可以利用隐私，也可以放弃隐私。

隐私权的基本内容包括：（1）隐私保密权，即保持自己的私人生活秘密不为他人所知晓。（2）隐私保护权，即维护自己的私人生活安宁和生活秘密不受他人的非法刺探、侵扰、公开等。在受到他人侵害时，可以请求司法救济。（3）隐私支配权，即隐私权人可以自主决定自己的私人生活方式，可以决定是否对外公开自己的生活秘密，可以利用自己的生活秘密以满足自己的精神、物质方面的需要。隐私权人还可以决定是否允许他人探知自己的隐私，并可决定是否允许他人利用自己的隐私。隐私的利用不得违反法律，不得损害社会公共利益和善良风俗。

隐私权的保护同时会限制其他民事主体的行为，《民法典》第1033条规定，除法律另有规定或者权利人明确同意外，任何组织或者个人不得实施下列行为：（1）以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；（2）进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；（3）拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；（4）拍摄、窥视他人身体的私密部位；（5）处理他人的私密信息；（6）以其他方式侵害他人的隐私权。

►个人信息保护

【分析】个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。《民法典》第111条规定，自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。《民法典》人格权编对个人信息保护作了具体规定。敏感个人信息是一旦泄露或者非法

使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

在个人信息保护中，处理个人信息成为规范的重点。《民法典》第 1035 条规定，处理个人信息的，应当遵循合法、正当、必要原则，不得过度处理，并符合下列条件：（1）征得该自然人或者其监护人同意，但是法律、行政法规另有规定的除外；（2）公开处理信息的规则；（3）明示处理信息的目的、方式和范围；（4）不违反法律、行政法规的规定和双方的约定。个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。但处理个人信息也有不承担民事责任的例外，主要包括：（1）在该自然人或者其监护人同意的范围内合理实施的行为；（2）合理处理该自然人自行公开的或者其他已经合法公开的信息，但是该自然人明确拒绝或者处理该信息侵害其重大利益的除外；（3）为维护公共利益或者该自然人合法权益，合理实施的其他行为。只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，个人信息处理者方可处理敏感个人信息。处理敏感个人信息应当取得个人的单独同意；法律、行政法规规定处理敏感个人信息应当取得书面同意的，从其规定。

自然人可以依法向信息处理者查阅或者复制其个人信息；发现信息有错误的，有权提出异议并请求及时采取更正等必要措施。自然人发现信息处理者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定处理其个人信息的，有权请求信息处理者及时删除。信息处理者不得泄露或者篡改其收集、存储的个人信息；未经自然人同意，不得向他人非法提供其个人信息，但是经过加工无法识别特定个人且不能复原的除外。信息处理者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集、存储的个人信息安全，防止信息泄露、篡改、丢失；发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，应当及时采取补救措施，按照规定告知自然人并向有关主管部门报告。国家机关、承担行政职能的法定机构及其工作人员对于履行职责过程中知悉的自然人的隐私和个人信息，应当予以保密，不得泄露或者向他人非法提供。

第十九章 婚姻家庭

第一节 亲属

一、亲属的概念和特征

【分析】亲属是指因婚姻、血缘和法律拟制而产生的一种人与人之间的社会关系。

亲属具有以下特征：

1. 亲属具有身份性。亲属具有固定的身份和称谓。亲属身份一经确定，除法律另有规定外，不得随意变更或解除。
2. 亲属产生的原因具有特殊性。亲属产生的原因主要包括结婚、出生、收养等。
3. 亲属间的权利义务具有法定性。亲属是法律所规范的社会关系，以权利义务为内容。这些权利义务均为法律所赋予，不可通过约定加以改变或放弃。

二、亲属的范围与家庭成员

【分析】亲属作为基于婚姻、血缘和法律拟制而产生的社会关系，可以上下左右延伸及延续，但法律所调整的只是一定范围内的亲属关系。哪些亲属关系应列入法律调整的范围，主要是由当时社会的经济基础及亲属关系在社会生活中的作用所决定，并与当时社会上层建筑相适应。《民法典》调整的亲属范围以近亲属为限，近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。此外，还有一个禁婚亲的

范围，即直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。

家庭成员，是指同居一家共同生活并互有权利义务的亲属。在我国，配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。可见，家庭成员仅仅是近亲属中的一部分，家庭成员一定是近亲属，但近亲属不一定是家庭成员。

三、亲属的种类

【分析】以亲属关系发生的原因为标准，可以将亲属分为配偶、血亲和姻亲三类。

1. 配偶。配偶即夫妻，是指男女双方因结婚而形成的亲属关系。

2. 血亲。血亲，是指相互之间具有血缘关系的亲属，包括自然血亲和拟制血亲。

(1) 自然血亲，是指出自同一祖先，因出生而自然形成的具有真实血缘联系的亲属。这些亲属无论是婚生还是非婚生，无论是全血缘（同父同母）还是半血缘（同父异母、同母异父），均为自然血亲。

(2) 拟制血亲，是指相互之间本无该种血亲应具有的血缘关系，但法律确认其与该种血亲具有相同的权利义务关系的亲属。拟制血亲有两种，一是因收养形成的血亲；二是继父母与受其抚养教育的继子女之间形成的血亲。

3. 姻亲。姻亲，是指因婚姻而产生的亲属关系，即配偶一方与对方的血亲之间产生的亲属关系，但配偶本身不在姻亲之列。

四、亲系与亲等

► 亲系

【分析】亲系是指亲属间的联络系统。亲属以婚姻、血缘为基础，构成纵横交错、互相交织的亲属网络。除配偶外，一切亲属都有一定的亲系可循。亲系有直系亲和旁系亲两种，由此，血亲可分为直系血亲和旁系血亲，姻亲可分为直系姻亲和旁系姻亲。

1. 直系血亲与旁系血亲

直系血亲，是指有直接血缘关系的血亲，包括生育自己和自己所生育的上下各代血亲。上溯至父母、祖父母、外祖父母等，下至子女、孙子女、外孙子女等，皆为直系血亲。直系血亲除自然直系血亲外，还包括法律拟制的直系血亲。

旁系血亲，是指彼此之间具有间接血缘关系的亲属，即双方之间无从出关系但同源于一共同祖先的血亲。如同源于父母的兄弟姐妹，同源于一祖父母的伯、叔、姑，同源于一外祖父母的舅、姨等，皆为旁系血亲。旁系血亲包括全血缘血亲和半血缘血亲，包括自然旁系血亲和法律拟制的旁系血亲。

2. 直系姻亲与旁系姻亲

直系姻亲含义有二：一是指与配偶的直系血亲，二是指与直系血亲的配偶。其实二者的范围是一致的，只是认识的角度不同而已，前者如儿媳与公婆，后者如公婆与儿媳等。同理，旁系姻亲含义也有二：一是指与配偶的旁系血亲，二是指与旁系血亲的配偶，前者如与配偶的兄弟姐妹，后者如与兄弟姐妹的配偶等。

► 亲等

【分析】亲等，是计算亲属关系亲疏远近的指数和尺度。我国对亲等的计算采用世代计算法，以代作为计算亲属关系亲疏远近的单位。代数越小，表明亲属关系越近；代数越大，表明亲属关系越远。

1. 直系血亲的计算。从己身开始，己身为一代，往上或往下数。上数至父母是二代，数至祖父母、外祖父母为三代。往下数也如此，己身数至子女是二代，数至孙子女与外孙子女为三代，依此类推。

2. 旁系血亲的计算。首先找出同源直系血亲，然后按直系血亲的计算法，从己身往上数至同源直系血亲，

记下世代数；再从要计算的旁系血亲上数至同源直系血亲，记下世代数。如果两边的世代数相同，则用一边的世代数定代数；如果两边的世代数不同，则取世代数大的一边定代数。依据此方法计算，兄弟姐妹之间为二代旁系血亲，己身与叔、姑、姨舅为三代旁系血亲。

第二节 结婚

一、结婚的要件

►结婚的实质要件

【分析】结婚的实质要件包括必备要件和禁止要件。

1. 结婚的必备要件，是指男女双方结婚时必须具备的法定条件。在我国，结婚必须具备以下三个条件：（1）男女双方完全自愿。（2）达到法定婚龄。男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。（3）男女双方均无配偶。

2. 结婚的禁止要件，是指法律不允许结婚的情形。在我国，直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。

►结婚的形式要件

【分析】结婚的形式要件，是指法律规定的结婚必须履行的法定程序。在我国，结婚必须履行的法定程序就是登记，要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。完成结婚登记，即确立婚姻关系。未办理结婚登记而以夫妻名义共同生活的男女，提起诉讼要求离婚的，应当区别对待：

1. 1994 年 2 月 1 日《婚姻登记管理条例》公布实施以前，男女双方已经符合结婚实质要件的，按事实婚姻处理。

2. 1994 年 2 月 1 日《婚姻登记管理条例》公布实施以后，男女双方符合结婚实质要件的，人民法院应当告知其补办结婚登记。未补办结婚登记的，按同居关系处理。

二、无效婚姻

【分析】无效婚姻，是指虽已办理结婚登记但因欠缺结婚实质要件而不具有法律效力的婚姻。

1. 婚姻无效的情形。根据《民法典》规定，婚姻无效的情形有：（1）重婚；（2）有禁止结婚的亲属关系；（3）未到法定婚龄。当事人以前述三种无效婚姻以外的情形请求确认婚姻无效的，人民法院应当判决驳回当事人的诉讼请求。当事人请求确认重婚的婚姻无效，提起诉讼时合法婚姻当事人已经离婚或者配偶已经死亡，被告以此为由抗辩后一婚姻自以上情形发生时转为有效的，人民法院不予支持。

2. 婚姻无效的宣告程序。对于婚姻无效，我国采用人民法院宣告无效制。

人民法院宣告婚姻无效的途径有两个。其一是根据当事人的申请。有权向人民法院请求确认婚姻无效的主体，包括婚姻当事人及利害关系人。利害关系人包括：（1）以重婚为由的，为当事人的近亲属及基层组织；（2）以未到法定婚龄为由的，为未到法定婚龄者的近亲属；（3）以有禁止结婚的亲属关系为由的，为当事人的近亲属。其二是对受理的离婚案件，人民法院依职权主动审查婚姻的效力。人民法院受理离婚案件后，经审查确属无效婚姻的，应当将婚姻无效的情形告知当事人，并依法作出婚姻无效的判决。人民法院就同一婚姻关系分别受理了离婚和请求确认婚姻无效案件的，对于离婚案件的审理，应当待请求确认婚姻无效案件作出判决后进行。

3. 无效婚姻的法律后果。无效的婚姻自始没有法律约束力。无效婚姻的具体法律后果表现在以下几个方面：

（1）身份上的后果。当事人自始不具有夫妻的权利和义务。（2）财产上的后果。当事人同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成的，除有证据证明为当事人一方所有的以外，按共同共有处理，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理，不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。（3）父母子女关系的后果。当事人所生的子女，适用《民法典》关于父母子女的规定。（4）损害赔偿。婚姻无效

的，无过错方有权请求损害赔偿。

三、可撤销婚姻

【分析】可撤销婚姻，是指虽已办理结婚登记，但撤销权人可基于法定事由向人民法院请求撤销的婚姻。

1. 婚姻可撤销的情形。根据《民法典》规定，婚姻可撤销的情形有两种：（1）受胁迫。这里的胁迫，是指行为人以给另一方当事人或者其近亲属的生命、身体、健康、名誉、财产等方面造成损害为要挟，迫使另一方当事人违背真实意愿结婚的情况。（2）隐瞒重大疾病。一方患有重大疾病，在结婚登记前未如实告知另一方的，另一方可以请求撤销婚姻。若当事人以结婚登记程序存在瑕疵为由提起民事诉讼，主张撤销结婚登记的，人民法院应告知其可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

2. 撤销婚姻的程序。撤销婚姻只能通过诉讼程序，撤销婚姻的机关是人民法院。因受胁迫而请求撤销婚姻的，只能是受胁迫一方的婚姻关系当事人本人。请求撤销婚姻的，应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。

3. 婚姻被撤销的法律后果。被撤销的婚姻自始没有法律约束力，被撤销的婚姻与无效婚姻具有相同的法律后果。

第三节 家庭关系

一、夫妻关系

► 夫妻人身关系

【分析】夫妻人身关系，是指基于夫妻身份在夫妻之间当然产生的、没有直接财产内容的权利和义务。夫妻人身关系具有以下特征：（1）发生在合法夫妻之间；（2）夫妻人身关系对夫妻双方而言既是权利，也是义务；（3）夫妻人身关系由法律直接规定，夫妻双方不能通过约定加以改变或消灭。

夫妻人身关系的具体内容包括：

1. 夫妻的姓名权。夫妻双方都有各自使用自己姓名的权利。

2. 夫妻的人身自由权。夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者干涉。

3. 夫妻对抚育未成年子女有平等的权利和义务。夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的權利，共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。

4. 夫妻相互忠实义务。夫妻应当互相忠实，互相尊重。夫妻一方为重婚、与他人同居以及其他违反夫妻忠实义务等目的，将夫妻共同财产赠与他人或者以明显不合理的价格处分夫妻共同财产，另一方主张该民事法律行违背公序良俗无效的，人民法院应予以支持，并依照民法典第 157 条规定处理。

► 夫妻财产关系

【分析】夫妻财产关系，是指夫妻在财产方面享有的权利和义务，包括夫妻财产制、夫妻间的相互扶养义务、夫妻间的相互继承权和夫妻间的日常家事代理权。

1. 夫妻财产制

在我国，夫妻财产制包括两种，即法定财产制和约定财产制。

（1）法定财产制

法定财产制，是指在夫妻对婚前或婚后所得财产归属没有约定的情况下，当然适用法律规定的财产制度，包括法定夫妻共同所有财产和法定夫妻个人特有财产两类。

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：①工资、奖金、劳务报酬；②生产、经营、投资的收益；③知识产权的收益，这里的“知识产权的收益”，是指婚姻关系存续期间，实际取得或者已经明确可以取得的财产性收益；④继承或者受赠的财产，但遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产除外；⑤其他应当归共同所有的财产。下列财产属于“其他应当归共同所有的财产”：一方以个人财产投资取得的收益；男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；男女双方实际取得或者应当取得的基本养老金、破产安置补偿费。此外，夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除孳息和自然增值外，应认定为夫妻共同财产。由一方婚前承租、婚后用共同财产购买的房屋，登记在一方名下的，应当认定为夫妻共同财产。

夫妻对共同财产有平等的处理权。一方未经另一方同意出售夫妻共同所有的房屋，第三人善意购买、支付合理对价并已办理不动产登记，另一方主张追回该房屋的，人民法院不予支持。夫妻一方擅自处分共同所有的房屋造成另一方损失，离婚时另一方请求赔偿损失的，人民法院不予支持。夫妻一方转让用夫妻共同财产出资但登记在自己名下的有限责任公司股权，另一方以未经其同意侵害夫妻共同财产利益为由请求确认股权转让合同无效的，人民法院不予支持，但有证据证明转让人与受让人恶意串通损害另一方合法权益的除外。婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产：①一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为；②一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治，另一方不同意支付相关医疗费用。夫妻一方未经另一方同意，在网络直播平台用夫妻共同财产打赏，数额明显超出其家庭一般消费水平，严重损害夫妻共同财产利益的，可以认定为民法典第 1066 条和第 1092 条规定的“挥霍”。另一方请求在婚姻关系存续期间分割夫妻共同财产，人民法院应予支持。夫妻一方为重婚、与他人同居以及其他违反夫妻忠实义务等目的，将夫妻共同财产赠与他人或者以明显不合理的价格处分夫妻共同财产，另一方以该方存在转移、变卖夫妻共同财产行为，严重损害夫妻共同财产利益为由，依据民法典第 1066 条规定请求在婚姻关系存续期间分割夫妻共同财产的，人民法院应予支持。

法定夫妻个人特有财产，是指在适用夫妻共同财产制的情况下，依据法律规定属于夫或妻个人所有的财产。下列财产为夫妻一方的个人财产：①一方的婚前财产；②一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；④一方专用的生活用品；⑤其他应当归一方的财产。当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，赠与合同中确定只归一方的，则为该方个人财产；未确定只归一方的，则归夫妻双方共同所有。军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费属于个人财产。需要指出的是，属于夫或妻一方的个人财产，无论是动产还是不动产，均不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产，除非当事人另有约定。

《民法典》第 1064 条规定，夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。债权人就一方婚前所负个人债务向债务人的配偶主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明所负债务用于婚后家庭共同生活的除外。夫妻一方与第三人串通，虚构债务，第三人主张该债务为夫妻共同债务的，人民法院不予支持。夫妻一方在从事赌博、吸毒等违法犯罪活动中所负债务，第三人主张该债务为夫妻共同债务的，人民法院不予支持。

（2）约定财产制

约定财产制，是指夫妻以契约确定夫妻财产关系的制度，在适用上具有优先于法定财产制的效力。夫妻财产约定的有效条件主要包括：第一，约定的主体须为具备完全民事行为能力的夫妻双方。第二，约定的意思表示必须自愿、真实。第三，约定的内容必须合法。约定的内容不得超出夫妻财产的范围，夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。第四，约定的形式必须合法。约定应当采用书面形式。婚前或者婚姻关系存续期间，当事人约定将一方所有的房产赠与另一方或者共有，赠与方在赠与房产变更登记之前撤销赠与，另一方请求判令继续履行的，人民法院可以按照《民法典》第658条的规定处理。夫妻财产约定的效力包括对内效力和对外效力，即夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，对双方具有法律约束力。夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的，夫或妻一方对外所负的债务，相对人知道该约定的，以夫或妻一方的个人财产清偿。

2. 夫妻间的相互扶养义务。夫妻有相互扶养的义务。需要扶养的一方，在另一方不履行扶养义务时，有要求其给付扶养费的权利。

3. 夫妻间的相互继承权。夫妻有相互继承遗产的权利，且互为第一顺位继承人。

4. 夫妻间的日常家事代理权。夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生法律效力，但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。夫妻之间对一方可以实施的民事法律行为范围的限制，不得对抗善意相对人。

二、父母子女关系

【分析】父母子女关系，又称为亲子关系，是指父母与子女间的权利和义务关系。父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。对民法典中继子女受继父或者继母抚养教育的事实，人民法院应当以共同生活时间长短为基础，综合考虑共同生活期间继父是否实际进行生活照料、是否履行家庭教育职责、是否承担抚养费等因素予以认定。《民法典》关于父母子女关系的规定适用于上述所有类型的父母子女。

父母子女关系主要包括以下内容：

1. 父母对子女有抚养的义务。父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。不直接抚养非婚生子女的生父或者生母，应当负担未成年子女或者不能独立生活的成年子女的抚养费。抚养费包括子女生活费、教育费、医疗费等费用。

2. 父母有教育、保护未成年子女的权利和义务。

3. 子女对父母有赡养扶助的义务。成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。子女对父母的赡养义务，不因父母的婚姻关系变化而终止。

4. 子女有不得干涉父母婚姻的义务。

5. 父母和子女有相互继承遗产的权利。

6. 父、母或成年子女对亲子关系有请求确认或否认的权利。对亲子关系有异议且有正当理由的，父或者母可以向人民法院提起诉讼，请求确认或者否认亲子关系。对亲子关系有异议且有正当理由的，成年子女可以向人民法院提起诉讼，请求确认亲子关系。

三、其他近亲属关系

【分析】其他近亲属关系包括祖孙关系和兄弟姐妹关系。

1. 祖孙关系

祖孙关系，是指祖父母、外祖父母与孙子女、外孙子女之间的权利和义务关系。祖父母、外祖父母包括生

祖父母和生外祖父母、养祖父母和养外祖父母。孙子女、外孙子女包括婚生孙子女和婚生外孙子女、非婚生孙子女和非婚生外孙子女、养孙子女和养外孙子女。《民法典》关于祖孙关系的规定适用于上述所有类型的祖孙。

《民法典》规定了祖孙之间的抚养义务和赡养义务，但负担这些义务是有条件的。

(1) 祖父母、外祖父母对孙子女、外孙子女承担抚养义务的条件是：①孙子女、外孙子女须为未成年人；②孙子女、外孙子女的父母已经死亡或父母无力抚养；③祖父母、外祖父母有负担能力。

(2) 孙子女、外孙子女对祖父母、外祖父母承担赡养义务的条件是：①孙子女、外孙子女为有负担能力的成年人；②祖父母、外祖父母的子女已经死亡或子女无力赡养；③祖父母、外祖父母必须是需要赡养的人。

2. 兄弟姐妹关系

兄弟姐妹关系，是指兄弟姐妹之间的权利和义务关系。兄弟姐妹是最近的旁系血亲，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。《民法典》规定了兄弟姐妹之间的扶养义务，但负担这些义务是有条件的。

(1) 兄、姐对弟、妹负担扶养义务的条件是：①兄、姐有负担能力；②父母已经死亡或父母无力抚养；③弟、妹必须是未成年人。

(2) 弟、妹对兄、姐负担扶养义务的条件是：①兄、姐必须是缺乏劳动能力又缺乏生活来源的人；②弟、妹是由兄、姐扶养长大；③弟、妹有负担能力。

第四节 离婚

一、离婚的概念和特征

【分析】离婚，是婚姻关系当事人在生存期间依法解除婚姻关系的法律行为。离婚具有下列法律特征：

1. 离婚主体只能是夫妻双方本人。
2. 离婚必须以有效婚姻关系的存在为前提。
3. 离婚必须在夫妻双方生存期间进行。
4. 离婚必须符合法定的条件，履行法定的程序。
5. 离婚会产生一系列法律后果。

二、登记离婚

【分析】登记离婚，是指夫妻双方自愿离婚，并就离婚的法律后果达成协议，经婚姻登记机关认可，即可解除婚姻关系的一种离婚方式。

1. 登记离婚必须符合下列条件：(1) 双方当事人必须是办理结婚登记的合法夫妻。(2) 双方当事人须为完全民事行为能力人。(3) 双方当事人必须有离婚的合意。(4) 双方当事人对子女抚养、财产以及债务处理等事项达成协议。

2. 登记离婚的程序。登记离婚必须经过申请、审查、登记三个环节。

(1) 申请。双方当事人须亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。上述期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。

(2) 审查、登记。婚姻登记机关查明双方确实是自愿离婚，并已经对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的，予以登记，发给离婚证。夫妻登记离婚后，一方以双方意思表示虚假为由请求确认离婚无效的，人民法院不予支持。

三、诉讼离婚

【分析】诉讼离婚，是指夫妻一方向人民法院提起离婚诉讼，人民法院依法通过调解或判决而解除婚姻关系的一种离婚方式。

1. 诉讼离婚的调解制度。（1）诉讼外调解。夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。在诉讼前由有关组织进行调解，就是诉讼外调解。诉讼外调解并不是离婚案件诉讼必经的前置程序，是否进行这种调解，由双方当事人自己决定。（2）诉讼中调解。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。调解是人民法院审理离婚案件的必经程序。

2. 判决离婚的法定理由。感情确已破裂是我国判决离婚的法定理由。夫妻感情确已破裂的情形包括：（1）重婚或者与他人同居；（2）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（3）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（4）因感情不和分居满二年；（5）其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。此外，经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

3. 诉讼离婚的特殊保护。（1）对军人婚姻的特殊保护。现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外。（2）对女方的特殊保护。女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚；但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

四、离婚的法律后果

【分析】离婚的法律后果，又称离婚的效力，是指离婚在当事人之间的人身关系、财产关系及父母子女关系方面所引发的一系列变化。

1. 离婚在当事人身份上的效力。离婚导致配偶身份消灭。

2. 离婚在当事人财产上的效力。

（1）夫妻间扶养义务的终止。

（2）夫妻相互间继承权的丧失。

（3）夫妻共同财产的分割。离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；离婚协议约定将部分或者全部夫妻共同财产给予子女，离婚后，一方在财产权利转移之前请求撤销该约定的，人民法院不予支持，但另一方同意的除外。一方不履行离婚协议约定的义务，另一方请求其承担继续履行或者因无法履行而赔偿损失等民事责任的，人民法院依法予以支持。双方在离婚协议中明确约定子女可以就上述赠与子女的相关财产直接主张权利，一方不履行离婚协议约定的义务，子女请求参照适用民法典第 522 条第 2 款规定，由该方承担继续履行或者因无法履行而赔偿损失等民事责任的，人民法院依法予以支持。离婚协议约定将部分或者全部夫妻共同财产给予子女，离婚后，一方有证据证明签订离婚协议时存在欺诈、胁迫等情形，请求撤销该约定的，人民法院依法予以支持；当事人同时请求分割该部分夫妻共同财产的，人民法院依照民法典第 1087 条规定处理。离婚时，就夫妻共同财产的分割双方协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。夫妻之间订立借款协议，以夫妻共同财产出借给一方从事个人经营活动或者用于其他个人事务的，应视为双方约定处分夫妻共同财产的行为，离婚时可以按照借款协议的约定处理。夫妻以共同财产投资有限责任公司，并均登记为股东，双方对相应股权的归属没有约定或者约定不明确，离婚时，一方请求按照股东名册或者公司章程记载的各自出资额确定股权分割比例的，人民法院不予支持；对当事人分割夫妻共同财产的请求，人民法院依照民法典第 1087 条规定处理。夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。夫妻一方未经另一方同意，在网络直播平台用夫妻共同财产打赏，数额明显超出其家庭一般消费水平，严重损害夫妻共同财产利益的，另一方在离婚分割夫妻共同财产时请求对打赏一方少分或者不分的，人民法院应予支持。夫妻一方

为重婚、与他人同居以及其他违反夫妻忠实义务等目的，将夫妻共同财产赠与他人或者以明显不合理的价格处分夫妻共同财产，另一方依据民法典第 1092 条规定请求在离婚分割夫妻共同财产时对该方少分或者不分的，人民法院应予支持。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产，诉讼时效期间为三年，从当事人发现之日起计算。婚前或者婚姻关系存续期间，当事人约定将一方所有的房屋转移登记至另一方或者双方名下，离婚诉讼时房屋所有权尚未转移登记，双方对房屋归属或者分割有争议且协商不成的，人民法院可以根据当事人诉讼请求，结合给予目的，综合考虑婚姻关系存续时间、共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，判决房屋归其中一方所有，并确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。婚前或者婚姻关系存续期间，一方将其所有的房屋转移登记至另一方或者双方名下，离婚诉讼中，双方对房屋归属或者分割有争议且协商不成的，如果婚姻关系存续时间较短且给予方无重大过错，人民法院可以根据当事人诉讼请求，判决该房屋归给予方所有，并结合给予目的，综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。给予方有证据证明另一方存在欺诈、胁迫、严重侵害给予方或者其近亲属合法权益、对给予方有扶养义务而不履行等情形，请求撤销前两类规定的民事法律行为的，人民法院依法予以支持。

婚姻关系存续期间，夫妻购置房屋由一方父母全额出资，如果赠与合同明确约定只赠与自己子女一方的，按照约定处理；没有约定或者约定不明确的，离婚分割夫妻共同财产时，人民法院可以判决该房屋归出资人子女一方所有，并综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。婚姻关系存续期间，夫妻购置房屋由一方父母部分出资或者双方父母出资，如果赠与合同明确约定相应出资只赠与自己子女一方的，按照约定处理；没有约定或者约定不明确的，离婚分割夫妻共同财产时人民法院可以根据当事人诉讼请求，以出资来源及比例为基础，综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，判决房屋归其中一方所有，并由获得房屋一方对另一方予以合理补偿。

（4）夫妻共同债务的清偿。离婚时，夫妻共同债务应当共同偿还。共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由人民法院判决。当事人的离婚协议或者人民法院生效判决、裁定、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的，债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。一方就夫妻共同债务承担清偿责任后，主张由另一方按照离婚协议或者人民法院的法律文书承担相应债务的，人民法院不予支持。

3. 离婚在父母子女关系上的效力。

（1）父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。但是，生父与继母或者生母与继父离婚后，当事人主张继父或者继母和曾受其抚养教育的继子女之间的权利义务关系不再适用民法典关于父母子女关系规定的，人民法院应予支持，但继父或者继母与继子女存在依法成立的收养关系或者继子女仍与继父或者继母共同生活的除外。继父母子女关系解除后，缺乏劳动能力又缺乏生活来源的继父或者继母请求曾受其抚养教育的成年继子女给付生活费的，人民法院可以综合考虑抚养教育情况、成年继子女负担能力等因素，依法予以支持，但是继父或者继母曾存在虐待、遗弃继子女等情况的除外。

（2）离婚后子女随何方生活的确定。离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。离婚诉讼中，父母均要求直接抚养已满两周岁的未成年子女，一方有下列情形之一的，人民法院应当按照最有利于未成年子女的原则，优先考虑由另一方直接抚养：①实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；②有赌博吸毒

等恶习;③重婚、与他人同居或者其他严重违反夫妻忠实义务情形;④抢夺、藏匿未成年子女且另一方不存在本条第一项或者第二项等严重侵害未成年子女合法权益情形;⑤其他不利于未成年子女身心健康的情形。离婚协议中关于一方直接抚养未成年子女或者不能独立生活的成年子女、另一方不负担抚养费的约定,对双方具有法律约束力。但是,离婚后,直接抚养子女一方经济状况发生变化导致原生活水平显著降低或者子女生活、教育、医疗等必要合理费用确有显著增加,未成年子女或者不能独立生活的成年子女请求另一方支付抚养费的,人民法院依法予以支持,并综合考虑离婚协议整体约定、子女实际需要、另一方的负担能力、当地生活水平等因素,确定抚养费的数额。前款但书规定情形下,另一方以直接抚养子女一方无抚养能力为由请求变更抚养关系的,人民法院依照民法典第 1084 条规定处理。子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。

(3) 离婚后子女抚养费的负担。离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。前述协议或者判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。离婚后,不直接抚养子女一方未按照离婚协议约定或者以其他方式作出的承诺给付抚养费,未成年子女或者不能独立生活的成年子女请求其支付欠付的抚养费的,人民法院应予支持;如果子女已经成年并能够独立生活,直接抚养子女一方请求另一方支付欠付的费用的,人民法院依法予以支持。父母不得因子女变更姓氏而拒付子女抚养费。父或者母擅自将子女姓氏改为继母或继父姓氏而引起纠纷的,应当责令恢复原姓氏。抚养费的给付期限,一般至子女 18 周岁为止。16 周岁以上不满 18 周岁,以其劳动收入为主要生活来源,并能维持当地一般生活水平的,父母可以停止给付抚养费。

(4) 离异父母对子女的探望权。离婚后,不直接抚养子女的父或者母,有探望子女的权利,另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议;协议不成的,由人民法院判决。父或者母探望子女,不利于子女身心健康的,未成年子女、直接抚养子女的父或者母以及其他对未成年子女负担抚养、教育、保护义务的法定监护人,有权向人民法院提出中止探望的请求。人民法院认为需要中止探望的,依法作出裁定;中止探望的情形消失后,人民法院应当根据当事人的请求书面通知其恢复探望。父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,另一方向人民法院申请人身安全保护令或者参照适用民法典第 997 条规定申请人格权侵害禁令的,人民法院依法予以支持。抢夺、藏匿未成年子女一方以另一方存在赌博、吸毒、家庭暴力等严重侵害未成年子女合法权益情形,主张其抢夺、藏匿行为有合理事由的,人民法院应当告知其依法通过撤销监护人资格、中止探望或者变更抚养关系等途径解决。当事人对其上述主张未提供证据证明且未在合理期限内提出相关请求的,人民法院依照前述规定处理。

五、离婚时的救济

【分析】离婚时的救济包括离婚时的经济补偿、离婚时的经济帮助和离婚损害赔偿。

1. 离婚时的经济补偿

夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿。

经济补偿请求权的成立条件: (1) 须一方在共同生活中对家庭负担了更多的义务; (2) 必须于离婚之时提出请求。

2. 离婚时的经济帮助

离婚时,生活确有困难的一方有权请求另一方给予适当帮助。

经济帮助请求权的成立条件: (1) 要求帮助的一方确实有生活困难。(2) 要求帮助一方的生活困难存在于离婚时。(3) 另一方有经济负担能力。经济帮助以帮助方有负担能力为前提。

3. 离婚损害赔偿

离婚损害赔偿,是指因夫妻一方的法定过错行为导致离婚的,无过错方有权向有过错方请求损害赔偿。

离婚损害赔偿请求权的成立条件包括：（1）须一方有法定过错。法定过错包括重婚，与他人同居，实施家庭暴力，虐待、遗弃家庭成员以及其他重大过错。（2）须一方的法定过错导致离婚。（3）须请求权人无法定过错。（4）须无过错方因离婚受到损害。损害包括物质损害和精神损害。如果双方都有法定过错，则任何一方都不能以对方有过错为由请求离婚损害赔偿。

离婚损害赔偿请求权的行使。无过错方作为原告向人民法院提起损害赔偿请求的，必须在离婚诉讼的同时提出。在婚姻存续期间，当事人不起诉离婚而单独提起损害赔偿请求的，人民法院不予受理。人民法院判决不准离婚的案件，对于当事人提出的损害赔偿请求，不予支持。当事人在婚姻登记机关办理离婚登记手续后，向人民法院提出损害赔偿请求的，人民法院应当受理。但当事人在协议离婚时已经明确表示放弃该项请求的，人民法院不予支持。夫妻双方均有法定过错情形，一方或者双方向对方提出离婚损害赔偿请求的，人民法院不予支持。

第五节 收养

一、收养的概念和特征

【分析】收养，是指自然人依照法定的条件和程序，领养他人子女为自己的子女，发生父母子女间权利义务关系的民事法律行为。

收养具有以下法律特征：（1）收养是双方法律行为。成立收养关系须收养人和送养人双方达成协议。（2）收养是身份法律行为。收养关系成立后，被收养人与收养人及其近亲属形成拟制血亲。同时，被收养人与其生父母及其近亲属的身份关系解除。（3）收养是要式法律行为。收养关系的成立必须办理收养登记。

二、收养关系的成立

【分析】收养关系的成立需要符合法定的实质条件和形式条件。

1. 收养关系成立的实质条件

（1）被收养人的条件。下列未成年人，可以被收养：①丧失父母的孤儿；②查找不到生父母的未成年人；③生父母有特殊困难无力抚养的子女。

（2）送养人的条件。下列个人、组织可以作送养人：①孤儿的监护人。监护人送养孤儿的，应当征得有抚养义务的人同意。有抚养义务的人不同意送养、监护人不愿意继续履行监护职责的，应当依法另行确定监护人。②儿童福利机构。③有特殊困难无力抚养子女的生父母。④未成年人的父母均不具备完全民事行为能力且可能严重危害该未成年人的，该未成年人的监护人可以将其送养。

（3）收养人的条件。收养人应当同时具备下列条件：①无子女或者只有一名子女。

②有抚养、教育和保护被收养人的能力。③未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病。

④无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录。⑤年满三十周岁。⑥无配偶者收养异性子女的，收养人与被收养人的年龄应当相差四十周岁以上。符合上述条件的收养人，无子女的可以收养两名子女；有子女的只能收养一名子女。

（4）须各方当事人达成收养合意。①收养人收养与送养人送养，应当双方自愿，并达成收养协议合意。②收养八周岁以上未成年人的，应当征得被收养人的同意。③生父母送养子女，应当双方共同送养。只有生父母一方不明或者查找不到的，才可以单方送养。④有配偶者收养子女，应当夫妻共同收养。

（5）放宽收养条件的法定情形。①收养三代以内旁系同辈血亲的子女，可以不受下列条件限制：被收养人为生父母有特殊困难无力抚养的子女；送养人为有特殊困难无力抚养子女的生父母；无配偶者收养异性子女

的，收养人与被收养人的年龄应当相差四十周岁以上。此外，华侨收养三代以内旁系同辈血亲的子女，还可以不受收养人无子女或者只有一名子女的限制。②继父母收养继子女。继父或者继母经继子女的生父母同意，可以收养继子女，并可以不受下列条件的限制：被收养人为生父母有特殊困难无力抚养的子女；送养人为有特殊困难无力抚养子女的生父母；收养人无子女或者只有一名子女；收养人有抚养、教育和保护被收养人的能力；收养人未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病；收养人无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录；收养人年满三十周岁；无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收养一名子女。③收养孤儿、残疾未成年人或者儿童福利机构抚养的查找不到生父母的未成年人，可以不受下列条件限制：收养人无子女或者只有一名子女；无子女的收养人可以收养两名子女；有子女的收养人只能收养一名子女。

2. 收养关系成立的形式条件

收养关系成立的形式条件，就是办理行政登记。收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。

三、收养的效力

【分析】收养的效力涉及以下三个方面。

1. 收养的拟制效力

自收养关系成立之日起，收养人与被收养人之间形成拟制的父母子女关系，养父母与养子女间的权利义务关系，适用《民法典》关于父母子女关系的规定；被收养人与收养人的近亲属之间也形成相应的拟制血亲关系，养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系，适用《民法典》关于近亲属关系的规定。

2. 收养的撤销效力

收养关系一经成立，养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系，因收养关系的成立而消除。

3. 收养行为的无效

无效收养的情形：（1）具有《民法典》关于民事法律行为无效的情形；（2）收养行为违反收养的实质条件和形式条件。

收养行为无效的法律后果：无效的收养行为自始没有法律约束力。

四、收养关系的解除

【分析】收养关系的解除涉及解除收养关系的法定情形、解除程序和解除的法律后果问题。

1. 收养关系解除的法定情形

（1）收养人侵害未成年养子女的合法权益。收养人不履行抚养义务，有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的，送养人有权要求解除养父母与养子女间的收养关系。

（2）养父母与成年养子女关系恶化。养父母与成年养子女关系恶化、无法共同生活的，可以协议解除收养关系。

2. 收养关系解除的程序

（1）依行政程序解除。即收养当事人经协商达成终止收养关系的协议，由收养登记机关登记予以解除收养关系。

依行政程序解除收养关系必须具备以下条件：①收养当事人之间达成了解除收养关系的协议。收养人在被收养人成年以前，不得解除收养关系，但是收养人、送养人双方协议解除的除外。养子女八周岁以上的，还应当征得本人同意。②协议当事人须具有完全民事行为能力。

当事人协议解除收养关系的，应当到民政部门办理解除收养关系登记。

(2) 依诉讼程序解除。即收养关系当事人不能就解除收养达成合意，一方依法诉请人民法院请求解除收养关系。

3. 收养关系解除的法律后果

(1) 身份上的效力

①拟制血亲关系消除。收养关系解除后，养子女与养父母以及其他近亲属间的权利义务关系即行消除。

②自然血亲关系恢复。收养关系解除后，未成年的养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系自行恢复。但是，成年养子女与生父母以及其他近亲属间的权利义务关系是否恢复，可以协商确定。

(2) 财产上的效力

①成年养子女给付生活费的义务。收养关系解除后，经养父母抚养的成年养子女，对缺乏劳动能力又缺乏生活来源的养父母，应当给付生活费。

②养父母的补偿请求权。因养子女成年后虐待、遗弃养父母而解除收养关系的，养父母可以要求养子女补偿收养期间支出的抚养费。生父母要求解除收养关系的，养父母可以要求生父母适当补偿收养期间支出的抚养费；但是，因养父母虐待、遗弃养子女而解除收养关系的除外。

第二十章 继承

第一节 继承概述

一、继承的概念和特征

【分析】继承是指将自然人死亡时遗留的个人合法财产依法转移给他人所有的法律制度。在继承中，死亡的自然人称为被继承人，依法承接被继承人遗产的人称为继承人。

继承具有如下特征：(1) 继承因自然人死亡而发生。(2) 继承主体是死者一定范围内的近亲属。自然人死亡后，能够继承其遗产的人只能是自然人，并且能够作为继承人的自然人只能是法律规定的死者的近亲属。

(3) 继承的客体是死者遗留的个人合法财产。(4) 继承产生财产权利变动的后果。自然人死亡后，其财产权的主体必定会发生变更，由死者的继承人成为财产权的主体。

二、继承的开始和继承的接受

【分析】继承从被继承人生理死亡或者被宣告死亡时开始。生理死亡以有关部门出具的死亡证明确认的时间为准，被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期，因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

相互有继承关系的数人在同一事件中死亡，难以确定死亡时间的，推定没有其他继承人的人先死亡。都有其他继承人，辈份不同的，推定长辈先死亡；辈份相同的，推定同时死亡，相互不发生继承。

继承开始的通知。继承开始后，知道被继承人死亡的继承人应当及时通知其他继承人和遗嘱执行人。继承人中无人知道被继承人死亡或者知道被继承人死亡而不能通知的，由被继承人生前所在单位或者住所地的居民委员会、村民委员会负责通知。

继承的接受。继承的接受是指继承人作出的同意继承被继承人遗产的意思表示。继承开始后，只要继承人没有表示放弃继承的，即视为接受继承。

三、继承权

【分析】继承权是指自然人根据法律的规定或者有效遗嘱的指定取得被继承人遗产的权利。

1. 继承权的特征

继承权具有以下特征：（1）继承权是自然人享有的权利。（2）继承权的产生是基于法律的规定或有效遗嘱的指定。基于法律规定产生的继承权是法定继承权，通过有效遗嘱指定产生的继承权是遗嘱继承权。（3）继承权的客体是遗产。（4）继承权是于被继承人死亡时才实际享有的权利。（5）继承权不得转让。继承权是因一定的身份关系而发生，因此具有专属性，不得转让给他人。

2. 继承权的放弃

继承权的放弃，是指继承人在继承开始后、遗产分割前作出的放弃继承被继承人遗产的权利的意思表示。

继承权放弃的时间。继承人放弃继承的意思表示，应当在继承开始后、遗产分割前作出。没有表示的，视为接受继承。遗产分割后表示放弃的，放弃的不再是继承权，而是所有权。

继承权放弃的方式。继承人放弃继承应当以书面形式向遗产管理人或者其他继承人表示。在诉讼中，继承人向人民法院以口头方式表示放弃继承的，要制作笔录，由放弃继承的人签名。

对继承权放弃的限制。继承人因放弃继承权，致其不能履行法定义务的，放弃继承权的行为无效。夫妻一方以另一方可继承的财产为夫妻共同财产、放弃继承侵害夫妻共同财产利益为由主张另一方放弃继承无效的，人民法院不予支持，但有证据证明放弃继承导致放弃一方不能履行法定扶养义务的除外。

对继承权放弃的反悔。遗产处理前或者在诉讼进行中，继承人对放弃继承反悔的，由人民法院根据其提出的具体理由，决定是否承认。遗产处理后，继承人对放弃继承反悔的，不予承认。

继承权放弃的效力。放弃继承的效力，追溯到继承开始的时间。放弃继承权的继承人，自继承开始就退出继承法律关系，继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。

3. 继承权的丧失

继承权的丧失，是指因发生法定事由，依法取消继承人继承被继承人遗产的资格。

继承人有下列行为之一的，丧失继承权：（1）故意杀害被继承人。继承人故意杀害被继承人的，不论是既遂还是未遂，均应当确认其丧失继承权。（2）为争夺遗产而杀害其他继承人。（3）遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重。继承人是否符合“虐待被继承人情节严重”，可以从实施虐待行为的时间、手段、后果和社会影响等方面认定。虐待被继承人情节严重的，不论是否追究刑事责任，均可确认其丧失继承权。（4）伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重。继承人伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，侵害了缺乏劳动能力又无生活来源的继承人的利益，并造成其生活困难的，应当认定为“情节严重”。（5）以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，情节严重。

继承人有前述（1）或（2）所列之行为，而被继承人以遗嘱将遗产指定由该继承人继承的，可以确认遗嘱无效，并确认该继承人丧失继承权。继承人有前述（3）（4）（5）所列之行为，确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。

继承权的丧失自继承开始之时发生效力。如果继承权的丧失是于继承开始后由人民法院确认的，则人民法院对继承人继承权丧失的确认溯及自继承开始之时发生效力。应当指出，继承人对于某一被继承人丧失继承权，并不影响其对其他被继承人的继承权。同时，继承权的丧失对继承人的直系晚辈血亲亦发生效力，即继承人丧失继承权的，其直系晚辈血亲不得代位继承。

四、遗产

【分析】遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。

1. 遗产的特征。遗产具有如下特征：

(1) 时间上的特定性。自然人死亡的时间是划定遗产的时间界限。遗产只能根据自然人死亡时其财产状况来确定。

(2) 内容上的财产性。遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产，具有财产性质。

(3) 范围上的限定性。遗产只能是死亡自然人的个人财产。

(4) 性质上的合法性。遗产只能是死亡自然人的合法财产。

(5) 法律上的可转让性。遗产为依照法律规定能够转让给他人所有的财产。

2. 遗产的范围。《民法典》采用开放性概括式的立法模式，从正面规定和反面排除两方面确定遗产的范围。一方面，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。另一方面，依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。承包人死亡时尚未取得承包收益的，可以将死者生前对承包所投入的资金和所付出的劳动及其增值和孳息，由发包单位或者接续承包合同的人合理折价、补偿，其价额作为遗产。

第二节 法定继承

一、法定继承的概念和特征

【分析】法定继承，是指直接根据法律规定的继承人范围、继承顺序以及遗产分配原则，由法定继承人继承被继承人遗产的法律制度。法定继承具有以下特征：

1. 法定继承基于一定的身份关系产生。在法定继承中，法律规定法定继承人的依据一般是基于继承人与被继承人之间存在亲属身份关系。

2. 法定继承是对遗嘱继承的补充。在效力上，遗嘱继承的效力优于法定继承。继承开始后，存在有效遗嘱的，应先适用遗嘱继承。不能适用遗嘱继承的，才可适用法定继承。因此，法定继承具有补充遗嘱继承的特征。

3. 法定继承是对遗嘱继承的限制。法定继承对遗嘱继承存在制约作用。例如，遗嘱继承人只能是法定继承人范围之内的人，遗嘱人必须在遗嘱中为缺乏劳动能力又没有生活来源的法定继承人保留必要的遗产份额。

4. 法定继承具有法定性、强行性。在法定继承中，继承人的范围、继承人参加继承的顺序和继承人应该继承的遗产及遗产的分配原则等内容都由法律直接规定，法律关于法定继承的规范为强制性规范，除法律另有规定外，不得排除其适用。

二、法定继承人的范围和法定继承顺序

【分析】法定继承人的范围，是指哪些人可以为法定继承人。在我国，法定继承人包括：配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母，以及对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳和丧偶女婿。

法定继承人中的子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女；父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母；兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹；祖父母、外祖父母，包括生祖父母、生外祖父母、养祖父母和养外祖父母。

法定继承顺序，是指法律规定的法定继承人参加继承的先后次序。《民法典》将法定继承顺序分为两个顺序。第一顺序：配偶、子女、父母，以及对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳和丧偶女婿。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

值得注意的是，在第一顺序中，收养关系成立后，养子女与养父母互为继承人，与生父母不再互为继承人。但被收养人对生父母扶养较多的，可以分得生父母适当的遗产。继子女继承了继父母遗产的，不影响其继承生

父母的遗产。继父母继承了继子女遗产的，不影响其继承生子女的遗产。只要丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母尽了主要赡养义务，不论他们是否再婚，都应作为第一顺序继承人。所谓尽了主要赡养义务或主要扶养义务，是指对被继承人生活提供了主要经济来源，或者在劳务等方面给予了主要扶助。在第二顺序中，继兄弟姐妹之间的继承权，因继兄弟姐妹之间的扶养关系而发生。没有扶养关系的，不能互为第二顺序继承人。继兄弟姐妹之间相互继承了遗产的，不影响其继承亲兄弟姐妹的遗产。养子女与生子女之间、养子女与养子女之间，系养兄弟姐妹，可以互为第二顺序继承人。被收养人及其亲兄弟姐妹之间的权利义务关系，因收养关系的成立而消除，不能互为第二顺序继承人。

三、适用法定继承的情形

【分析】根据《民法典》规定，有下列情形之一的，遗产中的有关部分按照法定继承办理：

1. 遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠；
2. 遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权；
3. 遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止；
4. 遗嘱无效部分所涉及的遗产；
5. 遗嘱未处分的遗产。

四、代位继承

【分析】代位继承是指被继承人的子女或兄弟姐妹先于被继承人死亡，应由被继承人的子女或兄弟姐妹继承的遗产份额，由被继承人的子女的直系晚辈血亲或兄弟姐妹的子女继承的法律制度。在代位继承中，先于被继承人死亡的子女或兄弟姐妹称为被代位继承人，被继承人的子女的直系晚辈血亲或兄弟姐妹的子女称为代位继承人。

代位继承是法定继承中的一种特殊现象，只适用于法定继承，不适用于遗嘱继承。如果遗嘱继承人系被继承人的子女或兄弟姐妹，且先于遗嘱人死亡，就不能发生代位继承，遗嘱中指定该继承人继承的遗产应按照法定继承处理。

代位继承须具备下列条件：

1. 须被代位继承人先于被继承人死亡。
2. 须被代位继承人是被继承人的子女或兄弟姐妹。在我国，被代位继承人既包括被继承人的子女，也包括被继承人的兄弟姐妹。所以，代位继承既适用于直系血亲，也适用于旁系血亲。
3. 须被代位继承人未丧失继承权。继承人丧失继承权的，其直系晚辈血亲不得代位继承。
4. 须代位继承人是被继承人的子女的直系晚辈血亲或被继承人的兄弟姐妹的子女。直系晚辈血亲包括自然血亲和拟制血亲。

被继承人的养子女、已形成扶养关系的继子女的生子女可以代位继承；被继承人亲生子女的养子女可以代位继承；被继承人养子女的养子女可以代位继承；与被继承人已形成扶养关系的继子女的养子女也可以代位继承。被继承人的孙子女、外孙子女、曾孙子女、外曾孙子女都可以代位继承，代位继承人不受辈数的限制。此外，丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母，无论其是否再婚，依照《民法典》第1129条规定作为第一顺序继承人时，不影响其子女代位继承。

代位继承的效力。具备代位继承条件的，代位继承人取代被代位继承人的继承地位参与继承，代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。若代位继承人为数人则只能共同继承被代位继承人有权继承的份额。但是，代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源，或者对被继承人尽过主要赡养义务的，分配遗产时，

可以多分。继承人丧失继承权的，其直系晚辈血亲不得代位继承。如该代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源，或者对被继承人尽赡养义务较多的，可以适当分给遗产。

五、法定继承的遗产分配

【分析】法定继承的遗产分配，是指在法定继承人之间分配被继承人的遗产。

1. 法定继承的遗产分配原则

在法定继承中，同一顺序继承人的应继承份额按照以下原则确定：

（1）一般情况下应当均等。在没有法律规定的特别情形下，同一顺序的法定继承人应按照人数平均分配遗产。继承人有扶养能力和扶养条件，愿意尽扶养义务，但被继承人因有固定收入和劳动能力，明确表示不要求其扶养的，分配遗产时，一般不应因此而影响其继承份额。

（2）特殊情况下可以不均等。在下列情况下，同一顺序法定继承人的继承份额可以不均等：①对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。②对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

③有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

④继承人协商同意的，也可以不均等。

2. 非继承人对遗产的取得

对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给适当的遗产。分给他们遗产时，按具体情况可多于或少于继承人。可以分给适当遗产的人，在其依法取得被继承人遗产的权利受到侵犯时，本人有权以独立的诉讼主体资格向人民法院提起诉讼。

第三节 遗嘱继承和遗赠

一、遗嘱继承的概念和特征

【分析】遗嘱继承，是指继承人按照被继承人生前所立的合法有效遗嘱继承被继承人遗产的法律制度。在遗嘱继承中，生前立有遗嘱的被继承人称为立遗嘱人或遗嘱人，依据遗嘱指定享有遗产继承权的人为遗嘱继承人。

遗嘱继承具有以下法律特征：

1. 遗嘱继承须以存在有效遗嘱为前提。

2. 遗嘱继承直接体现被继承人的遗愿。在遗嘱继承中，继承人、继承份额等都是由被继承人在遗嘱中指定的。

3. 遗嘱继承是对法定继承的排斥。遗嘱中所指定的继承人对遗产的继承不受法定继承人顺序、继承人应继承份额的限制。

4. 遗嘱继承的效力优于法定继承。在具体分割遗产时，有遗嘱的首先适用遗嘱继承。只有在没有遗嘱、或虽有遗嘱但遗嘱无效、遗嘱继承人放弃遗嘱继承或遗嘱继承人丧失继承权等情形时，才可适用法定继承。

二、遗嘱继承的适用条件

【分析】被继承人死亡后，只有具备以下条件时，才能适用遗嘱继承。

1. 须被继承人生前立有合法有效的遗嘱。

2. 须没有遗赠扶养协议。遗赠扶养协议的效力优于遗嘱继承。如果被继承人生前与扶养人订有遗赠扶养协议，被继承人对同一财产又立有遗嘱，则不能先适用遗嘱继承，而是应当先执行遗赠扶养协议。只有在没有遗赠扶养协议的情形下，遗产才可按照遗嘱继承处理。

3. 须遗嘱继承人未丧失继承权，也未放弃继承权。在适用遗嘱继承时，继承人也必须具有继承权。如果遗嘱继承人丧失继承权，则即使遗嘱中指定其为继承人，也不得参加遗嘱继承。另外，遗嘱继承人明确表示放弃继承的，也不可适用遗嘱继承。

三、遗嘱的概念和特征

【分析】遗嘱，是指自然人生前按照法律规定处分自己的财产及安排有关事务，并于死亡后发生法律效力的单方民事法律行为。

遗嘱具有以下法律特征：

1. 遗嘱是单方民事法律行为。遗嘱是遗嘱人自己一方的意思表示，无须有相对方的意思表示。

2. 遗嘱是死后生效的民事法律行为。遗嘱人死亡时遗嘱才生效，所以遗嘱人在生前任何时候都可以变更或撤回遗嘱。

3. 遗嘱是遗嘱人亲自所为的民事法律行为。设立遗嘱不得适用代理制度，遗嘱必须由遗嘱人亲自设立。

4. 遗嘱是要式民事法律行为。遗嘱只有符合法律规定的形式要件，才能发生效力。

四、遗嘱的形式

【分析】遗嘱的形式，是指遗嘱人处分自己身后财产及安排有关事务的意思表示的方式。根据《民法典》规定，遗嘱的形式有下列六种：

1. 自书遗嘱。自书遗嘱是指遗嘱人亲笔书写的遗嘱。自书遗嘱必须由遗嘱人亲笔书写，签名并注明年、月、日。自然人在遗书中涉及死后个人财产处分的内容，确为死者的真实意思表示，有本人签名并注明了年、月、日，又无相反证据的，可以按自书遗嘱对待。

2. 代书遗嘱。代书遗嘱是指由遗嘱人口述，由他人代为书写、记录的遗嘱。代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。

3. 打印遗嘱。打印遗嘱是指使用电脑、打印机等设备打印出的遗嘱。打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。

4. 录音录像遗嘱。录音录像遗嘱是指用录音录像设备录下遗嘱人的口述遗嘱或带有肖像的口述遗嘱。以录音录像形式立遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。

5. 口头遗嘱。口头遗嘱是指遗嘱人在危急情况下以口头方式设立的遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。所谓“危急情况”，一般是指遗嘱人生命垂危，突遇自然灾害、意外事故、战争等。

6. 公证遗嘱。公证遗嘱是指经公证机关公证的遗嘱。

为保证代书遗嘱、录音录像遗嘱、打印遗嘱和口头遗嘱的真实性，这几种遗嘱必须有两个以上见证人在场见证，并对见证人的资格作了限制性规定。下列人员不能作为遗嘱见证人：（1）无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人；（2）继承人、受遗赠人；（3）与继承人、受遗赠人有利害关系的人。继承人、受遗赠人的债权人、债务人，共同经营的合伙人，应当视为与继承人、受遗赠人有利害关系，不能作为遗嘱的见证人。

五、遗嘱的效力

►遗嘱有效

【分析】遗嘱有效应具备下列条件：

1. 立遗嘱人须有遗嘱能力。遗嘱能力是指遗嘱人立遗嘱时必须具有完全民事行为能力。无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱，即使其本人后来具有完全民事行为能力，仍属无效遗嘱。遗嘱人立遗嘱时具有完全民事行为能力，后来成为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，不影响遗嘱的效力。

2. 遗嘱人须意思表示真实。

3. 遗嘱内容必须合法。遗嘱的内容不得违反法律和公序良俗。例如，《民法典》第 1141 条规定，遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。如果某遗嘱没有为该类继承人保留必要的遗产份额，则该遗嘱的内容为不合法。

4. 遗嘱的形式必须符合法律的规定。

►遗嘱无效

【分析】遗嘱无效是指遗嘱因违反法律规定而不能发生法律效力。遗嘱无效的情形有：

1. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效。

2. 遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效。

3. 伪造的遗嘱无效。

4. 遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。

5. 遗嘱人以遗嘱处分了国家、集体或者他人财产的，应当认定该部分遗嘱无效。

六、遗嘱的变更和撤回

【分析】遗嘱的变更，是指遗嘱人生前依法对原先所立遗嘱内容作部分修改。遗嘱的撤回，是指遗嘱人废除原先所立的遗嘱，或者对原先所立遗嘱内容作全部修改。遗嘱人可以变更、撤回自己所立的遗嘱。遗嘱变更和撤回有三种方式：

1. 明示方式。遗嘱人另立新遗嘱，在新遗嘱中声明变更或者撤回原先所立的遗嘱。

2. 默示方式。遗嘱人通过行为变更、撤回原先所立的遗嘱。《民法典》第 1142 条第 2 款规定，立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。

3. 推定方式。遗嘱人立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

七、遗赠

【分析】遗赠是指自然人以遗嘱的方式将其个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织、个人，并于其死后生效的民事法律行为。在遗赠中，立遗嘱的自然人为遗赠人，被指定接受赠与财产的人为受遗赠人。

遗赠的特征。遗赠具备遗嘱所具有的法律特征，是单方民事法律行为、是死后生效的民事法律行为、是要式民事法律行为以及是遗赠人亲自所为的民事法律行为。

遗赠的接受与受遗赠权的丧失。继承开始后，受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。受遗赠人故意杀害被继承人的，丧失受遗赠权。

继承开始后，受遗赠人表示接受遗赠，并于遗产分割前死亡的，其接受遗赠的权利转移给他的继承人。

遗赠与遗嘱继承的区别主要表现在以下几个方面：

1. 受遗赠人与遗嘱继承人的法律地位不同。受遗赠人不是继承人，没有继承权；而遗嘱继承人是继承人，享有继承权。

2. 受遗赠人与遗嘱继承人的范围不同。受遗赠人必须是法定继承人以外的人，既可以是自然人，也可以是国家或者集体；而遗嘱继承人只能是法定继承人以内的人，并且只能是自然人。

3. 对遗赠和遗嘱继承的接受、放弃的方式不同。继承开始后，受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内，作出接受或者放弃受遗赠的表示；到期没有表示的，视为放弃受遗赠。遗嘱继承人在继承开始后、遗产处理前，没有以书面形式表示放弃遗嘱继承的，视为接受继承。

第四节 遗产的处理

一、遗产管理人

【分析】遗产管理人是指对遗产负责保存和管理的人。

1. 遗产管理人的确定

继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。对遗产管理人的确定有争议的，利害关系人可以向人民法院申请指定遗产管理人。

2. 遗产管理人的职责

根据《民法典》规定，遗产管理人应当履行下列职责：（1）清理遗产并制作遗产清单；（2）向继承人报告遗产情况；（3）采取必要措施防止遗产毁损、灭失；（4）处理被继承人的债权债务；（5）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产；（6）实施与管理遗产有关的其他必要行为。遗产管理人应当依法履行职责，因故意或者重大过失造成继承人、受遗赠人、债权人损害的，应当承担民事责任。

3. 遗产管理人的权利

遗产管理人有获得报酬权。《民法典》第 1149 条规定，遗产管理人可以依照法律规定或者按照约定获得报酬。

二、遗赠扶养协议

【分析】遗赠扶养协议，是指由遗赠人与扶养人签订的，由扶养人对遗赠人负生养死葬的义务，遗赠人将自己财产的部分或全部在其死后转移给扶养人所有的协议。扶养人不限于自然人，还包括组织，但自然人中的法定继承人不能作扶养人，国家也不能作扶养人。

1. 遗赠扶养协议的特征

（1）遗赠扶养协议是双方民事法律行为。

（2）遗赠扶养协议是有偿民事法律行为。遗赠人所享有的被扶养的权利，是以死后遗赠指定的财产为代价，扶养人获得遗赠财产的权利是以对遗赠人负生养死葬的义务为代价。

（3）遗赠扶养协议双方当事人义务履行的时间具有错时性。扶养人在遗赠人（被扶养人）生前履行扶养义务，而遗赠人于其死后才转移遗赠的财产。所以，在遗赠人死亡前，扶养人不得要求遗赠人将财产归于自己。

（4）遗赠扶养协议具有优先于遗嘱继承和遗赠的执行效力。被继承人生前与他人订有遗赠扶养协议，同时又立有遗嘱、遗赠的，继承开始后，如果遗赠扶养协议与遗嘱、遗赠没有抵触，遗产分别按协议和遗嘱、遗赠处理；如果有抵触，按协议处理，与协议抵触的遗嘱、遗赠全部或者部分无效。

2. 遗赠扶养协议与遗赠的区别

遗赠扶养协议与遗赠的区别主要有以下几个方面：

(1) 行为的性质不同。遗赠扶养协议是**双方、双务、有偿**民事法律行为；遗赠是**单方、单务、无偿**民事法律行为。

(2) 行为的形式不同。遗赠扶养协议采用**合同**形式；遗赠采用**遗嘱**形式。

(3) 主体的范围不同。遗赠扶养协议的扶养人限于法定继承人以外的个人或者组织，**不包括国家**；而遗赠中的受遗赠人除法定继承人以外的个人或者组织外，还包括国家。

(4) 主体资格不同。遗赠扶养协议的遗赠人与扶养人订立协议时须均为完全民事行为能力人；而遗赠人须为完全民事行为能力人，但**不要求受遗赠人为完全民事行为能力人**。

(5) 法律效力不同。遗赠扶养协议具有优先于遗嘱继承和遗赠的执行效力；而遗嘱继承与遗赠的法律效力是相同的。

3. 遗赠扶养协议解除的后果

继承人以外的组织或者个人与自然人签订遗赠扶养协议后，无正当理由不履行，导致协议解除的，不能享有受遗赠的权利，其支付的供养费用一般不予补偿；遗赠人无正当理由不履行，导致协议解除的，则应当偿还继承人以外的组织或者个人已支付的供养费用。

三、遗产的分割

【分析】遗产的分割是指按照遗嘱指定或法律规定在共同继承人之间对遗产进行分配的行为。

1. 遗产的确定

遗产的确定，是指在分割遗产前，应将遗产与他人共有的财产区分开。

(1) 遗产与夫妻共同财产的区分。夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，**应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产**。

(2) 遗产与家庭共同财产的区分。遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，**应当先分出他人的财产，其余的为被继承人的遗产**。

(3) 遗产与其他共有财产的区分。如与合伙人共有财产的区分、与朋友共有某物的区分等，先分出他人的财产，剩余的为遗产。

2. 遗产分割的原则

分割遗产时，应遵循如下原则：

(1) 先遗嘱继承后法定继承原则。在有遗嘱的情况下，首先应按照遗嘱的指定分割遗产。值得注意的是，遗嘱人未保留缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的遗产份额，遗产处理时，**应当为该继承人留下必要的遗产，所剩余的部分，才可参照遗嘱确定的分配原则处理**。继承人是否缺乏劳动能力又没有生活来源，应当按**遗嘱生效时**该继承人的具体情况确定。

(2) 保留胎儿继承份额原则。遗产分割时应当保留胎儿的继承份额，没有保留的，应从继承人所继承的遗产中扣回。为胎儿保留的遗产份额，如胎儿出生后死亡的，由其继承人继承；如胎儿娩出时是死体的，由被继承人的继承人继承。

(3) 法定继承的遗产分配原则。这部分内容见本章第二节第五部分。

(4) 互谅互让、协商分割原则。继承人应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承问题。

(5) 物尽其用原则。遗产分割应当有利于生产和生活需要，不损害遗产的效用。

3. 侵害他人继承权益的后果

人民法院对故意隐匿、侵吞或者争抢遗产的继承人，可以酌情减少其应继承的遗产。

4. 转继承

转继承是指继承开始后，继承人于遗产分割前死亡，本该由该继承人继承的遗产转由其法定继承人承受。

实际接受遗产的继承人称为**转继承人**，于继承开始后遗产分割前死亡的继承人称为**被转继承人**。

转继承应具备下列条件：（1）被转继承人于被继承人死亡后、遗产分割前死亡；（2）被转继承人未丧失继承权，也未放弃继承权；（3）被转继承人生前未立另有安排的遗嘱。

四、被继承人债务的清偿

【分析】**被继承人债务**，又称**遗产债务**，是指被继承人死亡时遗留的应由被继承人个人清偿的财产债务。被继承人债务主要包括生前所欠的税款、合同债务、侵权损害赔偿债务、不当得利返还债务等。被继承人以个人名义所借之债，有些是属于夫妻共同债务或家庭共同债务，此种情况下的债务不能全部作为被继承人的债务。

1. 被继承人债务清偿的原则

被继承人债务的清偿应遵循如下原则：（1）**限定继承原则**。继承人以**所得遗产实际价值为限**清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在其限。（2）**清偿债务优先于执行遗赠原则**。执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款和债务。（3）**保留必留份原则**。分割遗产，应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务；但是，应当为**缺乏劳动能力又没有生活来源**的继承人保留必要的遗产。（4）**连带责任原则**。继承人共同继承遗产系共同共有，各共同继承人对遗产债务应当承担连带责任。但在共同继承人内部，则应当按照各自继承遗产份额的比例分担遗产债务。

2. 继承人对遗产债务的清偿顺序

《民法典》第1163条规定，既有法定继承又有遗嘱继承、遗赠的，由法定继承人清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务；超过法定继承遗产实际价值部分，由遗嘱继承人和受遗赠人按比例以所得遗产清偿。

五、无人承受遗产的处理

【分析】无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有。

第二十一章 侵权责任

第一节 侵权责任概述

一、侵权责任的特征

【分析】侵权责任是指行为人对其侵权行为或准侵权行为造成的损害依法应当承担的民事法律后果。侵权责任具有如下法律特征：

1. 侵权责任以违反法定义务为前提。

2. 侵权责任的主要形式是损害赔偿。侵权责任的主要功能在于填补被侵权人因侵权行为所遭受的损害，损害赔偿就成了侵权责任的主要形式。虽然在有些情况下还有停止侵害、排除妨碍、消除危险等非财产责任形式，但大多也是与损害赔偿并用。

3. 侵权责任具有优先性。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。

二、侵权责任的归责原则

► 侵权责任归责原则的概念

【分析】侵权责任归责原则，是据以确定行为人承担侵权民事责任的根据和标准。

侵权责任归责原则的意义就是解决责任的根据问题，即可归责的事由。就过错责任而言，侵权人承担侵权责任的根据（可归责事由）是其过错；就无过错责任而言，侵权人承担侵权责任的根据（可归责事由）不是过错，而是其他事由，如行为或物存在对他人产生侵害的潜在危险性、存在特定的法律关系以及侵权人的优势地位就是无过错责任原则的可归责事由。

我国的侵权责任归责原则采用的是过错责任原则和无过错责任原则的二元归责体系。过错推定、公平责任不宜确立为归责原则。过错推定是过错责任原则适用中的一种特殊情形，公平责任在我国解决的不是侵权责任承担的根据（可归责事由），而是特定情况下分担损害后果的问题。

► 过错责任原则

【分析】过错责任原则，是指以行为人的过错作为归责根据的原则。

1. 过错责任原则的特征

过错责任原则具有以下特征：（1）过错责任原则是一种主观归责原则。它以行为人的主观心理状态作为确定和追究责任的绝对标准，即“有过错有责任”“无过错无责任”。（2）过错责任原则以行为人的过错作为责任的构成要件。（3）过错责任原则适用于一般侵权行为。（4）过错责任原则对确定责任范围具有决定性作用。行为人过错的大小决定了损害赔偿责任的轻重。

过错推定，是指依照法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。过错推定是过错责任原则适用中的一种特殊情形，它仍然以侵权人的过错作为确定责任的根据。

2. 过错责任原则的适用范围

过错责任原则适用于一般侵权行为，只有法律规定适用无过错责任原则的侵权行为，才不适用过错责任原则。但是值得注意的是，过错推定并非普遍适用于一般侵权行为，只适用于法律规定的几种侵权行为。

3. 过错责任原则的适用方法

过错责任原则的适用方法有二：一是谁主张谁举证，通常是由被侵权人对侵权人的过错进行举证和证明，而侵权人无须证明自己没有过错。二是过错推定实行举证责任倒置，即由侵权人承担证明自己没有过错的责任。如果侵权人不证明或不能证明自己不存在过错，则推定侵权人有过错。如果侵权人能够证明自己没有过错，则不承担侵权责任。

► 无过错责任原则

【分析】无过错责任原则，是指不论行为人有无过错，只要行为人损害他人民事权益，就应依法承担民事责任的原则。

1. 无过错责任原则的特征

无过错责任原则具有以下特征：（1）无过错责任原则不以行为人有过错作为责任的构成要件。在侵权责任构成要件方面，没有主观要件的要求。即无论侵权人有无过错，都要承担侵权责任。（2）无过错责任原则的适用必须有法律的明确规定。无过错责任原则只适用于法律规定的几种特殊侵权行为。（3）无过错责任原则仍然存在免责事由。即使适用无过错责任原则，如果损害是出于受害人自身原因或是其故意造成的，也会依法免除行为人的责任。

2. 无过错责任原则的适用范围

根据《民法典》规定，无过错责任原则主要适用于以下侵权行为：（1）产品质量不合格致人损害；（2）

机动车交通事故中机动车一方致非机动车或行人损害；（3）环境污染、破坏生态致人损害；（4）高度危险作业致人损害；（5）饲养的动物致人损害；（6）用人者的雇员在工作中致人损害；（7）被监护人致人损害。

3. 无过错责任原则的适用方法

既然无需考虑侵权人有无过错，所以在适用无过错责任原则时就免除了被侵权人对侵权人过错的举证和证明责任，侵权人也不得以证明自己没有过错而主张免责。但作为侵权责任的构成要件，**除主观要件不需举证外，被侵权人仍需证明侵权行为、损害后果以及二者之间的因果关系。**

第二节 一般侵权责任的构成要件

一、加害行为

【分析】**加害行为是指行为人实施的加害于被侵权人民事权益的不法行为。**加害行为包括**行为和违法**两个要素。加害行为首先必须有行为，其次，该行为必须违反了法律。加害行为可以分为直接加害行为和间接加害行为，积极加害行为和消极加害行为。

1. 直接加害行为和间接加害行为。直接加害行为，是指侵权人的加害行为**直接作用于**被侵权人受法律保护的人身或者财产权益，如侵权人亲自毁坏他人汽车。间接加害行为，是指侵权人**通过他人或者其他介质作用于**被侵权人受法律保护的人身或者财产权益，如教唆无民事行为能力人毁坏他人汽车。

2. 积极加害行为和消极加害行为。积极加害行为，也称**作为的侵权行为**，是指违反法律规定的不作为义务的行为，如毁坏他人名誉。消极加害行为，也称**不作为的侵权行为**，是指违反法律规定的作为义务的行为，如父母对未成年子女不履行抚养义务。

二、损害事实

【分析】**损害事实是指被侵权人的人身权利、财产权利以及其他利益所遭受的不利后果。**损害后果分为财产损失、人身损害和精神损害三类。

1. 财产损失。财产损失是指被侵权人的财产或人身所遭受的经济损失。财产损失可以分为**直接损失和间接损失**两类。直接损失是指**现有财产或既得利益**的丧失或减少。间接损失是指**可得利益**的丧失或减少，此种损失不是现实利益的丧失或减少，而是将来可得财产的丧失或减少，如被侵权人未来挣钱能力的丧失或降低、被侵权人可得的经营利润丧失或减少等。

2. 人身损害。人身损害是指被侵权人的人格权、身份权益所遭受的不利后果。如侵害被侵权人的生命权，其损害后果是被侵权人死亡。侵害被侵权人身体权、健康权，其损害后果是被侵权人的肢体、器官等的完好性被破坏、功能丧失或者降低，甚至导致被侵权人残疾、丧失劳动能力。

3. 精神损害。精神损害是指**被侵权人在精神方面出现痛苦或严重精神反常等现象**。根据精神损害的程度，精神损害可以分为**轻微精神损害、一般精神损害和严重精神损害**。

三、因果关系

【分析】**因果关系是指加害行为与损害事实之间的引起与被引起的关系。**加害行为是损害发生的原因，被侵权人遭受的损害则是加害行为的后果。由于因果关系的复杂性和多样化，关于因果关系的确定，国际上有多种判定规则。**我国主要有以下几种判定规则：**

1. 直接原因规则。行为与结果之间有直接原因关系的，无须再适用其他因果关系判断规则，直接确认其具

有因果关系。

2. 相当因果关系规则。确定加害行为与损害结果之间有无因果关系，要依行为时的一般社会智识经验作为判断标准，认为该加害行为有引起该损害结果发生的可能性，而在实际上该加害行为确实引起了该损害结果，则该加害行为与该结果之间有因果关系。相当因果关系规则可以用下列公式来说明：

大前提：依据一般的社会智识经验，该加害行为有引起该损害结果发生的可能性；

小前提：实际上该加害行为确实引起了该损害结果；

结论：那么，该加害行为是该损害结果发生的适当条件，二者之间有因果关系。

3. 近因规则。近因是指法律上的近因，当符合法律要求的加害行为与损害事实之间存在一个公平、公正意义上的“近距离”时，就可确定加害行为与损害结果之间存在因果关系。

4. 推定因果关系规则。在特定的场合，当被侵权人处于弱势，没有办法证明因果关系时，由侵权人负责证明自己的行为与损害之间没有因果关系。侵权人不能证明的，就可以推定存在因果关系。值得注意的是，适用推定因果关系必须要有法律的规定，目前我国法律仅规定了环境污染侵权和医疗事故侵权适用推定因果关系。

四、主观过错

【分析】过错是指侵权人的一种可归责的心理状态，表现为故意和过失两种形式。

故意是指行为人预见到损害后果的发生，并希望或者放任该结果发生的心理状态。故意这种心理状态之所以具有可责难性，在于这种心理状态的不正当性，并且行为人对于损害的发生具有完全的控制力和主动性。

过失是指行为人应当预见到损害后果的发生，却因为疏忽大意而没有预见到或已经预见而轻信能够避免损害后果发生的心理状态。过失分为重大过失和一般过失。所谓重大过失，是指行为人极为疏忽大意的情况；而一般过失则是指尚未达到重大过失的过失。过失这种心理状态之所以具有可责难性，在于这种心理状态的不正当性，行为人的行为是处于其控制之下的，损害后果是可以因行为人的适当注意而避免的。

第三节 损害赔偿

一、人身损害赔偿

【分析】人身损害赔偿，是指法律对被侵权人的人身权益遭受侵害的后果所采取的以金钱赔偿为内容的一种救济措施。

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

二、财产损失赔偿

【分析】财产损失赔偿，是指法律对被侵权人的财产权益遭受侵害的后果所采取的以金钱赔偿为内容的一种救济措施。财产损失赔偿包括侵害财产权益造成的财产损失赔偿和侵害人身权益造成的财产损失赔偿。

侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。

三、精神损害赔偿

【分析】精神损害赔偿，是指法律对被侵权人的精神损害所采取的以金钱赔偿为内容的一种救济措施。

在我国，精神损害赔偿适用于下列几种情形：（1）侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。（2）因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。（3）因当事人一方的违约行为，损害对方人格权并造成严重精神损害，受损害方选择请求其承担违约责任的，不影响受损害方请求精神损害赔偿。

四、惩罚性赔偿

【分析】惩罚性赔偿，是指法律规定某些情形下在补偿被侵权人的实际经济损失之外，再额外给予被侵权人一笔金钱的救济措施。

在我国，惩罚性赔偿适用于下列几种情形：（1）故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。（2）明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据有关规定采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。（3）侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

五、法定分担损失规则

【分析】法定分担损失，是指受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律规定由双方分担损失。这项规则不是侵权责任的承担问题，实际上体现的是公平观念，是公平原则在损害赔偿制度中的运用。

适用法定分担损失规则应同时满足下列条件：（1）当事人双方对损害的发生均无过错。（2）损害不属于适用无过错责任原则的情形。（3）分担损失不是必须平均分担。这项规则的适用，需要综合考虑受害人的损害，双方当事人的财产状况及其他相关情况等因素，才能得出双方分担的结果。

第四节 数人侵权行为及其责任

一、共同侵权行为及其责任

【分析】共同侵权行为是指二人以上共同故意或者共同过失侵害他人民事权益的行为。共同侵权行为的构成要件有：（1）主体的复数性，是指侵权人为二人或者二人以上。（2）意思上的联络性，是指数个行为人对加害行为具有共同故意、共同过失或者故意和过失的混合。（3）损害结果的单一性，是指共同侵权行为所导致的损害结果是一个不可分割的整体。

二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。

二、教唆行为、帮助行为及其责任

【分析】教唆行为，是指通过开导、怂恿、利诱、刺激等方法使被教唆者接受教唆意图的行为。帮助行为，是指通过提供工具或激励等方式在物质上或者精神上帮助他人实施侵权行为的行为。

教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护职责的，应当承担相应的责任。教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为，教唆

人、帮助人以其不知道且不当知道行为人为无民事行为能力人、限制民事行为能力人为由，主张不承担侵权责任或者与行为人的监护人承担连带责任的，人民法院不予支持。教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为，被侵权人合并请求教唆人、帮助人以及监护人承担侵权责任的，依照民法典第1169条第2款的规定，教唆人、帮助人承担侵权人应承担的全部责任；监护人在未尽到监护职责的范围内与教唆人、帮助人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。监护人先行支付赔偿费用后，就超过自己相应责任的部分向教唆人、帮助人追偿的，人民法院应予支持。教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为，被侵权人合并请求教唆人、帮助人与监护人以及受托履行监护职责的人承担侵权责任的，依照相关规定认定民事责任。

三、共同危险行为及其责任

【分析】共同危险行为，又称准共同侵权行为，是指二人或者二人以上共同实施危及他人人身或财产安全的行为并造成损害后果，但不能确定谁是实际侵权人的情形。

共同危险行为的构成要件有：（1）主体的复数性，是指危险行为人为二人或者二人以上。（2）行为的同一性。数个危险行为人实施的侵权行为是相同的。（3）时间上的同时性或相继性。如果数个危险行为人所实施的行为不是同时发生或相继发生，则不会成立共同危险行为。（4）行为的危险性。这种危险性表现为，每个人的行为都有可能侵害他人的民事权益，且这种可能性是现实存在的。（5）行为的独立性。每个人都单独实施了危险行为，彼此之间无关联或者结合关系。（6）实际侵权人的不确定性。（7）损害结果的单一性。

二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。

四、无意思联络的数人侵权行为及其责任

【分析】无意思联络的数人侵权行为是指二人以上虽无共同故意或者共同过失，但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的侵权行为。

无意思联络的数人侵权行为，其构成要件有：（1）主体的复数性。是指侵权人为二人或者二人以上。（2）无意思联络。（3）数个行为人分别实施了侵权行为。（4）损害结果的单一性。数个侵权行为的结合所导致的损害结果是一个不可分割的整体，或者是分别实施的侵权行为造成了同一损害。

二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。

二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。

第五节 侵权责任的抗辩事由

抗辩事由也称为不承担责任或减轻责任的法定事由。侵权责任的抗辩事由可以分为正当理由的抗辩事由和外来原因的抗辩事由两大类。

一、正当理由的抗辩事由

【分析】根据《民法典》规定，正当理由的抗辩事由有：

1. 正当防卫。内容参见第二章第四节“民事责任”。

2. 紧急避险。内容参见第二章第四节“民事责任”。

3. 自甘风险。自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。

4. 自助。合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

二、外来原因的抗辩事由

【分析】根据《民法典》规定，外来原因的抗辩事由有：

1. 不可抗力。内容参见第二章第四节“民事责任”。

2. 受害人故意。损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

3. 被侵权人有过错。被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

4. 第三人原因。损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

第六节 特殊责任主体的侵权责任

一、监护人责任

【分析】监护人责任是指监护人对其所监护的被监护人造成他人损害所承担的侵权责任。监护人责任具有以下特征：

1. 监护人责任是替代责任。行为人是被监护人，责任人是监护人。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。未成年子女造成他人损害被侵权人请求父母共同承担侵权责任的，人民法院依照民法典第 27 条第 1 款、第 1068 条以及第 1188 条的规定予以支持。夫妻离婚后，未成年子女造成他人损害，被侵权人请求离异夫妻共同承担侵权责任的，人民法院依照民法典第 1068 条、第 1084 条以及第 1188 条的规定予以支持。一方以未与该子女共同生活为由主张不承担或者少承担责任的，人民法院不予支持。离异夫妻之间的责任份额可以由双方协议确定；协议不成的，人民法院可以根据双方履行监护职责的约定和实际履行情况等确定。实际承担责任超过自己责任份额的一方向另一方追偿的，人民法院应予支持。未成年子女造成他人损害的，依照民法典第 1072 条第 2 款的规定，未与该子女形成抚养教育关系的继父或者继母不承担监护人的侵权责任，由该子女的生父母依照规定承担侵权责任。

2. 监护人责任为无过错责任。监护人承担的是无过错责任，只要被监护人的行为构成侵权行为，监护人就应当承担侵权责任。如果监护人尽到了监护职责，也只能减轻其责任，但不能免责。此外，委托他人监护的，监护人仍承担无过错责任。根据《民法典》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，被侵权人请求监护人承担侵权责任，或者合并请求监护人和受托履行监护职责的人承担侵权责任的，人民法院应当将无民事行为能力人、限制民事行为能力人列为共同被告。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，被侵权人合并请求监护人和受托履行监护职责的人承担侵权责任的，依照民法典第 1189 条的规定，监护人承担侵权人应承担的全部责任；受托人在过错范围内与监护人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。监护人承担责任后向受托人追偿的，人民法院可以参照民法典第 929 条的规定处理。仅有一般过失的无偿受托人承担责任后

向监护人追偿的，人民法院应予支持。

3. 承担损害赔偿责任时，应优先使用被监护人的财产。有财产的被监护人造成他人损害的，先从本人财产中支付赔偿费用。不足部分，才由监护人赔偿。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，被侵权人请求监护人承担侵权人应承担的全部责任的，人民法院应予支持，并在判决中明确，赔偿费用可以先从被监护人财产中支付，不足部分由监护人支付。监护人抗辩主张承担补充责任，或者被侵权人、监护人主张人民法院判令有财产的被监护人、限制民事行为能力人承担赔偿责任的，人民法院不予支持。从被监护人财产中支付赔偿费用的，应当保留被监护人所必需的生活费和完成义务教育所必需的费用。行为人在侵权行为发生时不满十八周岁，被诉时已满十八周岁的，被侵权人请求原监护人承担侵权人应承担的全部责任的，人民法院应予支持，并在判决中明确，赔偿费用可以先从被监护人财产中支付，不足部分由监护人支付。前述规定情形，被侵权人仅起诉行为人的，人民法院应当向原告释明申请追加原监护人为共同被告。

4. 监护人的赔偿请求权，是指非法使被监护人脱离监护，给监护人造成财产和严重精神损害的，监护人有请求侵权人赔偿的权利。非法使被监护人脱离监护，监护人有权请求赔偿为恢复监护状态而支出的合理费用等财产损失；导致父母子女关系或者其他近亲属关系受到严重损害的，应当认定为民法典第1183条第1款规定的严重精神损害；被监护人在脱离监护期间死亡，作为近亲属的监护人既有权请求赔偿人身损害，又有权请求赔偿监护关系受侵害产生的损失。

二、完全民事行为能力人暂时丧失意识的侵权责任

【分析】完全民事行为能力人暂时丧失意识的侵权责任，是指完全民事行为能力人暂时丧失意识，造成他人损害所承担的侵权责任。

完全民事行为能力人对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害有过错的，应当承担侵权责任；没有过错的，根据行为人的经济状况对受害人适当补偿。

完全民事行为能力人因醉酒、滥用麻醉药品或者精神药品对自己的行为暂时没有意识或者失去控制造成他人损害的，应当承担侵权责任。

三、用人者责任

【分析】用人者责任，是指用人者（用人单位、个人劳务使用人）对被使用人（工作人员、个人劳务提供者）在从事职务活动时致人损害的行为承担责任。

1. 用人单位责任

用人单位责任具有以下特征：（1）用人单位责任是替代责任。用人单位为其工作人员致人损害的侵权行为承担责任。（2）用人单位责任为无过错责任。即使用人单位无过错也应承担责任。（3）用人单位责任以用人单位与直接侵权人存在特定关系为前提，即用人单位与工作人员存在隶属关系、管理关系等。（4）用人单位责任是用人单位对工作人员在执行职务时致害行为承担的责任。

《民法典》第1191条规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。个体工商户的从业人员因执行工作任务造成他人损害的，也适用该条规定的用人者责任。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。被侵权人合并请求劳务派遣单位与接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任的，依照民法典第1191条第2款的规定，接受劳务派遣的用工单位承担侵权人应承担的全部责任；劳务派遣单位在不当选派工作人员、未依法履行培训义务等过错范围内，与接受劳务派遣的用工单位共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。劳务派遣单位先行支付赔偿费用后，就超过自己相应责任的部分向接受劳务派遣用工

单位追偿的，人民法院应予支持，但双方另有约定的除外。

2. 个人劳务使用人责任

个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。

提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。

四、定作人责任

【分析】定作人责任，是指承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人依法承担的责任。

承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。被侵权人合并请求定作人和承揽人承担侵权责任的，依照民法典第 1165 条、第 1193 条的规定，造成损害的承揽人承担侵权人应承担的全部责任；定作人在定作、指示或者选任过错范围内与承揽人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。定作人先行支付赔偿费用后，就超过自己相应责任的部分向承揽人追偿的，人民法院应予支持，但双方另有约定的除外。

五、网络侵权责任

【分析】网络侵权责任是指对发生在互联网上的各种侵害他人民事权益的行为而应承担的侵权责任。网络侵权责任分为以下几种类型：

1. 互联网上自己侵权责任

网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

2. 通知规则下的网络服务提供者的责任

网络用户利用网络服务实施侵权行为的，权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。

网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。

网络用户接到转送的通知后，可以向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据及网络用户的真实身份信息。

网络服务提供者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的权利人，并告知其可以向有关部门投诉或者向人民法院提起诉讼。网络服务提供者在转送声明到达权利人后的合理期限内，未收到权利人已经投诉或者提起诉讼通知的，应当及时终止所采取的措施。

3. 知道规则下的网络服务提供者的责任

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

六、违反安全保障义务的侵权责任

【分析】安全保障义务是指宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，在合理限度范围内应尽的使他人免受损害的义务。

宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。

因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。

七、教育机构的侵权责任

【分析】教育机构的侵权责任，是指幼儿园、学校等教育机构对无民事行为能力人和限制民事行为能力人在教育机构学习、生活期间受到的人身损害承担的侵权责任。

教育机构的侵权责任可以分为两种类型：

1. 教育机构对自己不作为致害的侵权责任

（1）对无民事行为能力人受到损害的责任。无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。

（2）对限制民事行为能力人受到损害的责任。限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵权责任。

2. 教育机构对第三人致害的侵权责任

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到教育机构以外的第三人人身损害，第三人、教育机构作为共同被告且依法应承担侵权责任的，人民法院应当在判决中明确，教育机构在人民法院就第三人的财产依法强制执行后仍不能履行的范围内，承担与其过错相应的补充责任。被侵权人仅起诉教育机构的，人民法院应当向原告释明申请追加实施侵权行为的第三人为共同被告。第三人确定的，未尽到管理职责的教育机构先行承担与其过错相应的责任；教育机构承担责任后向已经确定的第三人追偿的，人民法院依照民法典第 1201 条的规定予以支持。

第七节 产品责任

一、产品责任的概念

【分析】产品责任，是指因产品有缺陷造成他人财产、人身损害，产品生产者、销售者所应承担的侵权责任。

二、产品责任的归责原则和构成要件

【分析】我国产品责任的归责原则采取二元归责原则，既适用无过错责任原则，也适用过错责任原则，但以无过错责任原则为主导。

（1）无过错责任原则适用的情形：①生产者和销售者对直接责任（表面责任）的承担，均适用无过错责任原则。换言之，只要因使用或消费缺陷产品而受到损害的被侵权人向该产品的生产者、销售者主张赔偿，生

产者和销售者均不得以无过错抗辩，即使是无过错的销售者，也应首先承担直接责任。②生产者的最终责任。无过错的销售者向受害者承担直接责任后，得向生产者追偿，由生产者承担最终责任，生产者的最终责任属于无过错责任。如果受害者直接向生产者主张赔偿，这时适用的也是无过错责任。

(2) 过错责任原则适用的情形：①销售者的最终责任。由于销售者的过错使产品存在缺陷，销售者应承担最终责任。于此情形，如果销售者承担了责任，则不得再向生产者追偿；如果生产者承担了直接责任，生产者则可通过证明缺陷是由于销售者过错所致，而向销售者追偿。②运输者、仓储者等第三人的最终责任。运输者、仓储者等第三人不是直接责任的承担者，但如果产品的缺陷是因其过错所致，生产者或销售者在承担无过错的直接责任后，则可向有过错的运输者、仓储者等第三人追偿。运输者、仓储者等第三人对这种最终责任的承担适用过错责任原则。

产品侵权责任的构成要件有：(1) 产品有缺陷；(2) 被侵权人的人身、财产遭受损害；(3) 因果关系。产品缺陷与被侵权人遭受的损害之间具有因果关系。

三、产品责任的责任主体

【分析】产品责任的责任主体可概括为：(1) 生产者、销售者均为责任主体，被侵权人可选择向其中之一或者二者请求赔偿。(2) 产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。(3) 因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。

四、产品责任的承担

【分析】1. 因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。

2. 产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。依照法律规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被侵权人因此支出的必要费用。

3. 明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依法采取有效补救措施，造成他人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

第八节 机动车交通事故责任

一、机动车交通事故责任的概念

【分析】机动车交通事故责任，是指机动车因过错或者意外造成他人人身伤亡或者损失时相关主体承担的侵权责任。

二、各类机动车交通事故的责任主体及责任承担

【分析】主要有以下七种类型：

1. 租赁、借用机动车发生交通事故的责任主体及责任承担

因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔

偿责任。

2. 转让并交付机动车但未办理登记期间发生交通事故的责任主体及责任承担

当事人之间已经以买卖或者其他方式转让并交付机动车但是未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由受让人承担赔偿责任。

3. 转让拼装或者报废机动车发生交通事故的责任主体及责任承担

以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动车，发生交通事故造成损害的，由转让人和受让人承担连带责任。转让人、受让人以其不知道且不应知道该机动车系拼装或者已经达到报废标准为由，主张不承担侵权责任的，人民法院不予支持。

4. 挂靠营运情形下发生交通事故的责任主体及责任承担

以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由挂靠人和被挂靠人承担连带责任。

5. 擅自驾驶他人机动车发生交通事故的责任主体及责任承担

未经允许驾驶他人机动车，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任，但是《民法典》另有规定的除外。

6. 盗窃、抢劫、抢夺的机动车发生交通事故的责任主体及责任承担

盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害的，由盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用人不是同一人，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用人承担连带责任。

保险人在机动车强制保险责任限额范围内垫付抢救费用的，有权向交通事故责任人追偿。

7. 非营运机动车发生交通事故的责任主体及责任承担

非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属于该机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。

8. 投保义务人与交通事故责任人不是同一人的责任承担

未依法投保强制保险的机动车发生交通事故造成损害，投保义务人和交通事故责任人不是同一人，被侵权人合并请求投保义务人和交通事故责任人承担侵权责任的，交通事故责任人承担侵权人应承担的全部责任；投保义务人在机动车强制保险责任限额范围内与交通事故责任人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。投保义务人先行支付赔偿费用后，就超出机动车强制保险责任限额范围部分向交通事故责任人追偿的，人民法院应予支持。

9. 机动车车上人员的责任承担

机动车驾驶人离开本车后，因未采取制动措施等自身过错受到本车碰撞、碾压造成损害机动车驾驶人请求承保本车机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内，以及承保本车机动车商业第三者责任保险的保险人按照保险合同的约定赔偿的，人民法院不予支持，但可以依据机动车车上人员责任保险的有关约定支持相应的赔偿请求。

第九节 医疗损害责任

一、医疗损害责任的概念

【分析】医疗损害责任，是指因医疗机构及其医务人员的过错致使患者在诊疗活动中受到损害，由医疗机构承担的侵权责任。

二、医疗损害责任的构成要件

【分析】医疗损害责任的构成要件有四个：

1. 医疗机构及其医务人员具有违法的诊疗行为。

2. 患者遭受非正常的损害，即超出了正常医疗行为导致的正常损害范围。

3. 违法的诊疗行为与损害后果之间具有因果关系。

4. 医疗机构和医务人员有过错。如违反告知同意义务、违反医疗机构的规章制度。此外，患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推定医疗机构有过错：（1）违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定；（2）隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料；（3）遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。

三、医疗损害责任的承担

【分析】医疗机构与医务人员之间的关系符合用人者责任的特征，因此，医务人员是行为主体，医疗机构是责任主体。

患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，医疗机构不承担赔偿责任：（1）患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗；（2）医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务；（3）限于当时的医疗水平难以诊疗。在上述第一种情形中，医疗机构或者其医务人员也有过错的，应当承担相应的赔偿责任。

四、医疗产品责任

【分析】因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成患者损害的，患者可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追偿。

第十节 环境污染和生态破坏责任

一、环境污染和生态破坏责任的概念

【分析】环境污染和生态破坏责任，是指污染环境、破坏生态造成他人财产或者人身损害而应承担的侵权责任。

二、环境污染和生态破坏责任的归责原则及构成要件

【分析】环境污染和生态破坏责任适用无过错责任原则。

环境污染责任的构成要件包括：（1）有污染环境、破坏生态的行为。（2）发生损害。污染环境、破坏生态致人损害，既有财产损害，也有人身损害。（3）污染环境、破坏生态行为与损害之间存在因果关系。我国对环境污染和生态破坏责任的因果关系实行举证责任倒置。《民法典》第1230条规定，“因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。”

三、环境污染和生态破坏责任的承担

【分析】1. 责任主体。因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。侵权人赔偿后，有权向第三人追偿。

2. 责任范围。两个以上侵权人污染环境、破坏生态的，承担责任的大小，根据污染物的种类、浓度、排放量，破坏生态的方式、范围、程度，以及行为对损害后果所起的作用等因素确定。

3. 责任形式。违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复，所需费用由侵权人负担。

违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用：（1）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失；（2）生态环境功能永久性损害造成的损失；（3）生态环境损害调查、鉴定评估等费用；（4）清除污染、修复生态环境费用；（5）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。

第十一节 高度危险责任

一、高度危险责任的概念和特征

【分析】高度危险责任，是指因从事高度危险作业造成他人损害或者保有高度危险物品致人损害而应承担的侵权责任。

高度危险责任适用无过错责任原则。高度危险责任具有以下特征：（1）属于危险责任；（2）是对合法行为承担的责任；（3）是一种无过错责任；（4）是自己责任。

二、高度危险作业致人损害责任的类型及其责任承担

【分析】高度危险作业是指从事高空、高速、高压、易燃、剧毒及放射性等对周围的人身或者财产安全具有高度危险性的活动。

高度危险作业致人损害责任分为三种类型，对应的侵权责任如下：

1. 民用核设施致人损害责任。民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事故造成他人损害的，民用核设施的营运单位应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故意造成的，不承担责任。

2. 民用航空器致人损害责任。民用航空器造成他人损害的，民用航空器的经营者应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意造成的，不承担责任。

3. 从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具致人损害责任。从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻经营者的责任。

三、高度危险物品致人损害责任的类型及其责任承担

【分析】高度危险物品是指易燃、易爆、剧毒、放射性等对周围环境具有高度危险的物品。高度危险物品致人损害责任分为四种类型，对应的侵权责任如下：

1. 占有或者使用高度危险物致人损害责任。占有或者使用易燃、易爆、剧毒、高放射性、强腐蚀性、高致

病性等高度危险物造成他人损害的，占有人或者使用人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失的，可以减轻占有人或者使用人的责任。

2. 遗失、抛弃高度危险物致人损害责任。遗失、抛弃高度危险物造成他人损害的，由所有人承担侵权责任。所有人将高度危险物交由他人管理的，由管理人承担侵权责任；所有人有过错的，与管理人承担连带责任。

3. 非法占有高度危险物致人损害责任。非法占有高度危险物造成他人损害的，由非法占有人承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止非法占有尽到高度注意义务的，与非法占有人承担连带责任。

4. 未经许可非法进入高度危险区域损害责任。未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存放区域受到损害，管理人能够证明已经采取足够安全措施并尽到充分警示义务的，可以减轻或者不承担责任。

第十二节 饲养动物损害责任

一、饲养动物损害责任的概念

【分析】饲养动物损害责任，是指饲养的动物致人损害，动物饲养人或管理人依法承担的侵权责任。

二、饲养动物损害责任的归责原则

【分析】饲养动物损害责任的归责原则主要是无过错责任原则，但是动物园的动物造成他人损害的，动物园的侵权责任适用过错推定。

三、饲养动物致人损害责任的类型及其责任承担

【分析】饲养动物致人损害责任分为五种类型，对应的侵权责任如下：

1. 饲养动物损害的一般责任。饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

因第三人的过错致使动物造成他人损害的，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。动物饲养人或者管理人赔偿后，有权向第三人追偿。

2. 违反管理规定的动物损害责任。违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意造成的，可以减轻责任。

3. 禁止饲养的危险动物损害责任。禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，不得主张不承担责任或者减轻责任。

4. 动物园动物的损害责任。动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。

5. 遗弃、逃逸的动物损害责任。遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由原动物饲养人或者管理人承担侵权责任。

第十三节 建筑物和物件损害责任

一、建筑物和物件损害责任的概念

【分析】建筑物和物件损害责任，是指建筑物的建设单位、施工单位和物件的所有人、管理人或者其他主

体对其所管领的建筑物或物件致人损害应当承担的侵权责任。建筑物和物件损害责任是替代责任，因为建筑物和物件致人损害的基础是物而非人的行为。建筑物和物件损害责任的归责原则是过错责任原则，适用过错推定。

二、建筑物、构筑物或者其他设施致人损害的责任

【分析】建筑物、构筑物或者其他设施致人损害的责任分为两种

1. 建筑物等倒塌的致害责任。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

2. 建筑物等脱落、坠落的致害责任。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

三、抛掷物、坠落物致人损害的责任与补偿

【分析】《民法典》第1254条规定，禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。公安等机关应当依法及时调查，查清责任人。

物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。物业服务企业等建筑物管理人未采取必要的安全保障措施防止从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，具体侵权人物业服务企业等建筑物管理人作为共同被告的，人民法院应当依照民法典第1198条第2款、第1254条的规定，在判决中明确，未采取必要安全保障措施的物业服务企业等建筑物管理人在人民法院就具体侵权人的财产依法强制执行后仍不能履行的范围内，承担与其过错相应的补充责任。物业服务企业等建筑物管理人未采取必要的安全保障措施防止从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经公安等机关调查，在民事案件一审法庭辩论终结前仍难以确定具体侵权人的，未采取必要安全保障措施的物业服务企业等建筑物管理人承担与其过错相应的责任。被侵权人其余部分的损害，由可能加害的建筑物使用人给予适当补偿。具体侵权人确定后，已经承担责任的物业服务企业等建筑物管理人、可能加害的建筑物使用人向具体侵权人追偿的，人民法院依照民法典第1198条第2款、第1254条第1款的规定予以支持。

四、物件致人损害的责任

【分析】物件致人损害的责任分为以下几种

1. 堆放物倒塌的致害责任。堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

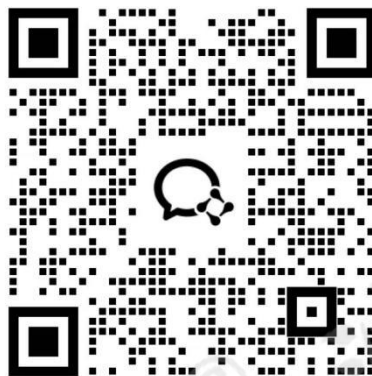
2. 妨碍通行物的致害责任。在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的，由行为人承担侵权责任。公共道路管理人不能证明已经尽到清理、防护、警示等义务的，应当承担相应的责任。

3. 林木的致害责任。因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害，林木的所有人或者管理人不能证明

自己没有过错的，应当承担侵权责任。

4. 地下设施的致害责任。这种责任又分为两种：（1）在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。（2）窖井等地下设施造成他人损害，管理人不能证明尽到管理职责的，应当承担侵权责任。

扫码加微，获取更多免费资料



扫描二维码，添加企业成员进行联系